

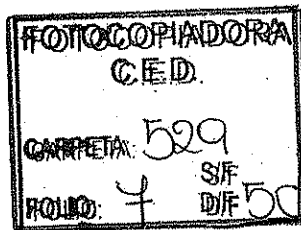
**Moncayo
Vinuesa
Gutiérrez Posse**

**DERECHO
INTERNACIONAL
PUBLICO**

Tomo I

ZAVALLA

Editor



52900007

10/10/04

10/10/04

10/10/04

341.0
MON
t.1
79816



79816

6ª reimpresión

© 1977 by Víctor P. de Zavalía S.A.
Alberti 835, 1223 Buenos Aires
Impreso en la Argentina
Queda hecho el depósito que indica la ley 11.723

ISBN: 950-572-102-1

PREFACIO

Tras muchos años de enseñanza del derecho internacional público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y otros establecimientos universitarios hemos decidido volcar los temas substanciales de la materia en una obra escrita, de la que el volumen presente constituye su primera parte.

Nos ha guiado un propósito eminentemente docente: brindar a los estudiantes un análisis de las normas e instituciones del derecho internacional público con un criterio rigurosamente jurídico que, naturalmente, no prescinda del contexto histórico-político en el que aquéllas se gestan y en el que cobran sentido.

En este orden de cosas, particular consideración merecen las reglas de derecho que vinculan a nuestro país y a los demás Estados latinoamericanos.

Hemos estimado que los temas descriptos debían serlo a través de un desarrollo sintético, pues la materia es vasta, aunque adecuado a los niveles que cabe presuponer y exigir en estudiantes universitarios.

Ante una realidad internacional evolutiva y de creciente complejidad, nos ha parecido de utilidad elaborar una obra introductoria que proporcione una versión actualizada del derecho internacional, que la exprese jurídicamente y que refleje, mediante casos y precedentes jurisprudenciales, su vitalidad y su vigencia.

Ella sólo pretende ser un instrumento eficaz de trabajo para los estudiantes de derecho y de ciencias políticas y sociales. Lejos está de bastarse a sí misma y su fin primordial se verá cumplido si sirve para la formación básica del estudiante y de estímulo para la profundización de los temas que en ella se tratan. Y también, si contribuye a afirmar la convicción de que el derecho internacional es el medio idóneo para asegurar una convivencia pacífica entre los Estados, basada en la justicia.

GUILLERMO R. MONCAYO

2

LISTA DE ABREVIATURAS

A.G.	Asamblea General de la ONU
A.D.L.A.	Anales de Legislación Argentina
A.F.D.I.	Annuaire Français de Droit International
A.J.I.L.	American Journal of International Law
B.Y.I.L.	British Yearbook of International Law
C.E.C.A.	Comunidad Económica del Carbón y del Acero
C.E.E.	Comunidad Económica Europea
C.D.I.	Comisión de Derecho Internacional de la ONU
C.I.J.	Corte Internacional de Justicia
C.J.C.E.	Corte de Justicia de las Comunidades Europeas
C.N.	Constitución de la Nación Argentina
C.P.J.I.	Corte Permanente de Justicia Internacional
C.S.	Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
I.C.L.Q.	International and Comparative Law Quarterly
O.E.A.	Organización de Estados Americanos
O.N.U.	Organización de las Naciones Unidas
R.C.A.D.I.	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye
R.G.D.I.P.	Revue Générale de Droit International Public
Y.B.I.L.C.	Year-Book of the International Law Commission

SUMARIO

Parte Primera. — INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES

I

1. Derecho internacional público.
2. La comunidad internacional.
3. Obligatoriedad del derecho internacional y fundamento de validez de la norma internacional.
4. Relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional.

Parte Segunda. — FORMACION DEL DERECHO INTERNACIONAL

II

1. Las fuentes del derecho internacional.
2. La costumbre.
3. Los tratados.
4. Los principios generales de derecho.

III

1. Medios auxiliares para la determinación de las reglas de derecho.
2. La equidad.
3. Los actos unilaterales de los Estados.
4. Los actos de los organismos internacionales.

INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES

I

1. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

a) Generalidades

1. Concepto, sujetos y objeto

A lo largo del tiempo se han propuesto diversas definiciones para describir al derecho internacional. De entre éstas es posible distinguir definiciones materiales y definiciones formales. Las definiciones materiales describen al derecho internacional de acuerdo al contenido histórico circunstancial de las normas pertenecientes al orden jurídico universal. En sus comienzos, el derecho internacional público fue definido como el derecho que regulaba las relaciones de los Estados tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. En la actualidad, ejemplos de definiciones materiales los encontramos dentro de la escuela jurídica soviética.¹

Las definiciones formales describen al derecho internacional en relación al proceso de creación de las normas o bien de acuerdo a los sujetos a quienes esas normas van dirigidas.² La que ha gozado de mayor aceptación por parte de la doctrina clásica es la que tradicionalmente ha defi-

¹ Para Kozheunikov (1951), el derecho internacional es la suma de los cambios históricos que afectan a las reglas de conducta reguladoras de las relaciones económicas y políticas, específicas de la lucha y cooperación de los Estados en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Para Tunkin (1961), sólo existe un sistema de derecho internacional obligatorio, tanto para Estados capitalistas como para Estados socialistas: "Derecho internacional es el conjunto de normas que se desarrollaron sobre la base del acuerdo entre Estados y que gobiernan sus relaciones en el proceso de luchas y cooperación entre ellos, y que expresando la voluntad de las clases dirigentes, son impuestas en caso de necesidad, por la presión (coacción) aplicada por los Estados en forma colectiva o individual"; Grzybowski, Kazimierz *Soviet Public International Law*, Leyden, 1970.

² Hans Kelsen distingue al derecho internacional de acuerdo al proceso de creación de la norma jurídica internacional independientemente de los sujetos a que éste hace referencia. Por su parte, A. Verdross y G. Scelle relacionan el concepto de derecho internacional con la idea del ordenamiento de la comunidad internacional. Mija de la Muela sostiene que derecho internacional es el ordenamiento jurídico propio de la comunidad internacional, que comprende un conjunto de normas emanadas de fuentes específicamente internacionales. Oppenheim y Lauterpacht llaman derecho internacional al conjunto de reglas consuetudinarias o convenidas en tratados, consideradas con fuerza jurídica y obligatorias para todos los Estados en sus relaciones mutuas.

nido al derecho internacional como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados.³ Frente a las evoluciones contemporáneas del contenido del ordenamiento jurídico internacional preferimos, a los efectos del presente trabajo, definir al derecho internacional como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Esta ampliación de la definición formal tradicional en nada afecta la calidad primordial de los Estados como actores principales en las relaciones internacionales. Ella ha sido adoptada por la mayoría de los publicistas contemporáneos.⁴

La definición aquí aceptada requiere anticipar ciertas precisiones en lo que hace a los sujetos vinculados por el derecho internacional y al objeto de este ordenamiento.

Subjetividad, tanto en derecho interno como en derecho internacional, puede ser definida como la cualidad que, originaria o derivadamente, posee un ente como receptor inmediato o como centro de imputación de derechos y obligaciones dentro de un orden jurídico dado. Sujeto de un ordenamiento jurídico es, entonces, todo ente que goza de algún derecho o debe cumplir alguna obligación en virtud de tal ordenamiento. En este sentido, la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de la ONU, al reconocer que dicha organización posee personalidad jurídica internacional, precisó que "esto significa que la ONU es un sujeto de derecho internacional con capacidad para poseer derechos y obligaciones internacionales".⁵

³ Conf. Carlos Calvo; en este sentido, Alf Ross dice que derecho internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones de todas las comunidades jurídicas soberanas, entre sí. Para Briery, el derecho internacional es el conjunto de reglas y principios de conducta que obligan a los Estados civilizados en sus relaciones mutuas (ídem, Hackworth).

⁴ Conf. L. A. Podestá Costa, H. Accioly, Delbez y Verdross.

⁵ Con motivo del conflicto árabe-israelí (1947-1948), el conde Folke Bernadotte, enviado como mediador por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, fue asesinado en territorio israelí por un grupo extremista. A la CIJ le fue solicitada por aquel órgano una opinión consultiva para que dictaminara si en el caso de que uno de los agentes de las Naciones Unidas sufre, en el ejercicio de sus funciones, un daño susceptible de comprometer la responsabilidad de un Estado, la ONU tiene capacidad para presentar contra el gobierno de jure o de facto responsable una reclamación internacional con el fin de obtener una reparación de los daños causados: a) a las Naciones Unidas; b) a la víctima o a sus derechohabientes. La Corte —tras afirmar que tal capacidad pertenece sin duda a los Estados— entiende que para responder a la cuestión propuesta debe determinar si la Organización se halla investida de personalidad internacional y que, toda vez que la Carta nada expresa al respecto, es preciso considerar los caracteres que ésta ha acordado a la Organización. La circunstancia de que la Carta la haya dotado de órganos y le haya asignado una misión propia; que haya impuesto a sus miembros la obligación de asistirle en toda acción que ella emprenda y la de aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad; que le haya otorgado capacidad jurídica y privilegios e inmunidades en territorio de cada uno de sus miembros y que haya previsto acuerdos para ser concluidos entre la Organización y sus miembros —convenciones que en la prác-

El Estado es, por su propia naturaleza, sujeto originario y necesario del ordenamiento jurídico internacional. Desde las etapas formativas del derecho internacional los Estados fueron considerados como "únicos" sujetos de ese ordenamiento.

Sin embargo, a partir de fines del siglo XIX, con la aparición de organismos interestatales, la ciencia jurídica presencia el nacimiento de nuevos sujetos del derecho internacional. Los organismos internacionales adquieren personalidad jurídica internacional; por lo tanto, al igual que los Estados deberán ser considerados como sujetos de ese derecho. Pero su personalidad jurídica no es originaria, depende inicialmente de la voluntad de los Estados que concurren a su creación. Tal voluntad se manifiesta, generalmente, en el acto constitutivo del organismo. Su capacidad jurídica resulta de las competencias adecuadas a sus fines, conferidas —expresa o implícitamente— en los tratados constitutivos o desarrolladas por la costumbre.⁶ Las relaciones entre los organismos internacionales y los Estados y la de los organismos internacionales entre sí, forman parte del ordenamiento jurídico llamado derecho internacional.

La evolución más reciente de las relaciones jurídicas entre Estados ha determinado la posibilidad de considerar también al individuo como sujeto del derecho internacional, pues existen normas jurídicas internacionales que regulan directamente su conducta.⁷ Esta subjetividad del indi-

viduo se han realizado— revela el carácter de la Organización, que ocupa una posición que la distingue de sus miembros a los que, de ser necesario, tiene el deber de recordarles ciertas obligaciones.

En opinión de la Corte, la Organización está destinada a ejercer funciones —en materias muy importantes y vastas— y a gozar de derechos que no pueden explicarse si la Organización no poseyese una extensa personalidad internacional y la capacidad de obrar en el plano internacional. La conclusión de la Corte es que la Organización es una persona internacional. Ello no significa que sea un Estado o que su personalidad jurídica, sus derechos y sus deberes, sean los mismos que los de un Estado; menos aun que sea un "super Estado", cualquiera sea el alcance jurídico de esta expresión. Significa que la Organización es un sujeto de derecho internacional, que tiene la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de prevalerse de esos derechos por la vía de la reclamación internacional. Partiendo de estas consideraciones de interés para la caracterización de la personalidad jurídica internacional, el Tribunal —tras otras y diversas argumentaciones— respondió afirmativamente a las dos cuestiones propuestas, CIJ, *Recueil*, 1949.

⁶ *Ibid.*, pág. 180. Los organismos internacionales gozan, por ejemplo, de la capacidad de celebrar tratados o de la de enviar representantes ante los Estados.

⁷ Así, ciertas normas jurídicas internacionales tipifican como ilícitas conductas directamente imputables a individuos, erigiendo en delitos internacionales la piratería, el tráfico de esclavos, el genocidio. Otras normas de este ordenamiento confieren derechos a las personas; el derecho a la vida, a la intimidad, a la integridad física, a ser oído en justicia. Este conjunto de derechos se denomina derechos humanos y han sido reconocidos internacionalmente por primera vez con tal carácter en la Carta de la ONU que en el art. 1.3, fija entre los propósitos para cuyo logro se crea la Organización "el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

viduo dentro del derecho internacional no es originaria sino que derivaría, en lo inmediato, de la voluntad de los Estados. El Estado participa con otros Estados en la creación de normas internacionales directamente dirigidas a los individuos, e interviene también en tal proceso cuando éste se lleva a cabo en el seno o con los auspicios de una organización internacional.

Pero esta participación de los Estados en el otorgamiento de derechos y obligaciones a los individuos, que los erigen para parte de la doctrina contemporánea en sujetos del derecho internacional, no modifica el hecho de que —una vez creadas las normas por la vía convencional o consuetudinaria— los sujetos del ordenamiento estén obligados a respetarlas.

La sola imputación directa de derechos u obligaciones internacionales confiere al individuo subjetividad dentro del ordenamiento jurídico internacional. Y esto es así, independientemente de que el individuo haya sido habilitado o no, para el ejercicio directo de las acciones correspondientes.

Son entonces sujetos del derecho internacional no sólo los Estados, sino también los organismos internacionales y, aún los individuos. En ciertas circunstancias otros entes pueden, a su vez, adquirir subjetividad internacional; tal es el caso, por ejemplo, de los grupos beligerantes y el de aquellos pueblos a los que se les reconoce un derecho a la autodeterminación.

La composición compleja de la comunidad internacional contemporánea en la que coexisten una pluralidad de sujetos no implica que todos ellos tengan capacidades idénticas. Como ya se expresó, el Estado es el sujeto primero y originario del ordenamiento internacional y como tal goza de la plenitud de derechos. Las demás entidades a las que se ha hecho referencia, si bien también tienen personalidad internacional, gozan de una capacidad limitada. Así, la de las organizaciones internacionales es eminentemente funcional en razón del objetivo para el que han sido creadas y la del individuo se refiere exclusivamente al respeto de los derechos que se le reconocen. Estas capacidades distintas de los distintos sujetos no modifica en nada el hecho de que todos tengan personalidad internacional. Con arreglo a tal criterio, la capacidad de participar en la elaboración de normas internacionales y la aptitud para prevalerse directamente de ellas, no vendrían a constituir caracteres necesarios para la asignación de subjetividad jurídica internacional.

En lo que concierne al objeto del derecho internacional, éste se ha visto ampliado a través de los años. El derecho internacional clásico se limitaba a la reglamentación de las relaciones entre los Estados en tiempo de paz y en tiempo de guerra. La aparición de nuevos sujetos derivados, a más del nacimiento de nuevos Estados como consecuencia del proceso de descolonización —acelerado a partir de la segunda guerra mundial— han ampliado el ámbito de aplicación personal del derecho internacional.

Por otra parte, el desarrollo de las comunicaciones, la creciente interdependencia entre Estados y los avances tecnológicos han propuesto nuevos ámbitos materiales de regulación y cooperación internacional. Se extiende así el contenido normativo del orden jurídico internacional. Nacen normas reguladoras de la cooperación y el desarrollo internacional en el campo económico y social; se contempla la reglamentación del espacio ultraterrestre y de los fondos marinos como espacios sustraídos a las soberanías estatales. Problemas tales como el de la contaminación ambiental, la utilización de la energía nuclear, el de la integración física y económica regional, etc., aparecen como novísimas materias consideradas por un dinámico y evolutivo derecho internacional contemporáneo. La preocupación por el hombre lleva a la jerarquización de sus derechos y libertades fundamentales a través de normas internacionales que tienden a su reconocimiento y protección.

2. Terminología

Al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional se lo denomina, indistintamente, Derecho Internacional, Derecho de Gentes, Derecho Internacional Público o Derecho de la Comunidad Internacional. El término "Derecho Internacional" proviene de la traducción literal del concepto inglés de *international law* utilizado por primera vez por Jeremías Bentham en el año 1789. Derecho Internacional no quiere decir, sin embargo, derecho entre naciones —nación en sentido político social—, sino que alude, básicamente, al derecho entre Estados; por lo tanto, se ha sostenido que sería más correcto hablar de derecho interestatal que de Derecho Internacional.

Los primeros doctrinarios del Derecho Internacional se refirieron a él como derecho de la guerra y derecho de la paz o bien como derecho de gentes. En la actualidad la doctrina alemana llama al derecho internacional *Völkerrecht* o sea derecho de los pueblos. La denominación de *Völkerrecht* reconoce como antecedente el concepto de *jus gentium* utilizado por los romanos. En el siglo XVIII, la idea del *jus gentium* penetra y domina a la doctrina internacionalista plasmada en las obras de Vattel y von Martens denominadas *Droit des Gens*. El término derecho de gentes renace dentro de la doctrina contemporánea conjuntamente con el resurgimiento de las teorías jus naturalistas que aluden al contenido humanista del derecho internacional.⁸ Los tratadistas norteamericanos, en su afán

⁸ Podestá Costa, L. A., *Derecho Internacional Público*, 4ª ed., Buenos Aires, T.E.A., 1961, t. 1, págs. 21-22.

⁹ Para Jenks, el derecho internacional es el derecho común de la humanidad en una fase incipiente de su desarrollo (Jenks, C. W., *The common law of mankind*, 1958). Los ius naturalistas españoles han propuesto la denominación de derecho de gentes, no en relación al concepto institucional romano de "gentes" como pueblo, sino "gentes" como conjunto de individuos protegidos por el derecho de los Estados (Miaja de la Muela, Antonio de Luna, Barcia Trelles, Trujol y Serra.)

4

por abarcar dentro de una misma disciplina jurídica a todas las relaciones internacionales, llaman derecho transnacional (*Transnational law*) al conjunto de normas jurídicas que regulan todas las relaciones —públicas o privadas— que traspasan las fronteras de los Estados.¹⁰

A fines del siglo XIX, los continentalistas europeos, seguidos por los publicistas latinoamericanos, adicionaron al término de Derecho Internacional el calificativo de público, para distinguirlo del, llamado por la ciencia jurídica, derecho internacional privado. En razón de ser el derecho internacional privado parte del derecho interno de los Estados, reservamos la denominación de Derecho Internacional para referirnos al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional.

Al aceptar la denominación de Derecho Internacional debemos aclarar que una distinta denominación no distorsiona la identidad del objeto descripto. Por lo tanto, Derecho Internacional es sinónimo de Derecho Internacional Público o de Derecho de Gentes.

3. Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado

La ciencia jurídica denomina Derecho Internacional Privado al conjunto de normas jurídicas que regulan las interrelaciones entre sujetos del derecho privado, en las que existen uno o varios elementos extraños al derecho interno de un Estado.

El Derecho Internacional Privado es el derecho de la extraterritorialidad del derecho privado extranjero.¹¹

El objeto del Derecho Internacional Privado como ciencia es, entonces, el estudio de las relaciones entre sujetos del derecho privado en las que a través de un elemento extraño al derecho interno del Estado se ponen en contacto dos o más ordenamientos jurídicos.¹²

El Derecho Internacional Privado es parte del derecho privado; o sea que no existe diferencia alguna en cuanto a la naturaleza del derecho privado sea éste llamado interno o internacional.

A la autonomía académico-científica de la ciencia del Derecho Internacional Privado, no corresponde una autonomía normativa-legislativa ni judicial.

Las normas jurídicas, objeto de estudio por parte de la ciencia del Derecho Internacional Privado, se crean y se constatan como cualquier

¹⁰ Jessupp, Vagts y Steiner.

¹¹ Conf. Basdevant, J., *Dictionnaire de la terminologie du Droit International*, París, Sirey, 1960, pág. 236; Goldschmidt, W., *Derecho Internacional Privado*. Editorial El Derecho, S.A.C.I.F.I., 1970, pág. 22: "El derecho internacional privado es el conjunto de normas indicadoras del derecho que resulta aplicable a un caso *ius privatista* con elementos extranjeros, inspirándose dichas normas en el respeto a la particularidad de tales elementos extranjeros"; Goldschmidt, W., *Revista de derecho civil de la Universidad Nacional de Tucumán*, año 1948/9, t. 1, n° 3, pág. 61.

¹² Batiffol, H., *Droit International Privé*, 5ª ed., París, Librairie Générale, 1970, pág. 2.

otra norma jurídica del derecho interno de los Estados (por ejemplo, el código civil argentino al igual que el código de comercio contienen normas consideradas por la ciencia jurídica como normas de Derecho Internacional Privado).

Distintos criterios se han utilizado para diferenciar al Derecho Internacional Público del Privado. La distinción clásica hace referencia, ya sea a los intereses particulares o comunes regulados por las normas jurídicas, es decir, su objeto, o bien a los sujetos a quienes esas normas van dirigidas. Una tercera tendencia trata de eliminar la clasificación del derecho, en público y privado, como divisiones históricas de la ciencia jurídica;¹³ esta posición en el plano internacional se relaciona con la idea del derecho transnacional, desarrollada por los tratadistas norteamericanos.¹⁴

En razón de ser el Derecho Internacional Privado esencialmente derecho interno, reservamos la denominación de Derecho Internacional al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional.¹⁵

4. La ciencia del derecho internacional

La ciencia jurídica del derecho internacional nace concomitantemente con la materia objeto de su estudio. Las desordenadas interrelaciones entre los Estados necesitaron del aporte clarificador y sistematizador de la doctrina jurídica. Dentro del pensamiento jurídico-político contemporáneo al surgimiento de los Estados se distingue así una clara orientación hacia la formulación de los principios y fundamentos de un nuevo orden jurídico internacional.

Entre los precursores de la ciencia del derecho internacional cabe mencionar principalmente a los teólogos españoles, padre Francisco de Vitoria (1486-1546 - *Reelecciones Teológicas*: N° 12 *De Indis*, N° 13 *De Jure Belli*) y padre Suárez (1548-1617); y al jurista italiano profesor de la Universidad de Oxford, Alberico Gentili (1552-1608). Pero es al holandés Hugo Grocio (1583-1642) a quien se le reconoce la paternidad de la ciencia del Derecho Internacional. Sus obras más importantes *Mare Liberum* (1609) y *De jure belli ac pacis* (1625) sentaron las bases del incipiente ordenamiento jurídico internacional. A partir de Grocio es posible ubicar a los doctrinarios del derecho internacional dentro de tres grandes líneas del pensamiento: a) el puro iusnaturalismo racionalista: Thomas Hobbes (1588-1679), Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728); b) el positivismo jurídico: Richard Zouche

¹³ Goldschmidt, W., "Derecho privado y derecho público", *Boletín del Instituto de Derecho Civil*, Universidad Nacional del Litoral, 1959-61, pág. 41.

¹⁴ Jessupp, Vagts y Steiner.

¹⁵ Cuando las normas del Derecho Internacional Privado son codificadas a nivel internacional, se aplicarán las normas del Derecho Internacional Público referidas al derecho de los tratados; Thrilway, H. N. A., *International Customary Law and Codification*, A. W. Sijthoff, Leyden, 1972.

(1590-1660), Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743), Johann J. Moser (1701-1785), George F. von Martens (1756-1821); c) la ecléctica o los continuadores del pensamiento de Grocio: Christian Wolf (1679-1754), Emerich de Vattel (1714-1767).

Durante los siglos XIX y XX los distintos publicistas abocados al estudio del derecho internacional se han identificado con alguna de estas escuelas clásicas del pensamiento jurídico internacional. La importancia de una u otra escuela ha respondido durante estos dos últimos siglos a las fluctuaciones del pensamiento jurídico general.¹⁶

El positivismo jurídico, muy en boga hasta hace tres décadas, se enfrenta en la actualidad con el iusnaturalismo racional y con la escuela sociológica, que apoyados en posturas seudojurídicas, soportan los embates de quienes alimentados por el escepticismo de una fluctuante política internacional no ven en el derecho internacional otra cosa que una mera expectativa de reciprocidad.

Tanto la primera como la segunda guerra mundial enseñaron a los Estados que el derecho internacional, como orden jurídico de la comunidad internacional, necesita del esfuerzo consciente de los pueblos tendiente a su desarrollo como un sistema vital de orden y no de caos, condicionado por las motivaciones e intereses concretos de los Estados. La creciente cooperación entre los Estados, más allá de discrepancias ideológicas y económicas, es el fiel reflejo de la vocación latente de la humanidad hacia la concreción de "standards", principios y valores comunes.

El desarrollo del derecho internacional necesita indefectiblemente de la infraestructura de la ciencia jurídica. El éxito de esta ciencia jurídica en el apoyo de aquel proceso dependerá, en gran medida, del compromiso que los doctrinarios asuman como verdaderos intérpretes de los valores aceptados por los beneficiarios mediatos de toda norma jurídica internacional.

b) Caracteres de este ordenamiento

1. Diferencias con el derecho interno y sus atenuaciones

Uno de los métodos tradicionales utilizado por la ciencia jurídica para caracterizar al derecho internacional se fundamenta en la comparación de este sistema con el derecho interno de los Estados. Así es que el ordenamiento jurídico internacional, tal como ha sido definido, presenta una serie de peculiaridades que lo distinguen de los distintos derechos internos. Estas características específicas indican que nos encontraríamos

¹⁶ Para una exhaustiva enumeración de Tratados y Publicistas, véase Oppenheim, L., *Tratado de Derecho Internacional Público*, 8ª ed., Lauterpach, H., Barcelona, Bosch, 1961, t. I, pág. 100 y siguiente.

frente a un derecho "imperfecto", si por "perfecto" entendemos a todo ordenamiento interno.

La doctrina, en general, sostiene que las diferencias esenciales entre el derecho interno y el derecho internacional radican en la inexistencia dentro de este último de: a) un órgano legislador; b) un órgano juzgador obligatorio; c) un vínculo de subordinación de los sujetos de ese ordenamiento.

a) Carencia de "órgano legislador"

El "legislador" de derecho interno no aparece en el derecho internacional. Los Estados, sujetos primarios y necesarios de este ordenamiento, son, al mismo tiempo, los generadores de la norma. La voluntad, expresa o tácita del Estado —evidenciada en la conclusión del acuerdo internacional, la aquiescencia, el cumplimiento de una práctica con conciencia de adecuar su conducta a una norma jurídica— es el origen inmediato de la norma. Aun cuando algunos mecanismos propios del derecho internacional contemporáneo puedan hacer pensar, aparentemente, en el "legislador internacional", ellos sólo dan lugar a la creación de normas de naturaleza "derivada". Es decir, que cuando determinados órganos de una organización internacional pueden dictar válidamente normas obligatorias para los sujetos del ordenamiento, esto es así en razón de que fueron esos mismos sujetos los que mediante el tratado constitutivo autorizaron al órgano "legislar" para situaciones específicas.¹⁷

Empero, aunque no existe en el derecho internacional general un órgano "legislativo centralizado", los Estados asumen funciones de sustancia legislativa cuando, a través de cualesquiera de los métodos válidos para el ordenamiento jurídico internacional, crean derecho. No reviste importancia, entonces, la carencia de un órgano que centralice la función legislativa —como en el derecho interno ocurre— si en el derecho internacional, con mayor o menor grado de centralización, la función creadora de normas generales se verifica conforme a otros mecanismos formales.

b) Carencia de un "órgano juzgador" obligatorio

Una de las facultades del Estado es la de aplicar su ordenamiento jurídico. A tal fin, éste se dota de los órganos que considera adecuados, a los que los sujetos deben *obligatoriamente* acudir para solucionar sus controversias. El derecho internacional general carece, en cambio, de un órgano jurisdiccional de aplicación, obligatorio, propio de la sociedad interestatal. Cuando se suscita una controversia entre Estados, éstos pueden,

¹⁷ Véase, por ejemplo, art. 189 y conc. del Tratado constitutivo de la CEE; art. 6 y conc. del Acuerdo Subregional Andino, que permiten a la organización dictar normas obligatorias para los Estados miembros y aún para las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

en una primera etapa, solucionarla mediante la negociación directa para lo que aplicarán, o no, el ordenamiento positivo internacional. Pueden, también, sin perjuicio de acudir a otros medios de solución pacífica, otorgar —mediante el acuerdo de voluntades— *imperium* a una instancia jurisdiccional. En este caso la jurisdicción —en tanto que facultad de decir el derecho— tiene su fundamento inmediato en la voluntad de los sujetos, careciendo del elemento de obligatoriedad que caracteriza a la potestad estadual.

En los supuestos en que el derecho internacional contemporáneo muestra la existencia de órganos jurisdiccionales permanentes y obligatorios con la función de aplicar o interpretar sus normas, la diferencia antes señalada parece desdibujarse. Es menester precisar, empero, que si bien el origen del *imperium* no está en la voluntad inmediata de los sujetos parte en la controversia, aquél se encuentra en las voluntades que aceptaron concordantemente, en un tratado constitutivo de una organización internacional, la existencia del órgano jurisdiccional.¹⁸

Pero esta carencia de un órgano jurisdiccional obligatorio y permanente dentro del ordenamiento jurídico internacional no contradice la existencia de una norma general¹⁹ de ese mismo ordenamiento por la cual los Estados están *obligados* a solucionar pacíficamente sus controversias. La instancia judicial es, entonces, sólo uno de los métodos de solución pacífica de controversias, pero no el único.

c) Carencia de un vínculo de "subordinación" de los sujetos

En derecho interno, los sujetos del ordenamiento no sólo deben cumplir sus normas, sino que pueden ser obligados a ello por los órganos del Estado que poseen tal competencia. En derecho internacional, no existe, en principio, un órgano superior a los sujetos que pueda efectuar el control del respeto a la norma y obligarlos compulsivamente a su cumplimiento; es éste un ordenamiento en el que los sujetos mismos tienen la competencia de tomar decisiones tendientes a la ejecución de la norma internacional dentro del marco de conductas legítimas que ese derecho les reconoce. Sin embargo, en algunos supuestos de las relaciones internacionales contemporáneas aparece un órgano supraestatal dotado del poder de coacción y de sanción,²⁰ aunque ello sólo ocurra porque los Estados que han creado la organización le han transferido tal competencia, auto-

¹⁸ Art. 164 y conc. del tratado constitutivo de la CEE por el que se crea una Corte de Justicia de la Comunidad ante la que pueden ser partes los órganos de la organización, los Estados y las personas que están bajo su jurisdicción.

¹⁹ Art. 2.3, Carta ONU.

²⁰ El Consejo de Seguridad de la ONU cuando actúa en el marco de las competencias que le atribuye el cap. VII de la carta.

rizándolo a actuar en ciertos casos y aceptando, en el mismo tratado constitutivo, conformarse a las resoluciones que éste adopte.²¹ En todo caso cabe destacar que se trata siempre de un poder de acción, de una capacidad de hacer ejecutar la norma, que emana de un órgano de naturaleza política.

2. Categorías de normas: normas imperativas (*ius cogens*) y normas dispositivas

En el derecho internacional contemporáneo encontramos dos categorías distintas de normas obligatorias: *normas dispositivas* y *normas imperativas*. La gran mayoría de las normas del derecho internacional son normas dispositivas. La *norma dispositiva* es aquella que admite acuerdo en contrario. Los Estados que crean una norma dispositiva pueden modificarla o derogarla por medio de sus voluntades concordantes. La noción de *norma imperativa*, si bien latente a lo largo del desarrollo contemporáneo del derecho internacional, adquiere fundamental importancia a partir de la segunda guerra mundial. El art. 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el *Derecho de los Tratados* la define diciendo que

"...una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter."

Es un hecho que en el derecho internacional contemporáneo hay ciertas reglas que los Estados no derogan por medio de acuerdos. Sin embargo, no existen criterios simples que permitan determinarlas. Cabe destacar que la mayoría de las normas de derecho internacional, aún siendo generales, no tienen este carácter. No sería tampoco posible decir que una disposición de un tratado tiene la naturaleza de imperativa por el sólo hecho de que las partes han estipulado que no es posible derogarla. Tal cláusula puede convenirse por razones de mera conveniencia. No es, entonces, la forma de una norma, sino la naturaleza particular de la materia a la que se aplica, la que puede darle el carácter de *ius cogens*. Toda norma imperativa de derecho internacional es una norma general en cuanto a su proceso de creación y aplicación, pero no toda norma general es, por este sólo hecho, una norma imperativa.

El contenido de las normas imperativas representa, conceptualmente, la manifestación normativa del orden público internacional.

Si bien existe consenso sobre qué es una norma imperativa, no existe un criterio generalizado entre los Estados para establecer cuáles son

²¹ Art. 25, Carta ONU.

imperativas. Así se sostiene, por ejemplo, que tendrían tal carácter las referidas a la igualdad soberana de los Estados, al cumplimiento de buena fe por las partes de todo tratado en vigor, a los derechos humanos, etc. Por su parte, el principio de la prohibición del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, contenido en el art. 2.4, de la Carta de la ONU, es generalmente aceptado y reconocido como norma imperativa de derecho internacional general.²²

3. Otras características

a) El Estado como sujeto y agente generador

En el ordenamiento jurídico internacional existe un sistema descentralizado tanto en el proceso de creación como en el de aplicación de las normas jurídicas. El Estado —al igual que toda organización internacional— es, a la vez, *agente generador* de normas internacionales y *sujeto* de ellas. Esa descentralización de los mecanismos para la creación y aplicación de normas pone de manifiesto la importancia de cada Estado, y la de toda organización internacional, como agente determinante de la obligatoriedad de las normas reguladoras de las relaciones internacionales. Así, por ejemplo, las voluntades estatales pueden concurrir a generar una norma internacional celebrando un tratado, pero una vez vigente éste se hallan sujetos obligatoriamente a la norma creada, no ya por el mero hecho de la concurrencia inmediata de tales voluntades sino por imperio del derecho internacional general que prescribe el sometimiento de las partes al tratado en vigor.

El agente generador de la norma se limita a través de ella. Y si el proceso formativo del orden jurídico internacional es expresión de potestades soberanas de los Estados, la limitación voluntaria de sus competencias mediante la normativización internacional va ampliando el campo de vínculos jurídicos internacionales obligatorios. De tal modo, el ámbito de materias reguladas por el derecho internacional comprende, hoy día, temas que tradicionalmente eran de competencia estadual.

b) Derecho de coordinación y derecho de subordinación

La descentralización del poder de creación y aplicación de normas jurídicas internacionales, para ciertos publicistas, ha impreso al ordenamiento jurídico internacional la calidad de sistema precario y rudimenta-

²² Véase al respecto el debate sostenido por los representantes de los Estados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados contenido en *Documentos Oficiales de la Conferencia, segundo período de sesiones, 1969, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria*, páginas 107-113; Verdross, A., "Jus dispositivum and jus cogens in international law", *AJIL*, 1966, vol. 60, págs. 55 a 63.

rio. Esta asimilación del derecho internacional al sistema de derecho de los pueblos primitivos confunde la verdadera esencia o naturaleza del derecho, que no depende de la centralización de poderes, sino de la obligatoriedad de las normas prescriptas.

Para la ciencia jurídica en general, el derecho internacional es un derecho de coordinación y no un derecho de subordinación. El derecho internacional no es un mandato de un superior dirigido a un sujeto subalterno, sino que es la formulación jurídica de las relaciones entre Estados. El hecho de que los Estados —al igual que los organismos internacionales— sean a la vez sujetos de derecho y sus agentes generadores, solamente puede llevar a la existencia de un sistema de coordinación de voluntades soberanas.²³

Clasificar al derecho internacional como derecho de coordinación, empero, en nada afecta el carácter obligatorio de la norma jurídica internacional. Por ejemplo, los sujetos que han participado en la creación de una norma convencional internacional quedan "subordinados" a su aplicación obligatoria. Esta "subordinación" a la obligatoriedad de la norma no se encuentra necesariamente condicionada por la inexistencia de una "subordinación" de los sujetos a un "poder de policía" internacional.²⁴ La distinción entonces entre un derecho coordinado y un derecho de subordinación se basa en el grado de centralización —o descentralización— de los mecanismos propios a todo ordenamiento jurídico para la creación y aplicación de sus normas.

c) Derecho Internacional general y Derecho Internacional particular

La doctrina anglo-sajona tradicionalmente ha distinguido entre "Derecho Internacional universal", "Derecho Internacional general" y "Derecho Internacional particular". Para ella, el "Derecho Internacional universal" sería el que obliga a toda la comunidad internacional de tal manera que sólo pudiese una norma de ese sistema ser modificada o derogada por el acuerdo unánime de todos los Estados. Una norma de "Derecho Internacional general" sería aquella que ha sido creada por un gran número de Estados entre los cuales se encuentran las grandes potencias de la comunidad internacional. Una norma de "Derecho Internacional particular" sería la que, habiendo sido creada por dos o más Estados, sólo obliga a éstos en sus relaciones mutuas. Esta clasificación adolece de ciertas incongruencias frente al desarrollo de la doctrina contemporánea del derecho internacional. Así es como se ha confundido al "Derecho Internacional universal" con el orden público internacional y al "Derecho Internacional particular" con el derecho dispositivo.²⁵

²³ Véase en este mismo capítulo: "La obligatoriedad del Derecho Internacional".

²⁴ Kaufmann, E., "Règles Générales de Droit de la Paix", *R.C.A.D.I.*, 1935, vol. IV, pág. 313 y siguiente.

²⁵ Conf. Fitzmaurice, McNair, Jennings, Lauterpach, Bishop.

Por nuestra parte, aceptamos un solo ordenamiento jurídico internacional en el cual coexisten normas generales y normas particulares. La norma general se distingue de la norma particular por el número de Estados participantes en el proceso de creación de esa norma. La norma jurídica particular obliga a dos o más sujetos de la comunidad internacional, mientras que la norma jurídica general obliga a toda, o por lo menos a casi toda, la comunidad internacional.

Ciertas normas particulares, al ser desarrolladas y aceptadas por todos los Estados de una región geográfica, han sido denominadas: normas jurídicas regionales.²⁶ Una norma regional es una norma del derecho internacional cuyo ámbito de aplicación queda limitado a las relaciones entre los sujetos de esa región.

d) *Posibilidad de que una misma norma internacional sea expresada simultáneamente por dos o más fuentes distintas*

Dentro del ordenamiento jurídico internacional existen supuestos en los que idénticos derechos y obligaciones son reconocidos simultáneamente a sujetos distintos en virtud de distintas fuentes de derecho. Así, por ejemplo, un tratado rige conductas de determinados Estados —los que en él son parte—, pero nada obsta a que esas mismas conductas aparezcan impuestas a Estados no parte —terceros Estados— en virtud de una costumbre.²⁷ Esto puede ocurrir tanto porque el tratado tiene el carácter de una convención codificadora que recoge normas consuetudinarias, que continúan vigentes para los Estados que no son partes en el tratado,²⁸ como porque, a partir de la entrada en vigor del tratado, se genera una norma consuetudinaria posterior que reitera idéntico contenido normativo.²⁹

²⁶ Durante la primera década de este siglo se discutió, en el ámbito doctrinario latinoamericano, la existencia o no, de un Derecho Internacional americano autónomo. A favor de la autonomía, el Dr. Amancio Alcorta y el jurista chileno Alejandro Álvarez sostuvieron que, por ejemplo, el principio del *uti possidetis*, el derecho de asilo diplomático, el no cobro compulsivo de las deudas públicas, entre otras, eran reglas privativas del derecho interamericano. Para nosotros, el llamado Derecho Internacional americano, al igual que el derecho particular de cualquier otra región o grupo de Estados, participa de la misma técnica jurídica del Derecho Internacional.

²⁷ Conf. CIJ, caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, Recueil, 1969, §§ 60 a 82. Véase el desarrollo del tema en el cap. II, al referirnos a la Convención de Viena de 1969 sobre el *Derecho de los Tratados*.

²⁸ Tal el caso, por ejemplo, de la Convención de Viena de 1961 sobre *Relaciones Diplomáticas* en las disposiciones referidas a la necesidad del acuerdo entre el Estado acreditante y el Estado receptor para el establecimiento de relaciones diplomáticas (art. 2), la designación del Jefe de la Misión (art. 4), el asiento de las oficinas de la misión (art. 12), la inmunidad de jurisdicción del agente diplomático (art. 31).

²⁹ Así, por ejemplo, el art. 1 del *Tratado Antártico* que establece la utilización de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos.

2. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

a) Origen

El origen del derecho internacional está íntimamente relacionado con el nacimiento durante los siglos XVI y XVII de los Estados europeos como unidades políticas, nacionales y soberanas. Por lo tanto, el derecho internacional nace en la modernidad como consecuencia del novísimo sistema europeo de estados-nación, gestados y desarrollados en el fermento de dos momentos históricos de trascendencia universal: el Renacimiento europeo y la Reforma.

El derecho internacional es, entonces, el ordenamiento jurídico de la sociedad de estados llamada por la doctrina en general, comunidad internacional.

Las comunidades organizadas de la antigüedad, al interrelacionarse, tanto a través de confrontaciones bélicas, como en tiempo de paz, dieron lugar al nacimiento de ciertas pautas de comportamiento de carácter obligatorio. En razón de ello, ciertas normas del derecho internacional contemporáneo reconocen como antecedentes prácticas antiquísimas sobre inmunidades diplomáticas, prisioneros de guerra, alianzas, arbitrajes, etc. Incluso, durante la Edad Media, existieron ciertas normas obligatorias entre las comunidades organizadas en torno al señor feudal. Estas comunidades feudales se sometían al rey y éste a su vez, al Papa o al Emperador. Estas relaciones de subordinación fueron, sin embargo, durante la Baja Edad Media, más la expresión conceptual de una filosofía imperante que el resultado de una verdadera concentración de poderes en la Iglesia o en el Imperio.³⁰

Sin entrar en la discusión de si los Estados modernos son un fenómeno histórico exclusivamente europeo o una respuesta natural a las necesidades humanas comunes a todas las culturas,³¹ debemos reconocer que,

³⁰ Hoffmann, S., *Teorías contemporáneas de las relaciones internacionales*, Técnos, Madrid, 1963; De Visscher, Ch., *Théories et Réalités en Droit International Public*, 4ª ed., París, Pédone, 1970.

³¹ Parry, C., en Sprensen, M., *Manual of Public International Law*, ed. by Macmillan, 1968.

como consecuencia de su poderío económico y militar, los Estados europeos cristianos cimentaron un nuevo orden o sistema jurídico universal que fue impuesto al resto de las comunidades no europeas vinculadas o sometidas a aquéllos. La idea del Estado trasciende las esferas europeas y el mismo sistema interestatal europeo permite la coexistencia de otros Estados como sujetos de las mismas reglas de derecho internacional, en tanto y en cuanto sean esos Estados no europeos, "civilizados".

En una etapa intermedia a las dos grandes épocas referidas, la antigüedad y los tiempos modernos, la idea del Estado solamente fue posible a través de un Estado universal. Para Roma, el derecho es uno solo. En la práctica, el derecho romano tuvo que adaptarse a las nuevas necesidades históricas y es así como aparece el *jus gentium* como el conjunto de costumbres creadas y puestas en práctica por todos los pueblos integrados en el imperio romano. Esta idea de un derecho común a todos y de validez universal, no significaba la aplicación de una sola y única jurisdicción.³²

En la Edad Media, la idea del imperio siguió siendo un principio básico del pensamiento político de la época. El desarrollo y penetración de la influencia de la Iglesia contribuyó a promover la concepción de un orden universal. Si bien la suprema potestad debía ser divina y no terrenal, el representante supremo de la Iglesia Católica pretendió también fundar un imperio terrenal como representante de la potestad divina. Los teólogos buscaron en las fuentes greco-romanas la concepción universalizada del derecho natural.³³

El creador de las leyes naturales sería, entonces, el legislador divino del universo. Así fue como el antiguo derecho natural y el *jus gentium*

³² Durante el Imperio, las jurisdicciones estaban divididas entre las provincias territoriales y una vez que se extendió la ciudadanía romana a todo el Imperio, dejó de tener sentido la distinción entre la ley a aplicar a determinados pueblos y la ley del lugar. Bajo estas condiciones político-jurídicas, se produce la invasión bárbara. Los invasores conocían y respetaban el sistema jurídico romano y solamente introdujeron un principio jurídico de significativa importancia: la ley personal. Este es un principio que deriva del concepto eminentemente tribal de los pueblos invasores. Su ley no podía ser compartida ni siquiera pretendía ser impuesta a los pueblos invadidos que continuaban con sus sistemas jurídicos. Este hecho llevó al predominio de la idea de que el derecho es personal y no universal. Pero cuando los pueblos bárbaros dejaron de ser nómades y se asentaron y convivieron con los pueblos invadidos, lo que en principio se consideró ley personal, se transformó en ley territorial. Los ordenamientos jurídicos se desarrollaron desde entonces como sistemas locales. Las fronteras de estos sistemas correspondieron, a grandes rasgos, a las divisiones territoriales de las provincias romanas, que por su parte se asentaban en realidades geográficas.

³³ Por tal se entiende, desde la antigüedad, al conjunto de normas que se desprenden de la naturaleza racional y social del hombre. El derecho, en su etapa primaria, abarcaría sólo aquellos principios fundamentales, necesarios para la existencia de un orden de convivencia pacífico, racional y moral. Para Platón, el derecho se enraizaba en la idea del bien; el estoicismo fundaba todas las leyes en una ley racional de validez universal que luego Cicerón denominaría *lex aeterna*. Para San Agustín, ésta es expresión de la sabiduría de Dios, cuyo reflejo en la conciencia humana constituye la *lex naturalis*. Véase Verdross, A., *Derecho Internacional Público*, tr. de A. Truyol y Serra, 3ª ed., Madrid, Aguilar, 1961, págs. 16 y 29-31.

se entrelazaron, como postulado cristiano, con la idea de un legislador divino del mundo, que justificaba la existencia y necesidad de un sistema de derecho común a todos los pueblos. Durante el esplendor de la Edad Media, la Iglesia reclamaba y recibía la obediencia de los individuos en cuestiones que iban más allá del ámbito espiritual. Cuando las unidades políticas llamadas Estados comienzan a consolidar sus poderes desde adentro, se resiente la división de poderes y competencias impuestas por la Iglesia. La Reforma religiosa, interpretada desde un punto de vista institucional como la rebelión de los Estados contra la Iglesia, declaró a la autoridad civil como suprema dentro de los ámbitos territoriales bajo su potestad. Aun en los Estados que no aceptaron la Reforma, la Iglesia, como fuerza política, no pudo competir con el Estado como unidad política nacional.

Los últimos tiempos de la Edad Media son el reflejo de las rivalidades y conflictos entre el Emperador y el Papa, por una parte, y los señores feudales y el imperio, por la otra.³⁴ La intensificación del intercambio comercial, el desarrollo y poderío de los burgos y sus zonas de influencia, el nacimiento de nuevas clases sociales y económicas, la amenaza constante de las guerras localistas, el surgimiento de identidades comunes a varias comarcas —tradiciones, lengua, religión—, los grandes descubrimientos, fueron los factores desencadenantes de una nueva distribución de poderes y potestades. El Renacimiento y la Reforma maduraron la revolución que determinó el desmembramiento del sistema feudal y el aglutinamiento de las comunidades locales en incipientes Estados nacionales.³⁵

³⁴ Del resquebrajamiento del sistema político universal surgen remozadas las ideas políticas sobre el Estado. Al término de la Edad Media, el surgimiento de gobiernos centralizados y fuertes fue lento e incongruente. A la descentralización de los poderes de administración pública se sumaban, durante esa época, los inconvenientes propios de una hegemonía político-espiritual, más aparente que real. La íntima relación personal con la posesión de la tierra facilitó la transición del feudalismo hacia una monarquía territorial. La lealtad personal del vasallo hacia el señor feudal se transforma en el deber de lealtad del súbdito hacia el monarca. El desmembramiento de los feudos medievales se produce como consecuencia de la falta de adaptación del sistema de lealtad al señor feudal y de la protección debida por éste a sus súbditos. Organski, A. F. K., *World politics*, A. Knopf, New York, 1961.

³⁵ Los pensadores de la época desarrollaron una serie de conceptos y teorías que ayudaron a racionalizar el nuevo estado de cosas. En torno a los problemas de la naturaleza del Estado moderno y del basamento del nuevo sistema u orden universal surgió la doctrina de la soberanía. Jean Bodin, en su libro *De Republica*, publicado en 1576, extrae conclusiones del estudio de la realidad política de su tiempo. Ante la descentralización de poderes, la rivalidad de los señores feudales y la intolerancia religiosa, propone la vigorización de la monarquía francesa. En la unidad de un gobierno radica su eficacia. El Estado necesita de una autoridad central de la cual emane el poder. Sin la *Summa Potestas* el Estado no sería tal. El Estado es una multitud de familias con sus posesiones comunes gobernadas por un poder supremo y por la razón. La manifestación esencial de la soberanía es el poder para crear la ley. Si bien el soberano no queda obligado por las leyes por él creadas, hay otro tipo de leyes que lo obligan y limitan. Ellas son la ley divina, la ley de la

naturaleza o razón, la ley que es común a todas las naciones y las *leges imperii* o leyes del gobierno. Por lo tanto, el poder del Estado no es arbitrario o irresponsable, sino derivado de una ley que es superior a él. Es el derecho el que hace al gobernante y la naturaleza del derecho determina que detrás de cada norma positiva existe una ley fundamental con una mayor fuerza obligatoria que le da vitalidad a la sabiduría del pasado. Para tener validez, la ley positiva deberá conformarse a aquella ley suprema y la soberanía es en esencia un principio de orden interno. Escritores posteriores a Bodin verán en la soberanía un principio de desorden internacional y se refieren a ella para probar que, por su propia naturaleza, los Estados están por sobre la ley. Como consecuencia de esta postura se identificó por una parte a la soberanía con el poder absoluto y por la otra con las potestades del Estado en sus relaciones con otros Estados.

La consolidación de los Estados modernos con gobiernos fuertes y absolutos fue deteriorando la idea medieval del derecho que delimita toda autoridad humana subsumiéndola a una autoridad superior. La ley la hace el hombre y es la manifestación de la voluntad jerarquizada. El derecho romano enseñó que la voluntad del príncipe es derecho. El acontecer histórico posterior a Bodin, reafirmó al soberano no como al gobernante por ley establecida, sino como sostenedor del poder más fuerte en el Estado, sin importar de dónde emana o de quién deriva ese poder. Estos conceptos son desarrollados por Thomas Hobbes (*Leviathan*, 1651) y Samuel Pufendorf (*De Statu Imperii Germani*, 1667) para quienes, soberanía, es un principio esencial de orden, el derecho no hace al soberano ni limita su autoridad, es el poder el que hace al soberano y el derecho es lo que él comanda y ordena. La soberanía es absoluta e ilimitada. El concepto de poder, integrado en el concepto de soberanía, exige la consolidación de la *summa potestas* en el epicentro generador del poder. La consecuencia directa de esta postura es que, en las relaciones entre Estados, el principio de la soberanía absoluta de los mismos, solamente los autorizaría a reconocer como normas jurídicas a aquellas que concuerdan con sus intereses. La guerra, lejos de estar proscripta en las relaciones internacionales, es el método natural para la solución de controversias.

Frente a la teoría de la soberanía absoluta, los primeros teóricos del incipiente derecho internacional estructuraron sus esquemas y formularon sus principios inspirados en el derecho natural. El derecho natural o derecho de la naturaleza de esa época, basado en el *jus gentium* y el *jus naturale*, ha sido definido como aquella parte de la ley divina que podrá ser descubierta a través de la razón humana, a diferencia con aquella parte del derecho divino que se encuentra directamente revelado. El derecho positivo que contradice al derecho natural no puede considerarse obligatorio. Oponiéndose a la teoría de la soberanía, el derecho natural deniega la total irresponsabilidad jurídica de los soberanos. Para, por ejemplo, Francisco de Vitoria (1480-1546), Domingo de Soto (1494-1560) y Luis de Molina (1535-1600), los límites del derecho internacional no coinciden con los del cristianismo sino con los de la humanidad; la relación entre naciones es de solidaridad, por lo que para que ésta se quiebre es necesario una causa justa; en la guerra, entonces, solo se pueden utilizar los medios que hagan triunfar la justicia. Hugo Grocio (1583-1645) en *De iure belli ac pacis* (1625) sostiene que los Estados forman una comunidad internacional como consecuencia de la existencia del derecho natural dictado por la razón y unido por la supremacía universal de la justicia. En el derecho de gentes general coexisten dos fuentes: a) el derecho de gentes natural que deriva de la razón, y b) el derecho de gentes positivo que deriva de la voluntad de los Estados.

Los defensores de la soberanía absoluta del Estado estuvieron también influenciados por la doctrina del derecho natural: la razón es fuente de derecho y no un mero medio para conocerlo; el derecho internacional no es derecho positivo, sino un conjunto de máximas de la razón —reglas de comportamiento recíproco— (Hobbes) o un principio de derecho natural que obliga a todos a asegurar el bien de la comunidad internacional (Pufendorf).

b) Evolución

La paz de Westfalia (1648), que puso fin a la Guerra de los Treinta Años, es considerada por la ciencia del derecho internacional como el momento histórico que marca la culminación del proceso de aceptación de un nuevo orden jurídico, político y religioso en Europa. Comienza la era del Estado secularizado que reconoce el principio de tolerancia religiosa. A partir de entonces se estructura el sistema moderno de Estados europeos, basado en los conceptos de *soberanía territorial e igualdad de derechos de los Estados*. Desaparece la hegemonía de los Habsburgo y surgen o se consolidan grandes potencias: Inglaterra, España, Portugal, Francia, Suecia y los Países Bajos. Alemania es sólo una expresión geográfica, formada por más de trescientos cincuenta Estados a los que se les reconoce "el libre ejercicio de la superioridad territorial tanto en las cosas eclesiásticas como en las políticas".

El orden político universal que representaba el Imperio es reemplazado por una pluralidad de Estados como entidades iguales y soberanas cuyas relaciones han de desarrollarse sobre una base y en un dominio exclusivamente laico y jurídico. Este proceso de secularización y centralización de poder en entidades estatales expresan un nuevo derecho público europeo e inaugura una nueva etapa que se prolongará hasta el fin de las guerras napoleónicas, dominada por el principio del *equilibrio de poder*. De acuerdo con este principio, ningún Estado ha de poder llegar a ser tan poderoso que esté en condiciones, solo o con sus aliados, de imponer su primacía a los demás. Se trataba de un criterio puramente mecánico, que partía de la hipótesis de la inamistad natural de los Estados, y de una concepción de acentuado individualismo internacional.³⁶ Un sistema complejo y cambiante de vínculos contractuales se impuso para el logro de tal equilibrio.

El derecho público europeo, llamado también derecho de gentes europeo, se estructura sobre las bases de una comunidad internacional enteramente descentralizada, carente de toda forma de organización, en la que se afirman los principios de la igualdad jurídica de los Estados y de la soberanía territorial. Los Estados ejercen sobre sus territorios un poder supremo y exclusivo. Tienen la facultad de imponer los medios de autotutela (las represalias o la guerra) que juzguen necesarios para ejercer sus derechos; se debilita el criterio medieval de la guerra justa y la guerra, reputada lícita, tiene la función de asegurar el reajuste dinámico del orden internacional.³⁷

En este período se establecen normas internacionales sobre la adquisición y pérdida de territorios; nace el moderno derecho de la ocupa-

³⁶ Truyol y Serra, "Genèse et structure de la Société internationale", R.C.A.D.I., 1959, vol. 96, pág. 586.

³⁷ Verdross A., *Derecho Internacional Público*, tr. Truyol y Serra, 4ª ed., Madrid, Aguilar, 1963, págs. 36-37.

ción; evoluciona el derecho de los tratados y las normas sobre la inmunidad de los Estados y de los agentes diplomáticos; se consolidan los principios del alta mar y las normas sobre el mar territorial.

Los grandes descubrimientos y conquistas de los siglos XVI y XVII no alteraron el carácter europeo y cristiano del sistema de Estados y del derecho público entonces imperantes. La paz de Utrecht (1713-1715) consolidó expresamente los principios fundamentales de ese orden jurídico. Cambian esos tratados la fisonomía de Europa y crean un nuevo equilibrio de fuerzas. A comienzos del siglo XVIII, España, Suecia y Holanda han perdido su papel preponderante. Emerge el poder de Prusia, erigida en reino en 1701, afianzado por la incorporación de Silesia y Posnania; el de Rusia bajo el reinado de Pedro el Grande, que se incorpora activamente a la política europea; persiste el poder de Austria en el centro de Europa —dueña de parte de Alemania, Italia del Norte y de parte de los Países Bajos—; y aun el de Francia, que bajo el reinado de Luis XV adquiere Lorena y Córcega.

Pero este siglo será testigo del notable acrecentamiento del poder de Gran Bretaña, a la que la Paz de Utrecht suministra las bases principales. El Imperio inglés se consolida en un ámbito extraeuropeo y su expansión colonial, tanto en las Indias como en América, se realiza a expensas de Francia y de España. El enfrentamiento de los imperialismos coloniales de Francia e Inglaterra, la lucha por posesiones extraeuropeas, por la preponderancia económica y la conquista de mercados desempeña un papel primordial en la historia de este siglo. Se expresa en una acentuada rivalidad marítima que va a concluir con la paz de París de 1763, que puso fin a la Guerra de los Siete Años y completa la obra iniciada en Utrecht con el abandono por Francia de la mayor parte de su imperio colonial en favor de Inglaterra.

La rigidez de los métodos coloniales de la primera potencia colonial llevó a la insurrección de las trece colonias más antiguas de América del Norte. Su independencia, proclamada el 4 de julio de 1776, fue reconocida por el tratado de Versalles de 1783.

La revolución norteamericana se hizo "en el nombre y con la autoridad del buen pueblo de estas Colonias". La idea de la legitimidad dinástica es sustituida en América por una *legitimidad democrática* basada en el libre consentimiento de los pueblos.⁸⁸ En nombre de iguales principios se hará, algunas décadas más tarde, la independencia de las colonias hispanoamericanas.

En una Europa occidental y central pacificadas, la Revolución francesa —a fines de ese siglo XVIII— habría de cambiar fundamentalmente a la sociedad internacional al proclamar, con criterios de validez universal, el nuevo principio de derecho público: el *derecho de los pueblos a disponer de sí mismos*, que convertiría al pueblo en la fuente de toda

⁸⁸ Truylol y Serra A., *La sociedad internacional*, Alianza Editorial, Madrid, 1974, pág. 44.

soberanía y titular del poder político. La Revolución francesa se presentaba como un órgano de la humanidad y sus Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados en términos abstractos y con alcance general, suministraron a los pueblos sus dogmas libertadores. Un decreto de noviembre de 1792 proclamaba "La Convención Nacional declara, en nombre de la Nación Francesa, que ella acordará fraternidad y socorro a todos los pueblos que quieran recobrar su libertad".⁸⁹

Pronto esta fórmula de la soberanía popular —con alcance general— sería sustituida por la de las fronteras naturales y, más tarde, por las viejas concepciones de la conquista. Un grave conflicto enfrentó a la Revolución francesa y a su continuador Napoleón I con Europa. Duró un cuarto de siglo. Francia enfrentó seis coaliciones y fue vencida finalmente por la coalición de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia.

Los tratados de París de 1814 y 1815 reglaron la suerte de Francia y para reconstruir el mapa de Europa las potencias se reunieron en el Congreso de Viena. El Acta final de Viena de junio de 1815, el tratado de la Santa Alianza de septiembre y los tratados de noviembre de 1815, entre ellos el segundo tratado de París, crearon un nuevo orden jurídico. La "paz de Viena" domina el siglo XIX y adquiere la importancia que otrora tuvieron la paz de Westfalia y la de Utrecht.

Las preocupaciones de los vencedores habían sido, básicamente, lograr un relativo equilibrio de fuerzas, para lo cual las fronteras europeas fueron remodeladas. Se obró entonces según la conveniencia de los soberanos, prescindiendo del deseo de los pueblos y del ya irrefrenable sentimiento nacional. Y, fundamentalmente, se procuró afirmar la solidaridad de los príncipes cristianos y la estabilidad de los tronos.

El Pacto de la Santa Alianza del 26 de septiembre de 1815, firmado por Austria, Prusia y Rusia, inspirado por el Zar Alejandro I, sería la expresión de esos principios y de la común voluntad de permanecer unidos "por los lazos de una fraternidad indisoluble y verdadera y de ayudar a socorrerse en cualquier ocasión y lugar". Aunque carente de eficacia real, la Santa Alianza se convirtió en el lema de una política que habría de hallar una manifestación real en el tratado del 20 de noviembre de 1815 del que también participó Inglaterra. De él emergió la *liga permanente* o Directorio de las cuatro potencias. Su finalidad fue asegurar el cumplimiento, por Francia, de las obligaciones de los tratados de París de 1814 y de 1815; excluir de su trono a Napoleón y su familia y resguardar la seguridad de sus respectivos Estados y la tranquilidad general de Europa en caso de que los principios revolucionarios volvieran a amenazarla. Tiene este tratado un rasgo inédito: se convino que los cuatro soberanos o sus ministros celebrarían en épocas determinadas conferencias en las que examinarían las medidas adecuadas para el mantenimiento de la paz y las relacionadas con los grandes intereses comunes. Se

⁸⁹ Colliard, C.-A., *Institutions des Relations Internationales*, 6ª ed., París, Dalloz, 1974, pág. 35.



inaugura en las relaciones internacionales un nuevo procedimiento, el de las *conferencias o congresos periódicos*.

La alianza de los cuatro países habría de transformarse pronto en la *Pentarquía* con la inclusión de Francia en el Directorio europeo, admitida en el Congreso de Aquisgram de 1818 en igualdad con sus vencedores.

En esta época de Restauración se pretendió erigir a un principio político, el de la *legitimidad*, en una norma del derecho de gentes. En su nombre y por decisión de Metternich se vino a legitimar el *derecho de intervención*. Por tres veces se haría uso de ese derecho, pese a la oposición de Inglaterra. En los Congresos de Tropeau (1820) y de Laybach (1821), Austria fue encargada de una intervención armada en nombre del llamado *orden europeo* para restablecer en Nápoles la autoridad absoluta de Fernando I y reprimió la insurrección liberal del Piamonte. En el Congreso de Verona (1822) se encomendó a Francia el restablecimiento de la monarquía absoluta de Fernando VII en España. Gran Bretaña se pronunció particularmente en contra de esta intervención; consideraba que la alianza debía resguardar a Europa de un poder revolucionario, pero no poner trabas a las ideas liberales. La solidaridad de los tronos comenzaba a quebrantarse y la política de intervención a declinar.

Las perspectivas de una intervención de las potencias de la Santa Alianza para restablecer el orden monárquico en América hispana habrían de quedar excluidas ante la política británica y en razón de la actitud asumida por el presidente de los EE. UU., J. Monroe, quien en su mensaje al Congreso de su país (2 de diciembre de 1823) enuncia ciertos principios políticos conocidos con el nombre de *doctrina Monroe*, que pasaron a constituir una pieza básica de la política exterior norteamericana.

El presidente de los EE. UU. considera que cualquier intento de las potencias europeas de extender su sistema político a cualquier lugar de América es peligroso para la paz y la seguridad de los EE. UU. y tras afirmar que su país no se ha inmiscuido ni se inmiscuirá en las colonias o dependencias europeas existentes en América, advierte que los EE. UU. no podrían admitir ninguna intervención con el propósito de oprimir o controlar de cualquier manera el destino de los gobiernos que han declarado su independencia, sino como la manifestación de una política inamistosa con respecto a los EE. UU.

En 1824, Gran Bretaña, por medio de Canning, hizo conocer su negativa a asistir a un Congreso sobre la cuestión colonial. La idea de intervención en el Nuevo Mundo se desvanecía y los principios rectores de la Santa Alianza dejarían de tener vigencia, al menos en sus formas originales, entre las potencias europeas.

La obra del Congreso de Viena había procurado estabilizar la Europa monárquica y consolidar las fronteras. El criterio de legitimidad contradecía el espíritu contemporáneo y era incompatible con las ideas de nacionalismo y de la soberanía de los pueblos que impulsarían los movimientos revolucionarios de 1830 y 1848.

En 1822, Grecia se segrega del Imperio otomano. Un protocolo de

Londres, de 1830, oficializa el nacimiento del nuevo Estado, de cuya independencia serían garantes Francia, Gran Bretaña y Rusia. La Revolución francesa de 1830 asesta el golpe más duro a la teoría de la legitimidad. Una nueva dinastía, la de los Orleans, desplaza a los Borbones. La constitución de ese año proclama la soberanía del pueblo y el *principio de no intervención* como la más valiosa salvaguardia de la independencia y soberanía de los Estados. Los principios revolucionarios se propagan con resultado dispar. El movimiento nacionalista polaco es sofocado por Rusia, pero triunfa, en cambio, un movimiento que se inicia en Bruselas y se extiende a toda Bélgica. Los antiguos países bajos austríacos, católicos, habían sido incorporados por la fuerza a Holanda para impedir su anexión a Francia. La independencia de Bélgica es reconocida en Londres por las cinco potencias de la Pentarquía y se le asigna un estatuto de neutralidad permanente. El estatuto territorial de 1815 sufría la primer modificación.

Se acentuaba la declinación del principio de legitimidad y cobraba vigencia el principio de las *nacionalidades*. Al Directorio europeo le sucede una forma más atenuada, a través de las cuales se sigue manifestando la preponderancia de un pequeño grupo de potencias: el *concierto europeo*, en cuyo seno Prusia, Austria y Rusia procuran preservar los principios de la Santa Alianza, en tanto Francia y Gran Bretaña alientan tendencias liberales.

La estructura conservadora de la Europa de Viena es conmovida en 1848 por un vasto movimiento revolucionario. Europa se ha industrializado. La cuestión social comienza a preocupar a los gobiernos; el artesano se proletariza, surgen las doctrinas socialistas y se desarrolla el sindicalismo. Ese movimiento se generaliza. Se trata de obtener regímenes más liberales ya sea mediante la proclamación de la República, como en París, a través de la obtención de una constitución, como en diversos Estados de la Confederación germánica, o de poner fin a la dominación extranjera. El régimen de Metternich se hunde, lo que impulsa la ola revolucionaria que, sin embargo, es finalmente vencida al escindirse la alianza de hecho entre la nobleza liberal y la burguesía moderada con los demócratas y socialistas.⁴⁰

La agitación nacional y republicana, no obstante, no cesa desde 1830. A los sentimientos e ideas nacionales se unen factores económicos. La revolución industrial cambiaba rápidamente las estructuras económicas; la fluidez de los nuevos medios de comunicación aproximaba a los pueblos y creaba una solidaridad de intereses que para lograr un cauce adecuado necesitaba superar el excesivo fraccionamiento político. La construcción de Europa según el principio de las nacionalidades es alentada por Napoleón III, plebiscitado Emperador de Francia, en tanto que el Zar de

⁴⁰ Renouvin, P., *Historia de las Relaciones Internacionales*, Madrid, Aguilar, 1960, t. II, vol. I, pág. 159.

Rusia, que había reprimido la subversión, había perdido poder tras la guerra de Crimea y la Paz de París de 1856 que le puso fin y en la que se admite a Turquía —primer país no cristiano— a participar del “orden público europeo”.

En la segunda mitad del siglo XIX se plasma la unidad de Italia y la de Alemania. Bajo la dirección de Cavour y en torno del Piamonte se realiza la unidad italiana en detrimento de Austria y de los Estados Pontificios. En 1861 se proclama el Reino de Italia con la dinastía de los Saboya. En Alemania, Bismarck, canciller de Guillermo I, procurará la unidad “por el hierro o por el fuego”. Las guerras victoriosas de Prusia contra Austria y Dinamarca aceleran el proceso. Se constituye la Confederación Alemana del Norte, con el Rey de Prusia como Presidente y Bismarck como canciller. Los Estados del Sud quedan vinculados a Prusia mediante una unión aduanera (*Zollverein*). La guerra victoriosa contra Francia consuma la unidad alemana. Tras la derrota de Sedán se hunde el Imperio francés. En enero de 1871 el Rey de Prusia es coronado emperador y Francia, erigida nuevamente en República, pierde Alsacia y Lorena.

Se inicia una etapa con el predominio de Alemania, que rompe el equilibrio entre las potencias continentales. Su restablecimiento será la preocupación primordial de este período que se prolonga desde 1890 hasta 1914, año en el que la guerra mundial quiebra el sistema, ya sumamente debilitado, del concierto europeo.

En tanto, en esa segunda mitad del siglo XIX, una rápida expansión colonial proyecta a las potencias europeas sobre el África y Asia.

Comenzado alrededor de 1880, el reparto de África prosiguió durante veinte años para concluir con el dominio casi total de las llamadas “Indias Negras”. Por otra parte, Francia extiende su autoridad desde Argelia y ejercerá su protectorado sobre Túnez y Marruecos. Gran Bretaña ocupa Egipto en 1882 y contemporáneamente Italia constituye su microimperio en Somalia y Eritrea. En esta vasta empresa colonialista rivalizaron las grandes potencias. Una Conferencia —la de Berlín de 1884-5— dedicada a los problemas del África Central estableció el *principio de la ocupación efectiva* de los territorios y reguló la situación de los ríos africanos. Creó una “Cuenca convencional del río Congo”; proclamó el *principio de la igualdad económica* y la libre navegación del Níger y del Congo. El rey Leopoldo II se hizo reconocer la propiedad del Estado independiente del Congo, dotado de verdadera personalidad jurídica. Una Conferencia posterior —Bruselas, 1890— buscó sistematizar los principios de la colonización africana y como medio de atenuar las rivalidades procuró, como la anterior, trasponer la teoría del equilibrio del poder al Continente negro.⁴¹

En Asia, el milenarismo aislamiento chino fue quebrado por la fuerza

⁴¹ Dollot, L., *Historia Diplomática*, tr. A. Garzón del Camino, ed. Alameda, México, 1954, pág. 123.

de la flota británica. Inglaterra, posesionada ya de la India, quiso abrir el vasto mercado chino a los productos de su industria en expansión. La acción comenzada con el tratado de Nankín (1842) —que puso fin a la guerra del opio y que determinó la apertura de puertos y derechos de extraterritorialidad— continuó sin pausas en un proceso de desintegración de la soberanía de China al punto que a fines del siglo anterior y a comienzos del actual no quedaba sino una independencia nominal del vasto país. Luego de los llamados “tratados leoninos” de 1898, por los que se arrendaban puertos a Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña y se concedían a estos países franquicias exorbitantes, China quedó virtualmente repartida en zonas de influencia extranjeras.

La política de los países occidentales mostró, en algunos aspectos, una cierta unidad en Asia, exteriorizada durante la guerra de los Boxers por el envío, en el año 1900, de una fuerza verdaderamente internacional, formada no sólo por países europeos, sino también norteamericanas y japonesas y por la intervención de Francia, Alemania y Rusia para temperar los términos de la paz que le fue impuesta a China en 1895 por el Japón victorioso.

Este país, sustraído de su aislamiento por los EE. UU. a partir de 1854, a diferencia de China, alcanzó a restaurar sus instituciones imperiales. Desde 1868 siguió una activa política de industrialización y de desarrollo militar. La victoria sobre China en 1895 le permitió a su turno y a semejanza de los Estados occidentales —cuya tecnología había imitado y absorbido— aspirar a convertirse en una potencia colonial. En 1902 se vincula a Gran Bretaña mediante un tratado de alianza, primer acuerdo igualitario entre una potencia europea y un Estado asiático de la era contemporánea. Su triunfo sobre Rusia en 1905 tuvo una acen tuada importancia política. Demostró que las potencias europeas no eran invencibles e impulsó el nacionalismo asiático, particularmente en la India.⁴²

En Marruecos y en los Balcanes se manifestó también la rivalidad de las potencias europeas y el predominio de sus intereses políticos. Los conflictos allí suscitados, como también las cuestiones del extremo oriente, determinaron el estado de paz armada en la Europa de fines del siglo XIX.

El ambiente de paz formal que, sin embargo, imperó en el continente, fue propicio para la realización de dos conferencias internacionales en La Haya, las de 1899 y 1907. La primera de estas conferencias codificó parcialmente el derecho de guerra terrestre y los métodos de solución pacífica de las controversias; instituyó una Corte Permanente de Arbitraje. La segunda conferencia aportó trece convenciones y una declaración afirmando el principio del arbitraje obligatorio. Se reguló la neutralidad en caso de guerra terrestre y marítima; regló la guerra marítima y se estatuyó un Tribunal Internacional de Presas. La segunda de estas conferencias

⁴² Caroline F. Ware, K. M. Panikkar y J. M. Romein, *Historia de la humanidad*, Ed. Sudamericana, 1976, vol. VI, t. I, pág. 44.

agrupó a cuarenta y cuatro Estados, muchos de ellos no europeos. Muestra ya la tendencia a extender el ámbito de la sociedad internacional, al menos para la regulación de cuestiones jurídicas.

En tanto, en América, la conferencia de Washington de 1899 convocada por iniciativa de los EE. UU. —que ya han surgido como poder mundial— señala el comienzo del sistema interamericano en el que —entre otros principios— se afirma precursoramente el *no reconocimiento* de las situaciones derivadas del empleo de la fuerza y se acoge el principio de la *solución pacífica de controversias*.

En Europa se consolidan los vínculos que tendían a mantener un equilibrio entre las potencias y se intensifica el armamentismo. Estas rivalidades políticas y una aguda competencia económica afectaban profundamente las relaciones entre los países de Europa central, Alemania y el Imperio Austro-húngaro, agrupados con el Imperio otomano en la Triple Alianza, por un lado, y Gran Bretaña, Francia y Rusia vinculados por la Triple Entente, por el otro, y llevarían a la Primera Guerra Mundial. La participación de los EE. UU., Japón e Italia en contra de los países centrales le confirió, en realidad, tal carácter.

A su término, tras más de cuatro años de guerra, cuatro Imperios habían sucumbido: el alemán, el austro-húngaro, el otomano y el ruso. Adviene la revolución comunista y el gobierno bolchevique se consolida en la lucha civil, a pesar de la intervención de las potencias aliadas. La comunidad internacional se institucionaliza con la creación de la Sociedad de las Naciones.

Si tal ha sido a grandes rasgos la evolución de la sociedad internacional desde el Congreso de Viena, nos queda por hacer una breve referencia a las normas internacionales que durante ese período se gestaron. El avance tecnológico, la expansión del comercio internacional y la intensificación de las relaciones internacionales contribuyeron al progreso del derecho internacional.

Se desarrolla el principio de la libre navegación de los ríos internacionales, que comienza con las normas del Congreso de Viena. Tratados internacionales resguardan los derechos de autor y la propiedad industrial. Para proteger al individuo se sanciona la abolición del tráfico de esclavos; se tiende a la protección de las minorías; se persigue la trata de blancas y el tráfico del opio.

Se procura humanizar la guerra y se emprende la codificación parcial de sus normas. Se desarrollan los métodos pacíficos para la solución de controversias. Y se dan los primeros pasos para la cooperación internacional en ámbitos técnicos, la que adquiere ciertos rasgos institucionales a través de las llamadas Uniones Administrativas. Se crean así, la Unión Telegráfica Internacional (1865), la Unión Postal Universal (1878), la Unión para la protección de la propiedad industrial (1883), la Unión para la protección de la propiedad literaria y artística (1884), la Unión para el transporte internacional por ferrocarril (1890), etc. Asimismo, exis-

ten organismos formados para la administración de los ríos internacionales, como el Rhin y el Danubio.

El derecho internacional no regula, empero, las cuestiones que comprometen los intereses vitales de los Estados.

En lo político, durante este período, la comunidad internacional se caracterizó por la primacía y autoridad que se habían asignado cinco potencias del Concierto europeo sin consentimiento expreso de los Estados. Sus competencias eran autodefinidas y en su ejercicio el interés de la comunidad internacional fue a menudo sacrificado al interés particular de las grandes potencias. Las bases del sistema emanaban de los tratados de 1815 y 1818, que no erigieron una organización política estable. Ante un problema determinado, los miembros del Directorio guardaban entera libertad de reunirse o no para considerarlo. Su acción estuvo presidida por un criterio empírico y sus Congresos no tenían, consecuentemente, sedes predeterminadas, ni competencias definidas. De ahí que cuando se consolidan en Europa los dos grupos antagónicos, el de la Triple Alianza y el de la Triple Entente, el sistema se quebranta. A fines del siglo XIX y a comienzos del actual, período de la paz armada, este esquema atenuado de organización de hecho de la sociedad internacional evidencia su insuficiencia.

Frente a la preponderancia que se habían asignado por derecho propio los miembros del Directorio, el Pacto de la Sociedad de las Naciones —que encabeza el Tratado de Versalles (1919) y los demás tratados de paz con las potencias vencidas— se basó en el principio de la igualdad soberana de los Estados miembros. Creó la organización más elaborada y universal que hasta entonces se conociera. Con la Sociedad de las Naciones la comunidad internacional tiene una base estatutaria y orgánica. Su misión principal fue la de preservar la paz y la seguridad y promover la cooperación internacional. Dotada de permanencia, a través de ella todos los miembros coparticipan en la consideración de las cuestiones internacionales, pues si en el Consejo de la Sociedad, de composición restringida, las grandes potencias se reservan una posición preponderante como miembros permanentes, la Asamblea acoge, con igualdad de voto, a todos los miembros. En el marco de la Sociedad de las Naciones funcionó una Corte Permanente de Justicia Internacional.

El Pacto sentó el principio de la seguridad colectiva al comprometer a los miembros a respetar y a preservar contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política existente. La guerra deja de ser algo que concierne sólo a los beligerantes para afectar a la Sociedad de las Naciones toda. Y si bien salvo esos supuestos de agresión aquella no fue proscripta, la observancia de ciertos requisitos —recurso al arbitraje o sometimiento previo de la divergencia al Consejo— condicionó su legitimidad.

La Sociedad de las Naciones tuvo éxito en campos diversos: en el de la cooperación internacional en los campos económico y social; con relación al tratamiento de los problemas coloniales, mediante la institución

del sistema de mandatos, que excluyó la anexión pura y simple de los territorios dependientes de las potencias vencidas (Alemania y Turquía) y buscó preservar —bajo control internacional— el bienestar y desarrollo de sus pueblos como “una misión sagrada de civilización”, a través del mandato asignado en nombre de la Sociedad a una potencia mandataria; en la protección de ciertas minorías, etc. Pero adoleció de deficiencias que comprometieron sus posibilidades, sobre todo en el campo político: a) el Pacto integraba el Tratado de Versalles y quedó de tal suerte vinculado a las vicisitudes políticas con las que, en él, se resolvieron problemas de índole territorial y económica; b) los Estados Unidos se negaron a participar en el sistema de Ginebra, lo que menguó su universalidad y limitó la eficacia de las sanciones. Desde un principio quedaron excluidas Rusia y Alemania. En 1933 se separó Japón y si Alemania fue admitida en 1926, cuando en 1934 se admitió a la URSS, aquella ya se había retirado. Al margen de la ausencia de los EE. UU., en momento alguno las grandes potencias integraron, simultáneamente, la Sociedad; c) el sistema de sanciones previsto para los casos de guerra de agresión era totalmente descentralizado y su efectividad venía a quedar librada a la discreción de sus miembros.

De tal modo, tras algunos éxitos parciales, como el arreglo de la cuestión de Silesia, entre Alemania y Polonia y el de las islas de Aland entre Finlandia y Suecia, entre otros, dos acontecimientos demostraron la debilidad de la Sociedad. El primero, la invasión de Japón a la China en 1931, que se apoderó de Manchuria y creó el Estado artificial de Manchukuo, situación de hecho ante la que la Sociedad de las Naciones debió doblegarse; y el segundo, la invasión de Italia a Etiopía, conflicto en el que la calificación de Italia como agresor, pronunciada por la Asamblea en 1935, y las sanciones económicas que la sucedieron —carentes de eficacia real— no impidieron la anexión de Etiopía a Italia. Vino luego la absorción de Austria por Alemania en 1938, su triunfo sobre Checoslovaquia en el tratado de Munich del mismo año y su invasión en 1939; la ocupación de Albania por Italia también en 1939.

Los factores y acontecimientos reseñados llevaron al fracaso político de esta primera experiencia de organización institucionalizada de la comunidad internacional. La expulsión de la URSS por su agresión a Finlandia fue su último acto político. Ninguna función cumplió cuando estalló la segunda guerra mundial. Quedaba, empero, una valiosa experiencia que fue aprovechada en la Conferencia de San Francisco. Abierta a todas las Naciones Unidas —es decir, a todos los países en guerra contra las potencias del Eje— elaboró en 1945 la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta vez los objetivos buscados son más amplios. No sólo se pretende mantener la paz y la seguridad internacionales, sino también fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pue-

blos; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos comunes.

Para su logro, se afirman ciertos principios como el de la igualdad soberana de los Estados miembros, el arreglo pacífico de las controversias internacionales y, entre otros, la *abstención de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza*. Este último principio, de por sí, comporta un avance fundamental en el derecho internacional. Supera en amplitud y precisión toda regulación anterior sobre la guerra y viene a consagrar la ilicitud no ya del recurso a la fuerza, sino también la de su amenaza. A partir de la Carta, la fuerza puede ser sólo lícitamente empleada por la Organización con la única excepción del derecho transitorio a la legítima defensa.

Con la ONU se consolida el proceso de institucionalización de la comunidad internacional. No sólo su estructura orgánica es más compleja que la de la Sociedad de las Naciones, sino que son más vastas sus competencias y mayores sus poderes. En favor del Consejo de Seguridad —en cuyo seno las cinco grandes potencias vencedoras, la República de China, Francia, la URSS, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los EE. UU. guardan el privilegio de ser miembros permanentes y el derecho de veto— se opera una verdadera transferencia de competencias estatales: puede disponer medidas coercitivas, incluso el empleo de la fuerza, que obligan a los Estados miembros. Reconocen ellos que tal órgano actúa en su nombre cuando asume la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional.

Las Naciones Unidas constituyen, al término de la segunda guerra mundial, la fuerza política esencial de la comunidad internacional y en torno a ella se ha erigido una vasta red institucional de alcances ya universales o regionales, de competencias generales o específicas, que reflejan la heterogeneidad y complejidad del mundo de la postguerra. Se caracteriza éste por transformaciones profundas de la vida internacional.

La comunidad internacional se ha universalizado. Al término de la segunda guerra mundial casi una cuarta parte de la población del mundo vivía en territorios dependientes. La ONU, al constituirse en 1945, contaba con 51 miembros. Era una institución eminentemente occidental. La declinación de Europa precipitó un proceso de descolonización que sería activado y propiciado por la propia Organización y que desintegró los imperios coloniales consolidados en la segunda mitad del siglo XIX. Este proceso es uno de los acontecimientos de mayor trascendencia política del siglo actual. Emergen nuevos Estados en Asia y, a partir de 1960, el fenómeno se acelera en África. La ONU, con sus actuales 149 Estados miembros, refleja ese cambio cuantitativo sustancial. Su representatividad es mucho mayor que la de la Sociedad de las Naciones y no tiene precedentes en anterior época histórica.

La comunidad internacional se ha expandido, ha ampliado el campo de sus preocupaciones e intereses. Preservar la paz y la seguridad perduran como los objetivos básicos de esa comunidad institucionalizada, pero éstos trascienden ahora al campo económico y social. Se ha afirmado la convicción de que no sólo las confrontaciones políticas e ideológicas pueden comprometer la paz, sino que la desigualdad económica de pueblos y naciones impide la existencia de un orden internacional estable. De ahí que la Carta haya hecho anticipadamente de la cooperación en la solución de los problemas económicos y sociales uno de sus propósitos fundamentales y haya impuesto a los Estados miembros la obligación de tomar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar la promoción del desarrollo económico y social.

Una red institucional compleja cubre casi todos los aspectos del desarrollo. Integra la llamada "familia" o "sistema" de la ONU, y está formada por la Organización a través de dos de sus órganos principales, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, y por un conjunto de organizaciones intergubernamentales autónomas vinculadas a ella mediante acuerdos particulares, los "organismos especializados".

Junto al derecho tradicional emerge un derecho de cooperación cuyo fin no es reglar conflictos, sino conciliar intereses. Se presenta como un derecho abierto, dinámico y progresista.

El prodigioso desarrollo científico y técnico verificado a partir de la segunda guerra mundial dio cauce, asimismo, a nuevos temas de regulación y cooperación internacionales. Al caducar el monopolio atómico de los EE. UU., un movimiento de cooperación internacional, a través de diversos tratados, procuró la utilización pacífica de la energía nuclear, evitar la proliferación de armas nucleares y realizar la desnuclearización de ciertas regiones. El espacio ultraterrestre, comprendiendo a la Luna y demás cuerpos celestes, han sido sustraídos a toda apropiación nacional y se hallan abiertos indiscriminadamente a la actividad pacífica de todos los Estados. Un criterio similar rige respecto de los fondos oceánicos más allá de las jurisdicciones nacionales, a los que se califica como "patrimonio común de la humanidad". Y mediante la cooperación internacional se procura preservar el medio ambiente.

La superación de la guerra fría ha contribuido a acentuar esta cooperación internacional. El enfrentamiento de las dos superpotencias —EE. UU. y la URSS— y la tensión y fricción constantes entre dos bloques antagónicos, el del mundo occidental y el socialista, caracterizó políticamente la primera etapa de la postguerra. Este antagonismo incidió en el funcionamiento de las Naciones Unidas y se manifestó en la actuación del Consejo de Seguridad, paralizado por el ejercicio del derecho de veto. Este período, en el que el potencial bélico de las dos superpotencias —dotadas de bombas termonucleares y de cohetes intercontinentales— es por vez primera en la historia capaz de extinguir la civilización, creó lo que se llamó *el equilibrio del terror* y condujo a la "mutua disuasión"

basada en la capacidad de destrucción recíproca.⁴³ La guerra fría mostró sus fases más agudas desde 1947 hasta la muerte de Stalin. Gradualmente su rigorismo se atenúa. En 1953 se firma el armisticio de Corea, en 1954 los convenios de Ginebra ponen fin a la primera guerra de Indochina, en 1955 se concluye el Tratado de Estado que restablece Austria como un Estado independiente y democrático, en 1956, con la intervención de las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas y el asentimiento de los EE. UU. y la URSS se interrumpe la acción militar israelí y franco-británica en Egipto. Pero es a partir de 1962, más precisamente tras la crisis de los cohetes en Cuba, que se afirma la política de la *coexistencia pacífica*. La certidumbre de que es imposible una victoria militar sobre el bloque antagónico sin el riesgo de la propia destrucción, el reconocimiento de la recíproca legitimidad y la aceptación de un mínimo de solidaridad entre todos los miembros de la comunidad fundamenta la nueva etapa de las relaciones internacionales. La irrupción del tercer mundo a la vida internacional y sus reclamos de un neutralismo positivo contribuyen a quebrantar el esquema bipolar rígido. Se acentúa la convicción de que es menester evitar la guerra y que cada Estado, cada bloque, debe convivir, coexistir con Estados o grupos de Estados cuyas valoraciones, cuya ideología e intereses políticos y económicos son disímiles.

Ni la oposición de intereses, ni los conflictos ideológicos, ni la abierta competencia se hallan excluidos, pero la existencia de un cierto grado de acuerdo, expreso o tácito, y de un mínimo de cooperación se imponen como necesarios para el mantenimiento del equilibrio y de la paz mundial. La teoría de la "coexistencia" se presenta como conforme a los imperativos del derecho internacional y propicia el desarrollo de las Instituciones internacionales.⁴⁴ Sus principios se encuentran recogidos en la Resolución A/2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 —que contiene la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas— y desarrollados, a través de una reciente formulación normativa, en el Acta final de Helsinki (agosto de 1975) aprobada en la Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, que afirma la política de la "détente".

En esta etapa de la evolución de la comunidad internacional, caracterizada por la convergencia de los Estados soberanos —que perduran como sus principales protagonistas— y múltiples organizaciones internacionales, el reconocimiento de los derechos humanos y su consagración a través de tratados internacionales marca un avance positivo en el proceso de afianzamiento de la subjetividad jurídica internacional del individuo y en la afirmación de contenidos éticos en las reglas positivas del derecho de gentes.

⁴³ Aberastury, M., *Política Mundial Contemporánea*, Paidós, 1970, pág. 193.

⁴⁴ Colliard, C.-A., *op. cit.*, pág. 70.

3. OBLIGATORIEDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL Y FUNDAMENTO DE VALIDEZ DE LA NORMA INTERNACIONAL

a) Obligatoriedad del Derecho Internacional

El escepticismo cotidiano del hombre de la calle frente al derecho internacional es fiel reflejo de la falta de información sobre las características propias de este ordenamiento jurídico.

Desde el punto de vista doctrinario distintas teorías sobre la naturaleza del derecho internacional han cuestionado su carácter jurídico. Para estas teorías, el llamado derecho internacional no sería entonces una rama de la ciencia jurídica, sino de la ética o de la moral internacional. Esta posición, que niega la existencia del derecho internacional, reconoce remotos antecedentes en el pensamiento político de Hobbes y Espinosa, para quienes la sociedad de Estados se encuentra en pleno estado de naturaleza, carece de legislador y de un poder coercitivo centralizado. Por lo tanto, cada Estado tiene tantos derechos como poder para efectivizarlos.

John Austin, fundador de la escuela analítica del derecho, es quien con mayor rigorismo científico definió al derecho internacional como parte de una moral positiva internacional. La escuela analítica no acepta como derecho ningún postulado que no emane de la voluntad de un poder político supremo. El derecho es siempre el mandato de un superior dirigido a un inferior. Esta relación no se da entre Estados, pues no existe una legislación universal emanada de un poder superior a ellos, ni tampoco una instancia jurisdiccional compulsiva, ni órganos centrales para la ejecución de las normas.

Los doctrinarios anglo-sajones clásicos argumentan, en contra de la escuela analítica, que todas las características por ella apuntadas para negar la naturaleza jurídica del derecho internacional, son instancias típicas de los sistemas legales primitivos o de los sistemas aún en pleno desarrollo, que no por ello dejan de ser verdaderos sistemas jurídicos.⁴⁵

La doctrina continental europea reacciona frente a los postulados de Austin distinguiendo entre un derecho de subordinación —caso del derecho interno de los Estados— y un derecho de coordinación —caso del derecho internacional.⁴⁶

⁴⁵ Conf. Oppenheim, Brierly, Lauterpacht, Mc Nair, Brownlie.

⁴⁶ Véase lo ya dicho en el punto 1 de este capítulo sobre "derecho de coordinación y derecho de subordinación".

Para los que como Hegel ven en el Estado la suprema organización humana, el derecho internacional no es otra cosa que el derecho estatal externo, pues no existe una voluntad superior en el proceso de creación de normas jurídicas internacionales, sino voluntades particulares. Esta postura doctrinaria es el antecedente inmediato de la teoría de la autolimitación de los Estados formulada como respuesta voluntarista al problema del fundamento del derecho internacional.

Las profundas transformaciones que se producen en la sociedad internacional a partir del siglo XIX favorecen el reconocimiento de la obligatoriedad de la norma internacional. Así, en las relaciones internacionales, los Estados comprueban que la política de fuerza —basada en el concepto de la soberanía absoluta— los conduce en definitiva a su propia destrucción. El comercio internacional, para desarrollarse, necesita de un marco jurídico con cierta estabilidad. Los Estados no pueden pretender vivir aislados y sienten el imperativo de ampliar sus vínculos asentándolos sobre bases jurídicas.

Se hace evidente a través de la conducta de los Estados su aceptación de un orden jurídico que los relaciona. Permanentemente pretenden que su accionar se adecua a las normas de derecho internacional y rechazan aquellas conductas que consideran violatorias de este derecho.⁴⁷ Se vinculan a través de fórmulas jurídicas y fundamentan sus políticas exteriores en el derecho internacional.

Infinidad de actos estatales cotidianos revelan el acatamiento a normas del derecho internacional. Así, por ejemplo, la libertad de navegación en alta mar, el respeto a las inmunidades diplomáticas, el cumplimiento de buena fe de los tratados en vigor, etcétera.

La participación de los Estados en la creación de las normas, traduce un interés en su contenido y demuestra la voluntad de cumplirlas.

Existe, además, un interés común en fortalecer el sistema jurídico internacional, pues dado el grado de interdependencia entre un crecido número de Estados, el debilitamiento del orden jurídico resiente la necesaria cooperación y la estabilidad de los vínculos. El beneficio inmediato que puede resultar para un Estado de la inobservancia de una norma jurídica internacional puede traducirse en perjuicio futuro, cuando un tercer Estado desconozca frente a aquél la misma norma, de la que entonces puede pretender prevalecerse.

La posibilidad de violación de normas internacionales no es más que la comprobación fáctica de la existencia de una norma jurídica violada, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

Los conflictos armados se presentan como las más grandes manifestaciones de violación de las normas internacionales que los proscriben, pero ello no dice de la ausencia de juridicidad del derecho internacional, como

⁴⁷ Observando el comportamiento de los Estados es factible formular todo tipo de juicios: el Estado A ha violado una norma de derecho; el Estado B y C han creado una norma convencional, etc. La posibilidad de realizar estos juicios nos demuestra la existencia de un sistema normativo.

tampoco el frecuente fenómeno de las luchas civiles o la ruptura del orden constitucional priva de carácter jurídico al derecho interno.

Si en el derecho internacional los mecanismos de sanción no han alcanzado un grado de desarrollo similar al que poseen en los derechos internos, ello no autoriza a privarlo de alcance jurídico. Aun en los ordenamientos internos hay casos en que el delito no logra ser sancionado o el derecho quebrantado no alcanza a ser restablecido.

Por otra parte, el legislador común que formula el derecho por medio de leyes no es indispensable para que exista un orden jurídico; el derecho surge independientemente del proceso de creación de la ley y las normas jurídicas también pueden emanar de acuerdos de voluntades de los sujetos de derecho —por ejemplo, de tratados multilaterales— o de la costumbre.

Ninguna de las peculiaridades del derecho internacional impide que concurren, en su caso, los supuestos esenciales de la juridicidad: la existencia de una pluralidad de sujetos, cuyas conductas respectivas se encuentran en interferencia intersubjetiva; y el reconocimiento, por parte de esos sujetos, de ciertas pautas de conducta que los obligan.⁴⁸

b) Fundamento de validez de la norma internacional

Distintas teorías han tratado de explicar la obligatoriedad del derecho internacional. Dentro de éstas es posible distinguir las teorías *voluntaristas* de las *objetivistas*.

1. Teorías voluntaristas

Las teorías voluntaristas, también llamadas subjetivistas, tratan de encontrar el fundamento del derecho internacional en la voluntad de los Estados. Su postulado básico expresa que la suprema voluntad de éstos es la que le da contenido jurídico a las normas internacionales. Estas teorías se desprenden del positivismo jurídico de fines del siglo XIX y principios del XX y dentro de ellas ubicamos a la teoría de la autolimitación, a la teoría de la voluntad común y a la doctrina soviética contemporánea.

a) Teoría de la autolimitación

Esta teoría reconoce antecedentes inmediatos en el pensamiento político de Hegel, pero es Jellinek quien le dio formulación científica al establecer que el Estado, en razón de su voluntad soberana, se obliga frente a otro u otros Estados. Jellinek identifica las bases del derecho con los fines del Estado. De acuerdo a la distribución política del poder entre las naciones, éste es el único juez de sus intereses y necesidades. Su soberanía implica que no existe subordinación alguna más allá de las creadas

⁴⁸ Pollock, F., *First book of jurisprudence*, pág. 28.

por su propia capacidad para obligarse a sí mismo. Pero esa obligación emana de un acto discrecional del Estado, no condicionado; por lo tanto, podrá “desobligarse” ejerciendo esa misma voluntad soberana inmanente e irrevocable. Las consecuencias extremas de la teoría de la autolimitación ponen en peligro la estabilidad que se quiere proteger a través de las normas internacionales. Sostener que el derecho internacional no es otra cosa que la suma de los derechos estatales externos, implica negar la existencia misma del derecho internacional. Este, afirma Jellinek, es sólo un derecho anárquico e imperfecto.⁴⁹

b) Teoría de la voluntad común

Esta teoría fue formulada por Triepel⁵⁰ como reacción a la teoría de la autolimitación. No basta la voluntad de un solo Estado, sino que es necesaria la concurrencia de dos voluntades, por lo menos, para que exista una norma del derecho internacional. Los actos concluyentes de un Estado, con relevancia en el orden internacional, serán los antecedentes válidos en el proceso de creación y formulación de una norma jurídica internacional. Pero solamente en la concurrencia y coincidencia de actos concluyentes válidos para cada Estado —o sea en el acuerdo de voluntades estatales— se sella y fundamenta el nacimiento de una norma jurídica internacional. La voluntad del Estado puede ser expresa (tratados) o tácita (costumbre). Esta posición niega el puro voluntarismo al proponer como corolario de su postulado básico el hecho de que una vez que el Estado ha participado en la creación de la norma, su violación compromete siempre e indefectiblemente su responsabilidad internacional. El consentimiento común de los Estados no puede ser alterado por la voluntad de uno solo de ellos, sin que éste incurra en un ilícito internacional.

c) Doctrina soviética contemporánea

Para Tunkin,⁵¹ uno de sus principales expositores, los principios de igualdad e independencia de los Estados indican que el único medio de crear normas obligatorias para los sujetos del derecho internacional es el acuerdo, entendiendo por tal a la *coordinación* de voluntades. Este concepto de coordinación de voluntades, que reemplaza al de voluntad común, tiene su origen en el hecho de que para la doctrina soviética el derecho internacional general es un ordenamiento que regula las relaciones entre Estados pertenecientes a sistemas económicos diametralmente diferentes. La coordinación de voluntades estatales se refiere tanto al contenido de

⁴⁹ Jellinek, G., *Teoría general del Estado*, tr. de F. de los Ríos, 2ª ed., Buenos Aires, Albatros, 1954.

⁵⁰ Triepel, H., *Völkerrecht und Landesrecht*, 1899, “Les rapports entre le droit interne et le droit international”, R.C.A.D.I., vol. I, 1923, págs. 77-121.

⁵¹ Tunkin, G. I., *Droit international public, problèmes théoriques*, 1965; “Co-existence and International Law”, R.C.A.D.I., vol. III, 1958, págs. 32-36.

una norma particular como a su reconocimiento como norma del derecho internacional.

En general, las teorías voluntaristas no explican la razón última de la obligatoriedad de la norma internacional, sino que se limitan, en realidad, a describir el proceso de creación de este ordenamiento.⁵²

2. Teorías objetivistas

Las teorías objetivistas tratan de encontrar el fundamento de la obligatoriedad del derecho internacional fuera de la voluntad de los Estados.

a) Positivismo italiano

Anzilotti⁵³ propone como base de todo el ordenamiento jurídico internacional el postulado *pacta sunt servanda*. Esta es una hipótesis que no puede comprobarse jurídicamente, pero su lógica y necesidad debe asumirse como implícita en el derecho positivo vigente. A partir de este postulado se puede construir una teoría positiva sobre la base del consentimiento de los Estados.

Para ciertos analistas de las teorías sobre el fundamento del derecho internacional, Anzilotti pertenecería al grupo de los voluntaristas, pues, en última instancia, el acuerdo de voluntades es la base del derecho internacional. Para nosotros, al estar ese acuerdo de voluntades condicionado a la aceptación de un postulado hipotético, su pensamiento se enrola dentro de las teorías objetivistas.

Cabe destacar que su teoría sólo explicaría la validez inmediata de una de las fuentes del derecho internacional: los tratados. La norma consuetudinaria⁵⁴ —en tanto que prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho— y los principios generales de derecho, no encontrarían fundamento inmediato de obligatoriedad dentro de su marco teórico.

b) La teoría normativa

Todo el esquema conceptual normativo de la teoría pura del derecho está íntimamente relacionado con el fundamento de validez del derecho

⁵² Brierly, J., en *The law of nations*, 6ª ed., New York y Oxford, Oxford University Press, 1963, sostiene que —en la práctica— los Estados están a menudo obligados por normas jurídicas internacionales a las que difícilmente pueda considerarse que han consentido; tal el caso de los nuevos Estados que han adquirido su independencia como consecuencia del proceso de descolonización y que se encuentran obligados por las normas del Derecho Internacional general.

⁵³ Anzilotti, *Curso de Derecho Internacional*, tr. López Olivares, 3ª ed., Madrid, Ed. Reus, 1935.

⁵⁴ Para Anzilotti la norma consuetudinaria no es más que un acuerdo tácito de voluntades entre los sujetos del derecho internacional, con lo que desaparece el elemento "tiempo" en la formación de la costumbre.

ordenamiento, derivando su validez de una norma fundamental básica e hipotética. Las normas particulares podrán obtenerse por medio de una operación intelectual que infiere de lo general lo particular. Congruente en general. Para Kelsen⁵⁵ todas las normas jurídicas pertenecen al mismo con estos presupuestos jurídicos, Kelsen encuentra el fundamento de validez de los tratados —es decir, su obligatoriedad— en una norma de derecho internacional consuetudinario: *pacta sunt servanda*, según la cual los tratados se concluyen para ser cumplidos. La costumbre está constituida por actos de los Estados. La norma básica⁵⁶ del derecho internacional, por lo tanto, tiene que ser una norma que admita a la costumbre como un hecho creador de normas y podría enunciarse diciendo "los Estados deberán comportarse como lo hayan hecho por costumbre". El derecho internacional consuetudinario, desarrollado sobre la base de esta norma, es el primer escalón en el orden jurídico internacional. El grado siguiente está formado por las normas creadas por los tratados. La tercera etapa está formada por normas creadas por órganos que a su vez son creados por tratados. Una norma consuetudinaria del derecho internacional: el principio de efectividad, aplicada a un determinado orden jurídico interno, sirve de sustento de validez a tal ordenamiento.

La teoría pura del derecho, al proponer como fundamento último de validez una hipótesis del razonamiento, no da una respuesta convincente sobre la obligatoriedad de las normas jurídicas internacionales, sino que establece un supuesto fundamental del cual se deriva un esquema particular de lógica normativa. Ignora la realidad de las conductas que el derecho ha de tener presente para normativizarlas.⁵⁷

c) La teoría sociológica

La llamada escuela sociológica, aplicada al derecho internacional, también explica la obligatoriedad de las normas jurídicas a través de ciertos postulados suprapositivos.

Duguit,⁵⁸ fundador de esta escuela, sostiene que el Estado, al igual que los individuos, debe sujetarse a las normas jurídicas. Estas normas están impuestas por la solidaridad social y se originan en la naturaleza

⁵⁵ Kelsen, H., *Principios de Derecho Internacional Público*, tr. H. Caminos y E. C. Hermida, El Ateneo, Buenos Aires, 1965, págs. 349-358.

⁵⁶ La norma básica del derecho internacional no es una norma de derecho positivo, pues no es creada por actos de voluntad de los seres humanos, sino supuesta por los juristas interpretando la conducta de los Estados jurídicamente. Kelsen, *op. cit.*, nota 52, pág. 269.

⁵⁷ De Vischer, Ch., sostiene que la teoría pura del derecho está totalmente desvinculada de la realidad social y su máximo error se centra en la aplicación de procedimientos de lógica abstracta a los problemas fundamentales del derecho internacional, que muchas veces deambula en los límites de la política y el poder; véase *Théories et Réalités en Droit International Public*, 4ª ed., París, Pédone, 1970, págs. 82-84.

⁵⁸ Duguit, L., *Traité de Droit Constitutionnel*, París, Ancienne Librairie Fontemoing y Cie., éd., 1924.

de los hombres y en sus necesidades esenciales. Estos son los únicos sujetos del ordenamiento jurídico. El derecho, en el orden interno, se aplica a los individuos que viven en un grupo social restringido, sometidos a la misma autoridad política; en el orden internacional, se aplica a los mismos individuos, pero pertenecientes a grupos sociales distintos. El Estado sólo puede, entonces, promulgar normas que consagren la solidaridad social. La objetividad propuesta por Duguit se reduce a la interpretación de tal solidaridad por parte de los que detentan el poder, poniendo así en peligro las libertades individuales que intenta preservar con su teoría.

Nicolás Politis,⁵⁹ seguidor de Duguit, sostiene que el derecho es simplemente un producto social. Los dirigentes de la sociedad en que ha nacido se limitan a formularlo en leyes o tratados. El derecho internacional no tiene más que una sola y única fuente: la conciencia jurídica de los pueblos.

Para Georges Scelle,⁶⁰ también discípulo de Duguit, el derecho, en cuanto a su proceso formativo, está condicionado por un imperativo social que responde a necesidades concretas de los individuos. Los grupos sociales imponen sus realidades biológicas al Estado que, como unidad política, las interpreta a través de normas jurídicas. El fundamento del derecho no es otro que tales necesidades condicionadas como imperativos. Si las normas no las consagran, en el orden interno se producirá una revolución; y en el orden internacional, una guerra. El mundo del derecho se inscribe, así, dentro de una lógica del ser.

Para Cavaré,⁶¹ lo que justifica y hace obligatorias a las normas del derecho internacional público es la necesidad para los individuos y para los Estados de mantener relaciones regulares y normales. Necesidad de orden biológico, económico y moral que se impone a la voluntad de la autoridad social y es reconocida por ella. Si, en oportunidades, parece ser ignorada, esto sólo ocurre en forma momentánea ya que por su naturaleza termina por imponerse. El derecho, unido íntimamente a la sociedad humana, no puede disociarse de las necesidades de ésta. Son ellas las que, en definitiva, lo legitiman.

d) Las teorías de derecho natural

i) *Teoría clásica del derecho natural* Para ésta, el fundamento del derecho internacional no es otro que su calidad de derecho derivado de la ley natural o de la ley divina, ya sea ésta revelada o descubierta a través de la razón humana. Esta concepción del derecho natural influyó en las primeras etapas del proceso evolutivo del derecho internacional. Para la antigüedad, el derecho natural es la *recta ratio* o razón que la divinidad ha comunicado al hombre. Para la escolástica católica existen, en orden jerárquico, una ley eterna, una ley natural y una ley positiva. El proble-

⁵⁹ Politis, N., *Les nouvelles tendances du droit international*, París, 1927.

⁶⁰ Scelle, G., *Précis de Droit des gens*, París, Sirey, 1932.

⁶¹ Cavaré, L., *Le droit international public positif*, 3ª ed., Pédone, 1967.

ma más espinoso del derecho natural radica en la determinación de la autoridad que puede enunciarlo, descubrirlo o interpretarlo.⁶²

ii) *Teoría de los derechos fundamentales*: La teoría de los derechos fundamentales deriva sus postulados del derecho natural clásico y se basa en la existencia de un estado de naturaleza en el cual se encuentran todos los Estados como consecuencia de no haber sobre ellos poder superior alguno. Cada Estado, por el hecho de existir, goza de ciertos derechos inherentes a su condición de tal. De estos derechos —independencia, igualdad soberana de los Estados, respeto mutuo y comercio internacional— se nutren y estructuran los principios rectores del ordenamiento internacional. Esta doctrina de los derechos fundamentales dificulta la posibilidad de explicar la expansión y el desarrollo del contenido del Derecho Internacional. Por otra parte, la atribución de esos derechos responde a un momento dentro del proceso histórico del sistema político-jurídico universal. En la actualidad, la creciente colaboración e interdependencia entre los Estados puede generar nuevos derechos distintos a los que presuntamente esta doctrina considera inmutables de acuerdo al orden natural preestablecido. Tampoco alcanza a responder por qué las normas jurídicas internacionales son obligatorias.

iii) *El ius naturalismo racional*: El más claro exponente de esta doctrina es Alfred Verdross,⁶³ para quien el Derecho Internacional Público basa su existencia en ciertas convicciones jurídicas coincidentes entre los Estados. Esas convicciones jurídicas provienen de la naturaleza humana, asegurando la subsistencia de un mínimo de valores universales y constantes. Preceden al derecho positivo, no sólo los hombres y sus relaciones, sino, también, las valoraciones determinadas por la naturaleza humana común. De estas valoraciones se deriva la fuerza obligatoria del derecho positivo que pertenece, así, al reino de los valores. El iusnaturalismo presupone ciertos valores formulados como principios jurídicos que fundamentan y le dan unidad a las relaciones entre Estados. Las normas del derecho internacional positivo se han ido constituyendo sobre la base de la conciencia jurídica común de los pueblos. Todo *usus* presupone principios jurídicos que por el uso pueden ser acatados. También, el derecho convencional internacional se basa en un principio jurídico general: el principio de la buena fe. Esta positivización de los principios generales de derecho no les ha hecho perder su rango originario toda vez que constituyen tanto el fundamento del derecho internacional, como normas particulares aplicables en aquellos casos en que este ordenamiento

⁶² Véase lo dicho en el punto 2 sobre Origen y Evolución de la Comunidad Internacional. El mayor expositor de esta escuela fue Pufendorf (1632-1694), con su obra *De jure naturae et gentium* (1672) en la que desarrolla parte del pensamiento de Grocio para quien el derecho no era siempre voluntario sino que, también, estaba constituido por principios de la recta razón.

⁶³ Verdross, A., *Derecho Internacional Público*, tr. Truyol y Serra, 3ª ed., Madrid, Aguilar, 1961, págs. 29-36.

no ha establecido normas propias.⁶⁴ La norma fundamental del derecho internacional positivo se expresa diciendo que los sujetos de este ordenamiento "deben comportarse según lo prescriben los principios generales del derecho y las normas del derecho convencional y consuetudinario que sobre la base de aquéllos se establezcan".

A nuestro juicio, los llamados "derechos naturales" o "principios fundamentales" serán normas positivas cuando así lo reconozcan y acepten los sujetos del derecho internacional. La obligatoriedad de aquéllos no derivará de su condición de tales *per se* sino de la voluntad inmediata de los agentes generadores de la norma.⁶⁵

Podemos concluir que todas las teorías sobre el fundamento del derecho internacional, en su momento, han aportado interesantes elementos fruto de especulaciones intelectuales aplicables a la disciplina jurídica en general. Pero el por qué de la obligatoriedad de las normas de cualquier sistema jurídico no podrá encontrarse en explicaciones propuestas por la ciencia jurídica. Sus métodos y propósitos no son apropiados para responder a este interrogante. Esta es materia de la filosofía jurídica. El fundamento mismo de la obligatoriedad de una norma jurídica es siempre extrajurídico. A la ciencia jurídica sólo le interesa cómo una norma jurídica es creada y no por qué es creada. Por ello, cuando la doctrina de la ciencia jurídica trata de explicar este fenómeno cae en abstracciones o en postulados que por sí solos no alcanzan a solucionar el problema planteado.

En el ordenamiento jurídico internacional, la conveniencia de los Estados y las expectativas de reciprocidad, sus necesidades internas o externas y la interdependencia entre éstos o grupos de éstos, escapan al análisis crítico de la ciencia jurídica que simplemente debe aceptar los hechos tal cual se dan, interpretando sus efectos desde el enfoque jurídico.

⁶⁴ Véase en el capítulo II.4, *Los principios generales de derecho*. Para los iusnaturalistas existen principios jurídicos que están por encima del derecho internacional positivo y que no solo posibilitan la solución de conflictos *non liquet*, sino que le dan fundamento de validez a todo el ordenamiento jurídico internacional. Por lo tanto, no sólo los principios generales del derecho previamente positivizados por los órdenes jurídicos coincidentes de los pueblos civilizados serán principios generales del derecho, sino que también lo son los principios jurídicos directamente obtenidos de la naturaleza del derecho; Verdross, A., *op. cit.*

⁶⁵ El iusnaturalismo de Verdross ha influenciado los esquemas de la técnica jurídica anglosajona a través del pensamiento de Lauterpacht (Lauterpacht, H., *The function of law in the international community*, Oxford, Clarendon Press, 1933, págs. 418-423) y Brierly, J., *op. cit.*, pág. 56. Este último sostiene que cuando se quiere explicar por qué cualquier sistema jurídico es obligatorio, en última instancia es inevitable recurrir a los presupuestos básicos del derecho natural como fueron expresados en la Edad Media y, mucho antes, en Grecia y Roma. Agrega que la explicación última del por qué de la obligatoriedad de todo el derecho es que el hombre, individualmente o asociado con otros hombres en un Estado, está condicionado, en tanto sea un ser racional, por la creencia de que el orden y no el caos es el principio que reina al mundo en el cual tiene que vivir.

4. RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Cada Estado genera con potestad soberana su orden jurídico interno y participa con los demás Estados, en una relación de igualdad jurídica, en la elaboración de normas internacionales. De la coexistencia de estos sistemas jurídicos, el uno internacional y los demás de derecho interno, se derivan problemas atinentes a sus relaciones.

El primero de estos problemas consiste en determinar si el derecho internacional puede ser aplicado directamente en el ámbito interno de los Estados o si necesita para ello una norma del derecho nacional que lo integre a este sistema jurídico; y el segundo problema —dada ya por supuesta la integración del derecho internacional en el derecho interno— radica en establecer su relación jerárquica con las demás normas del derecho nacional. Estos interrogantes han sido encarados de manera distinta, a través del tiempo, por la doctrina, la práctica internacional y los distintos derechos internos.

a) La doctrina

Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno han sido doctrinariamente enfocadas por dos concepciones antagónicas: la monista y la dualista.

1. El monismo

La teoría monista, bajo el presupuesto de la unidad del derecho, propone la existencia de dos subsistemas jurídicos relacionados jerárquicamente. Esta unidad implica que las normas se hallan subordinadas unas a otras, formando un sólo ordenamiento jurídico. Ello excluye la posibilidad de plantearse el primer problema: el derecho internacional integraría, sin más, el orden jurídico estadual.

Si bien todos los publicistas que comparten la teoría monista admiten que tanto el derecho internacional como el derecho interno pertenecen al mismo orden jurídico general, no están de acuerdo en cuanto a la relación de dependencia o subordinación entre ambos subsistemas.

13

Para unos, en esta unidad del derecho, prima el derecho interno sobre el derecho internacional. Este, el derecho internacional, está subordinado al derecho interno de cada Estado y en él fundamenta su existencia. El derecho internacional, que deriva así su fuerza obligatoria del derecho interno, no sería más que un derecho público externo de los Estados.⁶⁶

Una de las críticas formuladas a esta posición se basa en el principio de la continuidad e identidad de los Estados. Una norma de derecho internacional general establece que los cambios políticos producidos dentro del orden jurídico interno de los Estados no modifican sus obligaciones internacionales. En consecuencia, si se produjese una ruptura del orden constitucional por una revolución, el Estado seguiría obligado por sus compromisos internacionales contraídos válidamente por el gobierno destituido. Esto probaría que el orden jurídico internacional no deriva su fuerza obligatoria del derecho interno, ya que aquél permanece invariable no obstante la alteración del segundo.

Para otros autores,⁶⁷ en cambio, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Consideran ellos al derecho interno no sólo como derivado del derecho internacional, sino como subordinado y condicionado por éste.⁶⁸ Tal postura, a través de una formulación extrema, llevaría a la nulidad automática de las normas jurídicas inferiores contrarias a las normas superiores. Esta consecuencia dejaría sin explicación la realidad de actos lícitos para el derecho interno que constituyen, a su vez, ilícitos internacionales. Por otra parte, contradice el hecho histórico de que el derecho internacional nace y se desarrolla como respuesta a la coexistencia de un número de Estados seculares, nacionales y soberanos, con ordenamientos jurídicos internos independientes unos de otros.

En una formulación moderada, la concepción monista reconoce la posible coexistencia en ambos ordenamientos de normas incompatibles, pero afirma el criterio unitario final en la responsabilidad del Estado que con sus normas internas contraviene al derecho internacional. Empero, esta posición tampoco llegaría a explicar por qué la sanción al Estado transgresor —que se traduce en una reparación— no determina la genérica invalidación de la norma nacional, internacionalmente ilícita, que persiste en el derecho interno.

2. El dualismo

La teoría dualista propone la coexistencia de dos órdenes jurídicos independientes. Tanto el derecho internacional como el derecho interno

⁶⁶ Esta es la posición de la escuela soviética de derecho internacional, conf., Wenzel, *Juristische Grundprobleme*, 1920.

⁶⁷ Kelsen, H., "Le rapport de système entre le droit interne et le droit international public", *RCADI*, 1926, vol. IV, pág. 231 y sig. Verdross, A., *op. cit.*, págs. 63-73; Scelle, G., *Précis de droit des gens*, 1er. fascículo, pág. 32 y sig.; Politis, *Nouvelles tendances du droit international*, cap. II, pág. 55 y siguiente.

⁶⁸ Véase, sin embargo, en el punto 3.b) de este capítulo, la distinta concepción que al respecto sostienen estos autores.

tienen su propio ámbito de validez y su propio campo de acción. Anzilotti y Triepel figuran entre los representantes más destacados de esta doctrina.⁶⁹

El derecho internacional diferiría del derecho interno, en primer lugar, en razón de sus sujetos: el Estado, para el primero, y los individuos, para el segundo; diferiría, también, en cuanto a las fuentes —entendiéndose por tales al fundamento de validez de la norma— ya que la del derecho internacional es la voluntad común de los Estados y la del derecho interno es la voluntad del Estado; y, finalmente, las relaciones normadas por uno y otro ordenamiento serían de naturaleza distinta, teniendo cada uno de estos derechos una esfera de competencia que les sería propia.

Por lo tanto, para que una norma del derecho internacional pudiese ser invocada y aplicada en el ordenamiento interno sería necesario que mediase un acto del Estado que la transformase en derecho interno. Este proceso de transformación se conoce con el nombre de recepción o incorporación.

Según esta doctrina, un acto lícito para el derecho interno podría contravenir obligaciones internacionales del Estado. La violación del derecho internacional por una norma del derecho interno daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado, pero no invalidaría, por sí misma, a la norma interna.

Las críticas a la teoría dualista se centran en el hecho de que ciertas normas jurídicas internacionales penetrarían directamente en las legislaciones internas sin necesidad de aplicar un proceso de transformación del derecho internacional en derecho interno.⁷⁰ Se expresa, asimismo, que no existe diversidad de sujetos ni de fuentes.

Por otra parte, ciertos sistemas jurídicos receptan genérica y anticipadamente al derecho internacional, sin necesidad de actos concretos de transformación particulares para cada norma internacional.

La existencia de normas válidas para un ordenamiento e inválidas para el otro tampoco sería prueba definitiva de la dualidad de los sistemas jurídicos, pues en ciertos órdenes internos —cuya unidad no se cuestiona— existe también la posibilidad de que rijan normas contrarias a la constitución en tanto no se declaren inválidas y tal declaración, con frecuencia, sólo produce efectos para el caso que se juzga.

Puede concluirse que tanto la teoría monista como la dualista no alcanzan, dentro de su rigorismo, a dar una respuesta coherente para la solución global de los problemas que plantean las relaciones del derecho

⁶⁹ Anzilotti, *op. cit.*, pág. 46 y sig. y "Il diritto internazionale nei giudizi interni", 1905; Triepel, "Les rapports entre le droit interne et le droit international", *RCADI*, 1923, vol. I, pág. 76 y sig. Véase, sin embargo, en el punto 3 de este capítulo la distinta concepción que al respecto sostienen estos autores.

⁷⁰ Briggs, H., *op. cit.*, pág. 64.

internacional con el derecho interno. Sin embargo, monismo y dualismo prestan utilidad a la ciencia jurídica en cuanto encuadran racionalmente las áreas normativas en conflicto.⁷¹

Cabe, por tanto, para completar la cabal comprensión de las cuestiones planteadas, remitirse a las soluciones que resultan de la práctica internacional y de las regulaciones positivas internas.

b) La práctica internacional

La práctica internacional revela que el derecho internacional no regula en forma directa lo atinente a la manera en que sus normas se integran en los distintos derechos internos. Una norma consuetudinaria internacional determina que el método por el cual un Estado pone en vigencia los derechos y obligaciones internacionales dentro de su ámbito es materia reglada por el derecho interno de cada Estado. Es decir, al derecho internacional le resulta indiferente el medio, pero no el resultado: la falta de adaptación de la legislación interna a las obligaciones internacionales —cuando ello es necesario— genera la responsabilidad internacional del Estado.

La valoración conjunta de diversos antecedentes suministrados por la práctica internacional es, al respecto, concluyente.

En tal sentido, la C.P.J.I. en la opinión consultiva sobre el *Canje de poblaciones griegas y turcas*⁷² estableció que el Estado que ha asumido obligaciones internacionales válidas está obligado a realizar en su legislación las modificaciones que fueran necesarias para asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. En la opinión consultiva sobre la *Competencia de los Tribunales de Dantzig*⁷³ el mismo tribunal dijo que si bien Polonia no podía alegar la imposibilidad de adaptar su derecho interno a las obligaciones internacionales,

“...un tratado no crea derechos y obligaciones que afectan directamente a los individuos. La verdadera esencia del tratado se complementa, de acuerdo con la intención de las partes contratantes, con la adopción por parte de éstas de reglas que crean derechos y obligaciones a favor de individuos y aplicables por los tribunales nacionales.”

⁷¹ Por otra parte, estas teorías no se han preocupado por el estudio de aquellos supuestos en los cuales ciertas normas del derecho interno se integran dentro del derecho internacional. Los principios generales de derecho interno, por ejemplo, pueden llegar a ser fuente principal —fuente creadora— del derecho internacional en virtud de una norma de este ordenamiento que así lo dispone [art. 38.1, c) del Estatuto C.I.J.].

⁷² CPJI, 1925, Serie B, n° 10, pág. 20.

⁷³ *Ibid.*, 1928, Serie B, n° 15, págs. 26-27.

En todo supuesto, cualquiera sea el mecanismo de integración, la práctica internacional también afirma de modo inequívoco la *prevalencia* de las normas internacionales sobre las de derecho interno.

Así, la C.P.J.I. en el caso de los *Intereses alemanes en la Alta Silesia*⁷⁴ expresó que

“...para el derecho internacional y para la Corte que es el órgano de éste, las leyes nacionales son simples hechos, manifestaciones de la voluntad y de la actividad del Estado, al igual que las decisiones judiciales o las medidas administrativas.”

Criterio que reiteró en el caso de la *Fábrica de Chorzow*,⁷⁵ agregando que en razón de ser regulados los derechos y obligaciones de los Estados en sus relaciones internacionales por el derecho internacional, es este derecho y no el derecho interno de los Estados el que da las pautas a través de las cuales se determina la licitud de las conductas de éstos. En el caso de las *Zonas francas de la Alta Saboya y del País de Gex*,⁷⁶ entre Francia y Suiza, el mismo tribunal estableció que en razón de ser el derecho internacional el que determina los derechos y obligaciones de los Estados en sus relaciones mutuas

“Francia no puede prevalecerse de su legislación para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales.”

En la opinión consultiva sobre el *Trato de los nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polacos en el territorio de Dantzig*⁷⁷ dijo la C.P.J.I. que

“un Estado no podrá invocar frente a otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le imponen el Derecho Internacional o los tratados en vigor.”

En el caso de la *Universidad Peter Pázmány contra Estado Checoslovac* (*Apelación de una sentencia del Tribunal Arbitral Mixto Húngaro-Checoslovaco*)⁷⁸ y en el caso de las *Escuelas minoritarias en Albania*⁷⁹ la C.P.J.I. estableció que el hecho de que un Estado aplique la misma norma jurídica interna a sus nacionales, no exonera la responsabilidad internacional de ese Estado ante la violación de una obligación internacional impuesta por un tratado.

Tal criterio jurisprudencial ha sido reiterado por la C.I.J. en el caso

⁷⁴ CPJI, 1926, Serie A, n° 7, pág. 19.

⁷⁵ *Ibid.*, 1928, Serie A, n° 17, págs. 33-34.

⁷⁶ *Ibid.*, 1930, Serie A, n° 24, pág. 12.

⁷⁷ *Ibid.*, 1932, Serie A/B, n° 44, pág. 24.

⁷⁸ *Ibid.*, Serie A/B, n° 61, pág. 243.

⁷⁹ *Ibid.*, 1935, Serie A/B, n° 64, pág. 19.

de las *Pesquerías* (Reino Unido-Noruega) y en el de los *Nacionales de Estados Unidos en Marruecos* (Francia-Estados Unidos), entre otros.⁸⁰

En numerosos laudos arbitrales quedó también aceptada la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. En el caso del *Alabama*,⁸¹ entre Estados Unidos y Gran Bretaña resuelto en Ginebra en 1872, se estableció que Gran Bretaña no podía excusarse por el incumplimiento de una obligación internacional alegando insuficiencia de los medios legales a su disposición. En el caso de *las reclamaciones entre Gran Bretaña y Costa Rica*,⁸² el Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, W. H. Taft, actuando como árbitro, dijo que de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, la Corte Suprema no puede reconocer derechos a extranjeros atribuidos por un tratado que el Congreso haya dejado sin efecto por medio de una ley (superioridad en el orden interno de la ley posterior sobre un tratado anterior); sin embargo, frente a un tribunal internacional, la circunstancia de que una ley deje unilateralmente sin efecto a un tratado no afectará los derechos emergentes de éste, y su fallo debe necesariamente dar validez al tratado y declarar que la ley que lo repele carece de vigencia.

El anteproyecto sobre Responsabilidad del Estado preparado por la *Harvard Research on International Law*, en 1929, esboza el principio de la supremacía del derecho internacional. Idéntico criterio siguió la misma institución al preparar, en 1935, su anteproyecto sobre el derecho de los tratados. Ambos proyectos fueron tomados en cuenta por la C.D.I. al preparar el anteproyecto de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los tratados. En el art. 27 de ésta se expresa que

"Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado."⁸³

Concluyendo, podemos decir que en el orden internacional —ya sea como sistema jurídico independiente o como subsistema jerarquizado dentro de un orden jurídico general— tanto la jurisprudencia de la C.P.J.I. como la de la C.I.J. y la de los tribunales arbitrales han establecido la supremacía del derecho internacional. Por lo tanto, en caso de conflicto entre normas de derecho internacional y normas de derecho interno, aquéllas prevalecen.

c) Solución del problema desde el enfoque interno

Los Estados, al regular el método de integración de las normas del derecho internacional en su derecho interno, pueden disponer la directa

⁸⁰ CIJ, *Recueil*, 1951 y *Recueil*, 1952.

⁸¹ Moore, *Digest*, VII, 1061; cit. por Podestá Costa, L. A., *Derecho Internacional Público*, t. I, pág. 58, nota 21.

⁸² AJIL, 1924, pág. 159; cit. por Podestá Costa, L. A., *ibid.*, nota 20.

⁸³ Véase en particular el problema de la nulidad de los tratados concluidos en violación de una norma de importancia fundamental del derecho interno; art. 46 de la Convención de Viena de 1969 sobre *Derecho de los tratados*.

integración de aquéllas —directa aplicación—⁸⁴ o bien establecer que las normas internacionales deben ser *incorporadas* a través de disposiciones de derecho interno que operen la transformación de las normas internacionales en normas internas. Puede, inclusive, darse el caso de sistemas constitucionales que integren directamente las normas consuetudinarias y los principios generales de derecho al par que requieran para los tratados un acto interno de transformación.

Igual diversidad de criterios se manifiesta también en lo que respecta a la jerarquía que a las normas de derecho internacional se les asigna en los ordenamientos jurídicos nacionales. Si éstos, en general, afirman la prevalencia de los principios constitucionales con relación a las normas internacionales, difieren las soluciones cuando se trata de determinar la prelación o jerarquía entre éstas y las leyes internas. Las constituciones más modernas tienden a asignar, en este orden, prioridad a los tratados sobre las leyes internas, en tanto otros sistemas constitucionales, como el de Estados Unidos⁸⁵ —que ha sido seguido por nuestra Constitución—, tras afirmar la primacía de la Constitución precisan la igual jerarquía de los tratados y de las leyes dictadas por el Congreso en consecuencia de aquélla.

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA

La Constitución de la Nación Argentina determina las normas que integran el ordenamiento jurídico de nuestro país y precisa la relación jerárquica que entre ellas existe.

1. Los tratados

a) Los tratados y la Constitución

Los tratados en vigor en los que el Estado Argentino es parte, constituyen fuente autónoma del derecho positivo interno. Forman parte del orden jurídico nacional y prevalecen sobre los ordenamientos jurídicos provinciales. El art. 31 de la Constitución Nacional establece esta supremacía.

Esta disposición constitucional —armonizada con el art. 27— permite a la vez fijar la jerarquía de los tratados en relación con la Constitución. El art. 31 dispone:

"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley su-

⁸⁴ La *directa aplicación* de una norma internacional en el ámbito interno no implica, necesariamente, su directa operatividad.

⁸⁵ Dickinson, "The law of Nations as part of the National Law of the United States", 101, *U. Pa. L. Rev.* 26, 792 (1952). Erades and Gould, *The Relation between International Law and Municipal Law in the Netherlands and the United States*, 232-52 (1961).

prema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.”⁸⁶

A su vez el art. 27 establece:

“El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.”

La relación de estas dos disposiciones determina que un tratado no pueda oponerse a la Constitución. En el supuesto de un conflicto entre normas contenidas en uno y en la otra, la segunda siempre prevalecerá. Esta supremacía de la Constitución se halla también reconocida por el art. 21 de la ley 48.⁸⁷

Asimismo se ha argumentado, con razón, que un tratado no puede ser contrario a la Constitución porque esto importaría alterar el único método válido para su reforma según el procedimiento fijado en el art. 30.⁸⁸

La primacía de la Constitución Nacional sobre la base de lo dispuesto en el art. 31 fue claramente fijada por la Corte Suprema en el caso Alfonso Chantre (Fallos: 208:84), entre otros. Sostuvo el Tribunal que el Poder Ejecutivo Nacional no puede constitucionalmente expulsar del país al extranjero sometido a proceso ante los tribunales de justicia ni puede, a fin

⁸⁶ Puede considerarse que el art. 31 de la Constitución Nacional, de por sí, es suficiente para afirmar su primacía sobre los tratados. Estos, según la interpretación de nuestra Corte Suprema, se encuentran equiparados a las leyes de la Nación, las que deben ser dictadas “en consecuencia” de aquélla. Si esta compatibilidad con la Constitución es exigida a las leyes nacionales, los tratados —que le son jurídicamente iguales en rango— no podrían estar exentos de ella. De hallarse eximidos de conformarse a la Constitución dejarían de ser equiparables a las leyes y resultarían jerárquicamente iguales a la Constitución Nacional.

⁸⁷ El art. 21 de la ley 48 dispone que: “Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con las naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación, y los principios del Derecho de gentes según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento en el orden de prelación que va establecido”.

⁸⁸ El art. 30 de la C.N. dispone: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto”; conf. González Calderón, J. A., *Derecho constitucional argentino*, Buenos Aires, Lajouane, 1923, t. I, pág. 443 y sig.; Bidart Campos, G. J., en “Reflexiones sobre la rigidez y la supremacía de la Constitución frente a los tratados internacionales”, *Jurisprudencia Argentina*, Doctrina-1970, pág. 547 y sig., expresa que un tratado internacional no puede introducir reformas a la Constitución rígida, lo que equivale a sustentar la supremacía de la Constitución y la subordinación de los tratados a ella.

de asegurar su expulsión, mantenerlo detenido durante la tramitación de la causa y que

“la resolución VII de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz no se opone, en modo alguno, a las conclusiones precedentes...”

pero que tampoco podría oponerse válidamente pues,

“con arreglo al art. 31 de la Constitución Nacional que invoca el apelante, los tratados internacionales deben respetar las disposiciones de aquélla, cuya supremacía sobre todas las normas de derecho positivo asegura el precepto de referencia (cf. Willoughby, *On the Constitution*, §§ 308 y 314; *Principles*, pág. 239; Cooley, *Constitutional Limitations*, pág. 27, en nota).”

Al pronunciarse en el caso “Merck Química Argentina (S.A.) contra Gobierno Nacional” (Fallos: 211:162) sobre la validez constitucional de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia de la declaración del estado de guerra de la Argentina contra Alemania y Japón (decreto-ley 6945/45), en virtud de los decretos 7032/45, 10.935/45 y 11.599/46 —referidos estos últimos al régimen de la propiedad enemiga, ya previsto en la señalada Conferencia Internacional sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México, 1945)— que se tradujeron en la desposesión de los bienes, el retiro de la personería jurídica y la ulterior liquidación de la empresa, la Corte Suprema, por el voto de la mayoría de sus miembros expresó, entre otros fundamentos, que:

“no cabe discusión alguna sobre la existencia y preexistencia de tales poderes de guerra, por cuanto los principios rectores de que están informados en mira a la salvaguardia de la integridad e independencia nacional... son forzosamente anteriores y, llegado el caso, aún mismo superiores a la propia Constitución...”

“...Que, en cuanto a la República Argentina y en un aspecto de generalización de principios, el orden interno se regula normalmente por las disposiciones constitucionales que ha adoptado y por lo tanto, *manteniéndose en estado de paz*, ningún tratado podría serle opuesto si no estuviese ‘en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución’ (art. 27). Es decir, pues, que en tanto se trate de mantener la paz o afianzar el comercio con las potencias extranjeras, la República se conduce dentro de las orientaciones de la teoría “dualista”. Pero cuando se penetra en el terreno de la guerra en causa propia —eventualidad no incluida y extraña por tanto a las reglas del art. 27— la cuestión se aparta de aquellos principios generales y coloca a la República y a su gobierno político, en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el rigorismo de que puedan estar animados...”

Aunque parece desprenderse de esa aserción que en el estado de guerra cabría apartarse de la Constitución para asegurar la primacía de los tratados internacionales, no fue esta la conclusión final del fallo. Antes

bien, la legitimidad de las medidas impugnadas fue sustentada por la Corte, con fundamentos autónomos suficientes, en la amplitud de los poderes de guerra que la Constitución acuerda al Poder Ejecutivo de la Nación y en principios de derecho público interno, compatibles con las obligaciones internacionales. Afirmó así la Corte que

“el Presidente de la República, obrando dentro de las atribuciones que expresa e implícitamente le ha otorgado la Constitución sin limitación no contradicha por ninguna otra disposición aplicable en la especie, ha podido dirigir el estado de guerra en la forma y por los medios o con los efectos que ha creído más conveniente en resguardo de los elevados intereses de la Nación, sin que ello importe transgredir ninguna norma constitucional...”⁸⁹

b) Los tratados y las leyes de la Nación

El art. 67, inc. 19, de la Constitución Nacional establece que:

“Corresponde al Congreso... Aprobar o desechar los tratados con las demás naciones y los concordatos con la Silla Apostólica...”⁹⁰

Esta atribución específica del Congreso se ha materializado, consuetudinariamente, por medio de la sanción de una ley que aprueba el tratado, lo que implica la autorización para que el Ejecutivo manifieste internacionalmente el consentimiento del Estado en obligarse por el tratado.

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 de la Constitución Nacional se puede establecer que tanto la ley nacional como el tratado aprobado por el Congreso y que ha entrado en vigor con relación al Estado Argentino se encuentran en un mismo plano jerárquico. Todo conflicto entre normas de igual jerarquía se resolverá, entonces, aplicando los principios de la “ley posterior” y de la “ley especial”, según corresponda.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado tal conclusión en el caso “S. A. Martín & Cía. Ltda. c/ Administración General de Puertos s/ repetición de pago” (Fallos: 257:99),⁹¹ en el que expresó que

“...corresponde establecer que ni el art. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la

⁸⁹ En el caso “Compañía Azucarera Tucumana c/ Provincia de Tucumán” la Corte Suprema sostuvo que la Constitución “es un estatuto para regular y garantizar las relaciones y los derechos de los hombres que viven en la República, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra y sus provisiones no podrán suspenderse en ninguna de las grandes emergencias de carácter financiero o de otro orden en que los gobiernos pudieran encontrarse” (Fallos 150:150).

⁹⁰ Los concordatos con la Santa Sede, desde un punto de vista formal, son considerados tratados.

⁹¹ En ese caso juzgó la Corte Suprema que el decreto-ley 6575/58 (ley 14.467) modificaba al anterior Tratado de Comercio y Navegación celebrado con el Brasil, aprobado por ley 12.688, que estableció una exención de impuestos, tasas y gravámenes.

Nación. Ambos —leyes y tratados— son igualmente calificados como ‘ley suprema de la Nación’, y no existe fundamento normativo para acordar prioridad de rango a ninguno...” (consid. 6°).

“...que rige respecto de ambas clases de normas, en cuanto integrantes del ordenamiento jurídico interno de la República, el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores. En su expresión clásica: ‘*Leges posteriores priores contrarias abrogant*’, ha sido también admitido como consecuencia necesaria de la igualdad jerárquica señalada, por la doctrina y la jurisprudencia norteamericana...” (consid. 8°).

Este fallo tiene importancia pues precisa con claridad el criterio jurisprudencial acerca del problema de las relaciones del derecho internacional y del derecho interno al adherir, explícitamente, a la concepción con arreglo a la cual el tratamiento y regulación de las normas del derecho internacional como normas integrantes del ordenamiento jurídico interno, depende de la organización constitucional de cada Estado. Una norma de derecho internacional remitiría al derecho interno la solución del caso.

Expresó la Corte en el precedente mencionado:

“...el derecho internacional, con base en la distinción entre los tratados en cuanto convenios entre distintas potencias y como normas del ordenamiento jurídico nacional interno, remite también la solución, en el segundo aspecto, a la organización constitucional respectiva —conf. Kelsen, Hans, *Principles of International Law*, Nueva York, 1952, pág. 419; H. Lauterpach, *Regles Générales du Droit de la Paix*, Rec. des Cours de l'Académie de Droit International, 1937, IV, pág. 144; Verdross, *Derecho Internacional Público*, 3ª ed., Madrid, 1957, pág. 72; Oppenheim, *Tratado de Derecho Internacional Público*, Barcelona, 1961, vol. I, tit. I, cap. IV, parágs. 21 y 22—...” (consid. 9°).

De acuerdo con este criterio, las normas internas de un país podrían admitir la aplicación automática de los tratados —en la medida en que fueran operativos— como en nuestro sistema constitucional ocurre, o bien podrían exigir ante cada norma del ordenamiento jurídico internacional una concreta respuesta del derecho interno que la incorpore específicamente a él. Y también, conforme al mismo criterio, las normas del ordenamiento jurídico nacional podrán asignar un orden de jerarquía a las normas internacionales que asegure la primacía de éstas sobre aquéllas, su subordinación o su equiparación.

Naturalmente, esta discrecionalidad acordada a los sistemas constitucionales nacionales para fijar el método de integración de las normas internacionales y la relación jerárquica de las distintas fuentes, no implica asignar a las regulaciones internas efectos internacionales. Se trata de regulaciones de alcances estrictamente internos. La posible colisión entre normas de derecho interno y de derecho internacional y las soluciones que aporte cada derecho nacional dejan subsistentes las cuestiones de orden internacional que podrían suscitarse en caso de que en el orden in-

ch

terno la norma internacional resultase violada. Como también lo expresó la Corte Suprema

"...la posible cuestión de orden internacional subsistente es ajena, como principio, a la jurisdicción de los tribunales de justicia internos. Y depende de circunstancias atinentes a la conducción de las relaciones exteriores de la Nación, sujetas a reclamo por las altas partes contratantes, a cuyo respecto no cabe decisión de esta Corte..." (consid. 9°).⁹²

Y es evidente que en cualquier instancia internacional, las normas de este ordenamiento prevalecerán, al asignarse a las disposiciones internas el carácter de simples hechos.⁹³

c) Aprobación y ratificación de los tratados

La aprobación de un tratado a través de una ley de la Nación es, para el derecho internacional, un mero antecedente de su ratificación. La aprobación interna de un tratado por una ley es un acto jurídico distinto del acto internacional de ratificación en virtud del cual un Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por ese tratado.

De conformidad al derecho público argentino, en el proceso de conclusión de los tratados en buena y debida forma corresponde distinguir varias etapas: la negociación llevada a cabo por el Poder Ejecutivo; la firma, también por este Poder; la aprobación por el Congreso; y la ratificación por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el acto por el que el Congreso aprueba un tratado no es un acto de incorporación, sino un paso en el proceso de conclusión de los tratados que se perfecciona por medio de la ratificación internacional.⁹⁴

Para la conclusión del tratado es menester el acto aprobatorio del Congreso Nacional, pero los tratados no se encuentran incorporados al orden jurídico nacional meramente en virtud de la ley aprobatoria. Puede existir esa ley, sin que haya tratado en vigor: tal el caso, por ejemplo, de la ley 19.865 aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El sentido del art. 31 de la Constitución Nacional,

⁹² Idéntico criterio ha sostenido este Tribunal en "Esso, S.A. Petrolera Argentina c/Nación Argentina s/repetición", Fallos: 271:7. En sentido contrario se expresa Bidart Campos, *Derecho Constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1966, t. I, pág. 285 y sig., quien dice "...siguiendo las modernas normas positivas en la materia, entendemos que un tratado contrario a una ley anterior la deroga o modifica, y que una ley posterior opuesta a un tratado anterior debe considerarse inconstitucional...". Esta opinión concuerda con la que, en voto disidente expresara el juez de la Corte Suprema, doctor Tomás Casares en Fallos: 225:493: "...la tesis de que un tratado puede ser derogado por una ley posterior, importa sostener que cuando la Nación contrae un compromiso en el orden internacional, conserva la facultad de sustraerse a él por acto de su exclusiva voluntad, fuera de las formas y oportunidades que para su denuncia se hallan establecidas en él...".

⁹³ CPJI, Serie A, n° 7 (1926), pág. 19; Serie A, n° 17 (1928), págs. 33-34.

⁹⁴ Bidart Campos, *op. cit.*, t. I, pág. 280.

al enumerar las fuentes de nuestro derecho nacional y fijarles su jerarquía, es establecer como fuente autónoma directamente aplicable en el orden interno a los tratados. Estos no pueden ser asimilados, ni son reductibles a ninguna otra fuente. Cuando nuestra Corte Suprema aplica la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no aplica la ley que la aprobó, sino directa y exclusivamente ese tratado como fuente autónoma.⁹⁵

El acto de ratificación internacional es realizado por el Poder Ejecutivo con posterioridad a la aprobación interna. Por ello, al ser el nacimiento de la norma internacional ulterior al acto de aprobación interna, éste no producirá efectos jurídicos hasta que el tratado no haya sido debidamente ratificado y entre en vigor con relación al Estado Argentino.⁹⁶ Mal puede hablarse de incorporación al derecho interno de una norma que aún no tiene vigencia para el derecho internacional.⁹⁷

d) Operatividad de los tratados

Los tratados pueden ser operativos o programáticos de acuerdo a la voluntad de las partes. En el plano internacional, la C.P.J.I. sostuvo que no cabe discutir que el objeto de un acuerdo internacional, según la intención de las partes contratantes, pueda ser la adopción de reglas que crean derechos y obligaciones para los particulares directamente aplicables por los Tribunales Nacionales.⁹⁸

Para nuestra Corte Suprema, el hecho de que el Estado Argentino sea parte en un tratado no implica, por sí mismo, que ese tratado sea operativo y produzca efectos directos en el orden interno. Es decir, que los derechos y obligaciones en él contenidos puedan ser invocados directamente por los individuos y aplicados por los tribunales.

Para que todo tratado del que el Estado es parte produzca efectos directos —es decir que sea operativo— las normas jurídicas en él previstas deberán ser susceptibles de aplicación inmediata. Esta aplicación inmediata dependerá de la claridad y falta de condicionamientos del contenido

⁹⁵ En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el tratado "...adquiere validez jurídica en virtud de la ley aprobatoria, pero no por ello deja de tener el carácter de un *estatuto legal autónomo* cuya interpretación depende de su propio texto y naturaleza, con independencia de la ley aprobatoria" (Fallos: 202:353).

⁹⁶ En el mismo caso, afirmó la Corte Suprema que en el supuesto de tratados que contienen compromisos recíprocos, el cumplimiento al que la Nación queda obligada en virtud de la ratificación "...está naturalmente subordinado a la ratificación de la otra Nación contratante, esto es, a que esta última formalice su propia obligación correlativa, porque sin ello el compromiso de la primera carecería de razón de ser".

⁹⁷ Jiménez de Aréchaga, E., "Introducción al problema de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno", *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 1962, I-II, pág. 10. Goldschmidt, W., "Derecho internacional y derecho interno argentino", *El Derecho*, t. 23, pág. 423. Bidart Campos, "Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en la doctrina y el derecho comparado", *Revista de Derecho Español y Americano*, 1965, t. 10.

⁹⁸ Caso de la Jurisdicción de las Cortes de Danzig, CPJI, Serie B, n° 15 (1928).

de las normas y, concurrentemente, de la intención de las partes contratantes que deberá haber sido la de crear esos efectos sin necesidad de recurrir a acto reglamentario interno alguno.

La Corte Suprema sostuvo en el caso "Gregorio Alonso c/Haras Los Cardos" (Fallos: 186:258), que la ley 9688 no se entiende derogada *ipso facto* en virtud de la ratificación de la convención adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo sobre reparación de los accidentes de trabajo en la agricultura, toda vez que dicha convención obligaba a los miembros que la ratificasen a aplicarla "... a más tardar al 1º de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas esas disposiciones". Juzgó la Corte Suprema que

"la única forma de hacer efectiva la 'reparación de los accidentes de trabajo en la agricultura (art. 1º, inc. 3º)' es por medio de una ley que reglamente en forma clara y concreta los derechos y obligaciones de los asalariados agrícolas."⁹⁹

Una interpretación similar fue adoptada con relación a la Convención sobre limitación de la jornada laboral aprobada en la Primera Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Washington en 1919 (ley 11.726). Invocando anteriores precedentes publicados en Fallos 216:395 y análogamente en Fallos: 186:258 y 249:677, decidió la Corte que la inclusión de una cláusula con arreglo a la cual

"cada miembro que ratifique la convención se obliga a aplicarla desde cierta fecha 'y a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas sus disposiciones', condiciona la aplicación de las normas del Tratado a una ley que lo haga efectivo" (Fallos: 256:156).¹⁰⁰

⁹⁹ Este fallo provocó una controversia doctrinaria. Unsain sostuvo el criterio de la Corte e invocó el art. 19.5, d) de la Constitución de la OIT que dispone que si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades competentes, comunicará la ratificación formal del convenio al Director General "y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio" para afirmar la conclusión en el sentido de que los derechos y obligaciones contenidos en la convención mencionada debían, tras su ratificación, ser particularizados por medio de otra ley. (Unsain, A. M., "Accidentes en la agricultura", *La Ley*, t. I, pág. 147 y sig. Anastasi opinó, en cambio, que de la claridad e incondicionalidad del texto del tratado debidamente aprobado surge la cualidad operativa del mismo. (Anastasi, L., "Los obreros de la agricultura y el régimen de la ley 9688. Alcance de la ratificación de la convención de Ginebra", *La Ley*, t. X, pág. 1180 y siguiente.

Para la evolución doctrinaria y jurisprudencial sobre la cuestión de la operatividad directa de los tratados, véase Gnecco, J., "Los tratados internacionales frente a la Constitución y las leyes", *Revista del Colegio de Abogados de La Plata*, año 10, n° 19, págs. 123-155; Vanossi, J. R., *Régimen constitucional de los tratados*, Buenos Aires, 1969, pág. 181 y siguiente.

¹⁰⁰ Este criterio fue reiterado en Fallos: 263:63 y 263:122. En el último de los casos citados, los jueces doctores L. M. Boffi Boggero y Pedro Aberastury, con relación a la referida norma XIX de la Convención de Washington, formularon una disidencia sosteniendo que "La obligación de los Estados signatarios de 'adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas sus disposiciones' se limita a las que son necesarias; el Estado no se obliga a adoptar medidas innecesarias cuando las obligaciones que se asumen tienen, por su naturaleza, 'operatividad propia'".

La regla es, empero, la de la aplicación inmediata de los tratados cuando tal ha sido la intención de las partes y cuando las normas en ellos contenidas no necesitan de acto reglamentario alguno. En el caso "S.A. Quebrachales Fusionados c/capitán, armadores y dueños del vapor nacional Aguila", la Corte Suprema de Justicia consideró que las reglas establecidas en el art. 6º de la Convención de Bruselas sobre abordaje, asistencia y salvamento marítimos (1910) fueron "incorporadas de hecho al Código de Comercio por la ley aprobatoria respectiva, 11.132..." (Fallos: 150:84, reiterado en Fallos: 165:144). En la causa S.A. Editorial Noguer (Fallos: 252:262) ese Tribunal hizo aplicación directa del art. III, apartado 1º de la Convención Universal de Ginebra sobre Derecho de Autor, aprobada por decreto-ley 12.088/57, a la que —dentro de la esfera de su vigencia— consideró modificatoria de las disposiciones existentes en la Argentina respecto de la protección de la llamada "propiedad intelectual" —ley 11.723— (cons. 11º).

Y más recientemente, en la causa "Martínez, Enrique M. c/Ramos, José I. s/despido" (Fallos: 284:28), la Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria para conocer en el juicio invocando la disposición del art. 31, inc. c) de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por el art. 5º del decreto-ley 7672/63, norma ésta directamente operativa que priva de la inmunidad de jurisdicción civil al agente diplomático con relación a las acciones referentes a cualquier actividad profesional o comercial ejercida en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. Por considerar *prima facie*, y sin que comportara un pronunciamiento definitivo, que el supuesto de la norma concurría en el caso, se dispuso citar al agente diplomático a estar a derecho, sin necesidad de requerir la conformidad del gobierno del Estado acreditante.

2. La costumbre y los principios generales de derecho

El art. 27 y el art. 31 de la Constitución Nacional, como ya hemos visto, se ocupan parcialmente del problema de las relaciones del derecho interno con el derecho internacional. Ambos se refieren a los tratados, sin hacer mención a la costumbre internacional, ni a los principios generales de derecho.

El antecedente inmediato de estos artículos es la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Esta, en su art. 6, que describe el orden normativo federal y precisa la jerarquía de las fuentes, omite mencionar otras fuentes del derecho internacional que no sean los tratados; la explicación se encuentra en el hecho de que tanto la doctrina como la jurisprudencia anglosajona¹⁰¹ reconocen al derecho internacional consue-

¹⁰¹ Blackstone, W., *Commentaries on the Laws of England*, 1765, reimp. Oceana Publ., New York, 1976. En la jurisprudencia colonial: *Republica v. De Longchamps*, 1 Dall. 111, 1 L., Ed. 59 (Pa. 1784).

tudinario como parte integrante del derecho interno. Y la misma Constitución hace inequívoca referencia a la costumbre, por ejemplo, en el art. 1, sección 8, que confiere poderes al Congreso para definir y penar las ofensas contra "el derecho de las naciones".

En el sistema constitucional argentino, la costumbre internacional y los principios generales de derecho integran directamente su orden jurídico positivo ya que, con arreglo a las normas del derecho de gentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir en jurisdicción originaria y exclusiva las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros.¹⁰² Y, asimismo, el derecho de gentes es invocado por la C.N. para tipificar delitos cometidos fuera de los límites de la Nación para cuyo enjuiciamiento prevé una ley especial del Congreso que determinará el lugar en que haya de seguirse el juicio.¹⁰³

El art. 21 de la ley 48 impone a los tribunales y jueces nacionales la aplicación de "...los principios del derecho de gentes", aunque fijándoles —tanto a ellos, como a los tratados— un orden de prelación que no corresponde al que emana de la C.N.

A través de frecuentes invocaciones al "derecho de gentes", la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho directa aplicación de normas consagradas por la costumbre internacional y se ha pronunciado con la convicción de que

"la jurisdicción que se le ha acordado, en los términos de los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional, respecto de las 'causas' o 'asuntos' concernientes a los Embajadores y Ministros Extranjeros lo ha sido con arreglo al derecho de gentes y en garantía del más eficaz cumplimiento de las altas funciones de aquéllos" (Fallos 244:255; 284:28).

Esta jurisprudencia tiene antiguos precedentes. Ya en el caso publicado en Fallos 19:108 "D. Rufino Basavilbaso contra el Ministro Plenipotenciario de Chile, Dr. Diego Barros Arana sobre indemnización de daños y perjuicios", el Tribunal expresó:

"Los Ministros Diplomáticos están exentos, por el derecho de gentes, de la jurisdicción del país en que residen", "...aunque pueden renunciar a este privilegio con autorización del Gobierno que representan, y someterse a la jurisdicción local..."

La invocación de esta costumbre internacional fue reiterada en numerosos casos posteriores (Fallos 98:338; 107:395; 134:163; 139:255;

¹⁰² Arts. 100 y 101 de la C.N. y art. 24, inc. 1º del decreto-ley 1285/58 (ley 14.467).

¹⁰³ Art. 102 de la C.N. y art. 3º, inc. 1º de la ley 48.

141:127; 151:285; 175:344; 181:49; 182:185; 183:156 y 273; 190; 353; 194:415 y muchos otros).

Al margen de las cuestiones referentes a inmunidades y privilegios de agentes diplomáticos y consulares, la Corte Suprema hizo aplicación directa de normas consuetudinarias y de principios generales de derecho en supuestos muy diversos, aunque bajo la formal invocación de principios del derecho internacional público, la práctica internacional, la doctrina o jurisprudencia universalmente aceptadas, etcétera.¹⁰⁴

Así, a título de ejemplo, en normas de la costumbre internacional fundó la denegatoria al resarcimiento de perjuicios sufridos por actos de rebeldes en luchas civiles con la consideración de que a tal categoría de daños están sujetos tanto los nacionales como los extranjeros y

"...ninguna autoridad, nacional ni provincial, es responsable, por ley expresa, y jurisprudencia universalmente consentida" (caso "Darío David c/la Prov. de San Luis, por indemnización de daños y perjuicios", Fallos: 17:163).

Esta condición jurídica igualitaria entre los "habitantes" del país tuvo su expresión en pronunciamientos en que la Corte Suprema afirmó que

"...es un principio del Derecho de Gentes que toda Nación tiene jurisdicción sobre sus habitantes, hechos que ocurren en su territorio y casos judiciales que se producen a consecuencia de los mismos" (Fallos: 176:218, consid. 4º).

Asimismo, al caracterizar al gobierno de facto y admitir su posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él, se remitió a la "doctrina constitucional e internacional" que se uniforma en el sentido de dar validez a los actos de los funcionarios de hecho (Fallos: 158: 290).

El "derecho de gentes evolucionado al tiempo de su aplicación" fue invocado para interpretar con amplitud los poderes de guerra del Presidente de la República en el ya mencionado caso "S.A. Merck Química Argentina c/Nación Argentina" (Fallos: 211:162); y el acto de suspensión de la opción ejercida por un nacional extranjero para salir del país sin permiso especial mientras durara el estado de guerra fue también considerado como una facultad

"...indiscutiblemente reconocida por el derecho de gentes a los estados beligerantes" (Fallos: 201:477).

En el importante precedente sentado en el "Recurso de Habeas Corpus interpuesto por los tripulantes sublevados del buque de guerra chi-

¹⁰⁴ Véase Isidoro Ruiz Moreno: *El Derecho Internacional Público ante la Corte Suprema*, ed. Eudeba, 2ª ed., Buenos Aires, 1970.

leno 'La Pilcomayo' traídos a tierra en calidad de presos" (Fallos: 43:321), la Corte hizo lugar al recurso y dispuso la libertad de quienes se habían sublevado el 30 de marzo de 1891 en dicha nave de guerra surta en el Puerto de Buenos Aires y, por pedido de su comandante, habían sido arrestados en la Prefectura Marítima y puestos a disposición del Ministro de Chile por tres días, prorrogados por tres días más. Al requerir ese agente diplomático la devolución de los presos para ser conducidos a bordo de la cañonera, el Poder Ejecutivo no accedió a la petición porque ellos se encontraban sometidos a la justicia nacional a raíz del recurso de habeas corpus interpuesto en su favor. Juzgó la Corte —tras calificar como infracción de orden político a las conductas imputadas a los tripulantes, sublevados en apoyo del partido político levantado en armas contra el gobierno de Chile— que tratándose de delitos políticos o conexos con delitos políticos, las disposiciones de la legislación positiva del país (art. tercero, inc. segundo, de la ley nacional del 25 de agosto de 1885)

"y los principios universalmente consagrados en el derecho internacional público, establecen como una regla invariable la inviolabilidad de las personas comprometidas en ellos, una vez salidas de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se han llevado a cabo, y colocan a sus autores bajo la garantía moral del Estado sobre el territorio del cual se encuentran." ¹⁰⁵

La práctica de la Corte Suprema revela, pues, la aplicación directa de la costumbre internacional como fundamento de sus decisiones. A veces su invocación ha constituido el fundamento único o bien el fundamento sustancial de sus pronunciamientos; en otros supuestos, la aplicación de normas del derecho nacional ha convergido con aquélla para la solución del caso.

En este sentido, guarda interés la reciente decisión de la Corte Suprema en las actuaciones "Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

¹⁰⁵ Consideró el Tribunal "que son estos mismos los principios que rigen en el derecho internacional en relación a los prisioneros de guerra, ya sea esta pública o de Nación a Nación, ya meramente insurreccional o civil..." y "que en el caso de actos de hostilidad o de guerra civil llevados a cabo por insurgentes de un Estado extranjero en aguas territoriales de otro Estado, que es precisamente el caso de la cuestión, la regla consagrada en el derecho internacional es igualmente la de poner en libertad las personas de los últimos si no se han hecho justiciables por sus actos ante los tribunales del país en que éstos se han perpetrado y sólo entregar al Gobierno del Estado extranjero las naves o cosas tomadas a aquéllos...". La aplicación de normas consuetudinarias internacionales y de "las garantías y remedios que la Constitución y las leyes sin distinción consagran a la seguridad personal dentro de todo el territorio de la Nación" explicitadas en el valioso fallo, llevaron a la Corte Suprema a la conclusión de que "...ni el acto de la Legación de Chile haciendo entrega de las personas referidas como presos a la autoridad ejecutiva del país por insuficiencia de medios, impotencia o incapacidad propia para mantenerlos a bordo, ni el procedimiento de la última recibiendo en tal calidad por una mera razón de cortesía, sin obligarse a mantenerlos en secuestro más allá de lo que las leyes del país le permitiese, y negando en tal concepto posteriormente su devolución, pueden legítima y válidamente oponerse a la libertad inmediata a que tienen derecho los detenidos".

comunica situación planteada en autos 'Gómez Samuel c/Embajada Británica s/despido'" (24 de junio de 1976). No obstante la negativa del gobierno británico a aceptar la jurisdicción de los tribunales argentinos, el juez de la causa había declarado su competencia mediante un pronunciamiento que quedó firme. Ante la comunicación de la situación planteada, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Corte Suprema admitió la inmunidad de jurisdicción que se había alegado en las instancias ordinarias de la causa, dejando sin efecto lo actuado. Y si bien invocó la norma del art. 24, inc. 1º del decreto-ley 1285/58 que impide dar curso a una demanda contra un Estado extranjero sin la conformidad del país demandado, ante la circunstancia procesal de una resolución firme que se apartaba de ella, consideró la Corte —teniendo en cuenta "la importancia institucional del asunto"— que se imponía "...dar adecuada solución al problema planteado, según principios del derecho de gentes; de modo que no resulten violadas las bases del orden público internacional que, por encima de las formas en que se encausa el proceso, son de aplicación prioritaria en el caso". Es decir, la Corte Suprema encaró el caso como de inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero, aunque en uno de los considerandos parece referirlo a inmunidades diplomáticas y —al margen de un procedimiento regular— hizo aplicación de las normas consuetudinarias que resguardan la inmunidad estadual para asegurar su aplicación efectiva y para evitar su inobservancia en virtud de situaciones procesales adquiridas.

71

BIBLIOGRAFIA

- Aberastury, M., *Política Mundial Contemporánea*, Paidós, 1970.
- Akehurst, M., *Introducción al derecho internacional*, tr. M. Medina Ortega, Madrid, Alianza Ed., 1972.
- Anzilotti, *Curso de Derecho Internacional*, tr. López Olivares, 3ª ed., Madrid, Ed. Reus, 1935.
- Anastasi, L., "Los obreros de la agricultura y el régimen de la ley 9688 - Alcance de la ratificación de la convención de Ginebra", *La Ley*, t. X, pág. 1180 y siguiente.
- Anzilotti, "Il diritto internazionale nei giudizi interni", 1905.
- Bidart Campos, G. J., *Tratado de derecho constitucional*, Buenos Aires, Ediar S.A.
- Bidart Campos, G. J., "Reflexiones sobre la rigidez y la supremacía de la Constitución frente a los tratados internacionales", *Jurisprudencia Argentina*, Doctrina-1970, pág. 547 y siguiente.
- "Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en la doctrina y el derecho comparado", *Revista de Derecho Español y Americano*, 1965, t. 10.
- Brierly, J., *The law of nations*, 6ª ed., New York y Oxford, Oxford University Press, 1963.
- Briggs, H. W., *The Law of Nations*, 2ª ed., Appleton Century Crofts, 1966.
- Brownlie, *International Law*, Stevens, 1975.
- Bishop, W. W., *International Law Cases and Materials*, 2ª ed., Law Sch. Casebook Series, 1962.
- Cavarré, L., *Le droit international public positif*, 3ª ed., París, Pédon, 1967.
- Colliard, C. A., *Institutions des Relations Internationales*, París, Dalloz, 1974.
- Duguit, L., *Traité de Droit Constitutionnel*, París, Ancienne Librairie Fontemoing y Cie. éd., 1924.
- Dupuy, R. J., *Le droit international*, París, P.U.F., 4ª ed., 1972.
- Friedmann, W., *The changing structure of International Law*, Columbia Univ. Press, 1966.
- Gnecco, J., "Los tratados internacionales frente a la Constitución y las leyes", *Revista del Colegio de Abogados de la Plata*, año 10, n° 19, pág. 123 y siguiente.
- Goldschmidt, W., *Derecho Internacional Privado*, Buenos Aires, El Derecho, 1970.
- Goldschmidt, W., "Derecho internacional y derecho interno argentino", *El Derecho*, t. 7, pág. 785 y sigs. y t. 23, pág. 423 y siguientes.
- González Calderón, J. A., *Derecho constitucional argentino*, Buenos Aires, Lajouane.
- Green, L. C., *International Law through the cases*, 3ª ed., Oceana, 1970.
- Hackworth, *Digest of International Law*, vol. I, 1940-42.
- Harris, D. J., *Cases and Materials on International Law*, Sweet & Maxwell, 1973.
- Jellinek, G., *Teoría general del Estado*, tr. F. de los Ríos, 2ª ed., Buenos Aires, Albatros, 1954.
- Jenks, C. W., *The common law of mankind*, London, Stevens, 1958.
- Jessup, P. C., *Transnational Law*, Yale Univ. Press, 1956.
- Jiménez de Arechaga, E., "Introducción al problema de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno", *Revista Jurídica de Buenos Aires*, 1962, I-II, pág. 10.
- Kazimierz, *Soviet public international law*, Leyden, 1970.

- Kelsen, H., *Principios de derecho internacional público*, tr. H. Caminos y E. C. Hermda, págs. 349-358, Buenos Aires, El Ateneo, 1965.
- Kelsen, H., "Le rapport de système entre le droit interne et le droit international public", *R.C.A.D.I.*, 1926, vol. IV, pág. 231 y siguiente.
- Lauterpacht, H., *The function of law in the international community*, Oxford, Clarendon Press, 1933.
- Mc Dougal, "The impact of International Law upon national Law: a policy oriented perspective", *S. Dak. L. Rev.*, 25, 27-31 (1959).
- Moreno Quintana, Lucio M., *Tratado de derecho internacional*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1963.
- Mosler, H., "L'application du droit international public par les tribunaux internationaux", *R.C.A.D.I.*, vol. 80, 1957.
- Miaja de la Muela, A., *Introducción al derecho internacional público*, Madrid, 1960.
- O'Connell, D. P., *International Law*, Stevens and Sons, Oceana, 1965.
- Oppenheim, *Tratado de Derecho Internacional Público*, 8ª ed. por H. Lauterpacht, Barcelona, Bosch, 1961.
- Renouvin, P., *Historia de las Relaciones Internacionales*, Madrid, Aguilar, 1960.
- Podestá Costa, L. A., *Derecho Internacional Público*, 4ª ed., Buenos Aires, T.E.A., 1961.
- Politis, *Nouvelles tendances du droit international*, cap. II, París, 1927.
- Puig, J. C., *Derecho de la comunidad internacional*, Buenos Aires, Depalma, 1974.
- Ross, A., *A textbook of international law*, 1947.
- Rousseau, Ch., *Droit International Public*, París, Sirey, 1971.
- Ruiz Moreno, Isidoro, *El Derecho Internacional Público ante la Corte Suprema*, Buenos Aires, EUDEBA, 2ª ed., 1970.
- Schwarzenberger, G., *The frontiers of international law*, Londres, Stevens, 1962.
- Sears Vázquez, M., *Manual de Derecho Internacional Público*, México, 1964.
- Sørensen, Max, *Manual of Public International Law*, ed. by, London, Melbourne, Toronto, Macmillan, 1968.
- Scelle, G., *Précis de droit des gens*, París, Sirey, 1932.
- Starke, J. G., *Introduction to international law*, 7th. ed., Londres, Butterworths, 1973.
- Steiner & Vagts, *Materials on Transnational Legal Problems*, Foundation Press, New York, 1968.
- Thrillway, H. N. A., *International Customary Law and Codification*, Leyden, Sijthoff, 1972.
- 1923, vol. I, pág. 76 y siguiente.
- Unsain, A. M., "Accidentes en la agricultura", *La Ley*, t. I, pág. 147 y siguiente.
- Triepel, H., *Völkerrecht und Landesrecht*, 1899.
- Truyol y Serra, A., *Fundamentos de derecho internacional público*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1970.
- *La sociedad internacional*, Madrid, Alianza Ed., 1974.
- Tunkin, G. I., *Droit international public, problèmes théoriques*, 1965.
- Tunkin, G. I., "Coexistence and International Law", *R.C.A.D.I.*, 1958, vol. III.
- "Cours Général", *R.C.A.D.I.*, 1975.
- Triepel, "Les rapports entre le droit interne et le droit international", *R.C.A.D.I.*.
- Vanossi, J. R., *Régimen constitucional de los tratados*, Buenos Aires, 1969.
- Verdross, A., *Derecho internacional público*, tr. A. Truyol y Serra, 3ª y 4ª ed., Madrid, Aguilar, 1961, 1963.
- Verzijl, J. H., *The jurisprudence of the World Court*, A. W. Sijthoff-Leyden, 1966.
- de Visscher, Ch., *Théories et Réalités en Droit International Public*, 4ª éd., París, Pédone, 1970.

FORMACION DEL DERECHO INTERNACIONAL

II

1. LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

a) Concepto de fuente

Tradicionalmente se denominaban *fuentes* de un ordenamiento jurídico tanto a los elementos que formulaban el derecho positivo como a las razones de validez de ese derecho. Esta última acepción, sin embargo, ha caído en desuso. Cuando la ciencia jurídica contemporánea invoca una fuente de derecho no hace ya referencia al por qué de la obligatoriedad de la norma jurídica sino al cómo esa norma es creada y en qué forma ésta se manifiesta y verifica. De acuerdo a este concepto general de fuente de derecho como instrumento de la ciencia jurídica, autores modernos de derecho internacional definen a las fuentes distinguiendo entre: a) fuente, como causa u origen; b) fuente, como proceso de formulación o creación de normas, y c) fuente, como modo de verificar o constatar la existencia de la norma jurídica internacional.

b) Fuente formal y fuente material

Si se parte de las definiciones modernas de fuentes del derecho internacional es doctrinariamente posible clasificarlas en fuentes formales y fuentes materiales.¹⁰⁸

Las fuentes materiales son aquellas causas, orígenes e influencias que dan nacimiento a la norma jurídica y de las cuales el derecho internacional se nutre y desarrolla. Serán entonces fuentes materiales de este derecho, por ejemplo, las distintas convicciones y posturas políticas interna-

¹⁰⁸ Para Jennings esta clasificación no es en la práctica muy precisa, pues una misma fuente puede operar como fuente material y fuente formal. Un tratado que crea una serie de obligaciones para las partes será fuente formal para ellas y a la vez podrá ser considerado como fuente material para terceros Estados en tanto que prueba del desarrollo general de una *opinio juris sive necessitatis*; Jennings, R. Y., "General Course on Principles of International Law", R.C.A.D.I., vol. II, 1967, págs. 329-330.

cionales de los Estados, la interdependencia económico-social de éstos, determinados intereses y conveniencias nacionales o internacionales.¹⁰⁷

Las fuentes materiales dan la fundamentación extrajurídica de por qué nace una norma jurídica del derecho internacional, pero nada agregan sobre el contenido o la validez de esa norma. Las fuentes materiales se confunden entre sí con el origen del derecho internacional y en cierta medida con su fundamento. Por ello las llamadas fuentes materiales no son objeto de estudio de la ciencia jurídica, sino de la Teoría de las Relaciones Internacionales en tanto y en cuanto esta rama de las ciencias sociales se centre en el análisis del por qué de las interrelaciones formales de las unidades políticas llamadas Estados.

Dentro de la clasificación de las fuentes formales es posible distinguir entre procesos de creación (fuentes creadoras) y modos de verificación (fuentes evidencias).

Las fuentes formales como modos de verificación son fuentes formales en sentido amplio. Las fuentes formales como procesos de creación —llamadas también fuentes autónomas— son fuentes formales en sentido restringido.

Las fuentes formales en sentido amplio son entonces aquellas fuentes a través de las cuales el derecho se manifiesta y formula y en razón de ser su expresión visible y concreta, se definen como los modos de verificación de la existencia de normas jurídicas. Las fuentes formales en sentido restringido son aquellas aceptadas por el ordenamiento jurídico vigente como los modos o procesos válidos a través de los cuales el derecho internacional es creado. Las fuentes formales en sentido restringido, o sea como procesos de creación de normas, necesitan indefectiblemente manifestarse a través de un resultado verificable que no será otra cosa que la existencia misma de la norma jurídica creada.¹⁰⁸

Las fuentes creadoras (fuentes formales en sentido restringido) son a la vez fuentes formales en sentido amplio, pues constatan la existencia de una norma a través del resultado mismo del proceso creativo válido para el ordenamiento jurídico internacional. Las fuentes formales que sólo son modos de verificación y no coinciden con un proceso de creación preestablecido no hacen más que evidenciar la existencia de una norma jurídica internacional a la luz de los procesos de creación válidos para el ordenamiento jurídico internacional.

Esta clasificación entre fuentes formales en sentido amplio y fuentes formales en sentido restringido es la base para comprender la distinción

¹⁰⁷ Para D. P. O'Connell la idea fundamental detrás de la noción de fuente debería ser la del origen o impulso de creación de la norma jurídica y no la canalización formal de esas fuerzas motoras... fuentes como impulsos de creación y fuentes como procesos de cristalización de normas jurídicas. O'Connell, D. P., *International Law*, Stevens-Oceana, 1965, pág. 3 y siguientes.

¹⁰⁸ H. W. Briggs distingue entre un tratado como fuente de derecho en relación al "método de creación" del mismo, y el contenido sustantivo de ese tratado como "derecho internacional" (o sea como la norma jurídica creada). Briggs, H. W., *The Law of Nations*, Second Edition, 1966, Appleton Century Crofts, pág. 43 y sig. Para

que se infiere del art. 38 del Estatuto de la C.I.J. entre las fuentes principales y las fuentes auxiliares.¹⁰⁹

Los tratadistas modernos del derecho internacional coinciden en la necesidad de un replanteo analítico de la teoría general de las fuentes del derecho internacional.¹¹⁰ Por nuestra parte consideramos que la problemática actual que presentan éstas, como instrumentos o instituciones de la ciencia jurídica internacional, no se refiere al porqué de la obligatoriedad de la norma (fuente como fundamento), ni a las causas extrajurídicas que las motivan u originan (fuente material), sino al cómo esa norma es creada (fuente formal en sentido restringido) y en qué forma ésta se manifiesta y verifica (fuente formal en sentido amplio).

El estudio de las fuentes formales y la distinción entre fuentes formales en sentido amplio y fuentes formales en sentido restringido son las bases que proponemos como esquema doctrinario para captar la dinámica de las normas vigentes, reguladoras de la comunidad internacional.¹¹¹

c) Enumeración de las fuentes del Derecho Internacional

Al referirnos a las características del derecho internacional mencionamos la voluntad de los Estados como uno de los elementos determinantes de su contenido y evolución. La voluntad común de éstos, como

nosotros un Tratado es fuente del derecho no solo en relación a su "método de creación" (fuente formal en sentido restringido), sino también en relación al resultado verificable de ese proceso de creación que coincide con la existencia de las normas jurídicas contenidas y descriptas por ese tratado (fuente formal en sentido amplio).

¹⁰⁹ El esquema aquí propuesto contradice la distinción entre fuentes creadoras y fuentes formales esbozada por Ch. de Visscher y G. Scelle como corolario de la concepción objetivista del Derecho Internacional. (Véase Rousseau, Ch., *Derecho Internacional Público*, 3ª ed., Ariel, 1966, pág. 20). En tanto y en cuanto la fuente creadora se identifique con el proceso creativo formal independientemente de las causas-origen que motivan o fundamentan ese proceso sería más correcto hablar de fuentes materiales y fuentes formales y dentro de éstas, fuentes formales (modos de verificación) en sentido amplio y fuentes formales (procesos de creación) en sentido restringido.

¹¹⁰ Conf. Puig, J. C., *Derecho de la comunidad internacional*, Buenos Aires, Depalma, 1974, pág. 94; Barberis, J., *Fuentes del derecho internacional*, La Plata, Editora Platense, 1973.

¹¹¹ A fines del siglo pasado Pradier-Fodéré sostuvo que fuente es un instrumento intelectual por el cual la norma jurídica es descubierta (Pradier-Fodéré, *Droit International Public Positif*, 1885, vol. I, pág. 35 y sig.). Starke llama a las fuentes que nosotros definimos como fuentes formales, fuentes materiales, pero aclara que las fuentes materiales son las fuentes tangibles a través de las cuales se constata la existencia de la norma jurídica internacional. Esta posición, también compartida por Jennings, nos plantea el problema del estudio de las fuentes del derecho internacional no solamente como criterios para la determinación del derecho existente —*lex lata*—, sino también como proceso para la modificación y desarrollo de éste —*lex ferenda*— (Starke, J. G., *Introduction to international law*, 7th ed., Londres, Butterworths, 1973, pág. 34 y sig.; Jennings, R. Y., *op. cit.*, pág. 330).

agentes generadores, condiciona los procesos válidos de creación y verificación de las normas jurídicas internacionales.¹¹²

Kelsen sostiene que un elemento característico del derecho en general, y por lo tanto también del derecho internacional, es que regula su propia creación. La función de una constitución es especialmente regular la creación de normas generales por órganos especiales (legislación). El derecho internacional general o la comunidad constituida por el derecho internacional general también tiene su "constitución". La constitución de la comunidad internacional es el conjunto de normas del derecho internacional que regulan su creación, o en otros términos, que determinan las "fuentes" del derecho internacional.¹¹³

En este trabajo, siguiendo a Kelsen, al enunciar las fuentes del derecho internacional se hace referencia a las bases mismas de la constitución de este derecho aceptadas por los miembros de la comunidad internacional. Podemos considerar que aquéllas se encuentran enumeradas por el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

El artículo 38 del Estatuto de la Corte dice:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
 - a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
 - b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
 - c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
 - d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren."

El contenido de esta disposición es obligatorio para la C.I.J. cuando decide conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas por los Estados. En cambio, no estaría obligada, en principio, a su aplicación al formular una opinión consultiva que le requiriese el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, o alguno de los otros órganos de la ONU o un organismo especializado debidamente autorizado a tal fin. Sin embargo, la práctica del Tribunal, al igual que la de su antecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional, reconoció la obligatoriedad

¹¹² Para Anzilotti las únicas fuentes del derecho internacional son aquéllas que se hallan reconocidas, expresa o tácitamente, por los Estados como órganos originarios en la creación de normas jurídicas; Anzilotti, D., *Curso de Derecho Internacional*, tr. de la 3ª ed. de J. López Olivan, Madrid, Ed. Reus, 1935, pág. 61.

¹¹³ Kelsen, H., *Principios de Derecho Internacional Público*, tr. H. Caminos y E. C. Hermida, Buenos Aires, El Ateneo, 1965, pág. 259.

del texto en cuestión tanto en materia contenciosa como en materia consultiva.

Las normas contenidas en el art. 38 son también obligatorias para todos los Estados de la comunidad internacional. Esta obligatoriedad nace de la práctica reiterada y común de los Estados al aceptar a las fuentes enunciadas en esta norma como expresión del derecho internacional consuetudinario.¹¹⁴ Sin embargo, al no tratarse de una norma imperativa de derecho internacional general nada impediría que dos o más Estados se pusiesen de acuerdo para dirimir sus controversias fuera del marco de la estricta aplicación de las normas contenidas en el art. 38.¹¹⁵ De tal modo, cabe a los Estados, como agentes generadores de derecho, la posibilidad de aceptar nuevas fuentes creadoras de normas jurídicas internacionales.

La disposición a la que nos estamos refiriendo no menciona el término "fuentes de derecho". Este concepto puede inferirse del hecho de que la Corte debe aplicar el derecho formulado a través de los modos de verificación y de los procesos de creación enunciados por aquélla. Por otra parte, las definiciones de las fuentes contenidas en el art. 38 son meramente descriptivas. Tal carácter ha sido reconocido por la doctrina contemporánea en coincidencia con la interpretación dada por la CPJI y por la CIJ.¹¹⁶ Ahora bien, la enunciación que hace el art. 38 es taxativa para la Corte. Esta no podrá aplicar como normas jurídicas internacionales reglas que no hayan sido creadas por alguno de los procesos aceptados como válidos por dicha disposición.¹¹⁷

¹¹⁴ La Comisión de Redacción del Estatuto de la C.P.J.I., al formular el art. 38 de redacción similar al actual, sistematizó el derecho consuetudinario vigente en ese momento referido a las fuentes válidas para el ordenamiento jurídico internacional; por lo tanto es posible sostener que esta norma codifica una costumbre aceptada por la generalidad de los Estados que componen la comunidad internacional. El antecedente inmediato del art. 38 se encuentra en una disposición del Convenio XII, adoptado por la Conferencia de Paz de La Haya de 1907, por el que se creaba el Tribunal Internacional de Presas. En ella se establecía que el derecho a aplicar por este Tribunal, que en la práctica nunca se llegó a constituir, sería el derecho emanado de los convenios entre las partes en litigio, la costumbre, los principios generales de derecho y la equidad.

¹¹⁵ Véase lo dicho en el capítulo I, 1.b) sobre las normas imperativas y las normas dispositivas.

¹¹⁶ La interpretación exegética de los enunciados del art. 38 puede dar lugar a ciertos equívocos; así, por ejemplo, Jennings sostiene que los únicos tratados contemplados por el art. 38 son los tratados contratos y que la costumbre no es la prueba de la práctica de los Estados, sino que la práctica de los Estados es la prueba de la costumbre internacional. Asimismo, la "práctica generalmente aceptada como derecho" ha sido interpretada por la Corte como no excluyente de las prácticas particulares como prueba de la existencia de una norma consuetudinaria; conf. C.I.J., *Derecho de Paso sobre el territorio indio*, Recueil, 1960, pág. 6.

¹¹⁷ El problema del carácter taxativo o no del art. 38 ha sido revivido por parte de la doctrina que trata de fundamentar la autonomía de nuevos procesos de creación de normas jurídicas como fuentes principales del derecho internacional. H. W. A. Thirlway argumenta que en última instancia cualquier nuevo proceso de creación de normas jurídicas obtiene o deriva su carácter obligatorio de alguna de las fuentes consideradas como válidas por el ordenamiento jurídico internacional.

Los actos unilaterales de los Estados y los actos de los organismos internacionales, para poder ser considerados fuentes creadoras de derecho, deberán reconocer indefectiblemente como base y fundamento alguna de las fuentes principales enunciadas en el art. 38.¹¹⁸

d) Fuentes principales y fuentes auxiliares

El texto del art. 38 del Estatuto de la CIJ permite clasificar a las fuentes en principales y auxiliares. Las *fuentes principales* son los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. Las *fuentes auxiliares* —también llamadas subsidiarias— son la jurisprudencia y la doctrina. La equidad puede llegar a ser una fuente principal si media la expresa voluntad de las partes para que el tribunal falle *ex aequo et bono*.¹¹⁹

Las fuentes principales son los procesos a través de los cuales el derecho internacional es creado. Son, por sí mismas, capaces de verificar la existencia de una norma jurídica, pues el resultado del proceso de creación es verificable a través de ese mismo proceso creativo. En consecuencia, el modo de determinar la existencia de una norma coincide con el resultado del proceso de su creación.

Las fuentes auxiliares son los medios subsidiarios para la determinación de la existencia de las normas jurídicas. Las llamadas fuentes auxiliares no están facultadas por sí mismas para crear normas jurídicas; por lo tanto, la norma verificada por medio de una fuente auxiliar deberá reconocer siempre por antecedente, en cuanto a su proceso de creación, a una fuente principal.

Las *fuentes principales* o fuentes creadoras son fuentes formales en sentido restringido; las *fuentes auxiliares* o fuentes evidencia son fuentes formales en sentido amplio.

e) Jerarquía de las fuentes

El art. 38 del Estatuto de la CIJ no establece ninguna jerarquía entre las fuentes principales. La Comisión de Redacción del Estatuto de la

¹¹⁸ El Tratado de Roma de 1957, que creó la C.E.E. faculta en el art. 189 al Consejo y a la Comisión a dictar reglamentos, directivas y decisiones obligatorias para sus destinatarios. Los actos del Consejo y de la Comisión han dado lugar al nacimiento de un conjunto de normas jurídicas que se conoce como "derecho comunitario" o "derecho secundario". La obligatoriedad de este derecho secundario no reconoce otra fuente que el acuerdo de los Estados miembros de la CEE manifestado al momento de consentir en obligarse por el Tratado de Roma.

¹¹⁹ Sin embargo, el principio de equidad es un principio general de derecho que, como tal, es fuente principal; conf. C.I.J., *Plataforma continental del Mar del Norte*, *Recueil*, 1969, §§ 85 y 88; *Competencia en materia de pesquerías*, *Recueil*, 1974, § 69.

Corte Permanente había omitido incluir en el texto del art. 38 (antecedente del actual art. 38 del ECIJ) una propuesta según la cual las fuentes allí mencionadas debían ser aplicadas por el Tribunal en forma sucesiva. Esto ha otorgado flexibilidad, tanto a la CPJI como a la CIJ, para la apreciación y evaluación de las fuentes a aplicar al caso.

El orden de enunciación de las fuentes no determina una jerarquización entre ellas. La aplicación de la norma pertinente al caso se hará en función de los principios generales de derecho *lex specialis derogat generalis* y *lex posterior derogat priori*.¹²⁰ Todas las fuentes principales gozan de idéntica jerarquía.¹²¹ Ante un conflicto entre normas jurídicas expresadas en fuentes distintas, la Corte decidirá de acuerdo a su propio criterio cuál es la norma pertinente. En consecuencia, al encontrarse todas las fuentes principales en un mismo plano jerárquico, un tratado podrá derogar a una costumbre anterior y una costumbre posterior derogará al tratado anterior. Idéntico criterio se aplica con los principios generales de derecho en su relación temporal con las otras fuentes principales del derecho internacional.

¹²⁰ La estricta aplicación del principio de "la ley especial deroga a la ley general" podría dar lugar a contradicciones, por ejemplo, al identificar a toda convención internacional con la ley especial y a toda costumbre internacional con la ley general; podría ocurrir legítimamente que un tratado establezca normas generales que han sido particularizadas por la costumbre —práctica ulterior— entre dos o más Estados partes en ese tratado: en este caso, la costumbre ulterior sería la ley especial y el tratado la ley general. Este conflicto se resolvería aplicando las normas sobre interpretación del derecho de los tratados. Véase el desarrollo del tema en el cap. II, 3.b).

¹²¹ Sin embargo dos o más Estados podrán, de común acuerdo, establecer una jerarquía especial de las fuentes a aplicar para la solución de sus controversias.

2. LA COSTUMBRE

Desde sus orígenes, el contenido del derecho internacional se ha nutrido, principalmente, de la costumbre entre los Estados. Hasta mediados del siglo pasado el ordenamiento jurídico internacional reconocía casi exclusivamente normas jurídicas consuetudinarias. En la actualidad, la evolución del derecho hacia una *lex scripta* no sólo se manifiesta en la proliferación de los tratados, sino especialmente en la actividad codificadora emprendida por la organización de las Naciones Unidas.

Pero el gran auge de los tratados no ha desvanecido la importancia de la costumbre como fuente creadora del derecho internacional.

La fluidez de las relaciones entre Estados, aún hoy día, nos lleva a reconocer en la costumbre a una de las fuentes formales más dinámicas dentro del proceso creativo de normas jurídicas internacionales.

Pero, ¿qué es la costumbre internacional? Dentro del esquema general de las fuentes del derecho internacional hemos clasificado a la costumbre como fuente principal; por lo tanto, fuente creadora de normas jurídicas internacionales.

No sólo hemos identificado a la costumbre con un proceso de creación de normas, sino que también hemos denominado costumbre al resultado de ese proceso, por medio del cual se verifica la norma jurídica creada.

El art. 38 del Estatuto de la CIJ dice: "1. La Corte... deberá aplicar: ... b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;..." En razón de ser el enunciado del art. 38 del Estatuto de la CIJ meramente descriptivo, preferimos definir a la costumbre diciendo que es la práctica común y reiterada de dos o más Estados aceptada por éstos como obligatoria.

a) Elementos constitutivos

La doctrina tradicional ha distinguido en la costumbre dos elementos constitutivos: uno *material* y otro *psicológico*.¹²²

¹²² Esta distinción ha sido corroborada por la CIJ en el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, *Recueil*, 1969, págs. 3 y 44.

El elemento material es la práctica común y reiterada y el elemento psicológico es la aceptación de esa práctica como derecho; es decir, la conciencia o convicción de los Estados sobre su obligatoriedad.

1. Elemento material

La práctica de un Estado, para ser considerada como elemento constitutivo de una costumbre internacional, deberá ser siempre un acto concluyente, emanado de los órganos o agentes dotados de competencia internacional. Este acto propio, o acto unilateral de un Estado, deberá ser a su vez "concordante" con el contenido de otros actos, propios o unilaterales, de otro u otros Estados. Estos actos unilaterales concordantes —la práctica común a dos o más Estados— configuran el antecedente material del proceso formativo de una costumbre internacional.¹²³

La conducta eficaz constitutiva de la práctica internacional puede consistir en un obrar o bien en una actitud pasiva que implique la aceptación de actos concluyentes de otros Estados.

Para la doctrina tradicional esta práctica común de los Estados deberá ser reiterada en el tiempo. Resulta difícil determinar el término de reiteración de una práctica para que ésta genere costumbre. En algunos casos se ha hecho referencia a una práctica "inmemorial" o "con antigüedad de siglos", pero el elemento temporal es circunstancial y depende de la naturaleza de las conductas, de la frecuencia de su repetición y de su publicidad y generalidad.

A su vez, la repetición de los actos propios de los Estados deberá ser constante y uniforme para evidenciar la continuidad del comportamiento de éstos durante el proceso formativo de una costumbre internacional.¹²⁴ Se sostiene, también, que esa práctica común y reiterada deberá tener cierto grado de generalidad para poder configurar, así, el elemento material de la norma consuetudinaria.

Por nuestra parte pensamos que en el ordenamiento jurídico internacional coexisten normas particulares que obligan a dos o más Estados y normas generales que obligan a toda o a casi toda la comunidad internacional.

¹²³ La actividad de los órganos de un organismo internacional puede dar lugar a la creación de normas jurídicas consuetudinarias internas de esa organización. En este caso, los actos unilaterales de esos órganos serán los únicos antecedentes materiales en el proceso de creación de esa costumbre a aplicar internamente. La C.P.J.I. fundamentó en la práctica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los poderes de ésta para reglamentar internacionalmente las condiciones de trabajo de personas empleadas en la agricultura, establecidas en una convención adoptada en su seno. Opinión consultiva, C.P.J.I., *Serie B*, n° 2, 40-41.

¹²⁴ La conducta del Estado para crear derecho consuetudinario debe ser constante y uniforme; conf. C.I.J., caso del *Derecho de Asilo*, *Recueil*, 1950, págs. 276-277. Cabe distinguir, sin embargo, entre los actos unilaterales de los Estados que constituyen antecedentes de una costumbre internacional, y los actos unilaterales que comportan una manifestación del consentimiento para obligarse frente al derecho internacional mediante un acuerdo tácito; conf. C.P.J.I., caso de la *Groenlandia Oriental*, *Dinamarca-Noruega*, 1933, *Serie A/B*, n° 53, pág. 3.

Para que dos Estados estén obligados por una costumbre internacional bastará la práctica reiterada y común, aceptada por éstos como derecho. La CIJ en el caso del *Derecho de paso sobre el territorio indio* entre India y Portugal, sostuvo que una práctica particular entre dos Estados, aceptada por ella como derecho, da nacimiento a una norma consuetudinaria.¹²⁵ La aplicación por la Corte de una costumbre que no ha sido aceptada en general, es decir de una norma particular, no es contraria al art. 38, 1.b), de su Estatuto. Como ya se ha dicho, este artículo es meramente descriptivo de las fuentes en él enunciadas en forma taxativa. De no ser así, la disposición en cuestión implicaría una contradicción pues la costumbre no es una prueba de la práctica generalmente aceptada, sino que la práctica generalmente aceptada como derecho es una prueba de la existencia de la costumbre.

La práctica general como antecedente de una costumbre general es el resultado de la multiplicación de las prácticas precedentes de los miembros de la comunidad internacional, consolidadas en el tiempo.¹²⁶

Para que una costumbre internacional sea "general" no es necesario que en su proceso formativo hayan participado todos los Estados de la comunidad internacional, sino que bastará la concurrencia de la mayoría de ellos. Así, por ejemplo, los Estados sin costas marítimas no han podido contribuir con sus prácticas a la creación de normas consuetudinarias sobre el mar territorial; sólo los Estados con potencial aeroespacial podrán, a través de sus prácticas, determinar los antecedentes de futuras costumbres referentes a la aeronavegación espacial.¹²⁷

Ahora bien, toda norma consuetudinaria de tipo "general" no es necesariamente, por esa sola característica, una norma imperativa de dere-

¹²⁵ C.I.J., *Recueil*, 1960. En el caso se trataba de determinar el derecho del Estado de Portugal para atravesar el territorio del Estado de la India dirigiéndose de los enclaves portugueses de Dadra y Nagar-Aveli a Damao. La Corte observa que el paso de personas privadas y de funcionarios civiles no había sido objeto de ninguna restricción. Esta práctica había sido constante y uniforme y la Corte considera que ella "ha sido aceptada por las Partes como derecho y ha dado nacimiento a un derecho y a una obligación correspondiente".

¹²⁶ Virally, M., en Sørensen, M., *Manual of International Law*, Londres, Macmillan, 1968, pág. 131.

¹²⁷ Cabe destacar que la oposición de un Estado en particular no priva a la norma consuetudinaria general de su carácter de tal. Así, por ejemplo, si ante un caso determinado un Estado se niega a reconocer la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático que se encuentra debidamente acreditado ante él podría ocurrir que: a) una práctica establecida con conciencia de obligatoriedad entre el Estado acreditante y el Estado receptor hubiese establecido la renuncia recíproca de la inmunidad, a priori y para cualquier supuesto; caso en el cual la norma particular sería derogatoria de la norma general, en las relaciones entre las partes exclusivamente; o bien b) que simplemente el Estado receptor al no reconocer la inmunidad de jurisdicción del agente diplomático cometiese un ilícito internacional violando una norma de este ordenamiento. En los dos supuestos —uno lícito, otro ilícito— la oposición del Estado no le quitaría el carácter de "general" a la norma que establece la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos. Conf. caso de *Las Pesquerías Anglo-Noruegas*, CIJ, *Recueil*, 1951.

cho internacional general. Recordemos que la calidad de imperativa de una norma depende de la aceptación y el reconocimiento del carácter de tal por la comunidad internacional de Estados en su conjunto y no del sólo hecho de la participación en el proceso creativo de la comunidad internacional.¹²⁸

2. Elemento psicológico

No basta, sin embargo, una práctica común y reiterada entre Estados para que nazca una costumbre internacional. Es necesario, además, que los Estados, cuando así actúen, lo hagan con el convencimiento de obrar de acuerdo a derecho. Es decir, que un Estado asuma una actitud concordante con la práctica de otro u otros Estados con la convicción de la obligatoriedad de su obrar. Cualquiera sea la motivación del Estado como agente generador del derecho internacional, en última instancia, su conducta se manifiesta en una necesidad jurídica a través del acto unilateral por el cual el Estado, al así actuar, reconoce la obligatoriedad de su proceder como sujeto de derecho frente a otro u otros Estados.

La doctrina del derecho internacional ha identificado conceptualmente a la conciencia de los Estados referida a la necesidad jurídica de sus prácticas con la *opinio juris sive necessitatis* del derecho romano.¹²⁹ Mediante ella se logra diferenciar el uso de la costumbre internacional. Los usos son pautas de conducta seguidas por los Estados que responden a meros actos de cortesía cuya omisión o alteración no produce ningún efecto jurídico.

Al aceptar un elemento psicológico como constitutivo de la costumbre internacional se fundamenta el carácter volitivo y consensual de ésta como proceso de creación de normas jurídicas internacionales.¹³⁰ El mismo texto del art. 38, 1.b), del Estatuto de la Corte hace referencia a la *opinio juris* al describir a la costumbre como práctica generalmente

¹²⁸ Véase lo ya dicho en el capítulo I, 1.b) sobre las normas imperativas y las normas dispositivas.

¹²⁹ Guggenheim, *Lehrbuch des Völkerrechts*, 1948, págs. 46-47, niega la necesidad de la existencia del elemento psicológico, como constitutivo de la costumbre internacional, basándose en la imposibilidad de que éste se manifieste y abstraiga independientemente de la práctica común y reiterada; véase también Kelsen, H., "Théorie du Droit International Coutumier", *Revue Internationale de la Théorie du Droit*, 1939, pág. 253 y sig., y la evolución de su concepción en *Principios de Derecho Internacional Público*, tr. H. Caminos y E. C. Hermida, Buenos Aires, El Ateneo, 1965, págs. 264-266.

¹³⁰ D'Amato, "On consensus", *VIII Canadian Yearbook of International Law*, 1970, pág. 104, sostiene que el consenso es una fuente del derecho internacional, autónoma del consentimiento, la *opinio juris* o la adquiescencia. Sin embargo, no es posible fundamentar la costumbre en un consenso entre Estados, independientemente de la práctica de éstos, como antecedente material de la norma consuetudinaria. Jennings y Fitzmaurice se refieren a la *opinio juris* como al resultado del consenso general de los Estados y no como a la expresión del consentimiento. Tunkin, *op. cit.*, pág. 140, piensa que la *opinio juris* pone de manifiesto la necesidad del consentimiento tácito de los Estados para estar obligados por la costumbre internacional.

12

"aceptada como derecho". La jurisprudencia de los tribunales internacionales también ha reconocido tal naturaleza jurídica a la norma consuetudinaria.¹³¹

La norma consuetudinaria general, resultante de la costumbre como proceso creativo general, podrá obligar a terceros Estados que no hayan participado directamente en ese proceso siempre y cuando aquéllos no hayan realizado actos contrarios a esas prácticas o no hayan manifestado su disconformidad con ellas. El elemento psicológico, necesario durante el proceso formativo de una costumbre internacional, consiste —en estos supuestos— en la aceptación tácita y pasiva que implica aquiescencia sobre su obligatoriedad.¹³²

Una costumbre internacional general también obligará a los Estados que habiendo participado directamente en su proceso formativo quisiesen apartarse de ella, si se trata de una norma que ha sido aceptada y reconocida como imperativa por la comunidad internacional de Estados en su conjunto.¹³³

b) Prueba de la costumbre

La fluidez e imprecisión de las prácticas estatales como antecedentes de una costumbre internacional pueden dejar un cierto margen de incertidumbre en cuanto a su existencia.¹³⁴

¹³¹ En el caso del *Derecho de Asilo*, entre Colombia y Perú, en el que Colombia sostenía en virtud "del derecho internacional americano" que tenía el derecho de calificar el delito imputado a Haya de la Torre como político a los fines de acordarle el asilo diplomático, la C.I.J. dijo que de las pruebas producidas para constatar la existencia de una costumbre obligatoria entre las partes en litigio no era posible discernir ningún uso constante y uniforme *aceptado* como derecho; C.I.J., *Recueil*, 1950, págs. 276-277. Idéntico principio sentó este tribunal en el caso de los *Derechos de los nacionales de los Estados Unidos en Marruecos*, en el que determinó que no medió prueba suficiente para posibilitar a la Corte el concluir que un derecho al ejercicio de la jurisdicción consular fundado en la costumbre o uso ha sido establecido de tal manera que se haya convertido en obligatorio para Marruecos; C.I.J., *Recueil*, 1952, pág. 200. En el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, la C.I.J. estableció que la *opinio juris* encierra un sentimiento por el cual los Estados se consideran obligados legalmente y que una acción estatal habitual no es suficiente para configurar una obligación jurídica por sí misma, al desestimar las demandas de Dinamarca y los Países Bajos según las cuales la República Federal de Alemania estaba obligada a aceptar la división de la plataforma continental del Mar del Norte según la "regla de la equidistancia" en virtud de una norma consuetudinaria de contenido similar al art. 6 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental; C.I.J., *Recueil*, 1969, pág. 44.

¹³² Conf. Oppenheim, *op. cit.*, vol. I, págs. 874-875.

¹³³ Véase lo ya dicho en el capítulo I.1, b), sobre las *normas imperativas y las normas dispositivas*.

¹³⁴ Kelsen, *op. cit.*, pág. 263, sostiene que los hombres no saben necesariamente, al establecer una costumbre, que están creando con su conducta una norma jurídica, ni tampoco necesariamente intentan crear derecho. La norma jurídica es el efecto y no el propósito de su actividad.

En el caso de una costumbre general cabe suponer que el Estado contra el cual ésta se invoca ha participado en el proceso creativo o que, no habiéndose opuesto a su nacimiento, ha dado su aquiescencia. Este Estado puede sin embargo probar que ha realizado actos contrarios a las prácticas antecedentes de esa costumbre general, o bien que mediante protesta u otra conducta concluyente no ha brindado aquiescencia.¹³⁵

Tratándose de costumbres particulares, se ha considerado —como principio— que la parte que alega su existencia deberá probarla, como deberá probar también que la norma vincula a las partes en la controversia. Tal exigencia ha sido puesta de manifiesto en el caso del *Derecho de Asilo* por la CIJ al afirmar que

"...la parte que invoca una costumbre de este tipo deberá probar que esa costumbre ha sido establecida de tal manera que ha llegado a ser obligatoria para la otra parte."¹³⁶

En la determinación de la existencia de normas consuetudinarias la función cumplida por los órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, es relevante.

Para acreditar la existencia de las prácticas necesarias a la formación de la costumbre han sido invocadas múltiples manifestaciones del comportamiento de los Estados. En este orden, han podido ser alegados tanto actos internos de los Estados, como actos internacionales. Las leyes internas, decisiones judiciales nacionales, actos que reflejan prácticas gubernamentales reiteradas pueden exteriorizar esa conducta, como también pueden hacerlo actos internacionales, tales como la firma de una convención internacional, las reclamaciones diplomáticas, las reservas o diversas otras manifestaciones a través de las cuales se prueba la reiteración de prácticas estatales.¹³⁷

¹³⁵ La C.I.J., ha establecido en el caso de las *Pesquerías Anglo-Noruegas*, que una costumbre internacional, por más general que sea, no obliga a un Estado que constantemente se ha resistido a su aplicación, aún durante el proceso de su creación; C.I.J., *Recueil*, 1951.

¹³⁶ C.I.J., *Recueil*, 1950, pág. 276.

¹³⁷ En el caso "The Paquete Habana", la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que de la prueba producida (legislación estatal, tratados, decisiones de las cortes nacionales, doctrina, etc.) se desprende en forma incontestable la existencia de una regla consuetudinaria válida que otorgaba a las pequeñas embarcaciones pesqueras inmunidad ante actos de beligerancia en tiempo de guerra; EE.UU., *Supreme Court of Justice*, Doc., 1900, 175 U.S. 677. En el orden internacional, la C.P.J.I. —siguiendo un método similar para la determinación de la existencia o no de una costumbre internacional— decidió en el caso del *Lotus* que no existía una norma jurídica consuetudinaria que confiriera jurisdicción penal exclusiva al Estado de la bandera del buque en caso de abordaje en alta mar; C.P.J.I. (1927), Serie A, n° 10. Por su parte, la C.I.J. en el *Caso del Derecho de Asilo* sostuvo que del número limitado de ratificaciones a la Convención de 1933 sobre Asilo Político —invocada por Colombia— se ponía de manifiesto la debilidad del argumento de que los principios contenidos en ella reconocían por antecedente una costumbre regional latinoamericana; C.I.J., *Recueil*, 1950, pág. 277. La misma Corte, en el *Caso de la Plataforma Continental del Mar del*

En cuanto a la *opinio juris* deberá ser inferida de todas las circunstancias posibles y no solamente de los actos constitutivos del elemento material de la norma consuetudinaria invocada.¹³⁸

Los problemas que puede comportar la prueba de una costumbre internacional se acentúan en aquellos casos en que ésta modifica o deroga normas internacionales anteriores. ¿Desde qué momento, entonces, la repetición por dos o más Estados de actos que podrían ser considerados violatorios de una norma anterior puede a la vez ser entendida como antecedente de una nueva costumbre internacional?; es decir, ¿desde cuándo una nueva práctica común y reiterada dejaría de ser violatoria del derecho internacional para convertirse en un lícito internacional? En este supuesto la prueba de las nuevas prácticas y la convergencia de una *opinio juris* inequívoca se tornan rigurosas y el factor temporal adquiere un relieve particular a fin de precisar el momento en que nace la nueva norma consuetudinaria.

Ante los problemas de hecho que acarrea la verificación de la existencia de una costumbre internacional, el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU establece que dicha Comisión deberá considerar los medios para obtener pruebas fehacientes sobre la existencia del derecho internacional consuetudinario. La CDI deberá considerar los medios adecuados para hacer la prueba de la costumbre internacional más accesible y menos controvertida, como ser, a través de la selección y publicación de los documentos concernientes a la práctica de los Estados y de las decisiones de los tribunales nacionales e internacionales, con la obligación de dar conocimiento a la Asamblea General sobre el particular.¹³⁹

Norte determinó la no existencia de una norma consuetudinaria que obligue a las partes en la controversia a delimitar la plataforma continental común a Estados adyacentes de acuerdo al principio de la equidistancia; C.I.J., *Recueil*, 1969. Tanto en el caso del *Lotus* como en el caso de *Asilo* y en el caso de la *Plataforma continental del Mar del Norte*, las contradicciones resultantes de las pruebas producidas fueron el factor determinante para que tanto la C.P.J.I. como la C.I.J., negaran la existencia de una costumbre internacional obligatoria para las partes en la controversia. Véase en el Caso del *Derecho de Paso* entre Portugal e India el valor de las pruebas producidas para constatar la existencia de una costumbre particular; C.I.J., *Recueil*, 1960, pág. 6 y sigs.

¹³⁸ El juez Tanaka, en su opinión en disidencia en el Caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, I.C.J., *Recueil*, 1969, expresó que es extremadamente difícil constatar la existencia de una *opinio juris sive necessitatis* en cada caso en particular... No es posible evidenciar la existencia de una *opinio juris* independientemente de la existencia de ciertas prácticas externas... el buscar evidencias de las motivaciones subjetivas de cada práctica estadual comporta de hecho, un imposible.

¹³⁹ La Comisión de Derecho Internacional preparó en 1950 un listado —no exhaustivo— de las posibles formas de evidenciar prácticas estaduais en general. En ese listado se enumeran a los tratados, a las decisiones de las cortes nacionales e internacionales, a las legislaciones nacionales, a la correspondencia diplomática, a las opiniones de los consejeros legales de los Estados y a la práctica de los Organismos Internacionales; Y.B.I.L.C., 1950, II, págs. 368-372. Brownlie, por su parte, considera actos relevantes a los efectos de la prueba de prácticas estaduais, entre otros, los planes políticos de gobierno, a las conferencias y comunicados de prensa oficiales, las instrucciones y órdenes militares, navales y aeronáuticas, a los comentarios de los

c) Problemas recientes del derecho consuetudinario

1. Los nuevos Estados y la costumbre vigente

El surgimiento de nuevos Estados independientes y soberanos, como consecuencia del proceso de descolonización que experimenta la Comunidad internacional, plantea el problema de la aceptación o no por parte de esos nuevos Estados del *Derecho Internacional consuetudinario preexistente*.

Ellos no han participado en su proceso formativo. No han tenido oportunidad de contribuir con sus conductas a la creación de las normas; tampoco han podido demostrar su oposición. Por ello podría considerarse que para estos Estados no opera el carácter eminentemente consensual de los mecanismos de creación del derecho internacional.

La doctrina anglosajona opina que existiría siempre una aceptación del derecho internacional vigente por parte de los nuevos Estados. Esta aceptación no se expresa por medio de su consentimiento, sino que queda implícita en el acto mismo por el cual ellos acceden a la categoría de sujetos del derecho internacional.¹⁴⁰

En nuestra opinión el Estado adquiere personalidad jurídica en un contexto normativo que lo precede y que regula sus derechos y deberes como entidad política independiente y soberana. El carácter de sujetos del derecho internacional implica la calidad de agentes generadores de éste. Por lo tanto, los procesos formales de creación de normas jurídicas internacionales serán los canales naturales mediante los cuales estos nuevos sujetos podrán propiciar cambios o modificaciones al derecho vigente. A excepción de las normas imperativas, los nuevos Estados podrán cuestionar la obligatoriedad de toda otra norma general de ese derecho a través de actos concluyentes opuestos a ella, o bien por medio de actos reiterados de protesta. Resulta indudable que una costumbre internacional que fue generada a través de conductas de un número reducido de Estados en épocas en que la sociedad internacional los tenía como exclusivos protagonistas, no podría guardar su poder vinculatorio general si la gran mayoría de los Estados recién accedidos a la independencia la rechaza inequívocamente.

Sin embargo, la actitud de los nuevos Estados ha sido en general la de aceptar las normas internacionales, cuestionando aquéllas que se presentan como resabios de la dependencia colonial o como expresión de un poder hegemónico. En este orden de cosas, la pretensión de ingresar a las Naciones Unidas, manifestada por todo nuevo Estado, implica por un acto de voluntad expresa la aceptación de normas y principios funda-

gobiernos sobre los anteproyectos preparados por la CDI, etc.; Brownlie, I, *International Law*, Stevens, 1975.

¹⁴⁰ Conf. Oppenheim, Lauterpacht, Mc Nair, Bowett, Brownlie. Tal acto es, en general, la adhesión a la independencia como resultado de la descolonización.

mentales en la vida de relación internacional y traduce una comunidad de valores.¹⁴¹

Algo similar ocurre con las resoluciones declarativas de la Asamblea General de la ONU votadas por unanimidad o por grandes mayorías, cuando ellas reformulan normas consuetudinarias de vigencia anterior a la existencia de los nuevos Estados. Entonces, éstos, ajenos a su elaboración e implementación inicial, asumen tales normas y las consolidan mediante una expresión de voluntad autónoma que concurre a la adopción de la resolución.

Cobra también importancia el actual proceso de codificación del derecho internacional pues, ya sea que a través de él se viertan en tratados normas consuetudinarias preexistentes o que se las modifique, los nuevos Estados se sienten directamente concernidos al aceptar explícitamente costumbres precedentes expresadas en la nueva convención o al participar en su reelaboración y desarrollo progresivo.

En la actualidad, una costumbre internacional *presume* la aceptación del derecho internacional por parte de los nuevos Estados.

2. La Costumbre y los Organismos Internacionales

Los Organismos Internacionales, como sujetos del derecho internacional, tienen posibilidad por medio de sus prácticas reiteradas y concordantes con las de otro organismo internacional o de uno o más Estados, de participar en la creación de normas consuetudinarias internacionales. Esta posibilidad está sujeta a las limitaciones impuestas a su condición de persona jurídica por el mismo estatuto constitutivo. Si los Estados miembros del organismo internacional han otorgado a sus órganos la facultad de obligarlos por medio de tratados, implícitamente estar a reconocida la posibilidad de aceptar ciertas prácticas concluyentes de esas organizaciones como antecedentes de una costumbre internacional.¹⁴²

Por otra parte, las conductas seguidas por los órganos de un Organismo Internacional podrán dar lugar al nacimiento de prácticas obligatorias dentro de su derecho interno. En este caso, los elementos de la costumbre que provienen de una práctica de una autoridad jerárquica, se asemejan más a la costumbre del derecho interno que a la costumbre del derecho internacional.¹⁴³

¹⁴¹ Por ejemplo, la voluntad de crear condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional puedan ser mantenidas: Preámbulo de la Carta de la ONU; y la aceptación de la solución de controversias de conformidad a los principios de justicia y el derecho internacional: art. 1.1 de la Carta de la ONU.

¹⁴² Así, por ejemplo, una práctica de las organizaciones internacionales, seguidas por éstas con el convencimiento de adecuar su conducta a una norma jurídica, establece que los acuerdos negociados por uno de sus órganos han de ser "aprobados" por el órgano plenario de la organización para que se manifieste su voluntad de obligarse por el acuerdo.

¹⁴³ Véase en el cap. III.4. Los actos de los Organismos Internacionales.

3. La codificación del derecho internacional

La incertidumbre e imprecisión de las prácticas de los Estados, como antecedentes de normas consuetudinarias, los ha conducido a tratar de efectuar una formulación más precisa y sistemática de las reglas del derecho internacional. La *codificación* es, entonces, para el derecho internacional, el proceso de ordenamiento y sistematización del derecho existente y aún del derecho deseado, formulado en un cuerpo orgánico de normas escritas.

Reuter distingue dentro del derecho internacional entre codificación científica y codificación jurídica. La primera se identifica con el resultado de la actividad académica de los doctrinarios del derecho internacional, quienes proponen la elaboración o sistematización de reglas de derecho,¹⁴⁴ y la segunda, con una actividad similar, pero realizada por los Estados y que se materializa en convenciones internacionales.¹⁴⁵

Basdevant, en su *Diccionario de la Terminología del Derecho Internacional*, da una primera definición de codificación, diciendo que es la sistematización de normas jurídicas existentes. En una segunda definición, propone a la codificación como una actividad creadora, que no sólo declara el derecho existente, sino que lo ajusta y adapta y aún reforma o completa. En una tercera definición, relaciona el concepto de codificación con todo acuerdo internacional realizado por escrito.¹⁴⁶

Los primeros intentos de codificación del derecho internacional con carácter general los encontramos en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Cabe también destacar la importante actividad codificadora realizada por las Conferencias Panamericanas de México de 1902, de Río de Janeiro de 1906, de Santiago de Chile de 1923 y la de La Habana de 1928, sobre materias tales como derecho de los tratados, neutralidad, agentes diplomáticos, etcétera.

La Asamblea de la Sociedad de las Naciones, motivada por la necesidad de armonizar el derecho internacional existente, convocó en La Haya en 1930, a una conferencia internacional sobre codificación. De los temas previstos —nacionalidad, mar territorial y responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de los extranjeros— sólo se adoptó una Convención sobre ciertas cuestiones relativas a las obligaciones militares en algunos casos de doble nacionalidad, un Protocolo referido a ciertos casos de apatridia, y un Protocolo Especial relativo a la apatridia. Con excepción de este último, los demás entraron en vigor en 1937. El sentimiento de fracaso que dejó esta Conferencia,

¹⁴⁴ Trabajos realizados, por ejemplo, por el *Institut du Droit International*, la *International Law Association* y por el *Harvard Law School Research Institute*.

¹⁴⁵ Reuter, P., *Institutions Internationales*, 6ª ed., París, Collection Thémis, 1969, pág. 158.

¹⁴⁶ Basdevant, J., *Dictionnaire de la terminologie du droit international*, París, Sirey, 1960, pág. 120.

no influenció en la intención de los Estados representados en la Conferencia de San Francisco de 1945, quienes establecieron en el art. 13, 1, a) de la Carta de la ONU que la Asamblea General "...promoverá estudios y hará recomendaciones para... impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación".

En el ejercicio de estas atribuciones, la Asamblea General de la ONU, por Resolución del 21 de noviembre de 1947 [Res. 174 (II)], creó la Comisión de Derecho Internacional integrada actualmente por veinticinco miembros de reconocida idoneidad en derecho internacional que, actuando a título personal, son elegidos por la misma Asamblea General, de tal manera que queda asegurada la representación de las más importantes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos del mundo.¹⁴⁷

El estatuto de la CDI establece, en su art. 15, que la expresión *codificación del Derecho Internacional* es usada por conveniencia, para expresar la formulación y sistematización más precisa de reglas de este derecho en aquellas áreas en donde existe una profusa práctica de los Estados, a más de precedentes y doctrina. Por su parte, la expresión *desarrollo progresivo*, implica la preparación de anteproyectos de convenciones en materias aún no reguladas por el derecho internacional o en las que no hay suficiente desarrollo del derecho a través de la práctica de los Estados.

Brierly, como miembro del Comité de Redacción del Estatuto de la CDI, expresó que toda formulación de una costumbre internacional involucra un proceso de interpretación y ajuste de las prácticas de los Estados, que de hecho va más allá de su simple sistematización.¹⁴⁸ De los debates en el Comité de Redacción del Estatuto de la CDI, como de las reiteradas discusiones en el seno de la misma Comisión, cabe hoy día interpretar la definición de codificación del art. 15 del Estatuto, no sólo en función de la sistematización del derecho existente, sino también como un proceso tendiente a su adaptación, modificación y desarrollo. La CDI ha entendido que en el proceso de codificación del derecho internacional su actividad no se limita a la mera recopilación, en forma sistematizada, del derecho vigente.¹⁴⁹

¹⁴⁷ El Comité de la Asamblea General de la ONU sobre Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional y su Codificación, al redactar el Estatuto de la CDI, debatió la necesidad de distinguir la metodología y procedimientos a seguir en cuanto a la codificación por una parte y al desarrollo progresivo por la otra. Los representantes americanos sostuvieron que la codificación debía materializarse a través de simples enunciados científicos, mientras que el desarrollo progresivo debía concretarse en la elaboración de anteproyectos de convenciones internacionales. Los representantes soviéticos ante dicho Comité sostuvieron la necesidad de elaborar anteproyectos de Convenciones internacionales, tanto en el caso del desarrollo progresivo, como en el de la codificación del derecho internacional.

¹⁴⁸ U.N. Doc. A/AC. 10/SR 6, pág. 3 y siguiente.

¹⁴⁹ *Survey of International Law in relation to the work of codification of ILC*, U.N. Doc. A/CN. 4/15 noviembre, 1948, pág. 3 y siguiente. Esta interpretación corresponde a la segunda definición de Basdevant, *op. cit.*; Ago llama a este tipo de co-

La codificación, ya sea como proceso de creación de nuevas normas jurídicas internacionales o como proceso de cristalización ordenada del derecho vigente,¹⁵⁰ no es por sí misma una fuente autónoma del derecho internacional. El concepto de legislación universal, vinculado con el concepto de codificación internacional, no guarda relación alguna con el concepto de legislación empleado en el derecho interno de los Estados.

La codificación del derecho internacional se materializa indefectiblemente en una convención internacional. Es decir, que es siempre la voluntad inmediata de los sujetos del derecho internacional —en este caso expresada en un tratado— la que crea la norma codificada.¹⁵¹ La labor de la CDI tiene sólo por objeto otorgar a los Estados bases científicamente sólidas de discusión, contenidas en anteproyectos de convenciones codificadoras, para el momento en que éstos se reúnan en una conferencia internacional.¹⁵² Cabe destacar, asimismo, que la creación de la CDI por la Asamblea General, como organismo subsidiario de ésta,¹⁵³ no comportó en modo alguno delegación de los poderes conferidos a la A. G. por el art. 13 de la Carta.¹⁵⁴

Fruto de la labor preparatoria de la CDI son las Convenciones de Ginebra sobre Derecho del Mar de 1958, la Convención de Viena de 1961

de codificación, codificación normativa: Ago, R., "La codification du Droit International et les problèmes de sa réalisation", *Mélanges en hommage à Paul Guggenheim*, Ginebra, 1968; Manley Hudson sostiene que no es posible la existencia de un proceso de codificación sin desarrollo: *ILC, 3rd. session, ILC Yearbook*, 1951, pág. 123.

¹⁵⁰ Lauterpacht, H., "Codification and Development of International Law", *A.J.I.L.* (1955), vol. 49, pág. 16 y siguiente.

¹⁵¹ La codificación del Derecho Internacional Privado solamente se relaciona con la codificación del Derecho Internacional Público por el hecho de que aquella se materializa a través de un tratado internacional: Thrilway, H. W. A., *International Customary Law and Codification*, *op. cit.*, pág. 16; Vita, *International Conventions and national conflict systems*, R.C.A.D.I., 1969, vol. 126.I, pág. 111 y siguiente.

¹⁵² En algunas oportunidades la Asamblea General considera más adecuado constituirse en conferencia internacional codificadora en vez de convocar a los estados a una conferencia especial para tal fin. Así lo ha hecho para aprobar la Convención sobre Misiones Especiales, la que figura como anexo de la Resolución 2530 (XXIV).

¹⁵³ Facultad otorgada al órgano por el art. 22 de la Carta de la ONU.

¹⁵⁴ Así es que, cuando la A.G. de la ONU lo consideró adecuado, ha creado diversas comisiones especiales con la misión de preparar anteproyectos sobre temas específicos. Tal ha sido entre otros, el caso de la Comisión sobre los Principios que Rigen las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, que preparó el anteproyecto de la Resolución aprobada por la A.G. sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre que preparó los anteproyectos de las Convenciones sobre los Principios que deben regir la Actividad de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes, sobre el Salvamento y la Devolución de los Astronautas y la Restitución de los Objetos lanzados al Espacio Ultraterrestre y sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales y la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Océánicos fuera de las Jurisdicciones Nacionales, cuyos trabajos han servido de base a los debates que se llevan a cabo en la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, la Convención sobre Misiones Especiales de 1969, la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal de 1975.

Todas estas convenciones revisten gran importancia en el derecho internacional contemporáneo. En primer lugar, aquéllas que se encuentran en vigor constituyen derecho positivo convencional para los Estados parte. Pero además, para los terceros Estados —Estados que no son parte en ellas— pueden comportar una formulación clara y precisa de las normas consuetudinarias. Así, la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas en cuanto establece, por ejemplo, la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos en el Estado ante el cual están acreditados, recoge una vieja norma de derecho internacional general. Su formulación en la Convención clarifica el contenido de la regla para los Estados que no son parte en ella. Lo mismo puede ocurrir con el contenido de las convenciones que no se encuentran en vigor. De tal modo es posible invocarlas como prueba de la costumbre.

En segundo lugar, una convención codificadora puede crear normas totalmente novedosas, cuyo contenido, al generalizarse por la aceptación de terceros Estados, genera una norma consuetudinaria posterior. En este caso, también, la norma convencional puede ser útil como prueba del contenido de la costumbre. La Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Continental constituyó en esa época un desarrollo progresivo del derecho internacional al consagrar el derecho soberano del Estado ribereño sobre los recursos del lecho y subsuelo de la zona. Actualmente, una norma consuetudinaria otorga este derecho a todo Estado.

La labor que cumple en este sentido la ONU resulta un aporte más de la organización para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales mediante la vigencia y el desarrollo del derecho.

3. LOS TRATADOS

a) Generalidades

Los tratados son, en la actualidad, la fuente creadora de normas jurídicas internacionales más importante. Las múltiples y variadas relaciones interestaduales han asumido formalmente el carácter de acuerdos expresos de voluntades. La progresiva intensificación de esos vínculos y el acrecentamiento del número de Estados han llevado a la utilización de más en más frecuente de la técnica convencional, al par que el campo cubierto por la regulación de los tratados se ha ampliado y diversificado.

En el siglo XIX se celebraron diversas convenciones multilaterales en el seno de congresos y conferencias diplomáticas: los tratados de Viena de 1815 contienen disposiciones relativas a la navegación del Rin, a la neutralidad de Suiza y a los agentes diplomáticos; el Tratado de París de 1856 estableció la neutralidad del Mar Negro y regló la navegación del Danubio; el Acta de Berlín de 1885 determinó las condiciones de la adquisición de ciertos territorios en África; las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 precisaron los medios de solución pacífica de las controversias internacionales y las normas sobre la guerra terrestre y marítima y sobre neutralidad.

A fines de ese siglo, mediante tratados, se crean las primeras organizaciones internacionales, destinadas a desenvolverse en un dominio exclusivamente técnico —la Unión Telegráfica Internacional, la Unión Postal Universal, el Instituto Internacional de Pesas y Medidas, etc.— El proceso de normativización convencional se diversifica y se prolonga en un movimiento institucional. A través de tratados se elaboran normas particulares o normas abstractas que regulan conductas futuras de los Estados, cuyas voluntades convergen en tales convenciones y se separan e individualizan una vez producidas las normas de las que son "parte". Pero también, por vía convencional, se generan organizaciones permanentes en cuyo seno se manifiesta una voluntad distinta a la de los Estados que la crearon, quienes a su condición inicial de "partes" del tratado constitutivo, unen la de "miembros" de la institución constituida.

Este proceso de institucionalización por medio de convenciones multilaterales cobra auge en el siglo actual con el establecimiento de organizaciones políticas con vocación universal: la Sociedad de las Naciones,

creada en el Tratado de Versalles de 1919 y la Organización de las Naciones Unidas estructurada en la Carta de San Francisco en 1945. Ambas instituciones —como hemos dicho— han servido a su vez de cuadro para el esfuerzo consciente de los Estados tendiente a la codificación del derecho consuetudinario vigente y a su desarrollo progresivo. Uno de los resultados de este proceso es la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.

En su preámbulo, con razón se afirma “la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales” y se reconoce “la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales”.

En un sistema jurídico como el derecho internacional, carente de un órgano institucionalizado que centralice las funciones legislativas, resulta evidente la significación jurídica de los tratados multilaterales. Ellos posibilitan la creación de normas generales y abstractas destinadas a regir la conducta de numerosos Estados, en ámbitos de importantes intereses. A través de ellos, si no en las formas, se verifica en los resultados un proceso “quasi-legislativo” que estabiliza las relaciones internacionales y enriquece el derecho internacional.

El pronunciado desarrollo de este tipo de acuerdos obedece a razones de orden práctico, derivadas de su simplicidad y de la celeridad de su procedimiento formativo si se las compara con las normas de la costumbre, pero también es consecuencia de la preferente aceptación de esta fuente por parte de los países nuevos. En la elaboración de las normas convencionales asumen ellos un rol protagónico.

1. Denominación

Es doctrinariamente posible, tomando en cuenta el contenido y la forma, determinar ciertas pautas en cuanto a la terminología comúnmente usada por los Estados para referirse a los acuerdos entre sujetos del derecho internacional. Así, generalmente se denominan convenciones a los tratados codificadores adoptados con los auspicios de la ONU; carta o pacto a los tratados constitutivos de organizaciones internacionales; acuerdos a los tratados que no se celebran por escrito.

Pero, cualquiera sea su denominación particular —convención, pacto, acuerdo, carta, convenio, declaración, compromiso, protocolo, estatuto, notas reversales, acta, reglamento, etc.—, en todos los supuestos se define a un mismo negocio jurídico generalmente identificado como “tratado internacional”.

2. Definición

En sentido amplio se ha definido al tratado como el *acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional que tiende a crear,*

modificar o extinguir derechos de este ordenamiento. Esta definición comprende no sólo a los acuerdos entre Estados sino, también, a todo acuerdo entre uno o más Estados y uno o más organismos internacionales y a los acuerdos entre dos o más organismos internacionales entre sí. También incluye a los acuerdos entre dos o más sujetos del derecho internacional celebrados en forma verbal.¹⁵⁶ Los acuerdos entre un Estado y un individuo o una corporación no son tratados sino contratos internacionales regulados por un régimen jurídico especial determinado por la voluntad de las partes contratantes, especificada en el acuerdo.

En sentido restringido y al solo efecto de la aplicación de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, tratado es todo acuerdo entre Estados, celebrado por escrito y regido por el derecho internacional.

El art. 38, 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice:

“La Corte... deberá aplicar: a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes...”

En razón de ser este artículo meramente descriptivo de las fuentes en él enunciadas descartamos toda interpretación exegética por la cual se propone a las convenciones internacionales como fuentes de obligaciones más que como fuentes de derecho. La distinción entre fuentes de derecho y fuentes de obligaciones, defendido en el ámbito internacional por Fitzmaurice y Jennings, parecería no ser válida si se parte del presupuesto de que, tanto en el orden interno como en el internacional, a todo derecho corresponde una obligación.¹⁵⁶

La doctrina soviética entiende que los tratados son la fuente primaria o fuente fundamental del derecho internacional.¹⁵⁷ Sin embargo, los tratados, como fuente creadora del derecho internacional, fundamentan su validez en una norma consuetudinaria que establece que éstos son hechos para ser cumplidos.¹⁵⁸ Esta norma es, a la vez, un principio general de derecho interno de los Estados y un principio general del derecho internacional¹⁵⁹ que asume tal categoría en razón de ser una abstracción de normas jurídicas vigentes de este ordenamiento. La norma *pacta sunt ser-*

¹⁵⁶ Conf. C.P.J.I., caso de la *Groenlandia Oriental*, Serie A/B, n° 53 - 1933, en el que este Tribunal le dio el valor de un acuerdo verbal a la Declaración efectuada por el Ministro de Relaciones Exteriores Noruego Ihlen, respondiendo a una pregunta de Dinamarca referente a este territorio.

¹⁵⁷ Jennings, R. Y., “Recent developments in the I.L.C.: its relation to the sources of international law”, *I.C.L.Q.*, 1964, pág. 385 y sig.; Fitzmaurice, G., en *Symbols of Law*, 1958, pág. 153 y siguiente.

¹⁵⁸ Tiesk y Slusser, *A.J.I.L.*, 1958, vol. 52, págs. 699-726; Tunkin, G. I., *op. cit.*, pág. 92.

¹⁵⁹ Conf., Kelsen, H., *op. cit.*, págs. 268-269.

¹⁶⁰ Véase el desarrollo del tema en el cap. II, punto 4 sobre los *Principios generales de derecho*.

vanda tiene un contenido ético que para algunos autores ius naturalistas deriva del derecho natural. Sostener que una norma positiva deriva en abstracto de un orden ético determinado no contradice el hecho de que los Estados hayan aceptado a esos presupuestos éticos como normas jurídicas internacionales. Así, la máxima *pacta sunt servanda* es una norma del ordenamiento jurídico internacional por el hecho de haber sido aceptada como tal por los Estados, independientemente de que haya sido la consecuencia, o coincida, con una regla formulada por una postura filosófica de naturaleza extrajurídica.

3. Clasificación

i) *En cuanto al número de sujetos parte en un tratado*: Los tratados pueden clasificarse en bilaterales y multilaterales. Los tratados bilaterales son acuerdos internacionales celebrados entre dos sujetos del derecho internacional. Los tratados multilaterales son acuerdos internacionales celebrados entre varios sujetos del derecho internacional. Los tratados multilaterales en cuya celebración participa un gran número o la generalidad de los Estados de la comunidad internacional se conocen con el nombre de tratados colectivos; reservándose la denominación de tratados regionales para aquéllos celebrados por un número limitado de Estados con identidad de intereses sobre una región geográfica determinada.

ii) *En cuanto a las posibilidades de acceder al tratado*: Los tratados, según permitan o no la incorporación de Estados que no han participado en la negociación, pueden ser clasificados doctrinariamente en tratados *abiertos* o *cerrados*. Estos últimos, limitados en principio a los Estados negociadores, no contienen cláusulas que permitan la incorporación de terceros Estados. Ello no obsta a que los Estados parte —una vez entrado en vigor el tratado— por un acuerdo específico, ofrezcan o negocien con terceros Estados su incorporación. Los tratados abiertos, en cambio, posibilitan la adhesión de Estados que no han participado en las negociaciones, sin que para ello sea necesario que medie una invitación expresa de los Estados parte.

En los tratados se suelen insertar distintos tipos de cláusulas referidas a la posibilidad de adhesión. En algunos, tal facultad es ilimitada; es decir, el tratado está abierto a todos los Estados indistintamente.¹⁰⁰ En otros, las posibilidades de acceder se hallan reservadas exclusivamente a ciertos Estados designados expresamente, o bien tal facultad es acordada sólo a aquellos Estados que satisfagan criterios determinados previstos en el tratado.¹⁰¹

¹⁰⁰ Tal es el caso del tratado de renuncia a la guerra (Briand-Kellog, París, 1928); el tratado de Moscú de 1963 para proscribir ensayos de armas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo la superficie de las aguas; el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Londres, Moscú, Washington, 1968).

¹⁰¹ Por ejemplo, la pertenencia a un continente o a una determinada región geográfica, criterio éste característico de los acuerdos constitutivos de organismos regio-

No hay necesariamente correspondencia entre los tratados bilaterales y multilaterales por un lado, con los tratados cerrados y abiertos, por el otro. Una convención bilateral puede ceñirse exclusivamente a los Estados negociadores o bien admitir la adhesión de terceros Estados y lo mismo ocurre con los acuerdos multilaterales.

iii) *En cuanto a las formas de celebración del tratado*: La doctrina distingue entre tratados propiamente dichos o en buena y debida forma y acuerdos en forma simplificada. Los tratados en buena y debida forma son aquellos acuerdos internacionales concluidos a través de un proceso complejo de negociación, adopción del texto, firma y ratificación. Se formulan y evidencian por medio de un instrumento único. Los acuerdos en forma simplificada —*agreements*, notas reversales— son acuerdos internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y la firma, materializándose, comunmente, en varios instrumentos separados.

Esta clasificación no produce efecto internacional alguno ya que no hay distinción jerárquica entre ambas categorías de tratados ni, en principio, diferencia de contenido. Los acuerdos en forma simplificada son frecuentes en dominios de carácter técnico o administrativo, por ejemplo, reglamentos aduaneros, aéreos o postales, pero pueden regular también cuestiones políticas de importancia.¹⁰² Los acuerdos militares —convenciones de armisticio— son también de su dominio.

Por lo demás, los distintos procesos o formas mediante los cuales los Estados se van a obligar por un tratado son materia reservada a sus respectivos ordenamientos internos. Un mismo acuerdo internacional puede, así, ser para una de las partes un tratado propiamente dicho y para la otra un acuerdo en forma simplificada.¹⁰³

iv) *En cuanto al contenido u objeto del tratado*: Desde principios de este siglo la doctrina clasificó a los acuerdos internacionales en tratados de naturaleza normativa y tratados de naturaleza contractual. Los tratados de naturaleza contractual o tratados-contrato tienen por objeto regular la realización de un negocio jurídico concreto, estableciendo obligaciones específicas para los Estados parte.¹⁰⁴ Los tratados de naturaleza normativa o tratados-ley, establecen normas generales que reglamentan las conductas

nales —Consejo de Europa, Organización de Estados Americanos, Organización de la Unidad Africana— sin perjuicio de que, a más, pueda requerirse la concurrencia de otros requisitos de índole étnico-cultural, políticos, ideológicos, etc., verificables a través de distintos mecanismos de admisión.

¹⁰² Para los EE.UU. los acuerdos de Postdam y de Yalta constituyeron "acuerdos ejecutivos".

¹⁰³ Así, por ejemplo, el Acuerdo de Ayuda Mutua Franco-Americana de 1950 es, para Francia, un tratado en buena y debida forma y, para los Estados Unidos, un acuerdo en forma simplificada.

¹⁰⁴ Por ejemplo, un tratado estableciendo un límite, un tratado de intercambio comercial de determinados productos, etcétera.

futuras de las partes.¹⁶⁵ El contenido de las voluntades vinculadas mediante un tratado-ley sería común e idéntico el resultado y en él desaparecería toda idea de efecto conmutativo. No se refieren a un caso particular o a un negocio jurídico preciso, sino que regulan abstractamente un número de casos o situaciones *a priori* indeterminadas.

Esta clasificación en cuanto al contenido u objeto de los tratados fue asimilada, por parte de la doctrina moderna, a la clasificación de los tratados en multilaterales y bilaterales. Pero no todo tratado multilateral es un tratado normativo, ni todo tratado bilateral es un tratado contrato. La confusión provocada en esta materia proviene de la actitud de aquéllos que no aceptan a los tratados como proceso formal de creación de normas jurídicas, independientemente de su contenido.¹⁶⁶ La distinción entre tratados-contrato y tratados-ley nada agrega a la naturaleza jurídica común de todos los tratados. Los tratados normativos que regulan conductas de futuro no necesariamente tendrán aplicación general o universal,¹⁶⁷ ni tampoco todo tratado bilateral será un tratado que establezca derechos y obligaciones concretas sólo para las partes.¹⁶⁸ A la vez, un mismo tratado multilateral puede contener normas de naturaleza constitucional, contractuales y normativas.¹⁶⁹ Un tratado bilateral puede establecer para las partes reglas de carácter normativo.¹⁷⁰

¹⁶⁵ Por ejemplo, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados o las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar de 1958.

¹⁶⁶ Tampoco tiene relevancia para los tratados, como proceso creador de normas jurídicas, la distinción que hacen Oppenheim-Lauterpacht entre derecho internacional universal y derecho internacional particular. Starke recoge parte de la actual doctrina anglosajona al establecer que sólo los tratados normativos pueden ser considerados fuentes creadoras de derecho internacional. Los tratados-contrato, que conciernen exclusivamente a dos o más Estados, no crean derecho internacional *per se*, sino que son la evidencia de una norma jurídica antecedente o el precedente de una futura costumbre internacional. Brierly sostiene que la única clase de tratados que pueden ser considerados fuentes del derecho internacional son los aceptados por un gran número de Estados. Esas afirmaciones de la doctrina anglo-sajona provienen de la concepción según la cual, el derecho internacional es un derecho aceptado por todos o por casi todos los miembros de la comunidad internacional. Se fundan también en la afirmación de que coexisten fuentes de obligaciones independientes de las fuentes de derecho.

¹⁶⁷ Por ejemplo, el tratado de Montevideo de 1960 constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es un tratado con objeto económico concluido exclusivamente entre los Estados de la región.

¹⁶⁸ El tratado Hay-Pauncefote de 1901 entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y el tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 entre los Estados Unidos y Panamá establecen la libertad de navegación en el Canal de Panamá.

¹⁶⁹ El Tratado de Paz de Versalles de 1919 contiene la constitución de la Sociedad de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo; normas sobre las reparaciones de guerra; y disposiciones concernientes a la navegación de ciertos ríos internacionales.

¹⁷⁰ El tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña del 8 de mayo de 1871 sobre la constitución del tribunal arbitral para el caso del *Alabama*, codificó las normas sobre arbitraje internacional, las que se conocen bajo el nombre de "Reglas de Alabama".

Las clasificaciones precedentes distan de agotar la enumeración de las clasificaciones posibles. Así, podríamos referirnos también a los tratados multilaterales restringidos, a los constitutivos de organismos internacionales, a los adoptados con los auspicios de estos organismos o en su seno. Todas ellas revisten interés doctrinario en cuanto facilitan la comprensión de las distintas formas y contenidos que pueden asumir los tratados, cuya diversidad escapa a todo intento de sistematización unitaria.

Esta fuente ha sido tradicionalmente materia regulada por normas consuetudinarias, las que han sido descriptas por la doctrina y aplicadas por la jurisprudencia. Son, de tal modo, normas de costumbre las que reglan las diversas etapas que conducen a la celebración y conclusión de los tratados, el régimen de las reservas, la interpretación, observancia y aplicación de las convenciones y las causales de su nulidad y terminación.

En razón de que estas normas consuetudinarias —en lo que se refiere a los tratados celebrados por escrito y entre Estados— han sido codificadas por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, por conveniencia metodológica han de ser estudiados a través de las disposiciones contenidas en esta Convención; pues, aunque ella no se halla aún vigente, son —en lo sustancial— expresión de normas positivas.

b) El régimen de los tratados en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados

Como ya se ha expresado, esta materia, tradicionalmente regida por el derecho consuetudinario, se encuentra codificada en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.¹⁷¹ La Convención recoge normas consuetudinarias y crea otras, totalmente novedosas, realizando, así, una verdadera labor de desarrollo progresivo del derecho internacional. Tiene su origen en un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y fue adoptada en una conferencia internacional celebrada con los auspicios de la Organización.

1. Ambito de validez de la Convención

Es preciso determinar el ámbito de aplicación de las normas contenidas en la Convención para luego analizar las disposiciones, de forma y de fondo, que ella contiene.

¹⁷¹ Esta Convención establece, en el art. 84, que entrará en vigor al trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión. De conformidad a este artículo la Convención entró en vigor el 27 de enero de 1980. Fue firmado por la Rep. Argentina el 23 de mayo de 1969 y aprobada por ley 19.865, del 3 de octubre de 1972, publicado en el Boletín Oficial del 11 de enero de 1973, y ratificado con reservas el 5 de diciembre de 1972.

a) *Ámbito de validez personal*

El art. 1º establece que será aplicable, exclusivamente, a los tratados que se celebren entre Estados; el art. 2, 1 a) define qué es lo que debe entenderse por tratado a los efectos de la Convención. Dispone, así, que "Se entiende por 'tratado' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". El primero de los elementos que aporta esta definición es la necesidad de que el acuerdo se celebre *por escrito*. Un acuerdo verbal, aun cuando las partes fuesen Estados, no estaría contemplado por la Convención. En segundo lugar, es necesario que el acuerdo se celebre *entre Estados*. Conforme con esta disposición, el art. 6 consagra la capacidad de los Estados para celebrar tratados. La expresión "regido por el derecho internacional" debe interpretarse en el sentido de que el acuerdo está destinado a *producir efectos jurídicos* en este ordenamiento. Es decir, que el elemento que debe tenerse en cuenta es la intención de las partes, incorporada en un instrumento internacional, de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en dicho ámbito jurídico. La posibilidad de que el tratado conste en *uno o más instrumentos conexos* permite incluir en el marco de la Convención cierto tipo de obligaciones, formuladas en forma unilateral, vinculadas a un tratado preexistente.¹⁷² Finalmente, la disposición analizada pone el énfasis en las características del instrumento internacional y en la voluntad de las partes en él expresada para determinar la existencia de "un tratado", al que se le aplicarán las normas contenidas en la Convención, con prescindencia de la denominación que se le asigne. En efecto, al decir *cualquiera sea su denominación particular* se evidencia que, en la práctica de las relaciones internacionales, las partes suelen utilizar, como ya se ha visto, diferentes términos para llamar a un "tratado", sin que de ninguna manera la "denominación" del instrumento influya en la determinación de su naturaleza jurídica.

La Convención no incluye una "clasificación" de los tratados del tipo de las elaboradas por la doctrina. Con ello se tiende a demostrar el carácter unitario del derecho de los tratados ya que, en última instancia, todo tratado —multilateral o bilateral, acuerdo en forma simplificada o tratado formal, etc.— es un negocio jurídico que deriva su fuerza obligato-

¹⁷² Así, por ejemplo, las declaraciones voluntarias de los Estados, formuladas en virtud del art. 36.2, del Estatuto de la C.I.J., por las que expresan reconocer como obligatoria la jurisdicción del Tribunal respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, pueden considerarse "tratados" en la terminología de la Convención. El acuerdo de voluntades quedaría perfeccionado en el momento en que el Estado deposita el instrumento de aceptación de la jurisdicción internacional con relación a todo otro Estado que hubiese efectuado una declaración similar, y constituye un "ofrecimiento" para todos los Estados que lo quieran hacer en el futuro; conf. Iglesias Buigues, José Luis, "Les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la C.I.J.: leur nature et leur interprétation", *Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht* (1972), págs. 255-288.

ria inmediata, de un preciso acuerdo de voluntades y mediata, de las normas de derecho internacional que dan tal carácter al acuerdo de voluntades. La técnica de la Convención es la formulación de la regla de manera amplia para que sea posible aplicarla a todo tipo de acuerdo; incluyendo luego, de ser necesario, una segunda norma que contemple el caso de cierto tipo de tratados.¹⁷³ La Convención se ocupa, entonces, de todo acuerdo internacional que reúna las características expresadas en el art. 2, 1.a), pero no desconoce, antes bien, afirma, el valor de otros negocios jurídicos internacionales no comprendidos en su ámbito; tales, por ejemplo, los *acuerdos verbales* o los *acuerdos tácitos*¹⁷⁴ celebrados entre Estados. El art. 3 sienta una regla general en este sentido, precisando que sus normas tampoco afectarán el valor jurídico de los acuerdos celebrados por *otros sujetos* del derecho internacional,¹⁷⁵ y que cuando fuesen partes de un tratado Estados y otros sujetos, las normas de la Convención se aplicarán a las relaciones de los Estados entre sí; afirmando de esta manera el principio de la *relatividad* de las relaciones que emergen de un tratado. El ámbito de validez personal de la Convención está limitado, entonces, a los tratados celebrados por los Estados. Cabe aún hacer una aclaración: si bien es cierto que el ordenamiento que se analiza se aplicará a todos los tratados celebrados por los Estados que reúnan las características del art. 2, 1.a) y, en consecuencia, a los tratados constitutivos de organizaciones internacionales y a los que en su ámbito adopten los Estados, tal aplicación se hará sin perjuicio de las normas pertinentes de la organización (art. 5). Es decir, que se subordinan las normas de la Convención a las normas específicas de la organización internacional; aplicando un principio general de derecho podríamos decir que,

¹⁷³ Así, por ejemplo, el art. 13 al referirse "al canje de instrumentos que constituyen un tratado" toma en consideración a los acuerdos en forma simplificada; la Sección 2 de la Parte II, sobre las reservas, es aplicable a los tratados multilaterales, etcétera.

¹⁷⁴ Los primeros deben distinguirse de los segundos ya que en ellos hay una *expresión positiva* de voluntad de las partes; en los acuerdos tácitos es sólo una de ellas quien exterioriza su voluntad en tanto que la otra se muestra pasiva, respondiendo únicamente con el silencio. La C.P.J.I. en el caso del *Estatuto jurídico de Groenlandia Oriental*, Serie A/B, n° 43, pág. 71, reconoció el valor jurídico del acuerdo verbal al admitir que la declaración hecha al ministro de Dinamarca en Oslo por el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, en nombre de su gobierno y en el marco de sus competencias, obligaba a este último país.

¹⁷⁵ Por vía de interpretación de esta norma cabe decir que se acepta en la Convención la posibilidad de que otros sujetos del derecho internacional, que no sean los Estados, tengan la capacidad jurídica de celebrar tratados. La Conferencia recomendó a la Asamblea General de la ONU que ésta encomendase a la C.D.I. la elaboración de un proyecto de convención sobre los tratados negociados entre Estados y organizaciones internacionales o entre estas últimas. La Asamblea General aceptó esta recomendación y ese mismo año giró el tema a la C.D.I., la que, a partir de 1970, se ocupa de él. Sin embargo, esta norma no debe ser pensada como aplicable sólo a las organizaciones internacionales, sino que también podría considerarse la posibilidad de que, por ejemplo, "grupos beligerantes" celebren acuerdos internacionales.

en este caso, la norma especial deroga o modifica la norma general. Preciso es destacar que la disposición del art. 5 se refiere a los tratados específicamente adoptados en el ámbito de la organización y no a los celebrados con los auspicios o sobre la base de proyectos preparados por la organización internacional.¹⁷⁶

b) *Ámbito de validez temporal*

La Convención —conforme a lo establecido en su art. 4— se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de su entrada en vigor con respecto a tales Estados. Fija, así, el principio de la *irretroactividad* de la convención. Pero si tomamos en cuenta una de las características del derecho internacional, aquella según la cual una misma formulación puede ser norma *convencional* para ciertos Estados y norma *consuetudinaria* para otros,¹⁷⁷ vemos que en la medida en que la Convención recoge normas consuetudinarias, estas normas continuarán produciendo efectos jurídicos para los Estados que no lleguen a ser parte en ella: la fuente de sus derechos y obligaciones no se encontrará entonces en el tratado, sino en la costumbre. Congruente con esta característica del ordenamiento jurídico internacional, el artículo que es motivo de análisis, luego de fijar el principio de la irretroactividad, admite que ciertas disposiciones enunciadas en la Convención se apliquen a tratados celebrados por Estados con relación a los que ella no haya entrado en vigor, siempre que dichos tratados estén sometidos a tales disposiciones en virtud del derecho internacional general.

La característica que ahora se pone de relieve había sido ya tomada en cuenta en el art. 3, cuando la Convención se ocupa sucesivamente de los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos del derecho internacional; entre esos otros sujetos; y de los acuerdos internacionales no celebrados por escrito. El hecho de que estos acuerdos no es-

¹⁷⁶ Se podría pensar, por ejemplo, en los Convenios adoptados en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo.

Tal el caso de esta Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados que se ha adoptado en una Conferencia internacional celebrada con los auspicios de la ONU y sobre la base del proyecto preparado por la C.D.I.

¹⁷⁷ La República Argentina no es parte en la Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental que define jurídicamente la zona en el art. 1º; sin embargo, esta definición tiene validez para ella en tanto que norma consuetudinaria. La prueba de la norma podría encontrarse en la ley 17.094 (A.D.L.A., XXVI-C, pág. 1674) que, en términos idénticos, hace suyo el concepto en el art. 2º. La C.I.J. tuvo la oportunidad de ocuparse de la posibilidad de creación de una norma consuetudinaria a partir de una norma convencional y de la recepción de una norma consuetudinaria por una norma convencional en el caso de la *Plataforma Continental del Mar del Norte*, *Recueil*, 1969, §§ 60 a 82. En esta ocasión se discutía si el art. 6 de la Convención sobre Plataforma Continental era oponible a la República Federal de Alemania, que no había manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, en tanto que norma consuetudinaria. La Corte rechazó esta tesis sostenida por Dinamarca y los Países Bajos "aun cuando fuese justa en lo que concierne al menos a ciertas partes de la Convención" (§ 62).

tén regulados por la Convención, no obsta a que se les apliquen cualesquiera de las normas en ella enunciadas, a las que estuvieran sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención. El art. 38, ubicado en la sección relativa a los tratados y los terceros Estados —en la que se establece el principio de que los tratados sólo producen efectos para las partes— reconoce, sin embargo y en modo congruente con lo expresado, que una norma enunciada en un tratado puede llegar a ser obligatoria para terceros Estados como norma consuetudinaria. Finalmente, una de las disposiciones generales referidas a la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados (art. 43) dispone que en estos casos nada menoscabará el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado que ha sido declarado nulo, ha terminado o se encuentra suspendido en su aplicación, a la que esté sometido en virtud del derecho internacional, independientemente de ese tratado.

Es decir, entonces, que si bien en principio la Convención, luego de su entrada en vigor, sólo regirá aquellos tratados que celebren los Estados por escrito, ciertas disposiciones —las que están formuladas en normas consuetudinarias preexistentes o las que hayan de formularse en normas consuetudinarias nacidas a partir de ella— serán aplicables a todos los tratados con independencia de la vigencia de la Convención.¹⁷⁸

c) *Ámbito de validez territorial*

Aun cuando la Convención no contiene ninguna disposición referida al ámbito de validez territorial de sus normas, el derecho internacional general regula la cuestión. Conforme a éste, un tratado en vigor será obligatorio para las partes sobre la totalidad de su territorio. La misma Convención recoge esta norma consuetudinaria en el art. 29 sobre el ámbito territorial de aplicación de los tratados. Cabe destacar que el territorio es un elemento del Estado que comprende no solamente el territorio en sentido geofísico sino, también, todos aquellos espacios que estén sometidos a su jurisdicción.¹⁷⁹ En el período entre las dos guerras mundiales la práctica internacional entendía que, para que un tratado fuese aplicable al territorio colonial de un Estado parte, era necesario una declaración expresa en tal sentido. Los tratados no se extendían, de pleno derecho, a las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, los debates sostenidos en el seno de ONU permitieron invertir la presunción existente en el período anterior. De allí que, en ausencia de una "cláusula colonial", o de otra indicación en contrario, hay que presumir que un tratado se aplica a todos los territorios de los cuales son internacionalmente responsables los Estados parte. La práctica, en materia de sucesión de Estados, confirma esta norma general. Los nuevos Estados parti-

¹⁷⁸ Tal el caso, por ejemplo, del art. 26 según el cual "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" que recoge la norma consuetudinaria enunciada como *pacta sunt servanda*.

¹⁷⁹ Mar territorial, espacio aéreo, aguas interiores.

cipan, como parte, en una serie de tratados, mediante una *notificación de sucesión* basada en el consentimiento de la antigua metrópoli, sin que los tratados en cuestión hayan sido previamente extendidos a sus respectivos territorios en virtud de una notificación especial fundada en una "cláusula colonial" o sin que el tratado estipule, expresamente, tal extensión. El art. 29 debe interpretarse en el sentido de que los tratados se aplican a la totalidad del territorio de cada parte, independientemente de que se trate de territorios metropolitanos o dependientes. Este artículo no pretende prejuzgar sobre los problemas que se pueden plantear con relación a la sucesión de Estados en los tratados, tema que, por otra parte, está expresamente excluido del ámbito de la Convención por la disposición del art. 73.¹⁸⁰

2. La conclusión de los tratados

Luego de establecer el ámbito de aplicación de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, corresponde considerar todos aquellos actos que son necesarios en las relaciones internacionales para celebrar un tratado, manifestar el consentimiento en obligarse por éste, modificar o excluir los efectos jurídicos de algunas de sus disposiciones en su aplicación con un Estado parte, hasta la entrada en vigor del tratado.

a) Etapas conducentes a la celebración del tratado

i) *La negociación*: Cuando un Estado desea relacionarse con otro mediante un tratado designa una o varias personas para que lo representen con tal fin. A éstas les otorga los "plenos poderes", documento emanado de la autoridad competente del Estado, para iniciar las conversaciones tendientes a fijar el acuerdo de voluntades. La Convención acepta, en el art. 7, que en virtud de sus funciones representan al Estado, sin necesidad de presentar plenos poderes, los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores. Estas personas pueden, inclusive, obligar al Estado. También se considera que los jefes de las misiones diplomáticas y los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, en virtud de sus funciones, representan al Estado ante el Estado, la conferencia internacional, organización internacional u órgano en el que están acreditados, según sea el caso. En estos supuestos, sin embargo, estas personas sólo pueden negociar y adoptar el texto del tratado sin necesidad de autorización especial, pero no pueden ni autenticar

¹⁸⁰ Esto no debe interpretarse, sin embargo, en el sentido que el principio de los límites movedizos de los tratados se encuentre excluido del marco del art. 29. El principio está involucrado en la norma, pero referido a las "partes". Así, el tratado será aplicable a la totalidad del territorio de cada una de ellas en cada momento de su duración y no a la totalidad del territorio de las partes al momento de su celebración.

el texto ni obligar al Estado acreditante. Los plenos poderes no requieren un acto bajo forma sacramental, pueden constar en una carta o, aún, ser otorgados mediante un telegrama.

ii) *La adopción del texto*: Tiene por fin dar por terminada la etapa de la negociación. Es el momento en que los representantes de los Estados negociadores fijan los términos del acuerdo de voluntades redactando el texto del tratado. Este se adopta cuando todos los negociadores expresan su consentimiento con la redacción (art. 9, 1.). Sin embargo, cuando la negociación se ha llevado a cabo en el seno de una conferencia internacional bastará que dos tercios de los Estados presentes y votantes manifiesten su conformidad con el texto para que éste se considere adoptado. Esta norma (art. 9, 2.), tiene su origen en la práctica desarrollada en las conferencias celebradas con los auspicios de la ONU. En todas, con la sola excepción de la III Conferencia sobre el Derecho del Mar,¹⁸¹ el Reglamento de la Conferencia, preparado por la Secretaría General de la ONU y adoptado por los Estados negociadores al comienzo de cada una de ellas, establecía que el tratado se adoptaría por votación, necesitándose un pronunciamiento afirmativo de los dos tercios de los Estados presentes y votantes. Ahora bien, estas dos normas tienen una naturaleza residual; es decir, que se aplicarán si los Estados negociadores no llegan a un acuerdo especial para fijar otro mecanismo de adopción del texto con relación a un tratado determinado. Debe recordarse, también, lo ya dicho cuando nos referimos al ámbito de validez de la Convención de Viena con relación al principio general de derecho contenido en el art. 5 según el cual la norma especial deroga o modifica la norma general. Así, en el caso de una convención adoptada en el seno de una organización internacional, que prevea un mecanismo especial, la norma de la organización prima sobre la contenida en el art. 9.¹⁸²

iii) *Autenticación del texto*: Es el acto por el cual los negociadores establecen mediante su firma, su firma *ad referendum*, o su rúbrica, que el texto que tienen a la vista es aquél que ellos han adoptado y hace plena fe. También en este caso los negociadores pueden, en un supuesto determinado, acordar otro mecanismo para la autenticación si lo consideran más adecuado. Igualmente, si se trata de un convenio adoptado en el seno de una organización internacional, deberán seguirse para su autenticación los ritos establecidos por ella.¹⁸³ En la práctica de la ONU es dable encontrar tratados que han sido autenticados mediante la incorpo-

¹⁸¹ En la segunda parte de esta conferencia, celebrada en Caracas en 1974, los Estados negociadores establecieron que el tratado que se adopte lo será por consenso.

¹⁸² En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el art. 19, 2 de su tratado constitutivo establece que los convenios quedarán adoptados por el voto afirmativo de la mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes.

¹⁸³ En el caso de la organización precedentemente citada, el art. 19, 4 del tratado constitutivo establece que "El Presidente de la Conferencia y el Director General autenticarán, con sus firmas, dos copias del convenio..."

27

ración a una Resolución de la Asamblea General.¹⁸⁴ Finalmente, en las conferencias internacionales, el texto del tratado se incorpora al Acta Final siendo este instrumento firmado por representantes de los Estados negociadores en la conferencia. Esta firma es la que autentica el texto y establece, por tal vía, la reciprocidad del consentimiento acordado en el texto del tratado.

b) *Formas de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado*

Con la autenticación del texto, el acuerdo de voluntades de los negociadores queda definitivamente fijado, pero es necesario para que el tratado entre en vigor que, además, los Estados manifiesten expresamente la voluntad de obligarse por aquél. Los arts. 11 a 15 de la Convención de Viena enumeran, en forma enunciativa, los diferentes mecanismos que, con tal fin, pueden seguir los Estados. Estas disposiciones no incluyen una norma residual que pueda aplicarse para establecer la vía a seguir cuando el tratado mismo no contempla una cláusula en la que los Estados negociadores hayan acordado el modo en que van a expresar el consentimiento. La incorporación del art. 11 al texto del tratado, efectuada en la Conferencia de Viena, muestra bien a las claras la intención de los Estados negociadores de no fijar un método, en detrimento de otros, en el caso de silencio de un convenio determinado. Durante el primer período de la Conferencia, el representante del Uruguay —Alvarez— sostuvo la tesis de que la norma supletoria debía ser la *ratificación* a fin de salvaguardar los distintos sistemas internos. El representante del Reino Unido —Sir Francis Vallat— expresaba, en cambio, que la práctica de su país era la de considerar la *firma* como suficiente manifestación del consentimiento, cuando el tratado no disponía otra cosa. Es decir, que por idéntico fundamento —la preservación del orden jurídico interno— el representante del Reino Unido llegaba a un resultado inverso.¹⁸⁵ Cuando se procede a la votación, el principio de la ratificación es rechazado y la conferencia resuelve adoptar el texto del actual artículo 11 que, si bien no soluciona expresamente el problema de la norma supletoria, da flexibilidad al sistema, remitiéndose a la voluntad de los Estados negociadores.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Tal es el caso de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre Misiones Especiales, etc. En este supuesto no media firma alguna en el texto, quedando autenticado mediante la simple votación de la Resolución que lo contiene.

¹⁸⁵ A/CONF. 39/11, *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Documentos Oficiales de la Primera Sesión, Sesión 16, 8/4/1968.

¹⁸⁶ El art. 11 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados expresa "Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido".

i) *La firma*: La firma del tratado tiene por objeto autenticar el texto; pero, además, los Estados negociadores pueden acordar que baste para expresar el consentimiento en obligarse (art. 12). Puede tener lugar en el acto de la adopción del texto o, en el caso de ciertos acuerdos multilaterales, diferirse hasta una fecha determinada¹⁸⁷ a fin de que los Estados negociadores, u otros Estados invitados especialmente para ello, puedan también firmar el texto. La expresión del consentimiento mediante la firma es típica de los llamados "acuerdos en forma simplificada". A diferencia de la ratificación, la *confirmación de una firma ad referendum* no constituye la confirmación del tratado en sí, sino, simplemente, de la firma. En consecuencia, la confirmación da al Estado la calidad de signatario a partir de la fecha de la firma.¹⁸⁸

ii) *El canje de instrumentos que constituyen un tratado*: El art. 13 de la Convención se refiere a los acuerdos en forma simplificada; particularmente, a la práctica desarrollada entre los Estados de instrumentar acuerdos por "notas reversales". Mediante éstas un Estado propone a otro un determinado tratado, el Estado receptor contesta manifestando su consentimiento en una nota en la que se acusa recibo de la primera y en la que, generalmente, se transcribe íntegramente el texto.¹⁸⁹

iii) *La ratificación*: Es el *acto internacional* mediante el cual el Estado manifiesta en forma definitiva su voluntad de obligarse por el tratado. Lo hace en una declaración escrita denominada "instrumento de ratificación". Se considera que la obligación jurídica nace a partir del momento en que los Estados negociadores *canjean* estos instrumentos, dejando constancia de tal hecho en un acta, o a partir del momento del *depósito* del instrumento ante la persona designada para tal función en el cuerpo del tratado. Desde que el Estado *negociador* da su consentimiento y hasta el momento en que el tratado entra en vigor con relación a tal Estado, —lo que no tiene por qué, necesariamente, coincidir en el tiempo—, este Estado se denominará *Estado contratante*. El acto internacional de ratificación no debe confundirse con el *acto interno* de aprobación del tratado que puede dar un órgano del Estado, competente para tal fin según el derecho interno, y que

¹⁸⁷ La Convención de Viena sobre Relaciones consulares fue firmada por 32 Estados en el acto de la ceremonia de clausura de la conferencia, el 24 de abril de 1963. En virtud del art. 74 quedó abierta a la firma hasta el 31 de octubre del mismo año en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Viena y hasta el 31 de marzo de 1964 en la sede de la ONU. En este caso la firma tenía como único objeto autenticar el texto, puesto que la Convención exige la ratificación como forma de expresar el consentimiento en obligarse.

¹⁸⁸ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9 (A/6309/Rev. 1), págs. 30-31.

¹⁸⁹ Los acuerdos entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre medidas para facilitar el comercio y el transporte de mercaderías entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, y sobre abastecimiento y comercialización de productos de Y.P.F. en las Islas Malvinas se instrumentaron, ambos, en notas reversales del 13-IX-1974 que entraron en vigor ese mismo día.

72

en algunos ordenamientos es requisito previo al acto internacional.¹⁹⁰ Tradicionalmente, la ratificación era un acto formal destinado exclusivamente a que el soberano confirmase los plenos poderes conferidos a su representante en las negociaciones. No se trataba, entonces, de una aprobación del tratado sino de confirmar que el plenipotenciario estaba realmente autorizado para negociar y comprometer al Estado. Luego, la ratificación cambió de sentido y su fin fue el de permitir el control por el Legislativo de los actos del Ejecutivo. El art. 14, 2. de la Convención se refiere a la *aceptación* y a la *aprobación* expresando que ambas también podrán ser utilizadas como modos de manifestación del consentimiento del Estado en condiciones semejantes a las que rigen la ratificación. En la práctica internacional la "aceptación" constituye una innovación de terminología más que de método. Si un tratado establece que estará abierto a la firma bajo reserva de ratificación, el procedimiento en el plano internacional, es similar al de la firma bajo reserva de "aceptación". Si un tratado dispone que estará abierto a la "aceptación" sin firma previa, este procedimiento es similar al de la adhesión. El mismo término designa, entonces, dos procedimientos diferentes que, en definitiva, pueden considerarse como una forma simplificada de ratificación. El término "aprobación" se ha incluido aún más recientemente en la práctica internacional y lo expresado con relación a la aceptación es aplicable también a éste.¹⁹¹

iv) *La adhesión*: Es la facultad que se ofrece a un tercer Estado, un Estado que no ha participado en la negociación, de llegar a ser parte en el tratado. El ofrecimiento es necesario en todos los tipos de tratados, sea cual fuere su objeto.¹⁹² Es decir que, interpretando el art. 15 a *contrario sensu*,

¹⁹⁰ La Constitución Argentina en el art. 86, inc. 14, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de negociar tratados con las potencias extranjeras, pero los tratados así negociados deben someterse al Congreso para su aprobación (art. 67, inc. 19, C.N.). Esta se efectúa formalmente mediante la sanción de una *ley* que, luego de ser promulgada, se publica en el *Boletín Oficial*. Recién después de la aprobación por el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo está autorizado a ratificar y canjear o depositar, según sea el caso, el instrumento internacional de ratificación del tratado concluido en buena y debida forma.

¹⁹¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9 (A/6309/Rev. 1), págs. 31-33.*

¹⁹² Tanto en la C.D.I. como en la Conferencia, se planteó el problema de la posibilidad de establecer una norma que autorizase a *todos los Estados* a adherir a los tratados multilaterales generales, sin necesidad de ofrecimiento expreso. El fundamento de esta moción se basaba en el hecho de que, en general, los tratados multilaterales tienen por objeto crear normas objetivas de codificación por las que sería deseable que el mayor número posible de Estados se vinculase. De esta manera, sostiene la doctrina soviética, se obtendría un margen más amplio de seguridad en las relaciones internacionales. La doctrina occidental afirma, en cambio, que este tipo de tratados está abierto a la participación de un gran número de Estados mediante la cláusula usual en las convenciones adoptadas con los auspicios de la ONU, según la cual estos tratados están abiertos a la adhesión de "todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la

un Estado que no ha participado en la negociación no puede *imponerse* como parte en el tratado. En el texto de los tratados se establece, usualmente, quiénes son los sujetos del derecho internacional que pueden adherir. Se denomina tratado "abierto" al que contiene una cláusula de adhesión y tratado "cerrado" al que no contiene tal cláusula. En realidad un tratado plasma un acuerdo de voluntades sobre un *determinado objeto* entre *ciertos Estados*. El consentimiento, entonces, se otorga con relación al objeto y con relación a las partes. Ahora bien, tal como lo autoriza el artículo 15, c) es posible que el tratado no contenga disposición alguna referida a la capacidad de otros Estados para adherirse; sin embargo, si todas las partes se ponen de acuerdo para invitar a un determinado Estado a adherir al tratado, éste tiene la facultad jurídica de hacerlo. La terminología de la convención permite inferir que basta que la invitación la formulen los *Estados parte*, es decir, aquéllos que han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, que no necesariamente son todos *Estados negociadores*. Además, al hablar de Estado parte, la convención se está refiriendo a un *tratado en vigor* para aquéllos que formulan la invitación. En consecuencia, ésta se hará por acuerdo de partes sin necesidad del consentimiento para tal acto de los Estados negociadores —aquéllos que aún no han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado—, ni de los *Estados contratantes* —aquellos que ya han manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, pero con relación a los que el tratado aún no ha entrado en vigor.

c) *Determinación del momento en que nace el vínculo jurídico*

Si el tratado dispone que el consentimiento se expresará mediante la firma, es en el momento de ésta cuando los Estados se obligan. En los supuestos de tratados bilaterales que necesitan ratificación, la obligación nace en el momento en que los Estados canjean los instrumentos internacionales

Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la Convención". Esta fórmula, conocida con el nombre de *fórmula de Viena*, fruto de la negociación, es la que contiene, por ejemplo, el art. 83 de la Convención que estamos estudiando. Véase al respecto los debates en los *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Segundo período de sesiones, págs. 28-29, 198-206, 209-215 y 242-266. El texto propuesto en la Conferencia, como artículo 5 bis de la Convención, por Argelia, Ceilán, Hungría, India, Malí, Mongolia, República Árabe Unida, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Siria y Yugoslavia decía: "*Derecho a participar en los tratados*. Todos los Estados tienen derecho a participar en tratados multilaterales generales de conformidad con el principio de la igualdad soberana". Cabe destacar que, posteriormente, al adoptarse en Viena el 14 de marzo de 1975, con los auspicios de la ONU, la Convención sobre representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, entre sus cláusulas finales el art. 88 expresa: "La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier Estado...". Es decir, que para este tratado, y luego de adoptado el art. 15 de la Convención sobre el derecho de los tratados, los Estados negociadores optaron por la fórmula "todos los Estados".

de ratificación. Los Estados proceden a labrar un acta en la que dejan constancia del canje; la fecha en que éste se realiza es la fecha en que nace la obligación, salvo que el tratado mismo disponga otra cosa. En los supuestos de tratados multilaterales es usual que los Estados negociadores, en el texto del tratado, designen una persona que se ocupará de la guarda del texto original y recibirá los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.¹⁹³ La fecha del depósito del instrumento internacional ante tal persona es la que traduce el consentimiento en obligarse. El art. 18 de la Convención, de neto desarrollo progresivo del derecho internacional, es fuente, sin embargo, de una obligación especial desde el mismo momento de la firma del tratado, aún cuando fuese necesaria la ratificación posterior para que el Estado se obligue en los términos del tratado. Esta obligación especial, que pesa sobre los Estados negociadores y que se extiende a los contratantes, es la de no realizar actos que frustren el objeto y el fin del tratado. Esto indica que una vez que la Convención de Viena entre en vigor, los Estados parte en ésta deberán ser sumamente cuidadosos de los actos que realicen una vez que hayan celebrado un tratado, debiendo valorar todos los elementos y los objetivos de sus políticas internas e internacionales con el objeto de no realizar actos contrarios al fin del tratado antes de manifestar expresamente si van o no a obligarse por él. De otra manera verían comprometida su responsabilidad internacional.

d) Reservas

Las reservas son las declaraciones unilaterales que hacen los Estados, *en el momento de obligarse por el tratado*, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de éste en su aplicación al reservante. Obedecen, generalmente, a la oposición que encuentran algunas cláusulas del tratado en el órgano interno del Estado encargado de autorizar el consentimiento. La Convención, en el art. 19, consagra, como principio general, que los Estados pueden formular reservas a los tratados, salvo que éstas estén expresamente prohibidas en el texto o que sean incompatibles con el objeto y el fin perseguidos. Este principio, tan amplio, no hace muchos años que es aceptado en la práctica de las relaciones internacionales. En la época de la Sociedad de las Naciones se consideraba que era necesario preservar el tratado en su integridad. De este modo, para que un Estado reservante pudiese ser considerado parte en el tratado era necesario que todos los Estados parte aceptasen la reserva. Este principio de la unanimidad de la aceptación fue aplicado por el Secretario de esa Organización en su carácter de depositario de tratados internacionales. Sin embargo, en el ámbito interamericano, la Conven-

¹⁹³ En el caso de los tratados celebrados con los auspicios de la ONU es práctica designar como depositario al Secretario General de la Organización. Así, por ejemplo, en el caso de esta Convención, los arts. 82 y 83 determinan que tanto los instrumentos de ratificación como los de adhesión "se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas".

ción de La Habana de 1928 disponía que en los tratados internacionales celebrados entre diversos Estados la reserva hecha en el acto de la ratificación sólo afectaría la aplicación de la cláusula respectiva en las relaciones entre los Estados parte. El rechazo de la reserva no impedía la entrada en vigor de la Convención entre los Estados parte. Es decir, que una vez efectuada la reserva, aun cuando ésta fuera objetada, el tratado entraba en vigor y el Estado reservante era considerado parte en el tratado. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana aprobó provisoriamente las reglas preparadas en 1932 por una Comisión especial. En ellas se establecía que un tratado entrará en vigor en la forma en que fue firmado entre los Estados que lo ratifiquen sin reserva; cuando se formulan reservas, entrará en vigor entre los que acepten las reservas y el reservante con el alcance establecido por la reserva; y no entrará en vigor entre el Estado reservante y aquél que no acepte la reserva. Al menos uno de los Estados parte en el tratado tenía que aceptar la reserva, para que el reservante pudiese ser considerado parte en el tratado. Estas tres normas constituían la base del Sistema Panamericano. Hasta 1952, la práctica del Secretario General de la ONU, cumpliendo funciones de depositario, era similar a la que aplicaba la Sociedad de las Naciones.

Al adoptarse la *Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio*, el Secretario General de la ONU recibió ciertas ratificaciones con reservas. Esto planteaba el problema de saber si las reservas que no habían sido aceptadas podían ser válidas y, en consecuencia, computar las ratificaciones así formuladas para determinar la entrada en vigor del tratado. Este tratado necesitaba un número mínimo de ratificaciones para poder entrar en vigor.¹⁹⁴ El Secretario General hace saber la cuestión a la Asamblea General, la cual resuelve pedirle una opinión consultiva a la C.I.J. Esta, destacando que su respuesta tiene en miras solamente la convención en cuestión, en la que, por su naturaleza, es deseable que participe el mayor número posible de Estados, expresa que ningún Estado puede ser obligado sin su consentimiento, por lo que la reserva que se formula será válida, exclusivamente, para aquéllos que la acepten. Dice la C.I.J.: "Se puede considerar, igualmente, como un principio reconocido que toda convención multilateral es el fruto de un acuerdo efectuado libremente en lo que concierne a sus cláusulas y que en consecuencia no puede corresponder a ninguno de los contratantes destruir o comprometer lo que es el objeto o la razón de ser de la convención". La Corte llega a la conclusión de que la apreciación de toda reserva, y de los efectos de las objeciones que se le puedan hacer, depende de las circunstancias particulares de cada caso, pero que la reserva debe ser compatible con el objeto y el fin de la convención. El autor de las

¹⁹⁴ Es usual que cierto tipo de convenciones multilaterales requieran un número mínimo de ratificaciones para su entrada en vigor; así, por ejemplo, la Convención que estamos estudiando exige, en el art. 84, 35 ratificaciones o adhesiones para su entrada en vigor.

812

reservas objetadas por algunos de los contratantes es considerado, sin embargo, como parte en la convención en las relaciones con aquéllos que las han aceptado. La Asamblea General, al recibir la respuesta de la C.I.J., pide al Secretario General que, en lo concerniente a la Convención en cuestión, se atenga a la opinión consultiva y con relación a las demás Convenciones que se celebren en el futuro y de las que él sea designado depositario, no se pronuncie sobre el efecto jurídico de las reservas que se formulen, limitándose a comunicarlas a todos los Estados interesados, dejando que cada uno de ellos lo haga.¹⁹⁵

El sistema incorporado a la Convención por el art. 19 sigue, entonces, el criterio sostenido por la C.I.J. estableciendo, como norma subsidiaria para el caso de silencio del tratado, la posibilidad de efectuar reservas siempre que no sean contrarias a su objeto y a su fin. Se considerará que la reserva ha sido aceptada tácitamente si no se ha formulado ninguna objeción dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que se haya manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última fecha es posterior (art. 20, 5.). El Estado reservante será considerado como parte en el tratado cuando al menos uno de los Estados contratantes acepte la reserva expresa o tácitamente [art. 20, 4.a) y c)]. La reserva produce los efectos jurídicos deseados sólo entre el Estado reservante y aquéllos que la acepten: con relación a éstos, de una declaración unilateral pasa a ser un verdadero acuerdo de voluntades.¹⁹⁶ Si uno de los Estados interesados considera que la reserva no es válida puede *objectarla*; esto no impedirá, sin embargo, la entrada en vigor del tratado entre el Estado reservante y el Estado objetante, entendiéndose en tal caso que las disposiciones a que se refiere la reserva no se aplicarán entre los dos Estados en la medida que ella determina [arts. 20, 4. y 21, 3.]. Para que el tratado no entre en vigor entre ambos es necesario que el Estado que formula la objeción se oponga inequívocamente a tal hecho [art. 20, 4.b) *in fine*]. La Convención mantiene en un solo supuesto el *principio de la unanimidad* en la aceptación de la reserva para que el reservante pueda ser considerado parte en el tratado: es el supuesto de los tratados multilaterales restringidos.¹⁹⁷ Finalmente, en el caso de que se trate de un

¹⁹⁵ C.I.J., opinión consultiva sobre las *Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio*, Recueil, 1951, págs. 21, 23 y 24. En la práctica ulterior, el Secretario General hizo saber a los Estados interesados los instrumentos conteniendo reservas que recibía, fijándoles un plazo para la respuesta, transcurrido el cual las consideraría aceptadas tácitamente. En 1959 la Asamblea General imparte instrucciones al Secretario para que actúe de idéntico modo no sólo con relación a las convenciones celebradas después de 1952 sino, también, con todas aquéllas que se celebren con los auspicios de la ONU.

¹⁹⁶ Este acuerdo de voluntades constituiría un "tratado". Conforme a la definición contenida en el art. 2, 1.a) de la Convención, le serían aplicables sus disposiciones, de mediar aceptación por escrito.

¹⁹⁷ El art. 20, 2. dispone "Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado

tratado constitutivo de una organización internacional, la validez de la reserva queda subordinada a la aceptación por parte del órgano competente de la organización (art. 20, 3.). La Convención no prevé un mecanismo para la solución de la controversia que se plantea entre el Estado reservante y aquéllos que objetan la validez de la reserva o la objetan y se oponen a la entrada en vigor del tratado, por lo que los Estados, en tal supuesto, quedan sujetos, solamente, a la norma de derecho internacional general que los obliga a solucionar pacíficamente sus controversias por la vía que consideren más adecuada. Una reserva y una objeción a una reserva pueden retirarse en cualquier momento, salvo que el tratado disponga otra cosa (art. 22). La reserva y todos los demás instrumentos referidos a ella —aceptación expresa u objeción— deben formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a todos aquéllos que pudiesen llegar a ser parte en el tratado (art. 23, 1.). Cuando un Estado contratante o parte en un tratado ha efectuado una reserva, los Estados que con posterioridad manifiesten su consentimiento en obligarse por el tratado deben, en ese momento, formular las objeciones que pudiesen tener con relación a la reserva y, en su caso, oponerse inequívocamente a la entrada en vigor del tratado entre ellos y el reservante (art. 20, 5. *in fine*).

e) Entrada en vigor y aplicación provisoria

El art. 24 de la Convención establece que un tratado entrará en vigor cuando todos los Estados negociadores hayan expresado el consentimiento en obligarse por el mismo, a menos que el propio tratado disponga otra cosa. Sin embargo, hay ciertas disposiciones del tratado —las llamadas *disposiciones finales*— referidas a la autenticación del texto, la forma de manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado, las modalidades o la fecha de entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario, etc., que por su naturaleza y el objeto que persiguen, son aplicables desde la adopción del texto (art. 24, 4.). Los Estados dan su consentimiento para que estas disposiciones entren en vigor en el momento mismo en que adoptan el texto del tratado.¹⁹⁸

La entrada en vigor de un tratado no implica, necesariamente, su aplicación. Las dos situaciones pueden coincidir o no en el tiempo. Así, los tratados concluidos para el caso de conflictos armados, sólo se aplican

en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes". También en este caso la aceptación puede ser tanto tácita como expresa (art. 20, 5.).

¹⁹⁸ Estas disposiciones son aplicables aún en el supuesto del art. 9, 2, en el que el texto se adoptará por mayoría de los dos tercios, en razón de ser inherentes a la mecánica de la puesta en vigor del tratado en sí.

cuando ellos se producen.¹⁹⁹ También puede ocurrir que un tratado prevea su *aplicación provisoria*, antes de su entrada en vigor. Tal situación está contemplada en el art. 25 de la Convención. Este tiende a regular un acuerdo colateral de los Estados negociadores por el que, sea en el mismo tratado, sea de toda otra manera, éstos han convenido la posibilidad de aplicarlo antes de su entrada en vigor. La participación en este acuerdo colateral o accesorio está sometida a la condición resolutoria de llegar a ser parte o no en el tratado. Es decir, que el Estado dejará de ser parte en el acuerdo colateral en el momento en que manifieste su consentimiento en obligarse por el tratado o exprese su intención, notificándola a los demás Estados entre los que el tratado se aplica en forma provisoria, de no llegar a ser parte de éste. La posibilidad de la terminación del acuerdo en forma unilateral, tiende a subrayar el carácter provisorio de la aplicación del tratado; sin embargo, esto no menoscaba en nada el hecho de que el acuerdo accesorio, mientras esté en vigor, obligue a las partes en los términos de la norma contenida en el art. 26.

3. Observancia y aplicación de los tratados

Una vez que el tratado ha quedado concluido y entra en vigor, es fuente de derechos y obligaciones para los Estados parte. La fuerza obligatoria *inmediata* reside en la voluntad de obligarse por el tratado, pero el fundamento de validez *mediato* se encuentra en una norma consuetudinaria comúnmente enunciada como *pacta sunt servanda*. El art. 26 de la Convención la consagra disponiendo que todo *tratado en vigor* obliga a las partes de *buen fe*. El elemento de la *fides* era considerado ya en el derecho romano como fuente del carácter obligatorio de las convenciones internacionales.²⁰⁰ En el art. 2, 2. de la Carta de la ONU se dispone que los Miembros de la Organización deben cumplir de *buen fe* las obligaciones que han asumido en virtud de la Carta. El principio de la Declaración de Principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas [A/2625 (XXV)] extendería esta obligación a todos los Estados. El enunciado del artículo en cuestión no ha sido puesto en tela de juicio por los Estados, ni en sus comentarios al proyecto de la C.D.I., ni durante los debates en la Conferencia, puesto que no hace más que recoger una norma consuetudinaria del derecho de los tratados. El problema se ha planteado en la práctica de las relaciones internacionales con los casos que pueden constituir excepciones legítimas a la norma —invocación del abuso de derecho, de la diligencia debida,

¹⁹⁹ Así, por ejemplo, el art. 2 de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 dispone que "con exclusión de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempos de paz, la presente convención se aplicará en caso de guerra declarada o de todo otro conflicto armado..."

²⁰⁰ Tito Livio, refiriéndose a la conclusión de un tratado de paz, sostenía que los beligerantes *in fidem venerunt*.

etc.—. Se presume que los Estados actúan de buena fe, salvo prueba en contrario. Ciertas disposiciones de la Convención, como la obligación contenida en el art. 18, tanto para los Estados negociadores como para los Estados contratantes, o el principio del art. 45 sobre la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado, están íntimamente vinculadas con la buena fe y en ella se fundan. Cabe aclarar que no nos encontramos frente a un principio de moral o a una regla de comportamiento, sino frente a una verdadera obligación jurídica en la que la buena fe forma parte de la norma *pacta sunt servanda*. Esta se refiere a los tratados en vigor, es decir, a aquéllos por los que los Estados se han obligado y que no han sido, posteriormente, declarados inválidos.²⁰¹ Como corolario de esta norma el art. 27 consagra la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno y, así, un Estado parte "no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".²⁰²

El tratado en vigor obliga, en principio, para lo futuro y es por ello que sus disposiciones no pueden ser aplicables a actos, hechos o situaciones anteriores a la fecha de su entrada en vigor, con relación a cada parte en particular. El principio de la autonomía de la voluntad autoriza, sin embargo, a que las partes puedan establecer en el tratado, o a que pueda determinarse por otro medio, la retroactividad de la norma convencional (art. 28).²⁰³

²⁰¹ Como en seguida se verá, las causales de nulidad están taxativamente enunciadas en la Convención y ésta debe ser considerada como un cuerpo orgánico de normas. El tratado en vigor obliga en los términos del art. 26 hasta tanto no sea declarada la nulidad alegada por el procedimiento de solución de controversias previsto a tal fin, salvo los supuestos excepcionales de nulidad contemplados en los arts. 52 y 53. Cuando un tratado se encuentra en vigor se *presume* que éste es válido.

²⁰² Un análisis más detallado del tema se efectúa en el cap. I.4, *Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno* y en el contexto de la nulidad de los tratados, al estudiar el art. 46 de la Convención.

²⁰³ El principio de la no retroactividad de las convenciones se discutió en el caso de los *Fosfatos de Marruecos* que oponía a Italia y a Francia. El problema consistía en determinar si el conflicto tenía su origen en hechos anteriores o posteriores al 25 de abril de 1931, fecha en la que el Gobierno francés había reconocido la jurisdicción obligatoria de la C.P.J.I. La Corte, haciendo suya la tesis francesa, se declaró incompetente puesto que el origen del conflicto debía situarse en la época en la que los elementos generadores de la controversia se habían constituido. Esto había ocurrido con anterioridad al reconocimiento por parte de Francia de la jurisdicción obligatoria de la Corte (C.P.J.I., Serie A/B, n° 74, pág. 24). En el caso de las *Concesiones Mavrommatis en Palestina*, la C.P.J.I., en cambio, se pronunció por la retroactividad del Protocolo XII del Tratado de Lausana. Gran Bretaña alegaba la incompetencia de la Corte invocando que los actos que eran el objeto de la reclamación se habían producido algunos meses antes de la entrada en vigor del Protocolo. La Corte declaró: "El Protocolo XII se ha establecido con el fin de fijar las condiciones en las que ciertas concesiones acordadas por las autoridades otomanas antes de la conclusión del Protocolo tendrían que ser reconocidas y tratadas por las partes contratantes. Es, entonces, una característica esencial del Protocolo producir efectos

PS

El tratado en vigor obliga al Estado por la totalidad de su territorio (art. 29), tal como éste se encuentre integrado a lo largo de toda la vida del tratado. Los Estados suelen hacer declaraciones unilaterales, al manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado, referidas al ámbito territorial. Estas deben entenderse en el sentido de que, hasta tanto no sean aceptadas por las otras partes, no pueden considerarse comprendidas en la primera parte del art. 29. Tampoco puede entenderse que constituyan una reserva ya que éstas tienen por objeto modificar algunas de las disposiciones del tratado y las declaraciones en cuestión tienden a modificar todas las cláusulas del tratado en lo referido al ámbito territorial de aplicación. El término *territorio* comprende todas las zonas sometidas a la plena jurisdicción del Estado.

La observancia de los tratados impuesta por la norma *pácta sunt servanda* plantea el problema de un eventual conflicto o incompatibilidad entre tratados sucesivos concernientes a la misma materia. El sistema incorporado a la Convención en el art. 30 parte de la prioridad en la aplicación del tratado posterior, siempre y cuando esté en vigor, entre quienes son partes en el segundo tratado. Si el tratado posterior celebrado por todas las partes en el tratado anterior guarda silencio sobre la terminación de éste, será necesario resolver el conflicto mediante una interpretación previa de los dos tratados para determinar si concurren las condiciones previstas en el art. 59 de la Convención relativas a la terminación de un tratado o suspensión de su aplicación —implícitas— como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Cuando como resultado de esa interpretación previa se entienda que el tratado posterior ha puesto fin al anterior, las disposiciones del art. 30 no se aplicarán. Se estará en presencia de un solo tratado. Si la conclusión del tratado posterior constituye una infracción de los derechos de las partes en otro tratado, el problema se resolvería en el marco de la terminación de los tratados por violación (art. 60 y art. 30, 5.), y en el de la responsabilidad internacional del Estado por haber cometido un hecho ilícito internacional (art. 73 de la Convención). El art. 30, 3. regula el supuesto en que todas las partes en el tratado anterior son también partes en el tratado posterior. En este caso el tratado anterior se aplica únicamente en la medida que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior; el tratado posterior siempre prevalecerá. El art. 30, 4. se ocupa del caso en que no todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior. En este supuesto lo que se analiza son las relaciones emergentes de los trata-

con relación a situaciones jurídicas que se remontan a una época anterior a su propia existencia. Si la protección de los derechos reconocidos por el Protocolo XII contra las violaciones que hubieran podido cometerse antes de la entrada en vigor de este acto internacional no fuesen consideradas por sus cláusulas, el Protocolo carecería de efecto precisamente con relación al período en el que los derechos en cuestión tienen necesidad de protección. La Corte es, entonces, de opinión que el Protocolo garantiza los derechos reconocidos por él contra toda violación, independientemente del momento en que ella haya tenido lugar" (C.P.J.I., Serie A, n° 2, pág. 34).

dos y no el orden de prelación de un tratado sobre el otro. Así, las relaciones entre los Estados que son parte en ambos tratados estarán regidas por el tratado posterior; las relaciones entre los Estados parte en el primer tratado y que no son parte en el segundo y los Estados parte tanto en el primero como en el segundo, se regirán por el primer tratado; y entre un Estado que sólo sea parte en el tratado anterior y un Estado que sólo sea parte en el tratado posterior no se establecerá relación jurídica alguna.²⁰⁴

Las reglas que rigen las relaciones jurídicas emergentes de los tratados sucesivos concernientes a la misma materia reconocen una excepción, consagrada en el art. 30, 1., relativa al art. 103 de la Carta de la ONU.²⁰⁵ Esta disposición establece la prioridad de aplicación de la Carta en caso de conflicto entre ésta y cualquier otro tratado; sin embargo, esto no importa declarar la invalidez automática del segundo tratado sino reafirmar el carácter quasi-constitucional de la primera.

a) Interpretación de los tratados

El resultado de todo proceso interpretativo permite determinar el sentido o el alcance de las disposiciones de un tratado. La doctrina propone, para lograr tal fin, tres métodos distintos: a) el método textual, según el cual el texto escrito de un tratado es suficiente como elemento de interpretación;²⁰⁶ b) el método subjetivo, según el cual lo importante en la labor interpretativa es descubrir la voluntad real de las partes²⁰⁷ y; c) el método funcional o teleológico, según el cual el tratado debe interpretarse en función del objeto y del fin buscado con su conclusión.²⁰⁸ Cada uno de

²⁰⁴ A los fines de una mejor comprensión debe pensarse en un tratado multilateral como en una suma de tratados bilaterales en lo que concierne a la pluralidad de vínculos jurídicos generados por el tratado multilateral. Esta disposición es aplicación del principio de la relatividad de las relaciones emergentes de un tratado multilateral.

²⁰⁵ Art. 103, Carta ONU: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta".

²⁰⁶ Fitzmaurice, G. C., "The law and procedure of International Court of Justice: Treaty interpretations and certain other treaty points", B.Y.I.L., vol. XVIII (1951), págs. 1-28; "The law and procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty interpretation and other treaty points", B.Y.I.L., vol. XXXIII (1957), págs. 203-293; Resolución del Institut de Droit International del 19 de abril de 1956.

²⁰⁷ Lauterpacht, H., Rapport présenté à l'Institut de Droit International, Annuaire, 1950, vol. 43-I, págs. 366-460, Session de Bath; Annuaire, 1952, vol. 44-I, págs. 197-233; Annuaire, 1954, vol. 45-I, págs. 225-230.

²⁰⁸ OEA/Ser. F/III.8, 8ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de Punta del Este, Resolución VI (1962); ONU, Asamblea General, Resoluciones "Unión pro paz"; C.I.J.; opinión consultiva sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Recueil, 1949; C.J.C.E., sentencia en el caso del Reino de Bélgica c/Sociedad comercial Antoine Vloeberghs y Alta Autoridad de la C.E.C.A., Recueil, 1962, vol. VIII, págs. 356-357.

estos métodos preconizó procedimientos distintos como los más adecuados para realizar la labor interpretativa. Así, por ejemplo, en el caso del método textual, el empleo de procedimientos lingüísticos, lógicos, exegéticos o analógicos, serían los más convenientes para desentrañar el sentido del tratado. El método subjetivo se apoya, fundamentalmente, en los procedimientos históricos, poniendo de relieve el valor de los trabajos preparatorios en los que las partes habrían dejado las huellas de la real motivación que los llevó a plasmar el acuerdo de voluntades. El método funcional, de reciente desarrollo y en el que se basan los órganos de las organizaciones internacionales cuando interpretan el tratado constitutivo o tratado marco, se apoyará en la búsqueda del objeto y del fin del tratado tal como lo concibieron las partes en el momento de concluirlo y lo expresaron en su texto y como se perfiló en la práctica ulterior de la organización. En los hechos, todo proceso interpretativo, sea que se lleve a cabo por las partes, por una jurisdicción internacional o por un órgano de una organización internacional, se fundamenta en los tres métodos y utiliza todos los procedimientos preconizados por ellos para determinar el sentido de las disposiciones del tratado. Sobre la base de esta realidad, la CDI, partiendo del método textual, proyectó las normas sobre interpretación contenidas en los arts. 31, 32 y 33 de la Convención. El art. 31 está dedicado a los elementos *auténticos*, es decir a aquéllos originados en la actividad de las partes, dando así una regla general de interpretación. El art. 32 se refiere a los elementos *no auténticos* a los que se puede recurrir en el caso en que la aplicación de la regla general deje ambiguo u oscuro el sentido de los términos del tratado o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. El intérprete podrá también apoyarse en los elementos no auténticos, tales como los trabajos preparatorios, con el fin de confirmar el resultado interpretativo al que ya había llegado mediante la aplicación de la norma del art. 31. El art. 33 se ocupa del problema de los tratados que, como la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se autentican en dos o más idiomas. En este supuesto, como norma residual ante el silencio del tratado o falta de acuerdo de las partes, la Convención establece que todos los textos harán igualmente fe. Sin embargo, la comparación de los textos auténticos puede revelar una diferencia de sentido, caso en el cual será necesario acudir a las disposiciones de los arts. 31 y 32 para dar una interpretación que los concilie. Si la aplicación de tales normas no fuese suficiente para lograr el fin querido, en última instancia el art. 33 hace una remisión al objeto y al fin del tratado. Cabe destacar que, en este caso, el objeto y el fin serán siempre los que las partes hayan querido en el momento de la celebración del acuerdo; es decir, cuando expresaron su conformidad mediante la autenticación del texto con la existencia de las versiones en distintos idiomas y nunca los que pudiesen haber surgido de la práctica ulterior.

La regla general del art. 31, al establecer que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su

objeto y fin, con la posibilidad de dar a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes, recoge los tres métodos interpretativos por los que la doctrina se había manifestado en distintas oportunidades. El "sentido corriente" de los términos del tratado marca, como punto de partida de la labor interpretativa, el texto (método textual). La necesidad de tener en cuenta el "objeto y el fin" indica que el examen de éste debe hacerse a la luz del espíritu del tratado (método funcional). Finalmente, la posibilidad de investigar la intención de las partes si *consta* que ellas entendieron dar un "sentido especial" a un término del tratado (método subjetivo), por oposición al "sentido corriente" del que habla el art. 31, 1., tiende a aclarar en este caso la carga de la prueba. La buena fe, como principio de derecho internacional, rige todo el proceso interpretativo y obliga tanto a las partes como al intérprete.

El art. 31, 2. se refiere a los elementos emanados de la actividad de las partes, contemporáneos a la celebración del tratado. A los efectos de la interpretación debe tomarse en cuenta el contenido del tratado el que además del preámbulo —en el que probablemente estará enunciado el objeto y el fin perseguidos— comprenderá los anexos, los *acuerdos* referidos al tratado que hayan sido concertados por todas las partes en razón de una negociación de tipo global, y todo otro *instrumento* formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; dentro de estos últimos es posible pensar en los instrumentos de ratificación y en aquéllos que contienen reservas.

El art. 31, 3. contempla los supuestos de elementos también emanados de la actividad de las partes pero posteriores a su celebración. Estos pueden estar originados en *acuerdos* ulteriores referidos a la interpretación o aplicación del tratado, o en *prácticas* por las que conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación. El término *acuerdo* empleado en estas disposiciones indica que la concertación de voluntades no debe, necesariamente, instrumentarse en un "tratado" tal como lo define el art. 2, 1.a) de la Convención, sino que puede evidenciarse también en un acuerdo verbal o tácito. El art. 31, 3.c) plantea el problema de determinar cuáles son las normas de derecho internacional aplicables a las relaciones entre las partes. Si lo son aquéllas que se encontraban en vigor al momento de la celebración o conclusión del tratado, o las que se encuentran en vigor al momento de la interpretación. La Convención nada aclara al respecto, dejando en libertad al intérprete para que las determine efectuando su labor de "buena fe".²⁰⁹

²⁰⁹ En principio, el derecho a aplicar sería el vigente al momento de la celebración, ya que el intérprete trata de descubrir lo que las partes han querido al celebrar el tratado. El concepto del derecho intertemporal fue desarrollado por el árbitro Max Huber en el caso de la *Isla de Palmas*, entre los EE.UU. y los Países Bajos (A.J.I.L., 1928, pág. 909). Este principio admitiría, sin embargo, excepciones a fin de regular los problemas que se plantearían con relación a los "efectos" del tratado.

b) *Los tratados y los terceros Estados*

El art. 2, 1.h) de Convención define al *tercer Estado* como el Estado que no es parte en el tratado. Podría ocurrir que se trate de un Estado negociador, de un Estado que tiene el derecho de llegar a ser parte en el tratado o de un Estado que nada tenga que ver con éste. El principio de la autonomía de la voluntad en materia convencional tiene como consecuencia que los sujetos del ordenamiento que no han dado su consentimiento para la conclusión del tratado no se encuentran vinculados por él. El tratado sólo crea obligaciones y derechos para las partes. El art. 34 consagra un principio general de derecho, enunciado en el derecho romano como *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, que tiene su razón de ser en derecho internacional en la igualdad jurídica de los Estados que los hace soberanos e independientes unos de otros. La doctrina discute si esta regla puede o no tener excepciones en lo que hace al otorgamiento de derechos a favor de terceros Estados. Una parte de la doctrina entiende que, si tal es la intención de las partes, un tratado puede producir este efecto aun cuando los terceros Estados no estén obligados a aceptar o ejercer el derecho.²¹⁰ Otro grupo enuncia el principio, consagrado en el articulado de la Convención, según el cual el derecho no nace mientras no medie aceptación del tercer Estado. El art. 34 de la Convención confirma el ámbito de validez personal de la norma *pacta sunt servanda* (art. 26).

i) *Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados*: El art. 35 de la Convención requiere la existencia de dos elementos para que se pueda considerar que un tratado da origen a una obligación para un tercer Estado. En primer lugar, la intención de las partes de que una disposición del tratado cree tal obligación; en segundo lugar, que medie una *aceptación expresa*, formulada por escrito, que emane del tercer Estado. En realidad, la fuente de la obligación no es la disposición del tratado que la prevé sino el *acuerdo colateral* que se perfecciona entre las partes y el tercer Estado al dar éste su consentimiento. Estamos frente a un nuevo "tratado" que, por sus características, quedaría también dentro del ámbito de la Convención.²¹¹ El consentimiento requiere en este supuesto una forma sacramental para que sea posible considerar que se ha otorgado. Debe darse en forma expresa y por escrito. No puede, entonces, dentro del marco de la norma que analizamos, entenderse que sería admisible intentar probar el consentimiento tácito, invocando el silencio o la aquiescencia evidenciada en el comportamiento ulterior a la entrada en vigor del tratado, dado por el tercer Estado.

La obligación fundada en el tratado colateral terminará cuando las partes en el tratado y el tercer Estado den su consentimiento en tal sentido. La norma del art. 37, 1. que así lo establece, es una mera aplica-

²¹⁰ Jiménez de Arechaga, E., "Treaty stipulations in favor of third States", A.J.I.L. (1956), págs. 338-357; Lachs, Sir M., R.C.A.D.I., 1957-II, pág. 313, se fundan en la figura de derecho interno de la "gestión de negocios".

²¹¹ Conf., definición del art. 2, 1.a) de la Convención.

ción del principio de la autonomía de la voluntad, y de la regla *pacta sunt servanda*, en virtud del cual los acuerdos sólo pueden quedar sin efecto por la voluntad de todos aquéllos que los han concluido, no siendo dable concebir en tal marco jurídico un derecho unilateral de denuncia. El art. 35 reconoce, sin embargo, una excepción contemplada en el art. 75 de la Convención: el caso de un Estado agresor. En virtud del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional contemporánea es posible admitir que se le pueda imponer una obligación en virtud de un tratado a un tercer Estado considerado agresor, siempre y cuando se lo haga como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de la ONU, con respecto a la agresión del tal Estado.

ii) *Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados*: El caso, contemplado en el art. 36, es el de un tratado que origina un derecho para un tercer Estado y no un simple beneficio. Para que el derecho nazca es necesario que existan: a) intención de las partes de conferir el derecho al tercer Estado, a un grupo de Estados o a todos los Estados; y b) que medie consentimiento del tercer Estado. En este caso también la fuente del derecho está, no en el tratado mismo, sino en el *acuerdo colateral* que se perfecciona entre las partes en el tratado y el tercer Estado al dar éste su consentimiento. Pero en el marco de la constitución de derechos, el asentimiento no necesita expresarse en una forma sacramental; puede, inclusive, presumirse mientras no haya indicación en contrario, siempre que el tratado no disponga otra cosa. Sin embargo, como el art. 36, 2. subordina el ejercicio del derecho a las condiciones que para ello estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste, si tales condiciones comportan obligaciones a cargo del tercer Estado, la regla del art. 35, sobre la necesidad de dar el consentimiento en forma expresa y por escrito, prima sobre la del art. 36.

La Convención recoge en este artículo la jurisprudencia de la CPJI, en el caso de las *Zonas Francas*, entre Francia y Suiza.²¹² En marzo de 1815 las potencias aliadas, en el Congreso de Viena, hacen saber su deseo de crear medios territoriales que tiendan a consolidar la independencia del Estado Suizo. Por el tratado del 3-XI-1815 Francia acepta ante los aliados retirar su cordón aduanero en su frontera política con Suiza. La declaración de marzo había sido aceptada expresamente por Suiza, no así el tratado del 3 de noviembre. Este régimen de zonas francas se aplica durante todo el siglo XIX. En la Conferencia de Versalles de 1919, a iniciativa de Francia, se incorpora un artículo en el que se establece que las zonas francas no corresponden ya a la situación del momento, debiendo llegarse a un acuerdo al respecto con Suiza. Al no poder concluirse el acuerdo, Francia modifica unilateralmente la frontera aduanera. El caso es llevado ante la Corte donde Francia sostiene que se trata de un beneficio en tanto que para Suiza el acuerdo de 1815 le confería un verdadero derecho. La Corte, examinando las circunstancias históricas, constata que Suiza había

²¹² C.P.J.I., Serie A/B, n° 46, pág. 144.

aceptado expresamente la declaración de marzo de 1815 y que el acuerdo de noviembre no hace más que retomar los términos de la declaración. En consecuencia, como Suiza había dado su consentimiento, se había constituido un verdadero derecho a favor de ésta. El Tribunal agrega que aun cuando presumir el establecimiento de derechos no es algo usual, nada impediría que Estados soberanos pudiesen llegar a hacerlo. Se trata, entonces, de conocer la intención de los Estados en el caso.

El derecho emergente del acuerdo colateral terminará cuando medie consentimiento en tal sentido de las partes y del tercer Estado. La regla contenida en el art. 37, 2. permitiría establecer que en caso de silencio o falta de prueba de la intención de los intervinientes sobre la necesidad del consentimiento del tercer Estado, el derecho sería revocable unilateralmente por las partes en el tratado. Cabe destacar, sin embargo, que este supuesto habrá formado parte de la valoración efectuada por el tercer Estado al dar su consentimiento para el perfeccionamiento del acuerdo colateral y en tal sentido podrá válidamente interpretarse que en ese mismo momento ha dado, también, su consentimiento para la denuncia ulterior de las partes en el tratado de base sin su intervención.

iii) *Los tratados y el derecho consuetudinario*: Como se ha dicho al referirse a las características del derecho internacional²¹⁸ nada impide en este ordenamiento que una misma formulación se imponga en tanto que *derecho convencional* a los Estados parte en una determinada Convención y en tanto que *derecho consuetudinario* a los demás miembros de la comunidad internacional. Este fenómeno puede producirse en razón de que una convención codificadora recoja una norma de derecho consuetudinario preexistente —tal el caso del art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados—, o en virtud de que una disposición de una convención de tal naturaleza sea el antecedente de una norma consuetudinaria posterior por el hecho de su aceptación, con conciencia de obligatoriedad, por aquéllos que no son parte en el tratado —tal el caso de la Convención para la Represión y Sanción del Delito de Genocidio—. Este supuesto está expresamente previsto en el art. 38 de la Convención. Según esta disposición, lo dicho en materia de constitución de derechos y obligaciones en virtud de un tratado para un tercer Estado —en razón del principio de que un tratado es *res inter alios acta* (art. 34)— no impedirá que una norma en él enunciada llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional general.

iv) *Los tratados que crean "situaciones objetivas"*: Al hablar de tratados que crean situaciones objetivas, la doctrina se ha referido a: a) los tratados que fijan un régimen jurídico a aplicar a un espacio determinado, y b) los tratados que crean un nuevo sujeto de derecho internacional.

Los tratados que fijan un régimen jurídico a aplicar a un espacio determinado —neutralización, desmilitarización, internacionalización— deben analizarse tomando en cuenta si aquéllos que son parte tenían antes de la

²¹⁸ Véase cap. I, 1.b).

conclusión jurisdicción sobre ese espacio. En tal supuesto, nada les impediría llegar a un acuerdo sobre el régimen a aplicar, oponible al resto de la comunidad internacional en la medida en que el Estado tiene la competencia de dictar el ordenamiento jurídico válido para todos los espacios que se encuentran bajo su jurisdicción.²¹⁴ Si no la tenían, la obligación por parte de la comunidad internacional sólo podría originarse en una norma consuetudinaria posterior, de la que el tratado fuese el antecedente (art. 38).²¹⁵

En el caso de los tratados que crean un nuevo sujeto de derecho internacional, si los Estados que concluyeron el tratado constitutivo de la organización internacional representaban la mayoría de la comunidad internacional y si tenían la intención de crear un ente dotado de derechos y obligaciones en virtud del ordenamiento jurídico internacional con el fin primero de preservar la paz en el mundo —es decir, de propender al desarrollo y perfeccionamiento de la comunidad internacional—, este sujeto tendrá una personalidad jurídica objetiva.²¹⁶ Sin embargo, esto no importa alterar el contenido de la regla *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* ya que, en cuanto al "reconocimiento" de la personalidad por los terceros Estados —es decir, por los no miembros de la organización internacional— el problema que se plantea se resolverá aplicando los mismos principios que se desarrollarán al tratar el tema del reconocimiento de Estados. Si el ente creado goza de derechos y obligaciones en el orden jurídico internacional, será un sujeto de este derecho, independientemente del reconocimiento efectivo que de él hagan los demás sujetos de la comunidad internacional. Y en lo que hace a las disposiciones del tratado mismo y al derecho derivado emanado de los órganos competentes de la organización, no crearán derechos y obligaciones para los no miembros, sino, simplemente, en algunos supuestos, obligaciones para la organización y sus miembros de actuar de modo tal que los terceros Estados respeten los principios constitucionales de la organización.²¹⁷

Finalmente debe destacarse en esta materia que las disposiciones del art. 36 en lo referente a tratados en que se prevén derechos para terceros Estados, no menoscaban los intereses de los Estados que gozan del

²¹⁴ Así, por ejemplo, como un Estado está facultado para dictar las normas referidas a la navegación en su mar territorial, puede —de común acuerdo con otro Estado— establecer la neutralización de un espacio sometido a su jurisdicción.

²¹⁵ Así, por ejemplo, el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, en lo que concierne al uso pacífico de tal zona.

²¹⁶ Conf. C.I.J., opinión consultiva sobre *Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, Recueil, 1949.

²¹⁷ Conf. C.I.J., opinión consultiva sobre las *Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua del África del Sud en Namibia (Sud-Oeste Africano)* no obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Recueil, 1971, con relación a la obligación que impone a los Estados miembros de la organización el art. 2, 6. de la Carta de la ONU.

régimen de la nación más favorecida. En efecto, en tal entendimiento se votó la adopción del texto de este artículo en la Conferencia de Viena.²¹⁸

c) *Enmienda y modificación de los tratados*

El principio de la autonomía de la voluntad en materia convencional indica que un tratado podrá ser enmendado sólo por acuerdo entre las partes.

El término *enmienda* se utiliza para designar la hecha a un tratado,²¹⁹ que tiene por objeto modificar ciertas disposiciones de éste, o revisarlo en su conjunto, con relación a *todas las partes* intervinientes. Como comúnmente se trata de un nuevo tratado, se han de aplicar las disposiciones de la Convención sobre la celebración y la entrada en vigor. Sin embargo, nada impediría que la enmienda se consagrara en un acuerdo tácito o emergiese de la práctica ulterior de todas las partes, puesto que la teoría del "acto contrario" no es aplicable en derecho internacional.²²⁰ En efecto, este ordenamiento no sujeta a formas determinadas la expresión del consentimiento que otorgan los Estados para concluir acuerdos internacionales.

Todos los *contratantes* tienen derecho a participar en las negociaciones tendientes a la enmienda del tratado y, en consecuencia, tendrán derecho a llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. Esta última facultad le asiste, también, a todo Estado que tenga derecho a ser parte en el tratado original, sea en razón de haber intervenido en su

²¹⁸ Véase la declaración del Presidente de la Conferencia en el momento de la votación en *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Segundo período de sesiones, pág. 66.

²¹⁹ Norma general contenida en el art. 39 de la Convención.

²²⁰ Conf., C.D.I., *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9* (A/6309/Rev. 1), págs. 65-68. Cabe destacar, sin embargo, que el art. 38 del Proyecto de la C.D.I. sobre la modificación de un tratado por la práctica ulterior de las partes durante su aplicación no fue adoptado por la Conferencia. El representante de Finlandia —Castrén— al presentar a la Conferencia una enmienda tendiente a suprimir este artículo expresó que al contemplar la regla general de interpretación del art. 31 "toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado" se admitía ya que un tratado podía ser modificado por la práctica de las partes. En consecuencia, la distinción entre las dos disposiciones del proyecto era prácticamente inexistente. Fujisaki, representante de Japón, opinaba, en cambio, al presentar una enmienda con el mismo fin, que la práctica incompatible con un tratado no constituye el fundamento de una nueva regla de derecho sino un abuso de derecho y una violación del tratado. El representante de Argentina —de la Guardia— opinó que los argumentos avanzados en contra del artículo proyectado no eran convincentes. No ve una violación de la regla *pacta sunt servanda* si interviene un acuerdo entre todas las partes con el objeto de aplicar el tratado de una manera diferente de la prescrita por alguna de sus disposiciones. Sostiene que el art. 38 del proyecto se inspiraba en un principio existente, que contribuye a aproximar el derecho internacional a la realidad; *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Primer período de sesiones, reuniones 37 y 38.

negociación, sea en razón de haber sido invitado a adherir a aquél. Nuevamente el principio de la relatividad de las relaciones emergentes de un tratado²²¹ nos indica que el tratado en su forma enmendada regirá entre todos aquéllos que han manifestado su consentimiento en obligarse por la enmienda; el tratado en su forma original regirá entre aquéllos que han manifestado su consentimiento de obligarse por la enmienda y las partes en el tratado original que no lo han hecho y regirá, también, entre todos aquéllos que no han manifestado su consentimiento en obligarse por la enmienda. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado con posterioridad a la entrada en vigor de la enmienda, salvo que manifieste una intención diferente, será considerado parte en el tratado enmendado y parte en el tratado no enmendado con relación a toda parte en el tratado original que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmienda el tratado (art. 40).

El término *modificación*, contenido en el art. 41, se refiere al acuerdo concluido entre *dos o más partes* en un tratado multilateral que tiene por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. La CDI consideraba que existe una diferencia esencial entre los "acuerdos de enmienda", concebidos para enmendar un tratado entre todas las partes (aun cuando la enmienda no entre luego en vigor entre todas ellas) y los acuerdos concebidos *ab initio* para modificar la aplicación del tratado en las relaciones entre ciertas partes, exclusivamente.²²² En este último caso se trata de los llamados acuerdos *inter se*. El problema que éstos pueden presentar es que con ellos se contraría en alguna medida el objeto y el fin del tratado. En este caso, su conclusión y su aplicación haría incurrir a los Estados parte en el acuerdo *inter se* en responsabilidad internacional frente a los demás Estados parte en el tratado original. De ahí que el art. 41 se ocupe de establecer las condiciones en que válidamente ciertos Estados parte en un tratado multilateral podrán concluir un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado en sus relaciones mutuas. Para ello será necesario que la posibilidad de la modificación esté prevista en el tratado; en su defecto, la modificación no debe afectar al disfrute de los derechos que corresponden a las demás partes en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones y, además, no ha de referirse a ninguna disposición esencial para el cumplimiento del objeto y del fin del tratado en su conjunto. En este supuesto, también es necesario que aquellos Estados que quieran concluir un acuerdo *inter se* notifiquen su intención a las partes en el tratado y luego lo hagan con relación a la modificación del tratado que hayan estipulado en el acuerdo que concluyan.

²²¹ Véase lo dicho al comienzo de este punto sobre *Observancia y aplicación de los tratados* con relación al art. 30 de la Convención.

²²² Conf., C.D.I., *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9* (A/6309/Rev. 1), págs. 65-68.

4. Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados

La Parte V de la Convención se ocupa de las causales de invalidez, terminación —por voluntad de las partes o en virtud del derecho internacional— y suspensión en la aplicación de los tratados. Prevé, también, un procedimiento de solución de las controversias que se pudiesen plantear con motivo de la interpretación o aplicación de estas disposiciones y los efectos jurídicos de la nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de un tratado.

a) Disposiciones generales

Los arts. 42, 43, 44 y 45 enuncian una serie de principios generales aplicables a todos los casos de nulidad, terminación o suspensión de los tratados. Una vez que la Convención entre en vigor, los Estados que se hayan obligado por ella sólo podrán terminar o suspender los tratados celebrados con posterioridad, en virtud de las disposiciones del mismo tratado o de la Convención. Asimismo, la validez del tratado o del consentimiento dado por el Estado en obligarse por éste podrá impugnarse, exclusivamente, por las causales previstas en la Convención (art. 42). Este régimen contribuye a la certeza y a la estabilidad de las relaciones internacionales ya que afirma la presunción de validez de los compromisos que los Estados han asumido. Precisa el contenido de las reglas del *onus probandi* en el sentido de que aquél que alega la existencia de una causal de nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de un tratado deberá acreditarla. Al contemplar el art. 42 en forma alternativa la posibilidad de impugnar la validez del tratado o del consentimiento dado por el Estado en obligarse por el tratado considera el supuesto de un tratado multilateral al que, por ejemplo, un Estado se hubiese obligado en virtud de un error excusable. En este caso, si bien el consentimiento dado podría ser anulable, el tratado mismo sería válido y permanecería en vigor.

El art. 43 retoma el principio sentado en el art. 38 con relación a aquellas normas que llegan a ser obligatorias para terceros Estados en virtud del derecho consuetudinario. De esta manera, si un tratado es declarado nulo, termina o se suspende en su aplicación, en nada alterará para los Estados que habían sido parte el deber de cumplir todas las obligaciones que hubiese enunciado el tratado, a las que también estuviesen sometidos en virtud del derecho internacional, independientemente del tratado.

El principio de la integridad del tratado aparece reafirmado en el art. 44, concordando con la disposición contenida en el art. 17 según la cual un Estado sólo puede expresar su consentimiento en obligarse respecto de alguna o algunas de las cláusulas del tratado —y no de éste en su integridad— si el tratado mismo así lo permite o si las demás partes

contratantes lo consienten. El artículo que estudiamos autoriza, a título de excepción, a ejercer el derecho de denuncia o retiro sólo con relación a ciertas disposiciones del tratado cuando éste lo permite o las partes, de común acuerdo, lo convienen. En los casos de terminación o nulidad de los tratados, cuando la causa invocada se refiere a determinadas cláusulas del tratado, podrá alegarse la nulidad o terminación de dichas cláusulas y no de la totalidad del tratado si: a) éstas son separables del resto en lo que respecta a su aplicación; b) no han sido la base esencial del consentimiento en obligarse prestado por la otra o las otras partes, y c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no es injusta. Sin embargo, en caso de invocarse la nulidad fundada en coacción o en violación de una norma imperativa de derecho internacional general no se admitirá la división de las disposiciones del tratado.

Finalmente, el art. 45 establece la pérdida del derecho a alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado —salvo en los casos de violación del tratado o de un cambio fundamental en las circunstancias— retirarse de él o suspender su aplicación, si el Estado, después de haber tenido conocimiento de los hechos en que podía fundarla ha convenido expresamente que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según sea el caso (al. a); o si con su conducta ha dado lugar a considerar que ha dado su *aquiescencia* a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso (al. b). La norma contenida en este último párrafo receptaría el principio del *estoppel*, aceptado por la jurisprudencia internacional como una excepción de fondo válida para rechazar reclamaciones formuladas por un Estado que con su conducta anterior había dado lugar a que la otra parte en la controversia hubiese presumido su consentimiento con determinados hechos o situaciones.

El principio del *estoppel* requiere la conjunción de dos elementos: por una parte, una conducta o una actitud de un Estado que incite a la otra parte a adoptar cierta posición o, al menos, a hacerse una determinada representación de la situación; y, por la otra, la existencia de un perjuicio para la parte que ha confiado en el otro Estado.²²³ Esta norma es aplicación de la buena fe que debe regir las relaciones internacionales (art. 26).

²²³ El principio del *estoppel* fue planteado por primera vez en el ámbito internacional en el caso *Tinoco*, Ministro de guerra de Costa Rica que accede al poder en ese país por un golpe militar en 1917. Durante su gobierno se concluyen diversos contratos de concesión y se emite moneda. Vuelto al poder el gobierno constitucional declara nulos los contratos y las emisiones. Gran Bretaña reclama la ejecución de las obligaciones invocando el principio de identidad del Estado, pero Costa Rica alega el no reconocimiento por el demandante del gobierno Tinoco para fundar la falta de derecho a toda reclamación ulterior. En su criterio, se había producido *estoppel*. El árbitro único, William H. Taft rechaza este argumento declarando: "Un *estoppel* equitativo debe estar fundado en la actitud anterior de aquél contra quien se formula; actitud que colocó al demandante del *estoppel* en una posición tal que la verdad le sería perjudicial. Así, no reconociendo el gobierno Tinoco, Gran Bretaña no manifestó un deseo de no consentir los contratos concluidos por dicho gobierno. Un "no acto" como este "no reconocimiento" no podría en este caso tener un efecto supletorio."

b) Nulidad de los tratados.

Puede considerarse que un tratado ha sido válidamente concluido si el consentimiento ha sido expresado por quien tiene capacidad para hacerlo y se ha otorgado en forma consciente y libre. El derecho internacional contemporáneo requiere, además, que el objeto del tratado sea lícito. Es decir, que no sea contrario a una norma imperativa de derecho internacional general. Si alguno de estos requisitos no se cumple, la consecuencia será la anulabilidad o la nulidad del tratado, o del consentimiento dado por el Estado en obligarse por aquél. En el primero de estos supuestos, el Estado que considera haber otorgado inválidamente su consentimiento podría, con su conducta ulterior, dar la aquiescencia a la validez del acto. De esta manera el tratado seguiría en vigor y produciría todos los efectos jurídicos que con él se pensaban alcanzar. En el segundo de los casos, a fin de preservar el orden público internacional, la nulidad se produciría automáticamente y el tratado no sería susceptible de confirmación posterior por la voluntad de las partes.

La Convención enumera, en los arts. 46 a 53, las causales de nulidad de los tratados. Estas se refieren a la capacidad, al consentimiento y al objeto.

i) Capacidad: La capacidad en esta materia no se refiere ya a la de las partes, puesto que el art. 6 afirma la de todos los Estados para celebrar tratados,²²⁴ sino a la de los representantes del Estado. El art. 46, 1. dispone que un Estado no podrá alegar como causal de nulidad que su consentimiento ha sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, a menos que: a) esa violación sea manifiesta; b) se refiera a una disposición concerniente a la competencia para celebrar tratados, y c) afecte a una norma de importancia fundamental.

Véase, Vallée, Ch., "Quelques observations sur l'estoppel en droit des gens", R.G.D.I.P. (1973), vol. 77-4, págs. 949-999; C.I.J. caso de la *Plataforma continental del Mar del Norte*, Recueil, 1969, § 30. Dinamarca y los Países Bajos habían intentado acreditar ante la C.I.J. una serie de actos de la R.F.A. que, a criterio de los demandantes, traducirían la aceptación por parte de la demandada del régimen fijado en el art. 6 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre *Plataforma Continental*, para la división de la plataforma entre Estados vecinos o de costas enfrentadas. "...la Corte es de opinión que sólo la existencia de una situación de *estoppel* podría apoyar semejante tesis: sería necesario que la R.F.A. no pudiese ya negar la aplicación del régimen convencional, a raíz de un comportamiento, de declaraciones, etc., que no sólo testimoniasen de manera clara y constante su aceptación a este régimen, sino que, también, hubiesen conducido a Dinamarca o a los Países Bajos, fundándose en esta actitud, a modificar su posición en detrimento propio o a sufrir cualquier perjuicio". Conf. C.I.J., caso del *Templo de Preah Vihear*, Recueil, 1961.

²²⁴ Se excluye, así, toda discusión referida a los problemas que se pueden plantear en derecho público interno con relación a las distintas formas de organización que los Estados pueden asumir —Estados federados, Estados confederados— y los supuestos en que un Estado miembro de este tipo de uniones puede concluir válidamente un tratado; conf. debate en *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Segundo período de sesiones, págs. 6-17.

Este artículo concuerda con lo dispuesto en el art. 27 sobre la observancia de los tratados y se funda en el principio de la buena fe que rige las relaciones internacionales. El art. 46, 2. se incorpora al texto del proyecto en la conferencia de Viena a propuesta del Reino Unido.²²⁵ Tiene por objeto definir qué se entenderá por violación manifiesta y en consecuencia establece que será tal, si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda conforme a la práctica usual y de buena fe. La norma constitucional a la que se refiere es la efectivamente vigente en el momento de la conclusión del tratado.²²⁶ Actuar conforme a la práctica usual y de buena fe significa que el Estado debe haberse informado conforme a las exigencias de la normal prudencia, pero no necesariamente después de haber procedido a una investigación exhaustiva y de haber desplegado grandes esfuerzos para obtener interpretaciones autorizadas de la constitución y de la práctica del otro Estado.

El art. 47, concordante con el principio según el cual una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado y del criterio de objetividad sentado en el art. 46, establece que la inobservancia por parte del representante de un Estado de las restricciones específicas aportadas a sus plenos poderes para obligar al Estado no podrá alegarse por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que las restricciones hayan sido notificadas a los demás Estados negociadores, con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento. El caso podría plantearse en el supuesto en que un representante autorizado sólo a firmar un tratado bajo reserva de ratificación no lo hiciese así y el tratado estableciese su obligatoriedad a partir de la firma. En tal situación el Estado sólo podría alegar la inobservancia de la restricción como vicio de su consentimiento si, previo a la firma, la había notificado a los demás Estados negociadores.

ii) Consentimiento: La Convención recoge, en general, la doctrina de los vicios del consentimiento desarrollado en los distintos derechos internos, en tanto que principios generales de derecho, sin plegarse a los criterios de clasificación elaborados en distintos derechos privados.

Así, un Estado sólo podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento si: a) éste se refiere a un hecho o a una situación; b) su existencia se diera por supuesta por el Estado en el momento de la celebración del tratado, y c) fuese una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado (art. 48, 1.).²²⁷ Es decir que el error debe reunir como condición, para configurar un vicio del consentimiento,

²²⁵ A/CONF. 39/C.1/L.274.

²²⁶ Esto legitimaría internacionalmente el consentimiento dado, por ejemplo, en épocas de gobiernos de facto en que el Poder Ejecutivo ejerce también funciones legislativas; conf., interpretación del representante de Suecia en la Conferencia, Sr. Blix, *ibid.*, pág. 93.

²²⁷ Esta situación se planteó ante la C.P.J.I., en el caso del *Estatuto Jurídico de la Groenlandia Oriental* (Dinamarca-Noruega), Serie A/B, n° 53, en el que Noruega

33

ser de hecho y no de derecho, ser esencial y, finalmente, excusable. Esto último en razón de que el art. 48, 2. recoge un principio general de derecho según el cual nadie puede alegar su propia torpeza. En efecto, si el Estado de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error, no podrá alegarlo como vicio de su consentimiento.²²⁸ El vicio existirá si la manifestación exterior de voluntad no corresponde a la voluntad real del Estado. Si el error fuese sólo un error en la redacción del texto del tratado y no un error en el consentimiento, aquél será válido y su deficiencia podrá subsanarse por los mecanismos previstos en el art. 79 de la Convención.

Pero el Estado puede haber incurrido en error no ya por una confusión que le sea exclusivamente imputable, sino por haber sido inducido a ella por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador. En este caso quedará configurado el *dolo* y el Estado perjudicado podrá alegarlo como vicio de su consentimiento (art. 49). El dolo no sólo vicia el consentimiento sino que destruye la base de la confianza mutua entre las partes. Para que quede tipificado es necesario que medie un elemento psicológico —la intención del negociador de engañar— y un elemento material —las maniobras que constituyen la conducta fraudulenta—. Si estas conductas emanan de un tercer Estado y no de un negociador, el dolo no quedará configurado. Como en el caso del error, el dolo debe ser esencial; es decir, debe ser determinante del consentimiento otorgado por el Estado. Debe ser, además, excusable; esto es, que la víctima no debe haber sido negligente al dar su consentimiento.²²⁹

hacia valer que cuando el embajador de Dinamarca le había pedido declarar que no se oponía a que el Gobierno danés extendiese a toda Groenlandia sus intereses políticos y económicos, el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega no había comprendido que se trataba de aprobar la extensión del monopolio danés al conjunto de Groenlandia y que, en consecuencia, el consentimiento que había dado al pedido danés había estado viciado de error. La Corte decidió que la respuesta del Ministro había sido incondicional y definitiva, rechazando la existencia, en este caso, de error. El juez Anzilotti agrega: "Todo error debe ser excusable y no es fácil admitir que un gobierno pueda ignorar las consecuencias legítimas de una extensión de soberanía" (págs. 71 y 92).

²²⁸ La C.I.J. en el caso del *Templo de Preah Vihear* (Camboya-Tailandia), *Recueil*, 1961, en el que los mapas preparados en 1907 por una comisión mixta Franco-Siamesa —Francia en la época administraba Camboya y Tailandia era Siam— según la tión en territorio camboyano expresó que "es una norma de derecho establecida que tión en territorio camboyano, expresó que "es una norma de derecho establecida que una parte no podrá alegar un error como vicio de su consentimiento si contribuyó con su conducta al error" (pág. 26). La Corte puso de relieve que los mapas habían sido oportunamente comunicados al gobierno de Siam y que la prueba de la causa acreditaba la aquiescencia de este gobierno a la ubicación del Templo en territorio camboyano.

²²⁹ Conf. C.I.J., en el caso del *Templo de Preah Vihear*, *Recueil*, 1961, pág. 26. Un ejemplo de dolo se planteó en el tratado de Uccialli entre Italia y Abisinia, en 1889. Los negociadores italianos habían recurrido a una maniobra dolosa redactando

Uno de los medios posibles de obtener el consentimiento por *manio-
bras dolosas* sería la *corrupción del representante* de un Estado. La Convención contempla especialmente este supuesto en el art. 50. Así, se dispone que un Estado podrá alegar como vicio de su consentimiento la *corrupción* de su representante si ésta ha sido efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador.

Todos estos supuestos no acarrearán la nulidad automática del tratado o del consentimiento dado en obligarse por el tratado, sino que otorgan el derecho para el Estado que ha sufrido el vicio de *alegarlo* como causal de nulidad. Se trata de casos en que la nulidad es relativa.

Las disposiciones de los arts. 51 y 52 se vinculan con la necesidad de que el consentimiento se exprese en forma no sólo consciente sino, también, libre. La violencia ejercida tanto sobre el representante del Estado como sobre el Estado mismo origina la *nulidad absoluta* del tratado, el que carecerá de todo efecto jurídico. La segunda de estas normas, referida a la coacción sobre el Estado por la amenaza o el uso de la fuerza es de desarrollo progresivo puesto que en el derecho internacional clásico no se admitía esta causal de nulidad. Por el contrario, la manera normal de poner fin al estado de guerra y, en consecuencia, de hacer renacer entre las partes beligerantes —partes en la lucha armada— la aplicación de las normas propias del derecho internacional de paz, era mediante la conclusión de los llamados "tratados de paz". El interés de la estabilidad general exigía que los conflictos tuviesen un fin. En aras de tal objetivo era necesario que los tratados que les pusiesen término fuesen respetados, aun cuando se hubiesen concluido bajo el imperio de la fuerza.²³⁰ La disposición del art. 52 se vincula con el principio consagrado en el art. 2, 4. de la Carta de la ONU, según el que: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas". Este principio es, en la actualidad, una regla de derecho internacional general de

en italiano y en amárico el tratado, con textos que no correspondían exactamente en puntos importantes. En el texto etíope, la disposición del art. 17, relativa al recurso a los servicios del gobierno italiano por el emperador etíope en materia de relaciones exteriores, era simplemente facultativa, en tanto que en el texto italiano era obligatoria. Fundándose en este último el gobierno italiano proclamó unilateralmente el protectorado sobre Abisinia poco después de la firma del tratado. El Emperador Menelik II, basándose en el texto amárico había rechazado esta interpretación y denunciado el tratado. Italia, como consecuencia, declaró la guerra a Etiopía en 1895.

²³⁰ Conf. Decisión n° 136 del 25-VI-1952 de la Comisión de conciliación franco-italiana sobre la controversia referida a la interpretación del art. 79, 6.c) del Tratado de Paz con Italia: "Es bajo la coacción que el Estado vencido ha dado su consentimiento, pero sin embargo él lo dio y es por este consentimiento que el acuerdo nació... Los Estados vencedores no pueden... exigir que el Tratado de Paz no negociado sea interpretado de acuerdo a lo que era su voluntad interna; el Tratado de paz no negociado debe ser interpretado según la voluntad de los Estados vencedores tal como ellos la han concretado y que aparece objetivamente en el Tratado".

aplicación universal. (Sin embargo, no puede entenderse que el artículo tenga un efecto retroactivo sobre la validez de los tratados concluidos con anterioridad al establecimiento del derecho internacional contemporáneo.²³¹ No sería correcto interpretar que mediante él se privaría de validez *ab initio* a un tratado de paz o a otro tratado obtenido por la coacción antes del establecimiento del derecho moderno relativo a la amenaza o al empleo de la fuerza. Por su redacción se reconoce implícitamente que la norma que formula sería, en todo caso, aplicable a todos los tratados concluidos después de la entrada en vigor de la Carta.²³² Cabe destacar que cuando la fuerza es empleada a título de sanción en el marco de la ONU, el tratado que se impone a un Estado agresor no es nulo. Esto se infiere de la reserva general consagrada en el art. 75 de la Convención según la cual sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado." La referencia a los "principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas" permite inferir la validez de un "armisticio" por cuanto mediante éste no se pone fin a un "estado de guerra" sino que se intenta solucionar una controversia en la que se había invocado el principio de "legítima defensa" para justificar el recurso a la fuerza.²³³ Finalmente, la "fuerza" que menciona el art. 52 de la Convención es, indudablemente, la "fuerza armada". Pero nada impediría que en un caso determinado se pudiese interpretar que este concepto comprenda también la fuerza "económica" y la "política". En este sentido, durante la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados se adoptó una *Declaración sobre la prohibición de la coacción militar, política o económica en la celebración de tratados*²³⁴ en la que se condena solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad del consentimiento.

El art. 51 recoge, en cambio, un principio que había sido aceptado en el derecho internacional clásico. Se trata de la coacción ejercida en forma personal, sobre el representante del Estado, mediante actos o ame-

²³¹ "Un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho que le es contemporáneo", Arbitraje de la Isla de Palmas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. II, pág. 845.

²³² Conf. opinión de la C.D.I. expresada en *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9 (A/6309/Rev. 1), págs. 79-80.

²³³ Conf. art. 51 de la Carta ONU.

²³⁴ Conf., *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados*, Segundo período de sesiones, pág. 178.

nazas diversas contra él, a fin de obtener la manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado.²³⁵

iii) *Objeto lícito*: El derecho internacional clásico dejaba en total libertad a las partes para determinar el objeto del acuerdo de voluntades. La Convención, en cambio, le pone un límite, estableciendo el art. 53 la nulidad absoluta de todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Como ya se ha visto, la norma imperativa es una norma *aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados* en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser *modificada* por una norma que tenga el mismo carácter. La primer característica que presenta la regla imperativa es la necesidad de que la comunidad internacional no sólo la "acepte" como ocurre con la costumbre, sino que, además, la "reconozca" tal como lo hacen los Estados al concluir un acuerdo internacional. En segundo lugar, la norma imperativa no podrá ser derogada por la voluntad de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, sino, simplemente, "modificada" mediante otra norma que tenga idéntica naturaleza. La referencia al concepto de "comunidad internacional" nos indica que estamos en presencia de una *regla necesaria para la mínima convivencia pacífica de sus miembros* y que recoge valores o principios inexcusables que configuran un verdadero orden público internacional.

Mucho se ha discutido sobre el contenido de esta categoría normativa. En realidad, la respuesta sólo podrá conocerse en el momento en que planteada una controversia se determine que la regla invocada como imperativa ha sido reconocida y aceptada como tal por la comunidad internacional de Estados en su conjunto —lo que no implica decir *todos* los Estados— y que constituye un presupuesto necesario a la ordenada coexistencia de la comunidad internacional.

c) Terminación de los tratados

El hecho de que un tratado termine, o que una de las partes en el tratado no se encuentre ya obligada por él, significa que éste ha dejado de estar en vigor, o que ha dejado de estar en vigor para dicha parte. La regla del art. 26 sólo cubre a los tratados en vigor. Estos deben ser respetados por las partes y nadie puede pretender su modificación o su terminación si no es por alguna de las causas previstas en la Convención (art. 42). El art. 70 (1.b), consagra la irretroactividad de la terminación del tratado. Este deja de producir efectos jurídicos a partir del momento en que se le pone fin, pero tal hecho no afectará a ningún dere-

²³⁵ Como ejemplo se cita el caso del Presidente Hacha y del Ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia que fueron conducidos mediante métodos intimidatorios y amenazas contra su país, a firmar el tratado del 14-III-1939 instituyendo el protectorado alemán sobre Bohemia y Moravia.

34

cho, obligación o situación jurídica de las partes creada por la ejecución del tratado antes de su terminación. Un Estado, para liberarse de las obligaciones contenidas en un tratado, puede alegar una causa de nulidad o de terminación. Por ello la Convención se ocupa de ambas en la parte V con un régimen jurídico parcialmente común.²³⁶ Sin embargo, ambas instituciones tienen una naturaleza jurídica diferente y producen efectos jurídicos distintos.²³⁷ La Convención no prejuzga las consecuencias jurídicas que pueden acarrear, con relación a los tratados, la ruptura de hostilidades (art. 73), o la ruptura o ausencia de relaciones diplomáticas o consulares (art. 74), ni tampoco se ocupa de los supuestos en que las actitudes de las partes, o de alguna de las partes, en un tratado pueden hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional (art. 73).

Los tratados pueden terminar en virtud de la voluntad de las partes o en razón de la aplicación de ciertas normas del derecho internacional general.

i) Terminación del tratado por voluntad de las partes: Un tratado terminará en la fecha o en el momento en que sus propias disposiciones lo establecen [art. 54, a) 1]. Así, por ejemplo, si el tratado se ha concluido por un plazo de diez años, a la expiración de éste, el tratado se extinguirá. Puede también expresarse en su texto una condición resolutoria por la que en el momento en que se produzca el tratado terminará.²³⁸

Distinta es la situación que se plantea con relación al derecho de una de las partes de declarar que el tratado deja para ella de estar en vigor. El equilibrio de las relaciones emergentes de un tratado y la igualdad jurídica de las partes indican que un Estado no puede unilateralmente ponerle fin. Sólo podrá ejercerse el derecho de denuncia o retiro si el tratado mismo lo prevé; si la parte que intenta ejercerlo puede acreditar que consta de algún modo que fue la intención de las partes admitir tal posibilidad; o, si de la naturaleza del tratado puede inferirse el derecho de denuncia o retiro (art. 56).²³⁹

Un tratado puede terminar, también, si todas las partes,²⁴⁰ luego de consultar a los demás Estados contratantes, dan su consentimiento para

²³⁶ Este régimen común es el referido a las disposiciones generales y al procedimiento de solución de controversias.

²³⁷ Véase, en este punto, las consecuencias jurídicas de la nulidad y de la terminación de los tratados.

²³⁸ El Pacto de Varsovia contiene una condición resolutoria según la cual dejará de producir efectos jurídicos cuando se concluya un tratado previendo un sistema general de seguridad colectiva para toda Europa.

²³⁹ Derecho de denuncia —terminología comúnmente aplicada a los tratados bilaterales— o de retiro —terminología comúnmente aplicada a los tratados multilaterales.

²⁴⁰ En la opinión consultiva sobre el Régimen internacional del Sud-Oeste africano, *Recueil*, 1950, pág. 128, la C.I.J. admitió que el mandato era asimilable a un régimen internacional y que era necesario el consentimiento de las Naciones Unidas para que la Unión Sud-Africana pudiese modificarlo. Lo mismo se sostuvo en el caso del Sud-Oeste Africano, *Recueil*, 1962, pág. 319.

que ello ocurra [art. 54, b)]. No es necesario que el consentimiento se dé en otro tratado. Las partes pueden, al efecto, concluir todo tipo de acuerdo. Esto significa que el derecho internacional no ha reprobado la teoría "del acto contrario" de derecho interno. Corresponde, entonces, a los Estados interesados decidir la forma en que pondrán fin al tratado. Es posible considerar comprendido en esta disposición a la costumbre abrogatoria. Si de la práctica ulterior a la conclusión del tratado emerge que las partes han tenido la intención de ponerle fin se podrá entender, válidamente, que éste ha terminado por *desuetudo*.²⁴¹

Un tratado puede terminar porque todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia siempre que se desprenda del tratado posterior, o conste de otro modo, que tal ha sido la intención de las partes; o, las disposiciones del tratado posterior sean hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no puedan aplicarse simultáneamente (art. 59). El principio según el cual "la ley posterior deroga la ley anterior" indica la primacía del segundo tratado sobre el primero.²⁴² Este es un supuesto de terminación implícita por el hecho de la conclusión de un tratado posterior²⁴³ a diferencia del caso de terminación explícita contemplado en el art. 54, b). El art. 30, 3, considera el caso de las disposiciones de dos tratados que están en contradicción en tanto que el art. 59, b), se refiere a la terminación del tratado en sí mismo.

El art. 55 de la Convención establece que en el caso de un tratado multilateral en que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, éste no terminará por ese solo hecho, salvo que el tratado disponga otra cosa.²⁴⁴

De acuerdo a las disposiciones de la Convención —arts. 57 y 59— las normas sobre terminación de los tratados por voluntad de las partes son aplicables, *mutatis mutandi*, a los casos de suspensión de la aplicación

²⁴¹ Guggenheim, P., *Traité de droit international public*, t. I, pág. 225, reconoce que en virtud del derecho internacional general un tratado deja de estar en vigor cuando se forma una costumbre contraria de carácter derogatorio. Sin embargo, como este derecho no establece plazos de prescripción, la prescripción liberatoria se confunde con la fuerza derogatoria del derecho internacional consuetudinario. La abrogación de las convenciones internacionales por *desuetudo* fue reconocida en la sentencia arbitral del 21-X-1861 dada por el Senado de Hamburgo en el caso Yüille-Shorridge, entre Gran Bretaña y Portugal (Lapradelle y Politis, t. II, pág. 105).

²⁴² Conf. lo dicho en este punto, sobre *Observancia y aplicación de los tratados* con relación al art. 30 de la Convención.

²⁴³ Conf. opinión disidente del juez Anzilotti en el caso de la *Compañía de electricidad de Sofía*, C.P.J.I., Serie A/B, n° 77, pág. 92, "es generalmente admitido, que al lado de la abrogación expresa hay, también, una abrogación tácita que resulta del hecho en virtud del cual las disposiciones nuevas que formaba el objeto de estas últimas se encuentran reglada ahora por las nuevas disposiciones".

²⁴⁴ Así, si luego de entrar en vigor una Convención que exija por los menos treinta expresiones del consentimiento, en ejercicio del derecho de retiro, diez Estados dejan de ser parte en ella y el número de Estados parte queda por ese hecho reducido a veinticinco, a menos que el tratado mismo disponga otra cosa, éste seguirá estando en vigor, vinculando a los veinticinco Estados que aún son parte en él.

por voluntad de las partes. Esto se explica porque la consecuencia inmediata de la suspensión es la de impedir que el tratado produzca efectos jurídicos, limitada, en este supuesto, a un tiempo determinado. La norma del art. 58 autoriza a que dos o más partes en un tratado multilateral puedan celebrar un acuerdo *inter se* con el objeto de suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas si la posibilidad de tal suspensión está prevista en el tratado o, en caso de silencio del tratado, si con el acuerdo posterior no se afecta el disfrute de los derechos que a las demás partes corresponden en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones y la suspensión no es incompatible con el objeto y el fin del primer tratado. Esta norma concuerda con la contenida en el art. 41 sobre acuerdos tendientes a modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente. Ambas no prejuzgan sobre la responsabilidad en que puedan incurrir los Estados parte en el segundo acuerdo frente a los Estados parte en el primero en razón de la reserva general contenida al respecto en el art. 73 de la Convención; sólo se limitan a considerar cuándo el segundo tratado será válido entre las partes que lo han concluido.²⁴⁵

ii) *Terminación del tratado en razón de la aplicación de ciertas normas del derecho internacional general*: Los tratados pueden terminar, también, no ya por voluntad de las partes sino en virtud de ciertas disposiciones del derecho internacional general, codificadas por la Convención.

Así, el art. 60, 1. autoriza a una de las partes en un tratado bilateral, ante una violación grave del tratado cometida por la otra, a *alegarla* como causal de terminación o de suspensión de su aplicación total o parcialmente.²⁴⁶ Corresponde, entonces, a la parte perjudicada elegir entre solicitar la ejecución del tratado o invocar la violación como causa de extinción. Esta norma se funda en el principio del equilibrio de las prestaciones contenidas en un tratado.²⁴⁷ El derecho de invocar la violación como motivo de terminación existe sin perjuicio del derecho que podría tener la parte perjudicada de presentar una reclamación para ob-

²⁴⁵ En lo que concierne a la relatividad de los vínculos que emergen de un tratado multilateral recordar lo dicho con relación al art. 30, 4.

²⁴⁶ Conf., art. 44 sobre supuestos de divisibilidad de las disposiciones de un tratado.

²⁴⁷ En el caso de *las tomas de agua del Mosa*, C.P.J.I., Serie A/B, n° 70, Bélgica había pretendido que, construyendo ciertas obras contrarias al tratado de 1863, los Países Bajos habían perdido el derecho de invocarlo frente a ella. Reivindicaba, así, el derecho de suspender la ejecución de una de las disposiciones del tratado argumentando que los Países Bajos lo habían violado. Fundaba sus pretensiones en la aplicación del principio *in adimplenti non est adimplendum*. En razón de juzgar que los Países Bajos no habían violado el tratado, la Corte no se pronunció sobre el argumento de Bélgica. Sin embargo, en una opinión disidente, el juez Anzilotti expresó su criterio en el sentido de que el principio invocado por Bélgica era "tan justo, tan equitativo, tan universalmente reconocido que tenía que ser aplicado también en las relaciones internacionales". La U.R.S.S. declaró caducas sus alianzas con Gran Bretaña (1942) y con Francia (1944) en razón de entender que la conclusión por las potencias occidentales de los Acuerdos de París de 1954 con la República Federal de Alemania comportaba violación de los tratados anteriores.

tener reparación sobre la base de la responsabilidad internacional de la otra parte (art. 73). En el caso de una violación grave de un tratado multilateral, establece el art. 60, 2. que las demás partes, por acuerdo unánime, podrán tanto *suspender* su aplicación como *darlo por terminado* sea en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación o entre todas las partes. La parte que haya resultado *especialmente perjudicada* por la violación podrá *alegarla* como causa para *suspender* la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación. Este supuesto es idéntico al contemplado en el art. 60, 1. aplicable a los tratados bilaterales, en razón de que un tratado multilateral, en lo que concierne a la multiplicidad de vínculos jurídicos que se entablan en virtud de él, vendría a resultar en último análisis una suma de tratados bilaterales.²⁴⁸ Finalmente, *cualquier otra parte* podrá *alegar* la violación como causa para *suspender* la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado. El inc. 3 del artículo que consideramos define los hechos que constituirán *violación grave* de un tratado. Establece que tal será un rechazo del tratado no admitido por la Convención de Viena²⁴⁹ o la violación de una disposición esencial para la realización del objeto o del fin del tratado. Es decir, que la violación debe referirse a una disposición *esencial*, lo que no implica, necesariamente, que se trate de una cláusula *fundamental*, entendiendo por tal sólo aquellas que conciernen directamente a los fines últimos del tratado. Otras disposiciones que la parte considera como esenciales para la realización efectiva de los fines del tratado pueden haber sido decisivas para que concluya el tratado, aun cuando las cláusulas, en sí mismas, fuesen de naturaleza accesoria.²⁵⁰ Durante la Conferencia se acogió, normativizándolo en el art. 60, 5. el criterio doctrinario según el cual ciertas categorías de tratados no deben terminar por el hecho de su violación. Se trata de aquellos que tienen por objeto la protección de los heridos, de los enfermos y de los prisioneros en caso de lucha armada y, en general, todas las convenciones relativas a la protección de la persona humana.²⁵¹ Este párrafo excluye, así, de la aplicación de los principios de los párrafos 1. a 3 a los tratados de carácter humanitario.

El art. 61 autoriza a una parte a *alegar* la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para *darlo por terminado* o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la *desaparición* o *destrucción definitiva* de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad

²⁴⁸ Aplicación del principio de la relatividad de las relaciones emergentes de un tratado multilateral.

²⁴⁹ Por ejemplo: la denuncia de un tratado que no la autoriza y que no está encuadrada en ninguno de los dos supuestos de licitud del art. 56.

²⁵⁰ Conf., *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9 (A/6309/Rev. 1), págs. 87-88.

²⁵¹ Enmienda presentada por Suiza (A/Conf. 39/L.31).

es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para *suspender* la aplicación del tratado. Se contempla entonces el caso de fuerza mayor aun cuando ésta sea, en realidad, una causa eximente de responsabilidad por la inexecución de una obligación y la Convención no quiera prejuzgar sobre ninguna cuestión que pueda surgir como consecuencia de la responsabilidad internacional de un Estado (art. 73). Para ciertos autores²⁵² la desaparición de uno de los Estados parte pondría fin a un tratado bilateral si las obligaciones que en él se estipulan no se transmitiesen al Estado que lo sucede. Pero aquí se plantearía un problema de sucesión de Estados sobre el que la Convención tampoco ha querido prejuzgar (art. 73). En realidad, los casos de imposibilidad resultante de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado son casos en los que hay un cambio fundamental en las circunstancias que existían cuando se concluyó el tratado, situación contemplada en el art. 62. Sin embargo la C.D.I., y luego la Conferencia, prefirieron redactar dos disposiciones distintas dado que el supuesto del art. 62 puede involucrar otras situaciones y se expresa, además, en forma limitativa y como causa de excepción.

El caso del art. 62 es el de la llamada cláusula *rebus sic stantibus* que, para parte de la doctrina, sería una disposición implícita en toda convención²⁵³ —una condición resolutoria tácita— en virtud de la cual podría abrogársela unilateralmente cuando las circunstancias existentes a la época de su conclusión sufriesen modificaciones notables. Se trataría, entonces, de descubrir la voluntad común de las partes a la época de la conclusión del tratado para determinar si cabe o no considerar que el acuerdo ha terminado. Para otros autores, en cambio, sería una expresión del “estado de necesidad sobreviniente” por un hecho imprevisible a la época de la conclusión, que pondría en peligro la existencia de la parte que la invoca y que en razón del derecho de conservación le permitiría poner fin unilateralmente al tratado. El fundamento de la disposición contenida en la Convención es el de permitir la terminación del tratado unilateralmente sólo en ciertos supuestos excepcionales por razones de equidad y de justicia compatibilizando, mediante una norma objetiva, el interés de las partes con la regla *pacta sunt servanda*.²⁵⁴ Es así que sólo es posible alegar como causa para dar por terminado un tratado, un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración si: a) la existencia de esas circunstancias constituyen una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por

²⁵² Conf. Guggenheim, P., *Traité de droit international public*, t. I, pág. 226.

²⁵³ En el caso de los *Decretos de nacionalidad*, C.P.J.I., Serie C, n° 2, págs. 208 y 209 el Gobierno francés hizo valer que los “tratados perpetuos eran siempre susceptibles de terminar en virtud de la cláusula *rebus sic stantibus*” y que el establecimiento de un protectorado francés en Marruecos tenía por efecto abrogar ciertos tratados franco-británicos.

²⁵⁴ El inc. 1 del art. 62 se expresa en forma negativa; un Estado “no podrá” alegar... “a menos que”.

el tratado, y b) si ese cambio tiene por efecto *modificar radicalmente el alcance* de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.

El art. 62, 2.b), recoge un principio general de derecho al establecer que si el cambio fundamental de las circunstancias resulta de una violación al tratado o a una obligación del derecho internacional general, la parte que cometió tal violación no podrá alegarlo como causal para dar por terminado el tratado.²⁵⁵

Nunca podrá invocarse un cambio fundamental en las circunstancias como causal para dar por terminado un tratado o retirarse de él si se trata de un tratado que establece una frontera (art. 62, 2.a).

Finalmente, un tratado terminará y será nulo si luego de su conclusión surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general a la que éste se oponga (art. 64). En este supuesto, el objeto del tratado se convertirá en un ilícito internacional en razón de ser contrario al orden público internacional. Esta disposición es concordante con la contenida en el art. 53 sobre la nulidad absoluta de todo tratado que al momento de su celebración esté en oposición con una norma de *jus cogens*.

d) *Procedimiento de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la aplicación o interpretación de las disposiciones de la Convención relativas a la nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado*

El proyecto preparado por la C.D.I. sólo contenía como mecanismo de solución de las controversias que se pudiesen plantear con motivo de la Parte V de la Convención, la disposición del actual art. 65 que en sustancia remite a los medios indicados en el art. 33 de la Carta ONU.²⁵⁶ Los miembros de la C.D.I. consideraban que si se permitía invocar arbitrariamente una causal de nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de un tratado, peligraría la estabilidad de las relaciones internacionales. De allí que juzgasen esencial incluir en el proyecto normas referidas a las garantías del procedimiento a seguir para solucionar la eventual controversia.²⁵⁷ Ya en la Conferencia de Viena se manifestaron posiciones divergentes. Algunos Estados sostenían la necesidad de un mecanismo obligatorio de solución de controversias, de tipo jurisdiccional, aplicable a

²⁵⁵ La cláusula *rebus sic stantibus* fue invocada por Rusia para considerarse liberada de su obligación de mantener la neutralidad del Mar Negro y de no construir fortificaciones en sus márgenes, alegando como motivo la guerra franco-prusiana de 1870.

²⁵⁶ Los medios enumerados en dicho artículo son la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a elección de los Estados parte en la controversia.

²⁵⁷ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésima primera sesión, Suplemento n° 9 (A/6309/Rev. 1)*, págs. 94-97.

toda la Convención.²⁵⁸ Otros consideraban que éste sólo sería adecuado en los supuestos de invocación del *jus cogens*, en tanto que para las demás disposiciones de la Parte V sólo correspondería una referencia a los medios de solución pacífica de las controversias indicados en el art. 33 de la Carta de la ONU y, en caso de fracaso, la remisión a una jurisdicción arbitral, salvo que por acuerdo de las partes en la controversia se otorgase jurisdicción a la C.I.J.²⁵⁹ Un tercer grupo proponía un nuevo artículo en el que se estableciese un mecanismo de conciliación obligatoria bajo la égida de la ONU.²⁶⁰

Recién un día antes de la clausura de la Conferencia se logró llegar a un acuerdo. El punto de partida fue la propuesta de los "diez países".²⁶¹ En ella se sugería que en los casos de una controversia relativa a problemas de *jus cogens* cada parte "puede, por demanda, someterla a la decisión de la C.I.J. a menos que las partes de común acuerdo decidan someter el diferendo al arbitraje". Sin embargo, mientras Francia seguía sosteniendo que esa redacción no otorgaba con claridad un derecho de citación directa ante la C.I.J. en los términos del art. 36, 1 del Estatuto de ésta, quitándole seguridad al sistema, el grupo de los países del Este la consideraba como creativa de una obligación absoluta, que sólo hubieran aceptado de haber obtenido en la negociación la contrapartida que ellos esperaban: el reconocimiento de la universalidad de la Convención mediante la inclusión de la cláusula "todos los Estados".²⁶² No obstante estas posiciones extremas que se mantuvieron en la votación final, la propuesta obtuvo la mayoría necesaria para su adopción, estableciéndose el sistema de solución de controversias contenido en los arts. 65 a 68 y el Anexo de la Convención.

Según este mecanismo, cuando una parte, basándose en las disposiciones de la Convención alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar por escrito a las demás partes su pretensión, indicando la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta se funde. El instrumento de notificación deberá ser firmado por quien tenga la capacidad para representar al Estado a tal fin. Si transcurrido un plazo prudencial, que en ningún supuesto deberá ser inferior a tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, es decir, si no se plantea una controversia, la parte que haya

²⁵⁸ Propuestas de Suiza (A/Conf. 39/C.1/L.250 y A/Conf. 39/L.33) que apoyaban Filipinas, Italia, El Salvador y Colombia, implicando el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la C.I.J.

²⁵⁹ Enmienda de Japón (A/Conf. 39/C.1/L.338 y L. 339).

²⁶⁰ Proposición de los "diecinueve países" (A/Conf. 39/C.1/L.352 Rev. 1 y Corr. 3).

²⁶¹ Ghana, Nigeria, Tanzania, Sudán, Líbano, Kuwait, Marruecos, Túnez, Kenia y Costa de Marfil (A/Conf. 39/L.47/Rev. 1).

²⁶² Véase lo dicho al referirnos a la adhesión y la nota referida al artículo 5 bis sobre derecho a participar en los tratados.

hecho la notificación podrá adoptar la medida que haya propuesto. Si, por el contrario, una parte formula una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el art. 33 de la Carta de la ONU contando para ello con un plazo de doce meses a partir de la fecha en que se haya formulado la objeción. Transcurrido este término, si la controversia aún sigue pendiente y se trata de un problema relativo a la aplicación o a la interpretación de los arts. 53 o 64 de la Convención, cualquiera de las partes en la controversia, sin necesidad de requerir el consentimiento previo de la otra, puede llevar el caso ante la C.I.J., a menos que de común acuerdo decidan someterlo al arbitraje. Si se trata de la interpretación o de la aplicación de cualquier otro de los artículos de la Parte V, transcurrido el plazo de doce meses, cualquiera de las partes en la controversia puede presentar una solicitud al Secretario General de la ONU para que éste la someta a una comisión de conciliación. El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán un amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados y uno que no tenga la nacionalidad de ellos. Estos cuatro elegirán un quinto que será el presidente de la comisión. La designación de este último debe recaer en una persona cuyo nombre esté en una lista que establecerá el Secretario General integrada por juristas nombrados por los Estados miembros de la ONU o parte en la Convención. Cada Estado podrá designar hasta dos amigables componedores para formar la lista. Si las designaciones para integrar la comisión no se efectúan en los plazos que se prevén en el Anexo de la Convención, el Secretario General podrá hacer los nombramientos. Una vez en funciones, la comisión fijará las normas en virtud de las cuales se va a desarrollar el procedimiento ante ella. Luego de oír a las partes presentará un informe que se depositará en poder del Secretario General y se transmitirá a las partes en la controversia. Este no las obligará ni tendrá otro carácter que de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa.

El sistema de la Convención tiene carácter supletorio, es decir, sólo se aplicará si las partes en la controversia no han establecido entre ellas ningún otro mecanismo de solución. Es, evidentemente, fruto del compromiso logrado en Viena entre las distintas posiciones sostenidas por los Estados y quizá la práctica posterior a la entrada en vigor de la Convención lo revele insuficiente para proteger la estabilidad de los tratados.

e) Consecuencias de la nulidad.

Precisa la Convención que es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de ella y que las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. Empero, si a pesar de la nulidad se han ejecutado actos basados en el tratado nulo, se hace menester distinguir la situación que se presenta con relación a los actos cumplidos en virtud del

tratado con antelación a la determinación de la nulidad y la que se plantea con relación a los actos posteriores a tal momento.

ii) Actos anteriores: En los casos en que la nulidad se declare por error, violación del derecho interno o exceso de poder del representante del Estado, cualquiera de las partes en el tratado podrá exigir de la otra u otras partes que, en la medida de lo posible, vuelva las cosas al estado anterior, restableciendo la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado tales actos. Esta solución dada por la Convención no prejuzga en modo alguno sobre el problema que se pueda plantear con relación a la responsabilidad internacional de los Estados parte en el tratado, o sobre cuestiones referidas a la reparación. Sin embargo, los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado.

En los casos en que la nulidad se declare por dolo o corrupción o cuando el tratado carezca de efectos jurídicos por la coacción ejercida sobre el representante del Estado o sobre el Estado mismo, aun los actos ejecutados presumiblemente de buena fe por la parte a quien le sea imputable el dolo, el acto de corrupción o la coacción, serán considerados como ilícitos. Este Estado no tendrá derecho a exigir de la otra, o de las otras partes, que vuelva las cosas al estado anterior a la ejecución de los actos que se realizaron en virtud del tratado.

Finalmente, si el tratado es nulo por ser contrario a una norma imperativa de derecho internacional general, las partes deben en lo posible eliminar las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa y ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa anterior a la celebración del tratado. Si, en cambio, tal norma aparece con posterioridad a la celebración del tratado y por tal hecho éste se convierte en nulo y termina, la terminación del tratado no afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general.

ii) Actos posteriores: Como principio, las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. A partir del momento en que se determine la nulidad de las disposiciones de un tratado, éstas ya no constituirán para las partes fuente de derechos y obligaciones.

f) Consecuencias de la terminación o suspensión

En este caso la Convención sólo da normas de carácter residual para el supuesto en que las disposiciones del tratado que termina, o se suspende, no contemplen tal situación o que las partes no convengan algo al respecto.

Ante el silencio del tratado y la no existencia de convenio de las partes, la Convención establece que la terminación del tratado, o la suspensión de su aplicación, eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliéndolo; sin perjuicio del deber que les incumbe de continuar acatando las obligaciones enunciadas en él a las que estén sometidas en virtud del derecho internacional independientemente del tratado que termina o se suspende.

En lo que concierne a los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de los Estados parte creados por la ejecución del tratado antes de su terminación o suspensión, éstos seguirán siendo válidos. Cabe destacar que esta disposición se refiere a las partes y no contempla el problema que se pueda plantear con motivo de "derechos adquiridos" por los particulares.

Al igual de lo que ocurre en el caso de un tratado nulo, en este supuesto la Convención tampoco prejuzga sobre la responsabilidad internacional de los Estados parte en el tratado, o sobre cuestiones referidas a la reparación, que se pudiesen originar en actos que motivaron la terminación del tratado; tales como su violación por una de las partes.

5. Depósito, corrección de errores en los textos, registro y publicación de los tratados

La Parte VII de la Convención está dedicada a las normas procesales que rigen los mecanismos que siguen los Estados interesados luego de la celebración del tratado, no ya con relación a la forma de obligarse o a los efectos jurídicos que puede producir el tratado para las partes, sino en lo que concierne al tratado mismo.

a) Depósito

Los Estados negociadores, al adoptar las "disposiciones finales" de un tratado, pueden establecer que uno o varios de ellos, o una organización internacional o el principal funcionario administrativo de una organización internacional, sea el depositario del tratado. Quien, o quienes, sea designado con tal carácter será el encargado de guardar el texto auténtico del tratado, así como todos los demás instrumentos que se refieran a éste. Podrá extender copias certificadas del texto original; deberá informar a las partes y a los Estados facultados para llegar a serlo de los actos, de las notificaciones y comunicaciones relativos a éste; deberá, además, informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la

²⁶³ El Tratado de 1963 que prohíbe los ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua, por ejemplo, prevé varios depositarios en vez del tradicional depositario único (EE.UU., el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la U.R.S.S.). Lo mismo ocurre con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

fecha en que se ha recibido o depositado, el número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesarios para la entrada en vigor del tratado. Será quien se ocupe de registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas y, en general, deberá desempeñar todas las funciones que se le otorgan en virtud de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las que se establezcan en el tratado que lo designa y las que los Estados contratantes le confíen.

El depositario tiene el carácter de funcionario internacional en lo que hace al desempeño de sus funciones, lo que implica una imparcialidad total en su gestión. Si llegase a surgir una discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del desempeño de las tareas de éste, el depositario tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de los Estados signatarios y de los Estados contratantes. Por ello, el papel que cumple con relación al tratado es puramente técnico, limitándose sus facultades de control a los aspectos formales del tratado y de los demás instrumentos relativos a éste. El depositario no debe efectuar apreciaciones de carácter político o relativas al fondo. Así, al recibir instrumentos que contengan, por ejemplo, objeciones a reservas, debe limitarse a ponerlos en conocimiento de los demás Estados parte en el tratado y de los facultados para llegar a serlo, sin abrir juicio sobre ellas.

b) Corrección de errores en los textos

Si luego de la autenticación del texto de un tratado los Estados signatarios y los Estados contratantes advierten que existe un error podrán proceder a su corrección.

La Convención distingue, en cuanto al procedimiento a seguir, entre los casos en que existe un depositario del tratado y aquéllos en que no se ha efectuado tal designación. En ambos supuestos, sin embargo, para proceder a la corrección es necesario que medie acuerdo entre todos los signatarios y contratantes.

En el caso en que haya un depositario, éste notificará a los signatarios y a los contratantes el error y la propuesta de corregirlo y fijará un plazo adecuado para que se hagan objeciones a la corrección propuesta. A su expiración, si no ha mediado objeción, será el depositario quien efectuará la corrección del texto y la rubricará, extendiendo un acta de rectificación del texto que comunicará con copia a las partes y a los Estados facultados para llegar a serlo. Si se ha formulado una objeción, el depositario la comunicará a los signatarios y a los contratantes.

Cuando no haya depositario del tratado, a menos que los Estados signatarios y contratantes decidan actuar de otro modo, éstos procederán a introducir la corrección pertinente en el texto, rubricándola; o bien formalizarán un instrumento o canjearán instrumentos en los que se haga constar la corrección; o bien formalizarán por el mismo procedimiento que se haya empleado para el texto original, un texto corregido de todo el tratado.

Estas disposiciones se aplican también al caso de un tratado autenticado en dos o más idiomas.

El texto corregido sustituirá *ab initio* al texto defectuoso, a menos que los Estados signatarios y los Estados contratantes decidan otra cosa al respecto.

Si el tratado ha sido registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas, la corrección deberá serle notificada.

c) Registro y publicación

La creencia de que la publicidad de las relaciones internacionales es un factor de paz, determinó que en el Preámbulo del Pacto de la Sociedad de las Naciones se repudiase la diplomacia secreta. Acorde con ello, el art. 18 del Pacto establecía la obligación de los Estados miembros de la organización de registrar en la Secretaría, para su publicación, todos los compromisos internacionales que concluyesen. La sanción prevista en caso de incumplimiento, cuyo rigorismo no se vio reflejado en la práctica, era la no obligatoriedad del acuerdo. El art. 102 de la Carta de la ONU retoma esta disposición con relación a los miembros de la organización, pero la sanción no es ya la invalidez del acuerdo sino la prohibición de invocar ante sus órganos el compromiso no registrado. Es decir, que el acuerdo es válido en sí mismo y obliga a los Estados parte. Por una resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de febrero de 1946 los Estados no miembros de la organización tienen la facultad de pedir el *archivo e inscripción* de los compromisos que concluyan. A su vez el reglamento del 24 de diciembre de 1946, modificado el 12 de diciembre de 1950, establece que el Secretario General debe registrar *ex officio* un tratado o acuerdo internacional cuando la organización misma es parte.

El art. 80 de la Convención amplía el ámbito de validez personal del art. 102 de la Carta de la ONU a todos los Estados que lleguen a ser partes en esta Convención, independientemente de su carácter de miembros de la organización. De allí la terminología empleada en el párrafo 1.º al establecer que los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o *archivo e inscripción*, según el caso, y para su publicación. La Secretaría General de la ONU publica una colección de tratados registrados en francés y en inglés que continúa una serie similar llevada por el Secretario de la Sociedad de las Naciones.

El párrafo 2 del art. 80 concuerda con lo dispuesto en el art. 77, 1.º g) en el sentido de que el depositario de un tratado será la persona autorizada para transmitirlo a la Secretaría de las Naciones Unidas a fin de su registro, o archivo e inscripción, y su publicación. Esto, sin embargo, no modifica en nada el alcance de la obligación de los Estados miembros de la ONU de conformidad al art. 102 de la Carta.

4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO

La doctrina moderna no está en un todo de acuerdo sobre la naturaleza de los principios generales de derecho como fuentes creadoras de normas jurídicas internacionales. Tratadistas como Rousseau, Starke y Podestá Costa, por distintos motivos, no le dan a los principios generales de derecho jerarquía de fuentes principales, sino de meras fuentes subsidiarias o auxiliares en la verificación de las reglas del derecho internacional. Estas posturas doctrinarias no se compadecen con el contenido del art. 38, 1 del Estatuto de la C.I.J. que dice que "La Corte... deberá aplicar... c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas..." Para determinar la naturaleza de los principios generales de derecho como fuentes principales, o sea como fuentes creadoras, de acuerdo al inc. c) del art. 38.1, debemos distinguir entre principios generales de derecho interno reconocidos por los Estados civilizados y principios generales del derecho internacional.

a) Principios generales de derecho reconocidos por los Estados en sus ordenamientos internos

El art. 38, 1.c), se refiere concretamente a los principios generales de derecho interno reconocidos por los Estados civilizados. Esta interpretación no sólo se fundamenta en la exégesis misma del art. 38, sino que reconoce la intención de la Comisión de Redacción del Estatuto de la C.P.J.I., defendida especialmente por Lord Philimore, como miembro integrante de dicha Comisión.

Lauterpach sostiene que los principios generales de derecho, mentados por el art. 38, provienen de ciertas nociones esenciales de los ordenamientos jurídicos internos.²⁰⁴ El hecho de que los Estados apliquen internamente principios de derecho concordantes con los aplicados por otros Estados, fundamenta la presunción de que la intención común es también la de aplicarlos en sus relaciones mutuas. Esta presunción ha sido corroborada, incluso con anterioridad a la redacción del primitivo art. 38 del Estatuto de la C.P.J.I., por la práctica reiterada de los Estados.

²⁰⁴ Lauterpacht, H., *Private Law sources and analogies of International Law*, Londres, 1927.

Esta última aseveración implica reconocer a una costumbre internacional como la fuente creadora de la norma jurídica que establece que los principios generales de derecho interno reconocidos por los Estados civilizados son, a su vez, fuentes creadoras, pero deducir de este razonamiento que los principios generales de derecho no serían fuentes creadoras sino meros modos de verificar la existencia de una norma jurídica internacional (que reconoce por antecedente una costumbre internacional), es confundir el problema que plantean las fuentes del derecho con el fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico internacional.

Dentro de esta misma argumentación se ha sostenido²⁰⁵ que los tratados descansan, como fuentes creadoras, en una norma consuetudinaria, (*pacta sunt servanda*) y que si bien tanto la costumbre, como los tratados y los principios generales de derecho deben ser aplicados por la C.I.J. de acuerdo al art. 38 de su Estatuto, la obligatoriedad de este último como convenio internacional, proviene de aquella misma regla consuetudinaria, fundamento último de todos los acuerdos internacionales.

Para nosotros, una vez que el derecho vigente se cristaliza en un sistema de fuentes determinado, los llamados a aplicar el derecho creado por esas fuentes no necesitan recurrir a sus fundamentos de obligatoriedad, sino que simplemente deben aceptarlas, aplicándolas como obligatorias. Por ello, cada uno de los principios generales de derecho interno, reconocidos por los Estados, no necesita de una costumbre antecedente para ser aceptado individualmente como fuente creadora del derecho internacional. La utilización de un sistema analógico y comparativo para determinar qué principios de derecho interno adquieren categoría de fuentes creadoras del derecho internacional es totalmente independiente de la existencia, o no, de la práctica concurrente de los Estados que así los acepten. El sistema analógico basado en el estudio comparativo de los distintos órdenes jurídicos internos es un proceso orientado a la determinación de principios coincidentes y no necesariamente a la comprobación del consenso de los Estados sobre esas coincidencias.

Por otra parte, la circunstancia de que el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia —a diferencia del artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional— establezca que las controversias internacionales deben ser decididas "conforme al derecho internacional", ha sido considerada como un obstáculo para admitir la eficacia internacional de las reglas de derecho interno. Tal consideración es equívoca, porque lo que el art. 38, 1.c) hace, es reconocer la existencia de normas de derecho internacional autónomas, compuestas o integradas por normas de derecho interno comunes a los distintos sistemas jurídicos.

En la práctica de la C.I.J., al igual que en la de la C.P.J.I., la coincidencia de opiniones de sus miembros sobre los principios generales de derecho interno de los Estados —que adquieren calidad de fuentes creadoras del derecho internacional— comporta la utilización de un proceso

²⁰⁵ Kelsen, H., *op. cit.*, págs. 268-269.

analógico, garantizado, en cierta forma, por el hecho de ser aquéllos, en su conjunto, representantes de las grandes civilizaciones y de los principales sistemas jurídicos del mundo, en conformidad con el art. 9 del Estatuto de la C.I.J.

La C.I.J., al igual que la C.P.J.I., si bien no ha hecho en sus fallos u opiniones consultivas expresa referencia a la aplicación del art. 38, 1.c), en reiteradas ocasiones ha aplicado principios "generalmente reconocidos" que notoriamente corresponden a los principios generales de derecho interno, concordantes entre los Estados.²⁶⁶ Tales como el de la obligación de reparar el perjuicio ocasionado; el principio de que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee; la autoridad de la cosa juzgada, etcétera.

De esta realidad Guggenheim deduce que los principios generales de derecho son meramente declarativos de la jurisprudencia reiterada de los tribunales internacionales.²⁶⁷ Starke, por su parte, sostiene que el inc. c) del art. 38, 1 fue adoptado para proveer a la Corte de elementos adicionales para decidir en todos los casos, incluso en aquéllos en donde las otras fuentes fueran insuficientes. Las abstracciones que representan el contenido mismo de los principios generales de derecho determinan la imposibilidad de la existencia de situaciones *non liquet*.²⁶⁸ Por nuestra parte, observando la actividad de la C.P.J.I. y de la C.I.J., aceptamos con H. Lauterpacht que, a más de constituir una fuente autónoma, estos principios

²⁶⁶ En el caso de *las Concesiones Mavrommatis en Palestina*, C.P.J.I. (1924), Serie A, N° 2, pág. 28, el tribunal aplicó el principio general de subrogación. En el caso de las indemnizaciones de *las Fábricas de Chorzow*, C.P.J.I., Serie A, N° 17 (1928), el tribunal sostuvo que nadie puede ser juez en su propia causa —pág. 32— y que cualquier violación a un acuerdo implica una obligación de reparar —pág. 29—. En el caso de *los empréstitos Servios*, C.P.J.I. (1929), Serie A, el tribunal rechazó la aplicación del principio de preclusión (*stoppel*) como principio general de derecho; la Corte Internacional de Justicia, por su parte aplicó el principio del *Stoppel* en los siguientes casos: Caso concerniente al *Templo de Preah Vihear*, CIJ, Recueil, 1962, pág. 6; caso de la *Barcelona Traction*, excepciones preliminares, CIJ, Recueil, 1964; caso de las *Plataformas Continentales del Mar del Norte*, CIJ, Recueil, 1969, pág. 26. En el caso de las *tomas de agua del Río Mosa*, en su opinión individual, el Juez Manley O. Hudson, sostuvo que el tribunal debe aplicar la equidad como parte integrante del derecho internacional: C.P.J.I. (1937), Serie A/B, N° 70, pág. 76 y siguiente.

La CIJ argumentó en la opinión consultiva sobre el *régimen jurídico del África Sudoccidental*, CIJ, Recueil, 1950, pág. 146 y sig., sobre la importancia de la teoría general de los mandatos; en la opinión consultiva sobre el efecto de los fallos del *Tribunal Administrativo de la ONU* que acuerdan indemnización, CIJ, Recueil, 1954, pág. 53 y sig., aplicó el principio de la *res judicata*; en el caso del *África Sudoccidental* (segunda fase), CIJ, Recueil, 1966, pág. 39 y sig., negó el principio de la "*actio popularis*" como principio general de derecho y reafirmó la necesidad y universalidad de ciertos principios procesales.

²⁶⁷ Guggenheim, "*Traité de droit international public*", 2° ed., 1967, vol. I, pág. 299 y siguiente.

²⁶⁸ Starke, J. G., "*Introduction to International Law*", 7° ed., Butterworths, Londres, 1972. Conf. Kelsen, H., *op. cit.*; para Jennings los principios generales, ante aparentes debilidades u oscuridades del derecho a aplicar, permiten a los tribunales internacionales encontrar soluciones comprometidas con el desarrollo progresivo del derecho internacional.

pueden servir como importantes instrumentos para el desarrollo progresivo del derecho internacional.²⁶⁹

b) Los principios generales del Derecho Internacional

Los principios generales del Derecho Internacional son abstracciones de las normas que integran el ordenamiento jurídico internacional general; es decir, no son por sí mismas fuentes creadoras del derecho internacional. Estos principios generales del derecho pueden, sin embargo, coincidir con el contenido de una norma jurídica internacional. En estos casos, los principios generales del derecho internacional son derecho positivo, formulado por medio de una de las fuentes válidas —principales o creadoras— para el derecho internacional. Cuando mencionamos como principio general del derecho internacional a la libertad de mares, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una abstracción deducida de una costumbre internacional, reafirmada convencionalmente y que regula el comportamiento de los sujetos de derecho internacional en la alta mar. Sostener que la libertad de los mares, la igualdad y la soberanía de los Estados, la no agresión o la regla *Pacta sunt servanda* son principios generales del derecho internacional, comporta aceptar un proceso de abstracción de normas positivas que realiza la ciencia jurídica para facilitar la sistematización y conocimiento del derecho internacional vigente. Pero este proceso de abstracción no es privativo de la ciencia jurídica y muy comúnmente, en esferas políticas internacionales se habla de principios del derecho internacional, no ya como abstracciones del derecho vigente, sino como presupuestos políticos para la modificación o interpretación del derecho internacional.²⁷⁰

Cuando el juez o árbitro internacional se han referido, en reiteradas ocasiones, a los principios "reconocidos en general", la notoriedad de éstos, como abstracciones de normas jurídicas del derecho internacional,

²⁶⁹ Lauterpacht, H., "*The development of the International Law by the International Court*", Londres, ed. 1958, pág. 158 y siguiente.

²⁷⁰ Así por ejemplo, la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas —*Resolución A/2625 (XXV)*— sistematiza como principios generales del derecho, normas jurídicas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, en tanto que el capítulo I sobre Principios Fundamentales de las Relaciones Económicas Internacionales de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974, enuncia ciertos principios generales que no responden a abstracciones de normas jurídicas preexistentes. Estos últimos no podrán ser considerados como jurídicos más allá de la naturaleza propia de la Resolución de la A.G. que la enuncia o formula. Tunkin, G. J., *op. cit.*, pág. 244, sostiene que los principios generales del derecho internacional son aquéllos que pueden derivarse, únicamente, de los tratados y de la costumbre internacional, pues no existe la posibilidad de coincidencias internas entre los Estados, debido al antagonismo ideológico de los distintos órdenes jurídicos. Verdross, A., *op. cit.*, 3° ed., págs. 123-125, ha argumentado que de la interrelación de los principios del derecho internacional se fundamenta la obligatoriedad del derecho internacional; los principios generales del derecho, para este autor, son fuente principalísima que determina la unidad del derecho y fundamenta a la costumbre y a los tratados; tienen, en su opinión, un basamento suprapositivo.

exime a aquéllos de hacer referencia a la fuente creadora precedente del principio general invocado.

Una última consideración nos lleva a plantear la posibilidad de elevar los principios generales del derecho internacional a la categoría de fuentes principales, como procesos independientes de creación de normas jurídicas internacionales. Frente a este problema es importante destacar que el carácter netamente evolutivo del derecho internacional, a más del uso no exclusivo por parte de la ciencia jurídica del concepto de principios generales del derecho internacional, restaría seguridad a la determinación de la validez del contenido de éstos como base autónoma de creación de normas jurídicas internacionales.

III

1. MEDIOS AUXILIARES PARA LA DETERMINACION DE LAS REGLAS DE DERECHO

a) Decisiones judiciales

El art. 38, 1 del Estatuto de la C.I.J. establece que "La Corte... deberá aplicar: ... d) las decisiones judiciales... como medio(s) auxiliar(es) para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 59..."

El art. 59 del mismo Estatuto dice que: "La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido." Este último artículo establece el efecto de la relatividad de la cosa juzgada para los fallos de la Corte, pero nada dice sobre los alcances de éstos como modos auxiliares para la determinación de las reglas de derecho.

La remisión hecha por el art. 38 al art. 59 del Estatuto debe entenderse como una reafirmación del alcance de los fallos de la Corte, en cuanto a la imposibilidad de constituir "precedentes" creadores de normas jurídicas internacionales. Pero dicha remisión en nada obsta a que la Corte se refiera a sus fallos anteriores o a los fallos de la C.P.J.I., a los efectos de determinar la existencia de una norma del derecho internacional.

Cuando la Corte hace alusión expresa a sus sentencias anteriores no les da a éstas jerarquía de fuentes creadoras, sino que las invoca como medios por los cuales es posible verificar la existencia de normas jurídicas internacionales.

Cuando el juez aplica derecho existente para dirimir un conflicto determinado, particulariza en la sentencia derechos y obligaciones de las partes, contenidos en una norma jurídica antecedente.

La decisión judicial de la C.I.J. es siempre la consecuencia directa de la aplicación de normas jurídicas internacionales. Pero la Corte puede al aplicar una norma de derecho internacional precisar su contenido, interpretándola.

Las decisiones judiciales no son por sí mismas normas jurídicas internacionales con el alcance de fuentes creadoras de derecho, sino la prueba fehaciente y directa de la existencia de una norma jurídica preexistente,

88

La actividad propia de la Corte podrá, sí, influir en una nueva interpretación del contenido y alcance de la norma.

Cuando la Corte deba aplicar una costumbre internacional, que no ha sido formulada con precisión por la práctica reiterada de los Estados, será la misma Corte la llamada a verificar el contenido y alcance de aquélla. Esta actividad de la Corte, directamente relacionada con la determinación de las reglas del derecho internacional, formuladas a través de la costumbre, ha sido interpretada como una importante contribución al proceso del desarrollo progresivo del derecho internacional.²⁷¹

La Corte, al aplicar en sus fallos principios generales de derecho, deberá recurrir a un proceso analógico comparativo con el fin de precisar su existencia y contenido. Esta actividad de la Corte no debe ser interpretada como creadora de principios generales de derecho, pues éstos existen independientemente de su aplicación por el tribunal, al ser reconocidos como tales por los Estados.

Cabe concluir entonces, que las decisiones judiciales no son fuentes creadoras sino los medios auxiliares más efectivos para verificar la existencia de normas jurídicas internacionales.

b) La doctrina

El art. 38, 1.d), del Estatuto de la C.I.J., establece también como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho internacional, a la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones.

El publicista, o sea el estudioso del derecho internacional, no crea derecho a través de su actividad académico-científica, sino que interpreta y sistematiza el derecho existente, a la vez que propone normas de conducta de acuerdo a esquemas conceptuales predeterminados.

Cuando el art. 38, 1.d), hace referencia a la doctrina de los publicistas como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, se refiere a la actividad de interpretación y sistematización por medio de la cual puede clarificarse el alcance y contenido de las normas jurídicas internacionales existentes.

Como es muy difícil aislar la actividad del doctrinario internacional de su formación jurídico-política nacional, el art. 38, 1.d) hace expresa referencia a los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones para asegurar que la verificación de la existencia de normas jurídicas inter-

²⁷¹ Gardner, J. C., "Judicial precedent in the making of international public law", J.C.L., 3rd ser., XVII (1935), págs. 251-259, sostiene que después de los tratados, la jurisprudencia de los tribunales internacionales es la fuente más importante en el desarrollo del Derecho Internacional Público. Rousseau, Ch., *op. cit.*, pág. 69 y sig., considera a las decisiones judiciales como un positivo factor en el desarrollo de la costumbre internacional, pero sostiene que, aunque la jurisprudencia sea un elemento importante y esencial de la costumbre internacional, no puede aquélla ser considerada por sí sola como fuente autónoma del derecho.

nacionales corresponda, por lo menos, a un consenso entre distintos tratadistas representativos de los diversos ordenamientos jurídicos internos.

En la actualidad, la importancia de la doctrina como medio para determinar la existencia de normas jurídicas es limitada. Distinto fue el caso de los primeros doctrinarios del derecho internacional, quienes fueron creando un sistema técnico adecuado para estudiar y entender jurídicamente las interrelaciones de los Estados, como nuevos fenómenos políticos de los siglos XVI y XVII.

Fundamental importancia revisten a su vez los trabajos de los llamados autores tradicionales del derecho internacional de los siglos XVIII y XIX, pues al ser el derecho internacional, durante estos siglos, esencialmente derecho consuetudinario, la fluida maraña de prácticas y declaraciones estatales necesitó de la labor de quienes interpretaron el alcance jurídico de éstas.

En las primeras décadas del siglo XX, varios autores internacionalistas se limitaron a la descripción y al análisis de la práctica contemporánea de los Estados: el contenido de sus doctrinas se identificaba con el derecho internacional entonces vigente. La doctrina posterior a la segunda guerra mundial ha cuestionado y ha relativizado el valor de ciertas aseveraciones deducidas de prácticas de los Estados, ya perimidas, centrandose sus objetivos en el carácter netamente evolutivo del derecho internacional.

La C.I.J. y su antecesora la C.P.J.I. no ha hecho referencia en sus opiniones consultivas o fallos a publicistas determinados, si bien ambos tribunales han mencionado en reiteradas oportunidades, en forma genérica, a la "doctrina" y a las "enseñanzas".

La doctrina recogida por el trabajo de ciertos institutos especializados en el estudio del derecho internacional ha influido no sólo sobre la enseñanza de ese derecho, sino, fundamentalmente sobre la actitud de los Estados, tanto en la interpretación y clarificación del derecho a aplicar como en relación a su desarrollo progresivo.

Debemos destacar la importante obra realizada por el Institut de Droit International, creado en Gante en 1873; la International Law Association, fundada en Bruselas en 1873; la American Society of International Law (Washington, 1906) y l'Académie de Droit International de La Haye (1923).

Las opiniones de los jueces de la C.I.J. en sus votos en disidencia o en sus votos por separado, al igual que la actividad de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional son relevantes aportes en cuanto a la existencia y contenido de las normas jurídicas internacionales.

Los Estados fundamentan jurídicamente sus políticas internacionales evaluando las opiniones de sus asesores legales, quienes, en cierta medida, desarrollan las actividades críticas típicas de los publicistas internacionales. Las misiones especiales de los Estados a conferencias internacionales, generalmente responden a esquemas conceptuales nacionales, bajo formulaciones jurídicas de doctrinarios internacionalistas que, en la mayoría de los casos, incluso, integran esas misiones estatales.

En la actualidad, la disminución de la importancia de la actividad de los publicistas en el proceso de verificación de normas jurídicas se ve compensada por la creciente incidencia de los estudiosos del derecho en la preparación de formulaciones jurídicas para el desarrollo progresivo del derecho internacional. De esta manera, la actividad crítica de toda doctrina jurídica no ha quedado relegada a un mero ejercicio académico.

2. LA EQUIDAD

El art. 38, 2. del Estatuto de la C.I.J. dice que "la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren".

La inclusión de este párrafo final en el art. 38 responde en gran medida a las inquietudes y presiones ejercidas en la Comisión de Redacción del Estatuto de la C.P.J.I. por los representantes anglosajones, para quienes la equidad es parte integral del derecho sustancial.

Esa norma fue ideada, según Anzilotti, no sólo para resolver conflictos de acuerdo a la aplicación del principio de la equidad, sino también como mecanismo al cual se debe recurrir en busca de una base compromisoria.²⁷²

La equidad, como institución jurídica, está históricamente relacionada: a) con el derecho pretoriano, que nace en Roma como un modo de atemperar los excesos del formalismo jurídico, y b) con la jurisdicción del *Canciller* que cumplió funciones similares a las del derecho pretoriano, dentro del derecho inglés medioeval.

El concepto guarda una íntima relación con la idea de justicia y si bien no hay en la actualidad un consenso general sobre su contenido, la equidad ha sido invocada como medio para atemperar²⁷³ y completar²⁷⁴ el derecho y podría serlo aún para suplirlo.

²⁷² Anzilotti, *op. cit.*, pág. 107. En el caso de las *Tomas de Agua del Mosa*, el juez Hudson, en su opinión individual concurrente sostuvo que, si bien la Corte no ha sido expresamente autorizada para aplicar la equidad, ésta es parte del derecho internacional; por lo tanto, la Corte puede aplicarla independientemente de que las partes lo hayan o no pactado. C.P.J.I., Serie A/B, n° 70, 1937.

²⁷³ La equidad ha sido reiteradamente invocada por una de las partes en conflicto a los efectos de atemperar el rigorismo del derecho vigente, que niega la posibilidad de reparar daños ocasionados durante acciones bélicas. Caso de la extensión oriental de la *Compañía Telefónica Australasia y China Ltda.*, Inglaterra contra EE. UU., Tribunal arbitral, 1923.

²⁷⁴ Los árbitros del Tribunal arbitral mixto especial en el caso entre Portugal y Alemania, por el laudo del 31 de julio de 1928, sostuvieron la necesidad de aplicar por analogía y de acuerdo al espíritu del derecho internacional general, la equidad como modo de completar el vacío de las normas internacionales existentes, 8, *Recueil des décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes*, 409-4133.

La solución de conflictos internacionales a través de la aplicación de la equidad, ha sido pactada en varios acuerdos arbitrales.²⁷⁵

Pero, si bien en reiterados laudos arbitrales ha sido invocada la equidad²⁷⁶ hasta el momento la C.I.J. no ha sido llamada a decidir *ex aequo et bono* (igual aconteció durante la vida de la C.P.J.I.).

Hasta su fallo de 1966 sobre el *Sud-Oeste Africano*, la C.I.J. ha dicho que su función es la de decir el derecho y no de hacer un justicia subjetiva bajo la apariencia de reglas morales vagas, más o menos asimilables a la equidad. "La Corte juzga en derecho y no puede tener en cuenta principios morales sino en la medida en la que se les ha conferido una forma jurídica suficiente".²⁷⁷

Sin embargo, en el caso de 1969 sobre la *Plataforma Continental del Mar del Norte* la Corte afirma que "cualquiera sea el razonamiento jurídico del juez, sus decisiones deben ser justas; por lo tanto, en tal sentido, equitativas... No se trata en consecuencia en el caso de una decisión *"ex aequo et bono"*, y agrega "no se trata de aplicar la equidad simplemente como una representación de la justicia abstracta, sino de aplicar una regla de derecho que prescribe el recurso a principios equitativos conforme a las ideas que siempre han inspirado el desarrollo del régimen jurídico de la plataforma continental en la materia".²⁷⁸

Esta doctrina de la Corte fue reafirmada en los casos de las competencias en materia de pesca suscitados entre Gran Bretaña e Islandia y la República Federal de Alemania e Islandia.²⁷⁹

De este modo, en su reciente evolución, la Corte parece aplicar la equidad como principio general de derecho, de los contemplados en el art. 38, 1.c) de su Estatuto.

²⁷⁵ Por el Tratado del 21 de julio de 1938 para la solución del conflicto del Chaco entre Paraguay y Bolivia, se estableció que el límite de la zona en conflicto sería determinado por los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, EE. UU., Perú y Uruguay y que éstos, como árbitros, decidirían de acuerdo al principio *ex aequo et bono*. Véase La Foy, *The Chaco dispute and the League of Nations* (1941).

En el laudo arbitral para la solución del conflicto de límites entre Guatemala y Honduras (1933) el Tribunal aplicó el principio del *uti possidetis* a la luz del principio de la equidad, de acuerdo a lo estipulado en el compromiso arbitral antecedente. U.N., *Rep. Intl. Arb. Award*, 1307, *Annual Digest* 1933/34, Caso 46.

La Comisión Mixta de reclamaciones entre Inglaterra y EE. UU., establecida por el acuerdo del 18 de agosto de 1910, discutió la aplicación de la equidad en los casos de la extensión oriental de la *Compañía Telefónica Australasia y China Ltda.* (Inglaterra contra EE. UU., 1923) y en el caso de los indios Cayugas (Gran Bretaña contra EE. UU., 1926).

²⁷⁶ En el caso James Pugh, entre Irlanda y Panamá, el árbitro *ad hoc*, debió decidir la razonabilidad del poder de policía panameño para arrestar a un ciudadano irlandés, basándose en el principio de la equidad - 3 U.N. *Rep. Intl. Arb. Awards*, 1439 (julio 6, 1933).

El laudo arbitral (15 de mayo de 1868) del rey de Bélgica en el conflicto entre EE. UU. y Chile, aplicó por expresa disposición del compromiso arbitral el principio *ex aequo et bono*. 2 Moore, *International arbitrations*. 1449 (1898).

²⁷⁷ *Recueil*, 1966, pág. 34.

²⁷⁸ *Recueil*, 1969, §§ 88 y 85.

²⁷⁹ *Recueil*, 1974, § 65.

El concepto *ex aequo et bono* tal como está sentado en el art. 38, 2. del Estatuto de la CIJ no es identificable con la equidad concebida como principio general de derecho, ni como método de interpretación que permite al juez atenuar el rigorismo de las normas, sino como la posibilidad conferida al órgano jurisdiccional de decidir las controversias creando la norma individual de derecho a aplicar al caso.

A través de este procedimiento, las partes podrían jerarquizar a la institución del *ex aequo et bono* como una fuente autónoma o principal del Derecho Internacional Público, asimilable a la equidad como parte sustancial del derecho tal como es entendida en el sistema anglo-sajón.

3. LOS ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS

La ciencia del derecho internacional se plantea el problema de determinar si los actos unilaterales de los Estados pueden o no ser fuentes principales de derecho internacional.

Se consideran actos unilaterales de los Estados a aquellas manifestaciones de voluntad emanadas del Estado y que tienden a producir ciertos efectos jurídicos. En general, la expresión *actos unilaterales* está referida a actos diplomáticos tales como el reconocimiento, la renuncia, la protesta, la notificación, la promesa. Al distinguir entre la actividad que aquéllos realizan como sujetos del derecho internacional y su actividad como agentes generadores de la norma²⁸⁰ debemos también distinguir entre actos unilaterales de los Estados como sujetos y actos unilaterales de éstos como agentes generadores de derecho.

i) El Estado, en tanto que sujeto del derecho internacional, no está facultado por el ordenamiento positivo para crear por sí solo normas jurídicas internacionales. La subjetividad del Estado frente al ordenamiento internacional se define por la capacidad de éste como centro de imputación de derechos y obligaciones internacionales. La actividad de un Estado, como sujeto de derecho internacional, comportará siempre la aplicación o violación de una norma jurídica preexistente.

Los actos unilaterales de los Estados pueden ser meras aplicaciones de normas jurídicas en vigor —la adhesión a un tratado o su denuncia, por ejemplo— o, siendo contrarios a éstas, generar su responsabilidad internacional; tal, una denuncia no autorizada por el tratado.

Cuando los actos unilaterales de un Estado incompatibles con el derecho positivo son reiterados por otro u otros Estados, pueden constituir precedentes de una nueva norma jurídica internacional. Son también precedentes en los supuestos en que los actos unilaterales se refieren a conductas novedosas, aún no reglamentadas por el derecho vigente.

Considerar a un acto unilateral como precedente no implica aceptarlo como *creador* de la norma jurídica. El acto unilateral de un Estado necesita del acto unilateral concordante de otro u otros Estados para dar nacimiento a una disposición del derecho positivo.

²⁸⁰ Véase lo dicho en el capítulo I. 4. a) sobre la *carencia de "órgano legislador"* de la sociedad internacional.

ii) Los Estados, como agentes generadores, crean normas jurídicas internacionales a través de las llamadas fuentes principales o fuentes creadoras. La igualdad soberana de los Estados, como principio general del derecho positivo, impide que se impongan derechos u obligaciones a un Estado por el mero acto unilateral de otro. En los casos en que esto parece ocurrir, en realidad el acto unilateral se fundamenta en una norma jurídica preexistente. No es posible, entonces, concebir una norma jurídica internacional en cuyo proceso formativo solamente ha participado un Estado. Puede suceder, como así lo ha reconocido la práctica de los Estados, que la intervención de otro u otros Estados en la creación de la norma se evidencie en una actitud meramente pasiva. Esta actitud implica aquiescencia, comprometiendo, así, la voluntad inmediata del Estado en la creación de la norma. La *protesta* o la *reclamación* son los actos unilaterales de un Estado mediante los cuales éste puede hacer saber su voluntad de oponerse al nacimiento de una norma jurídica internacional producto de la actividad de uno o varios Estados.

Del proceso descentralizado de creación de normas entre y para Estados soberanos e iguales jurídicamente surge la obligación de éstos de actuar o reaccionar frente a las conductas de otros Estados que pudiesen ser consideradas como precedentes potenciales de normas obligatorias.²⁸¹

Como ya hemos visto, el art. 38 del Estatuto de la C.I.J. no menciona a los actos unilaterales entre las fuentes a aplicar por la Corte; por lo tanto, en razón del carácter taxativo de su enunciado, ninguna sentencia de este tribunal podrá fundarse exclusivamente en una norma jurídica supuestamente creada por un acto unilateral de un Estado.

La decisión de la C.I.J. en los casos de *los ensayos nucleares*,²⁸² entre Australia y Francia y Nueva Zelandia y Francia, plantea un interesante interrogante doctrinario sobre la naturaleza de los actos unilaterales como fuentes creadoras de derecho. Ante los reiterados ensayos nucleares realizados por Francia en el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelandia solicitaron a la Corte "... juzgar y declarar que la ejecución de ensayos atmosféricos adicionales con armas nucleares en el Océano del Pacífico Sur no se ajusta a las reglas aplicables del derecho internacional y ordenar que la República de Francia no debe llevar a cabo ningún ensayo adicional de tal tipo". La Corte entendió que el objetivo de los peticionantes era obtener que Francia pusiese fin a los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur. Una vez presentadas las Memorias de las actoras ante el tribunal, el Presidente de Francia anunció la intención de su Gobierno de suspender la ejecución de los ensayos nucleares en la atmósfera, después de terminada la serie programada para 1974. Ante esta nueva cir-

²⁸¹ Así, por ejemplo, la declaración del Presidente Truman de los EE.UU., del año 1945, sobre la plataforma continental de su país, al no recibir protesta alguna, por parte de los demás Estados y ser reiterada por actos estatales de contenido similar, constituyó el precedente que generó una nueva norma jurídica internacional según la cual todo Estado tiene derechos soberanos a la explotación de los recursos de su plataforma continental.

²⁸² *Recueil, C.I.J., 1974.*

cunstancia, la Corte consideró que se encontraba frente a una situación en donde el objetivo de las demandas había sido satisfecho por el hecho de que Francia, a través de declaraciones unilaterales, asumió la obligación de no realizar más ensayos nucleares en la atmósfera del Pacífico Sur.

La Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada y fundó su posición expresando que "...como Corte de derecho tiene obligación de resolver controversias existentes entre los Estados, esas controversias deben continuar existiendo en el momento en que la Corte tome su decisión". Sostuvo, entonces, que "...en razón de haber desaparecido el objeto de las demandas no hay nada sobre lo que juzgar".²⁸³

La Corte asignó a la declaración unilateral de Francia efectos vinculatorios. Para ella tal declaración crea "una obligación jurídica individual" que no necesita aceptación, ni siquiera una respuesta o reacción de otros Estados, pues tales requisitos serían incompatibles con la naturaleza estrictamente unilateral del acto jurídico. La creación de esta obligación jurídica descansa según la Corte en el principio de la buena fe.²⁸⁴

Nos hallaríamos entonces ante un acto generador de una obligación individual que produce este efecto jurídico en razón de aplicar una norma positiva general como lo es la obligación de actuar de buena fe. Esta última constituye un principio general de derecho de los reconocidos como fuente autónoma por el art. 38, 1.c) del Estatuto de la C.I.J.

La doctrina internacional contemporánea, en general, no otorga a los actos unilaterales calidad de fuente autónoma en tanto que proceso de creación de derecho, lo que no implica desconocerles efectos jurídicos cuando son aplicación de una norma positiva. Revisten ellos importancia, asimismo, como precedentes para la creación de derecho.²⁸⁵

²⁸³ *Ibid.*, §§ 43 y 58.

²⁸⁴ *Ibid.*, § 46.

²⁸⁵ Conf. Venturini, G. G., "Valeur juridique des attitudes et des actes unilatéraux des Etats", R.C.A.D.I., 1961, II vol. 112; Suy, E., "Les actes juridiques unilatéraux en Droit International Public", Bibliothèque de Droit International, Vol. XIII, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1962; Dehaussy, J., "Les actes juridiques unilatéraux en droit international public; à propos d'une théorie restrictive", Journal de Droit International, vol. 92, 1965.

4. LOS ACTOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Los tratados constitutivos de los organismos internacionales contienen, generalmente, disposiciones por las que se faculta a los órganos a adoptar decisiones, resoluciones, reglamentos o recomendaciones dirigidos a los Estados miembros.²⁸⁶ Estos tratados constitutivos también contemplan la posibilidad de autorizar a los órganos por ellos creados a reglamentar sus propios derechos y obligaciones, al igual que ciertos derechos y obligaciones de los individuos directamente vinculados con los organismos internacionales.²⁸⁷ La doctrina llama al conjunto de normas que reglamenta el funcionamiento de los órganos, derecho interno de los organismos internacionales.²⁸⁸

Frente a esta realidad, autores contemporáneos proponen una nueva categoría de fuentes creadoras de derecho llamada legislación internacional.²⁸⁹

Los efectos jurídicos de los actos de los organismos internacionales dependen de lo que al respecto se disponga en los tratados constitutivos. En ciertos supuestos, aquellos efectos podrán también inferirse de los poderes implícitos de la organización o bien de las prácticas reiteradas de sus órganos, creadoras de una costumbre internacional.

La diversidad y complejidad de organismos internacionales impide

²⁸⁶ La terminología empleada para distinguir a los distintos actos realizados por los órganos de un organismo internacional no es uniforme; por ello, en cuanto a la terminología, corresponde remitirse a las normas pertinentes de cada uno de los tratados constitutivos.

²⁸⁷ Es decir, de los "funcionarios internacionales".

²⁸⁸ Verdross, A., "On the concept of international law", A.J.I.L., 1949, v. 43 págs. 435-440; Cahier, Ph., "Le droit interne des organisations internationales", R.G.D.I.P., 1963, v. 67, pág. 563.

²⁸⁹ Skubiszewski, "Enactment of law by international organisations", B.Y.I.L., 1965, v. 41-6, pág. 198. En razón del carácter taxativo del art. 38 del E.C.I.J. sostiene Thirlway que toda pretendida nueva fuente del derecho internacional deberá reconocer un parentesco directo con una o más de las fuentes allí enunciadas. Por lo tanto, los actos de los organismos internacionales generalmente derivarán su fuerza obligatoria del tratado constitutivo o de una costumbre internacional. Fridmann, W., "Cours Général", R.C.A.D.I., 1969, vol. II, pág. 142, considera que los actos de los organismos internacionales son importantes elementos en el desarrollo del derecho internacional pero no tienen, por sí mismos, carácter de actos legislativos internacionales.

englobarlos en una categoría uniforme. Difieren en cuanto a propósitos y objetivos, a su composición, a sus potestades. De igual modo difieren sus posibilidades o su aptitud para establecer normas.

Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en el marco de una entidad de carácter universal, y ciertos actos del Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, en un ámbito regional, nos permiten analizar las posibilidades normativas de las instituciones internacionales. En aquéllas, aunque con distinto alcance, esas posibilidades logran su expresión más significativa.

i) *Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU*: En principio, las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias para los miembros de la organización; tienden, sólo, a influenciar en la actividad de los Estados mediante recomendaciones que fijan pautas de conducta. Aunque siendo meras recomendaciones, bajo ciertas circunstancias, producen importantes consecuencia jurídicas. Por ejemplo, la actividad del Estado miembro de la ONU motivada en el cumplimiento de una resolución de la A. G. será siempre lícita para el derecho internacional.

Sin embargo, en ciertos casos, una resolución podría ser considerada obligatoria en razón de reiterar normas contenidas en un tratado²⁹⁰ o recoger una costumbre internacional.²⁹¹ En estos supuestos, la fuerza obligatoria no derivaría de la resolución en sí, sino del tratado o de la norma consuetudinaria de la que es expresión.²⁹²

La voluntad expresada por un Estado al votar a favor o en contra de una resolución de la A. G. podría ser interpretada como la manifestación de reconocer, o no, la necesidad jurídica del contenido de dicha resolución. La convergencia de numerosas voluntades estatales en la aprobación de una resolución comprueba en modo instantáneo la existencia de una *opinio juris*. Y la práctica reiterada de los Estados, concordante con la expresión de esa *opinio juris* enunciada en una resolución, da lugar al nacimiento de una norma jurídica internacional. En este caso, la resolución del órgano no sería la fuente creadora, sino la prueba del elemento psicológico de la costumbre.

²⁹⁰ Por ejemplo, la Resolución A/2625 (XV), sobre la Declaración de Principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, es la medida en que reitera el contenido del art. 2 de la Carta de la ONU.

²⁹¹ La Resolución A/2131 (XX) "Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía" en cuanto acoge una costumbre general. Sprensen sostiene que cuando una resolución de la A. G. confirma derecho consuetudinario existente, le infunde una expresión de autoridad. Las resoluciones de la A. G. pueden contribuir a la cristalización de una norma consuetudinaria expresada vagamente en la práctica de los Estados, pero no puede modificar el derecho existente o crear nuevas normas.

²⁹² Asamoah, O. Y., *The legal significance of declarations of the General Assembly of the United Nations*, La Haya, 1966, pág. 12 y sig.; Blaine Sloan, F., "The binding force of a recommendation of the General Assembly of the U.N.", *B.Y.I.L.*, 1948, 1-33.

De ello resultaría una alteración en el proceso habitual de gestación de la norma consuetudinaria. No es ya la práctica seguida de la *opinio juris*, sino que el elemento psicológico precede a las conductas reiteradas y converge, anticipadamente, para su nacimiento.²⁹³

En diversos casos, las resoluciones de la A. G. son la expresión de convicciones jurídicas arraigadas o traducen necesidades colectivas que van a plasmar luego, con cierta inmediatez, en convenciones internacionales. Así, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Res. A/217 (III) del 10 de diciembre de 1948, se aprobaron en ese Órgano el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, ambos en vigencia y, tras la Res. A/1962 (XVIII) sobre Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre del 13 de diciembre de 1963, se aprobó el Tratado sobre dicho espacio en el que se incluye a la Luna y Otros Cuerpos Celestes, el 27 de enero de 1967, también vigente.²⁹⁴

Asimismo, ciertas resoluciones comprueban situaciones de hecho que condicionan la aplicación de diversas normas de la Carta de la ONU; por ejemplo, la calificación de un territorio como no autónomo determina la aplicación del cap. XI de dicha Carta.

En otro orden de cosas, hay un supuesto en que las resoluciones son siempre obligatorias para la Organización y para sus Miembros. Se trata del caso en que éstas se refieren a actos del derecho interno de la Organización. Así, por ejemplo, obligan a los Estados miembros y a la propia Organización, las resoluciones de la A. G. sobre el presupuesto de la ONU, admisión y expulsión de miembros, creación de organismos subsidiarios, elección de integrantes de otros Órganos, etcétera.²⁹⁵

Puede concluirse, entonces, que aun cuando no quepa asignar a las Resoluciones de la A. G. el carácter de fuente autónoma de derecho internacional, revisten gran importancia en el desarrollo de este orden

²⁹³ Jennings, R. Y., "General Course", *R.C.A.D.I.*, 1967, vol. II, sostiene que es más correcto hablar de una forma incipiente de legislación universal que de una reversión del proceso creador de la costumbre internacional, ya que, como en el caso de la aprobación de la resolución sobre el espacio ultraterrestre de 1963, su obligatoriedad está condicionada a la aceptación por la práctica ulterior de los Estados. Cheng, D., "United Nations resolution on Outer Space: instant international Customary Law?", *I.J.I.L.*, January 1965, pág. 23, considera que la manifestación de la *opinio juris* es suficiente para crear una norma jurídica consuetudinaria. Cabe destacar que la propuesta de Filipinas de atribuir a las resoluciones de la Asamblea General naturaleza legislativa fue rechazada por la gran mayoría de los Estados representados en la Conferencia de San Francisco de 1945; véase el debate en *U.N.C.I.O., Documents*, vol. IX, pág. 70 y siguiente.

²⁹⁴ La Argentina es parte (Ley 17.989, B.O. del 2/IV/1969).

²⁹⁵ Para Verdross, la fuerza obligatoria de aquellos actos deriva de la aplicación directa de las estipulaciones contenidas o implícitas en los tratados constitutivos de cada organismo internacional; conf. art. 17 de la Carta de ONU, *C.I.J.*, opinión consultiva sobre *Ciertos gastos de las Naciones Unidas*, *Recueil*, 1962.

jurídico. En este sentido, es innegable la influencia de Resoluciones tales como la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos (Res. A/217 (III)); la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales (Res. A/1514 (XV)); la Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la Explotación y Utilización del Espacio Ultraterrestre (Res. A/1962 (XVIII)); la Resolución sobre la Soberanía Permanente sobre los recursos naturales (Res. A/1803 (XVII)); la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía (Res. A/2131 (XX)); la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Res. A/2625 (XXV)); Declaración de Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (Res. A/2749 (XXV)); Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Res. A/3281 (XXIX)); Resolución sobre la Definición de Agresión (Res. A/3314 (XXIX)); las Resoluciones estableciendo la Primera Década para el Desarrollo (Res. A/1710 (XVI)) y la Estrategia Internacional del desarrollo para la segunda década para el desarrollo (Res. A/2626 (XXV)), entre otras.

ii) *Actos del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas*: Los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas²⁹⁶ prevén los alcances jurídicos de los actos de sus órganos, a los que asignan en diversos supuestos efectos vinculatorios, no sólo con relación a las propias Comunidades, sino también a los gobiernos de los Estados miembros y a las empresas o individuos establecidos en el territorio de éstos.

Así, por ejemplo, el art. 189²⁹⁷ del tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea establece el valor jurídico de los reglamentos, las decisiones, las directivas, las recomendaciones y dictámenes aprobados o formulados por la Comisión y por el Consejo. Atribuye a los reglamentos eficacia general, obligatoriedad en todas sus partes e inmediata aplicabilidad; a las directivas, un efecto vinculatorio sólo para el Estado miembro al que es dirigida, al que deja libertad en la elección de los medios adecuados para su implementación; y a las decisiones les confiere obligatoriedad en todas sus partes para sus destinatarios. Las recomendaciones y los dictámenes, por el contrario, carecen de efecto obligatorio.

²⁹⁶ Se entiende por Comunidades Europeas el conjunto integrado por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París de 1951), Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma de 1957) y Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado de Roma de 1957). Sus miembros originarios eran Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y la República Federal de Alemania. El Tratado de Bruselas de 1965 estableció órganos comunes para las tres entidades; éstos son: un Consejo, una Comisión, una Corte y un Parlamento. El ingreso de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la República de Irlanda y de Dinamarca a las Comunidades se concretó en enero de 1972.

²⁹⁷ Véase también el art. 14 de la CECA.

La Corte de Justicia, otro de los órganos de las Comunidades, ha extendido los alcances previstos en el art. 189 citado para los reglamentos de la Comisión y del Consejo a: a) todas las normas del tratado constitutivo de la CEE (caso "van Gend en Loos contra Nederlandse Administratie der Belastingen", 26/62, Rec. IX (1963), CMLR 105; caso "Salgoil contra Ministerio del Comercio Exterior" 13/68, Rec. XIV 661 (1969) CMLR 181; caso "Luck contra HZA Köln Rheinau", 34/67, Rec. XIV, 359); b) las directivas del Consejo y de la Comisión (caso SACE contra Ministerio de Finanzas italiano", 33/70, Rec. XVI, 1213 (1071) CMLR 123); c) las decisiones del Consejo y de la Comisión (caso "Grad contra Finanzamt Traunstein", 9/70, Rec. XVI, 825 (1971) CMLR 1).

La actividad de los órganos de las Comunidades ha dado lugar a la creación de un conjunto de normas jurídicas derivadas que, integradas con las disposiciones de los tratados constitutivos, configuran el llamado *derecho comunitario*.²⁹⁸ Este derecho regula ámbitos que, aunque limitados por los tratados constitutivos, son de vital importancia. Tales, los referidos a la política arancelaria común, a la libre circulación de personas, a la política agraria común, a la seguridad social, etc. El derecho comunitario, si bien presenta ciertas características propias en cuanto a su proceso de formación, no es otra cosa que derecho internacional. El origen de los poderes de los órganos de las Comunidades se encuentra en la transferencia de competencias normativas realizadas por los Estados miembros.



²⁹⁸ La Corte de las Comunidades estableció que la Comunidad constituye un nuevo sistema legal en el derecho internacional; conf. "Van Gend en Loos contra Nederlands Administratie der Belastingen", ya citado. Por otra parte, en reiteradas oportunidades ha aplicado principios generales de derecho; conf. "Comisión contra Gobierno de Italia" 10/61, 1962, CMLR 187. Para Pescatore, P., *Derecho de la integración*, I.N.T.A.L., 1973, pág. 51, el derecho comunitario es un derecho derivado que tiene por base la distribución de competencias establecidas por los tratados constitutivos. Ha desarrollado una dinámica propia en manos de las instituciones llamadas a crearlo y en las de la Corte de Justicia que tiene por misión interpretarlo. Conf. Parry, C., "E.E.C. Law", Sweet & Maxwell, 1973.

BIBLIOGRAFIA

- d'Amato, A., *The concept of custom in international law*, Cornell University Press, 1971.
- Anzilotti, *Curso de derecho internacional*, tr. López Olivares, 3ª ed., Madrid, Ed. Reus 1935.
- Barberis, J., *Fuentes del derecho internacional*, La Plata, Editora Platense, 1973.
- Basdevant, J., *Dictionnaire de la terminologie du droit international*, Paris, Sirey, 1960.
- Briggs, H. W., *The law of nations*, 2ª ed., Appleton Century Crofts, 1966.
- Degan, *L'interprétation des accords en droit international*, La Haya, Nijhoff, 1963.
- Diaconu, J., *Contribution à une étude sur les normes impératives en droit des gens (jus cogens)*, Bucarest, 1971.
- Dupuy, R. J., *Les accords conclus par les organisations internationales*, Paris, Institut des Hautes Etudes Internationales, 1968-1969.
- Elias, T. O., *The modern law of treaties*, Oceana, 1974.
- de la Guardia, E. y Delpech, M., *El derecho de los tratados y la Convención de Viena de 1969*, Buenos Aires, La Ley, 1970.
- Guggenheim, P., *Traité de droit international public*, 2ª ed., 1967.
- Guggenheim, P., *Lehrbuch des Völkerrechts*, 1948.
- Higgins, R., *The development of international law through the political organs of the United Nations*, Londres, Oxford Univ. Press, 1963.
- Kelsen, H., *Principios de derecho internacional público*, tr. H. Caminos y E. C. Hermida, Buenos Aires, El Ateneo, 1965.
- Lauterpacht, H., *Private Law sources and analogies of International Law*, Londres, 1927.
- Mc. Nair, Lord, *Law of treaties*, Oxford, Clarendon Press, 1961.
- O'Connell, D. P., *International Law*, Stevens and Sons, Oceana, 1965.
- Parry, C., *The sources and evidences of International Law*, Manchester Univ. Press, 1965.
- Pescatore, P., *Derecho de la integración*, I.N.T.A.L., 1973.
- Reuter, P., *La Convention de Vienne sur le droit des traités*, Paris, Armand Colin, 1970.
- Rosenne, Sh., *The law of treaties: A guide to the legislative history of the Vienna Convention*, Leyden, Sijthoff, 1970.
- Rousseau, Ch., *Derecho Internacional Público*, 3ª ed., Ariel, 1966.
- Sinclair, I. M., *The Vienna convention on the law of treaties*, Manchester, Manchester University Press, 1973.
- Sørensen, M., *Les sources du droit international*, Copenhague, 1946.
- Starke, J. G., *Introduction to international law*, 2th ed., Londres, Butterwerthe, 1973.
- Suy, E., *Les actes juridiques unilatéraux en droit international public*, Paris, 1962.
- Sztuchi, J., *"Jus cogens" and the Vienna convention on the law of treaties, a critical appraisal*, Viena, Springer Verlag, 1974.
- Thrillway, H. N. A., *International customary law and codification*, Leyden, Sijthoff, 1972.
- Tunkin, G., *Remarks on the judicial nature of customary norms of international law*, Cornell University Press, 1961.
- de Visscher, Ch., *Problèmes d'interprétation judiciaires en droit international public*, Paris, Pédone, 1963.
- Voicu, L., *De l'interprétation authentique des traités internationaux*, Paris, 1968.
- Ago, R., "La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation", en *Mélanges en hommage de Paul Guggenheim*, Genève, 1968.
- d'Amato, A., "On consensus", *VIII Canadian Yearbook of international law*, 1970, pág. 104 y siguiente.
- Barberis, J., "La prescripción adquisitiva y la costumbre en el derecho internacional", *Jurisprudencia Argentina*, 1967-IV, s.d., pág. 378 y siguiente.
- Berlia, "Contribution à l'interprétation des traités", *R.C.A.D.I.*, vol. 114, (1965) I, págs. 283-333.
- Blaine Sloan, F., "The binding force of a recommendation of the General Assembly of the U.N.", *B.Y.I.L.* (1948), págs. 1-33.
- Brand, "Recherches sur l'Etat tiers en droit international public", *R.G.D.I.P.*, vol. 72 (1968), págs. 17-96.
- Brandon, "The validity of non-registered treaties", *B.Y.I.L.*, vol. 29 (1952) págs. 186-204.
- Briggs, H., "Reflections on non-retroactivity of treaties", *Revista Española de Derecho Internacional*, segunda época, vol. 21 (1968), nº 2, págs. 320-327.
- "Procedures for establishing the invalidity or termination of treaties under the International Law Commissions 1966 draft articles on the law of treaties", *A.J.I.L.*, vol. 61-4 (1967), págs. 976-989.
- Cahier, Ph., "Le droit interne des organisations internationales", *R.G.D.I.P.* (1963), v. 67, pág. 563.
- "Les traités et les Etats tiers", *R.C.A.D.I.*, 1974.
- "Les caractéristiques de la nullité en droit international", *R.G.D.I.P.*, vol. 76 (1972), págs. 645-691.
- Caicedo Castilla, "Les tendances politiques exprimées au sein de la 2ème. session de la Conférence de Vienne sur le droit des traités", *R.G.D.I.P.*, vol. 73 (1969), págs. 790-794.
- Cheyet, "Les accords en forme simplifiée", *A.F.D.I.*, vol. 3 (1957).
- Cheng, D., "United Nations resolution on the Outer Space: instant international customary law", *I.J.I.L.*, January, 1963, p. 23 y sig.
- Cot, J. P., "La conduite subséquente des parties à un traité", *R.G.D.I.P.*, vol. 70 (1966), págs. 328-345.
- "La bonne foi et la conclusion des traités", *Revue Belge de droit international*, vol. 4 (1968), nº 1, págs. 140-159.
- Capotorti, F., "L'extinction et la suspension des traités", *R.C.A.D.I.*, 1971-III, págs. 417-587.
- Dascal, J. R., "El derecho de los tratados y su relación con los concordatos celebrados por la Santa Sede. Alcance del art. 1º de la Convención de Viena de 1969", *Jurisprudencia Argentina*, 1974.
- Dupuy, R. J., "Codification et règlement des différends. Les débats de Vienne sur les procédures de règlement", *A.F.D.I.*, vol. 15 (1969), págs. 70-91.
- Elias, T. O., "Problems concerning the validity of treaties", *R.C.A.D.I.*, 1971-III, págs. 332-416.
- Falk, R. A., "On the quasi-legislative competence of the General Assembly", *A.J.I.L.* (1966), v. 60, pág. 782 y siguiente.
- Ferrer Sanchis, P. A., "Los conceptos de *jus cogens* y *jus dispositivum* y la labor de la Comisión de Derecho Internacional", *Revista Española de Derecho Internacional*, 1967, págs. 763-780.
- Fitzmaurice, "The law and procedure of the International Court of Justice: Treaty interpretation and other treaty points", *B.Y.I.L.*, vol. 28 (1951), págs. 1-28; vol. 33 (1957), págs. 203-295.

- *The law and procedure of the International Court of Justice, General Principles and Sources of International Law*, B.Y.I.L., vol. 35, 1959.
- en *Symbolae Verzijl*, 1958, pág. 153 y siguientes.
- Fridmann, W., "Cours Général", R.C.A.D.I., 1969, vol. II.
- Gardner, J. C., "Judicial precedent in the making of international public law", J.C.L., 3rd. ser., XVII (1935), págs. 251-259.
- González Campos, "La aplicación del futuro convenio sobre derecho de los tratados a los acuerdos vinculados con organizaciones internacionales", *Revista Española de Derecho Internacional*, segunda época, vol. 21 (1968), n° 2, págs. 360-386.
- Jenks, "The conflict of law-making treaties", B.Y.I.L., vol. 30 (1953), págs. 401-453.
- Jennings, R. Y., "General Course on Principles of International Law", R.C.A.D.I., 1967, vol. II.
- "Recent developments in the I.L.C.: its relation to the sources of international law", I.C.L.Q. (1964), pág. 385.
- Jiménez de Aréchaga, E., "La estipulación en favor de terceros en el derecho internacional", *Cuadernos del Centro de Estudios de Derecho Comparado*, n° 1, Montevideo, 1956.
- Kearney, R., "The treaty on treaties", A.J.I.L., vol. 64 (1970), págs. 495-561.
- Kelsen, H., "Théorie du droit international coutumier", *Revue Internationale de la Théorie du Droit*, 1939, pág. 352 y siguiente.
- Kunz, A., "The nature of customary international laws", A.J.I.L. (1953), v. 47, pág. 662 y siguiente.
- Lachs, M., "The law of treaties. Some general reflections on the report of the International Law Commission", en *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Ginebra, 1968, págs. 391-492.
- Lauterpacht, H., "Codification and development of international law", A.J.I.L., (1955), v. 49, pág. 16 y siguiente.
- "Some observations on the problem of *non liquet* and the completeness of the legal order", en *Symbolae Verzijl*, 1958, pág. 196.
- Lissitzya, "Treaties and changed circumstances" (*rebus sic standibus*), A.J.I.L., vol. 61-4 (1961), págs. 895-922.
- Mc. Dougal, M., "International Law Commission's draft articles upon interpretation: textuality redivivus", A.J.I.L., vol. 61 (1967), págs. 992-1000.
- Mc Nair, Lord, *The general principles of law recognized by civilized Nations*, B.Y.I.L., vol. 33, 1957.
- Marek, K., "Contribution à l'étude du jus cogens", en *Hommage à Paul Guggenheim*, págs. 426-459.
- Nahlick, "La Conférence de Vienne sur le droit des traités. Une vue d'ensemble", A.F.D.I., vol. 15 (1969), págs. 24-53.
- Nisot, J., "Les réserves aux traités et la Convention de Vienne", R.G.D.I.P., vol. 77 (1973), págs. 200-206.
- Oraison, A., "Le dol dans la conclusion des traités", R.G.D.I.P., vol. 75 (1971), págs. 617-673.
- Pastor Ridruejo, "Los efectos de acuerdos internacionales respecto a los terceros", *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 13 (1960), n° 3, págs. 387-411.
- Ruda, José María, "Las reservas a las convenciones multilaterales", *Revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas*, 1965, pág. 7 y siguiente.
- "Reservations to treaties", R.C.A.D.I., 1976, vol. III, págs. 101-212.
- Rosenne, S., "The depositary of international treaties", A.J.I.L., vol. 61-4 (1967), págs. 923-945.
- "More on the depositary of international treaties", A.J.I.L., vol. 64 (1970), 838-852.
- Santa Pinter, "Jerarquía e interpretación de los tratados internacionales", *Jurisprudencia Argentina*, 1960, II, págs. 344-351.
- Schwebel, E., "Some aspects of international *ius cogens* as formulated by the international Law Commission", A.J.I.L., vol. 61-4 (1967), págs. 946-975.

- Sinclair, "Vienne Conference on the law of treaties", I.C.L.Q., vol. 19 (1970), págs. 47-69.
- Skubiszewski, "Enactment of law by international organisation", B.Y.I.L. (1965), v. 41-6, pág. 198 y siguiente.
- Stone, "Non liquet and the function of law in the international community", B.Y.I.L. (1959), v. 35, pág. 124.
- Tammes, A. J. P., "The inter-action of the sources of international law", X *Netherlands Tijdschrift* (1963).
- Vallée, Ch., "Quelques observations sur estoppel en droit des gens", R.G.D.I.P., vol. 77 (1973), págs. 949-999.
- Verdross, A., "On the concept of international law", A.J.I.L. (1949), v. 43, pág. 435 y siguiente.
- "Jus dispositivus and jus cogens in international law", A.J.I.L. (1966), pág. 55 y siguiente.
- Verplaetse, J., "Apuntes sobre la doctrina *rebus sic standibus* en el derecho internacional a la luz de algunos casos actuales", *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 1 (1951), págs. 113-133.
- Virally, M., *La valeur juridique des recommandations des organisations internationales*, 2 *Annuaire Français* 66, 1959.
- "Réflexions sur le jus cogens", A.F.D.I., 1966, págs. 5-29.
- de Visscher, Ch., "Positivisme et jus cogens", R.G.D.I.L. (1971), vol. 75, págs. 5-11.
- Vita, "International conventions and national conflict systems", R.C.A.D.I., 1969, v. I.

INDICE DE CASOS CITADOS

1. Corte Internacional de Justicia

<i>Fallos</i>	<i>Pág.</i>
Competencia en materia de pesquerías	80, 158
Derecho de Asilo	83, 86
Derecho de los nacionales de EE.UU. en Marruecos	58-86
Derecho de paso sobre el territorio indio	79, 84, 88
Ensayos nucleares	161
Pesquerías Anglo-Noruegas	58, 84, 87
Plataforma Continental del Mar del Norte	26, 80, 82,
	86, 87, 88,
	104, 130, 150,
	158
Sud-Oeste Africano	136, 150, 158
Templo de Preah Vihear	132, 150

Opiniones consultivas

Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua del Africa del Sud en Namibia (Sud-Oeste africano) no obstante la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad	126
Efecto de los fallos del Tribunal administrativo de la O.N.U.	150
Régimen internacional del Sud-Oeste africano	136, 150
Reparación de los daños sufridos al servicio de la O.N.U.	14, 125
Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio	113

2. Corte Permanente de Justicia Internacional

<i>Fallos</i>	
Concesiones Mavrommatis en Palestina	117, 150
Empréstitos servicios	150
Estatuto jurídico de la Groenlandia Oriental	83, 97, 102,
	131

CA

Fábrica de Chorzów	57, 150
Fosfatos de Marruecos	117
Intereses alemanes en la Alta Silesia	57
Lotus	87
Tomas de agua del Mosa	138, 150, 157
Universidad Peter Pázmány contra Estado Checoslovaco	57
Zonas francas de la Alta Saboya y del País de Gex	57, 103

Opiniones consultivas

Canje de poblaciones griegas y turcas	56
Competencia de los Tribunales de Dantzig	56
Decretos de nacionalidad en Túnez y en Marruecos	140
Escuelas minoritarias en Albania	56
Trato de los nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polacas en el territorio de Dantzig	57

3. Decisiones arbitrales

Alabama	58
Compañía Telefónica Australasia y China Ltda.	157, 158
Guatemala-Honduras (1933)	158
Islas de Palmas	121, 134
James Pugh	158
Portugal-Alemania (T.A.M. 1928)	157
Reclamaciones entre Gran Bretaña y Costa Rica	58
Tinoco	129

4. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Alfonso Chantre	60
Compañía Azucarera Tucumana c. Prov. de Tucumán	62
Dario David c. Prov. de San Luis	69
Esso S.A. Petrolera Argentina c. Nación Argentina	64
Gregorio Alonso c. Haras Los Cardos	66
Martínez E. M. c. Ramos J. I.	67
Merck Química Argentina S.A. c. Gobierno Nacional	61, 69
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto comunica situación planteada en autos "Gómez S. c. Embajada Británica s/despido"	70
Recurso de Habeas Corpus interpuesto por los tripulantes sublevados del buque de guerra chileno La Pilcomayo	69
Rufino Basavilbaso c. Ministro Plenipotenciario de Chile doctor Diego Barros Arana	68
S.A. Editorial Noguea	67
S.A. Martín y Cía. Ltda. c. Administración General de Puertos	62
S.A. Quebrachales Fusionados c. capitán, armadores y dueños del vapor nacional Aguila	66-67

INDICE

Prefacio	9
Lista de abreviaturas	10
Sumario	11

Parte Primera. — INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES

I

1. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO	13
a) Generalidades	13
1. Concepto, sujetos y objeto	13
2. Terminología	17
3. Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado	18
4. La ciencia del derecho internacional	19
b) Caracteres de este ordenamiento	20
1. Diferencias con el derecho interno. Sus atenuaciones	20
a) Carencia de "órgano legislador"	21
b) Carencia de "órgano juzgador" obligatorio	21
c) Carencia de vínculo de "subordinación" de los sujetos	22
2. Categorías de normas: normas imperativas (<i>ius cogens</i>) y normas dispositivas	23
3. Otras características	24
a) El Estado como sujeto y como agente generador	24
b) Derecho de coordinación y derecho de subordinación	24
c) Derecho Internacional general y Derecho Internacional particular	25
d) Posibilidad de que una misma norma internacional sea expresada simultáneamente por dos o más fuentes	22
2. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL	27
a) Origen	27
b) Evolución	31

3. OBLIGATORIEDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL Y FUNDAMENTO DE VALIDEZ DE LA NORMA INTERNACIONAL	44
a) <i>Obligatoriedad del Derecho Internacional</i>	44
b) <i>Fundamento de validez de la norma internacional</i>	46
1. Teorías voluntaristas	46
a) Teoría de la autolimitación	46
b) Teoría de la voluntad común	47
c) Doctrina soviética contemporánea	47
2. Teorías objetivistas	48
a) Positivismo italiano	48
b) La teoría normativa	48
c) La teoría sociológica	49
d) Teorías del derecho natural	50
i) Teoría clásica del derecho natural	50
ii) Teoría de los derechos fundamentales	51
iii) El ius naturalismo racional	51
4. RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL	53
a) <i>La doctrina</i>	53
1. El monismo	53
2. El dualismo	54
b) <i>La práctica internacional</i>	56
c) <i>Solución del problema desde el enfoque interno</i>	58
<i>Constitución de la Nación Argentina</i>	59
1. Los tratados	59
a) Los tratados y la Constitución	59
b) Los tratados y las leyes de la Nación	62
c) Aprobación y ratificación de los tratados	64
d) Operatividad de los tratados	65
2. La costumbre y los principios generales de derecho	67
Bibliografía	72

Parte Segunda. — FORMACION DEL DERECHO INTERNACIONAL

II

1. LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL	75
a) <i>Concepto de fuente</i>	75
b) <i>Fuente formal y fuente material</i>	75
c) <i>Enumeración de las fuentes del Derecho Internacional</i>	77
d) <i>Fuentes principales y fuentes auxiliares</i>	80
e) <i>Jerarquía de fuentes</i>	80

2. LA COSTUMBRE	82
a) <i>Elementos constitutivos</i>	82
1. Elemento material	83
2. Elemento psicológico	85
b) <i>Prueba de la costumbre</i>	86
c) <i>Problemas recientes del derecho consuetudinario</i>	89
1. Los nuevos Estados y la costumbre vigente	89
2. La costumbre y los organismos internacionales	90
3. La codificación del derecho internacional	91
3. LOS TRATADOS	95
a) <i>Generalidades</i>	95
1. Denominación	96
2. Definición	96
3. Clasificación	98
i) En cuanto al número de sujetos parte en un tratado	98
ii) En cuanto a las posibilidades de acceder al tratado	98
iii) En cuanto a las formas de celebración del tratado	99
iv) En cuanto al contenido u objeto del tratado	99
b) <i>El régimen de los tratados en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados</i>	101
1. Ambito de validez de la Convención	101
a) Ambito de validez personal	102
b) Ambito de validez temporal	104
c) Ambito de validez territorial	105
2. La conclusión de los tratados	106
a) Etapas conducentes a la celebración del tratado	106
i) La negociación	106
ii) La adopción del texto	107
iii) Autenticación del texto	107
b) Formas de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado	108
i) La firma	109
ii) El canje de instrumentos que constituyen un tratado	109
iii) La ratificación	109
iv) La adhesión	110
c) Determinación del momento en que nace el vínculo jurídico	111
d) Reservas	112
e) Entrada en vigor y aplicación provisoria	115
3. Observancia y aplicación de los tratados	116
a) Interpretación de los tratados	119

3) Los tratados y los terceros Estados	122
i) Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados	122
ii) Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados ..	123
iii) Los tratados y el derecho consuetudinario	124
iv) Los tratados que crean "situaciones objetivas"	124
c) Enmienda y modificación de los tratados	126
4. Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados ..	128
a) Disposiciones generales	128
b) Nulidad de los tratados	130
i) Capacidad	131
ii) Consentimiento	131
iii) Objeto lícito	135
c) Terminación de los tratados	135
i) Terminación del tratado por voluntad de las partes	136
ii) Terminación del tratado en razón de la aplicación de ciertas normas del derecho internacional general	138
d) Procedimiento de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la aplicación o interpretación de las disposiciones de la Convención relativas a la nulidad, terminación, retiro o sus- pensión de la aplicación de un tratado	141
e) Consecuencias de la nulidad	143
i) Actos anteriores	144
ii) Actos posteriores	144
f) Consecuencias de la terminación o suspensión	144
5. Depósito, corrección de errores en los textos, registro y publicación de los tratados	145
a) Depósito	145
b) Corrección de errores en los textos	146
c) Registro y publicación	147
4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO	148
a) Principios generales de derecho reconocidos por los Estados en sus orde- namientos internos	148
b) Los principios generales del Derecho Internacional	151

III

1. MEDIOS AUXILIARES PARA LA DETERMINACION DE LAS REGLAS DE DERECHO	153
a) <i>Decisiones judiciales</i>	153
b) <i>La doctrina</i>	154

2. LA EQUIDAD	157
3. LOS ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS	160
4. LOS ACTOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES	163
i) Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU	164
ii) Los autos del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas ..	166
Bibliografía	168
Índice de casos citados	172

-79816

45

franJamoradd